

國立雲林科技大學科技法律研究所

碩士論文

Graduate School of Science and Technology Law
National Yunlin University of Science & Technology

Master Thesis

生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約法律爭議問題之研究

—以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心

Research on Legal Disputes of Labor Service Purchasing
Contracts of Biomedical Waste Disposers

—Centered on the Yunlin County Class A Biomedical
Waste Treatment Company

廖國言

Kuo—Yen Liao

指導教授：袁義昕 博士

Advisor：Yi—HsiYuan, Ph.D.

中華民國 111 年 6 月

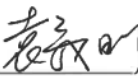
June 2022

國立雲林科技大學
碩士班學位論文考試委員會審定書
National Yunlin University of Science and Technology
Thesis Oral Defense Approval Form

本論文係 廖國言 君在本校 科技法律研究所碩士班 所提論文 生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約法律爭議問題之研究—以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心 碩士資格水準，業經本委員會評審認可，特此證明。

The student LIAO, KUO-YEN enrolled in the Master's program in Graduate School of Science and Technology Law has satisfactorily passed the oral defense of the thesis Research on Legal Disputes of Labor Service Purchasing Contracts of Biomedical Waste Disposers — Centered on the Yunlin County Class A Biomedical Waste Treatment Company.

口試委員：
Oral defense
committee members

袁義昕 

林家祺 

林洲富 

指導教授：
Advisor(s)



所長：
Dean of Graduate
Institute



中 華 民 國 111 年 7 月 8 日

摘要

生物醫療廢棄物處理業者受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，依據政府採購法相關法令，必須面臨勞務採購之招標、投標、得標及簽訂勞務採購契約等階段，而當生物醫療廢棄物處理業者實際參與勞務採購標案過程中，常有發生面臨勞務採購標案之法律爭議問題，此一議題少有相關論文及研究進行探討，故本文研究方向即在探究生物醫療廢棄物處理業者所面臨之勞務採購標案法律爭議問題，並以站在雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司之角度鳥瞰參與勞務採購標案之法律爭議問題，尤以勞務採購之招標、投標、得標及簽訂勞務採購契約等階段之法律爭議問題最為重要，所以本文研析範圍專注僅限於勞務採購之招標、投標、得標及簽訂勞務採購契約等階段，希冀能幫助大家就此些生物醫療廢棄物處理業者所面臨之勞務採購標案法律爭議問題有初步了解。

關鍵詞：生物醫療廢棄物處理業者、勞務採購標案法律爭議問題



Abstract

Biomedical waste disposal companies are entrusted with the treatment of biomedical waste produced by government agencies or government agencies. According to the relevant laws and regulations of the Government Procurement Law, they must face the stages of bidding, bidding, winning and signing labor procurement contracts. When biomedical waste treatment companies actually participate in the labor procurement bidding process, there are often legal disputes in the labor procurement bidding process. There are few relevant papers and studies on this topic. Therefore, the research direction of this paper is to explore the biomedical The legal disputes in labor procurement tenders faced by waste disposal companies, and from the perspective of a Class-A biomedical waste treatment company in Yunlin County, the legal disputes involved in labor procurement tenders, especially labor procurement tenders, The legal disputes in the stages of bidding, winning the bid and signing the labor procurement contract are the most important, so the scope of this article is limited to the tendering, bidding, winning and signing of the labor procurement contract. Preliminary understanding of the legal disputes in labor procurement tenders faced by medical waste disposal companies.

Key words: biomedical waste disposal companies, legal disputes in labor procurement tenders

誌謝

時光匆匆而過，在進入研究所讀書，已完成科法所大部分之學程，接著也要確認自己想要撰寫之研究所畢業論文題目及內容，及找指導教授，由於本人於就讀研究所時，所選擇修習之科目，就是新興科技領域相關之法律，本人原本也以為本人所撰寫之研究所畢業論文題目及內容也將朝著此方向著手擬訂。

所幸在經袁義昕所長在法學論文寫作之課堂裡，給予自己想要撰寫之研究所畢業論文題目及內容之擬訂想法及提醒，不妨得從自己工作有關之方向著手，能寫出屬於自己之東西，而不是都在模仿別人撰寫出來之東西，從自己不甚明瞭之領域作為研究所畢業論文題目及內容，這樣並沒有辦法突破就該領域已專研之學者見解及先進已完成之論文期刊之內容，經過袁義昕所長之有力提醒之下，自己重新思索自己想要撰寫之研究所畢業論文題目及內容，由於自己本身服務於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司，該服務公司主要就是處理生物醫療廢棄物，而自己工作內容就是包括但不限於從事該服務公司所簽訂之契約審閱、修改及契約紛爭處理等，所以最後決定就是朝向本文題目及內容撰寫。經本人懇請袁義昕所長擔任本人之指導教授後，袁義昕所長不在意本人之不才及駑鈍，仍欣然同意擔任本人之指導教授，感謝袁義昕所長願意不吝惜予以指導，並與袁義昕所長討論後，最後決定本人研究所畢業論文之題目。袁義昕所長在本人之本文撰寫過程中，不辭辛勞給予指導及修改，本人感謝袁義昕所長於本人在本文撰寫期間之啟發及指導，感激不盡。

感謝口試委員林家祺教授及林洲富教授於口試階段提供之寶貴建議及提醒，本人獲益良多，經採納林家祺教授及林洲富教授之精闢意見後，本人逐步修改本文之內容更臻完善，最後使本人研究所畢業論文得以順利完成，萬分感謝。

在修習之科目當中，感謝學長、學姐及 109 級同班同學之不吝指教及熱心之幫忙下，完成科目之修習，也重拾當學生之樂趣，想起自己距離當學生之時代已經很久了，超過 20 年有餘，感謝同學們之陪伴、科法所師長之指導，自己由衷感謝。

最後感謝親愛之老婆，幸蓉，妳體諒及寬容本人任性選擇就讀研究所時，而無法陪伴妳及兩個可愛小孩—泳晴及建豪，在本人不在家時，無法分擔辛勞下，對泳晴及建豪之照顧及對家之付出。在家人之支持下，及在無後顧之憂下，完成本文之撰寫。

廖國言 謹誌

2022 年 6 月於雲科大科技法律研究所



目錄

摘要	i
Abstract.....	ii
誌謝	iii
目錄	v
表目錄	viii
圖目錄	x
第一章 緒論	1
第一節 問題提出	1
第二節 研究目的	5
第三節 研究方法與研究限制	7
第四節 研究流程與論文架構	12
第二章 我國生物醫療廢棄物處理之現狀	14
第一節 生物醫療廢棄物之定義與種類	14
第一項 生物醫療廢棄物之定義	14
第二項 生物醫療廢棄物之種類	18
第三項 COVID-19（新冠肺炎）廢棄物	21
第二節 採取焚化處理之生物醫療廢棄物處理業者	26
第一項 生物醫療廢棄物之處理	26
第二項 生物醫療廢棄物處理業者之定義	31
第三項 生物醫療廢棄物處理業者之種類	34
第四項 生物醫療廢棄物處理業者之設備	35
第三章 我國生物醫療廢棄處理業者就勞務採購標案之處置	38
第一節 政府採購行為之介紹	38

第一項 政府採購行為探究之必要性	38
第二項 政府採購行為探究之重要性	40
第三項 政府採購行為之意義、基本原則、特色及影響	40
第四項 政府採購行為之主體、客體	43
第五項 政府採購行為之性質	46
第六項 政府採購行為之定性	48
第一款 學說上及實務上之見解	48
第二款 雙階段理論扮演之角色	55
第七項 公法與私法相互影響	57
第八項 行政院公共工程委員會函釋之效力	60
第二節 勞務採購招標方式	64
第三節 勞務採購之共同投標	70
第四節 勞務採購投標廠商資格爭議	74
第一項 勞務採購投標廠商資格要求	74
第二項 勞務採購投標廠商資格爭議發生	89
第三項 實務上勞務採購爭議處理	103
第一款 我國政府採購爭議救濟途徑	103
第二款 外國政府採購爭議救濟途徑	125
第四章 我國生物醫療廢棄物處理勞務契約定性之研析	141
第一節 政府採購契約之成立與生效	141
第一項 招標、投標、決標之法律性質	141
第一款 要約之引誘說	141
第二款 要約說	142
第三款 小結	142
第二項 招標契約之法律性質	145

第一款 本約說	145
第一款 預約說	146
第一款 小結	147
第二節 勞務採購契約之履約規範	151
第三節 勞務採購契約之探究	153
第四節 勞務採購契約定性探討	161
第一項 勞務採購契約內容	161
第二項 勞務採購契約定性爭議	161
第五章 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突	195
第一節 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之差異	195
第一項 契約訂定之法律依據不同	195
第二項 契約訂定之過程不同	196
第三項 契約訂定之雙方當事人不同	196
第四項 契約訂定之內容不同	197
第五項 契約訂定之爭議處理方式不同	198
第二節 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之相似性	200
第一項 契約訂定之目的、主體、標的、履行方式相同	200
第二項 契約訂定之成立類似	200
第三項 契約訂定之定性類同	200
第三節 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約衝突之處理方式	203
第六章 結論與建議	207
第一節 結論	207
第二節 建議	209
參考文獻	221

表目錄

表 1 醫療廢棄物定義	17
表 2 「附表三生物醫療廢棄物」	20
表 3 生物醫療廢棄物之處理方式	28
表 4 處理生物醫療廢棄物之處理機構	34
表 5 採購主體類別及定義	45
表 6 公私法區別之實益	48
表 7 公私法區別之理論	49
表 8 判決及裁定彙整表	54
表 9 法條介紹	64
表 10 招標方式介紹	67
表 11 標案類別介紹	68
表 12 投標廠商資格要求	74
表 13 廢棄物處理之投標廠商基本資格之要求	79
表 14 生物醫療廢棄物標案介紹	79
表 15 歷年得標數量統計	87
表 16 2021 年得標案件	87
表 17 資格限制競爭提供錯誤行為態樣	94
表 18 採購異議書	117
表 19 採購申訴書	120
表 20 契約分類方式	154
表 21 契約自由原則類型	157
表 22 政府採購契約之本質	162
表 23 法院判決	164
表 24 主管機關認定之勞務於政府採購實務之解釋	172
表 25 僱傭、委任、承攬之契約性質比較	176
表 26 判決介紹	192

表 27 事業廢棄物委託處理性質	202
------------------------	-----



圖目錄

圖 1 醫療院所廢棄物分類	2
圖 2 醫療院所廢棄物產出	2
圖 3 醫療廢棄物的種類	15
圖 4 醫療廢棄物的種類	15
圖 5 旋轉窯焚化爐架構圖	37
圖 6 異議處理流程圖	107
圖 7 申訴處理流程圖	108
圖 8 採購作業流程	158
圖 9 政府採購流程	159



第一章 緒論

第一節 問題提出

壹、生物醫療廢棄物之定義及處理尚待釐清

雖然國內廢棄物清理法相關規定制定歷時已久，然而對於生物醫療廢棄物之了解並不清楚，直覺反應都會認為應該屬於醫療院所所產生之廢棄物，然而醫療院所產生廢棄物中，生物醫療廢棄物僅係醫療院所產生廢棄物之其中一種類而已，但醫療院所所產生之廢棄物實際上應該再行細分為：（一）一般廢棄物，就是員工生活垃圾；（二）一般事業廢棄物，就是訪客生活垃圾、不具有危險性之一般性醫療廢棄物、人體或動物用藥、營建廢棄物及再利用等；（三）有害事業廢棄物，具有危險性、厭惡性或致感染之可能性，包括但不限於生物醫療廢棄物。一般廢棄物仍得交由垃圾車載運清除處理，而生物醫療廢棄物必須以專業清運車輛清除至專門處理生物醫療廢棄物之處理廠商予以處理，且各自有不同之處理方法。而專門處理生物醫療廢棄物之處理廠商之處理方式有諸多方式，包括但不限於焚化處理及滅菌處理等。況且依據廢棄物清理法相關規定，不僅醫療院所會產出生物醫療廢棄物，包括醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，也都會產出生物醫療廢棄物。基於一般民眾對於何謂生物醫療廢棄物、國內有哪些專門處理生物醫療廢棄物之業者及生物醫療廢棄物應採取何種處理方式都不是很了解，連同對於 COVID-19（新冠肺炎）疫情在國內發生，國內就防疫期間相關防疫廢棄物之處理，也不甚了解，有關生物醫療廢棄物之定義與分類、生物醫療廢棄物之處理方式及國內專門處理生物醫療廢棄物之處理業者等殊值深入探討，並將在本文一併釐清。

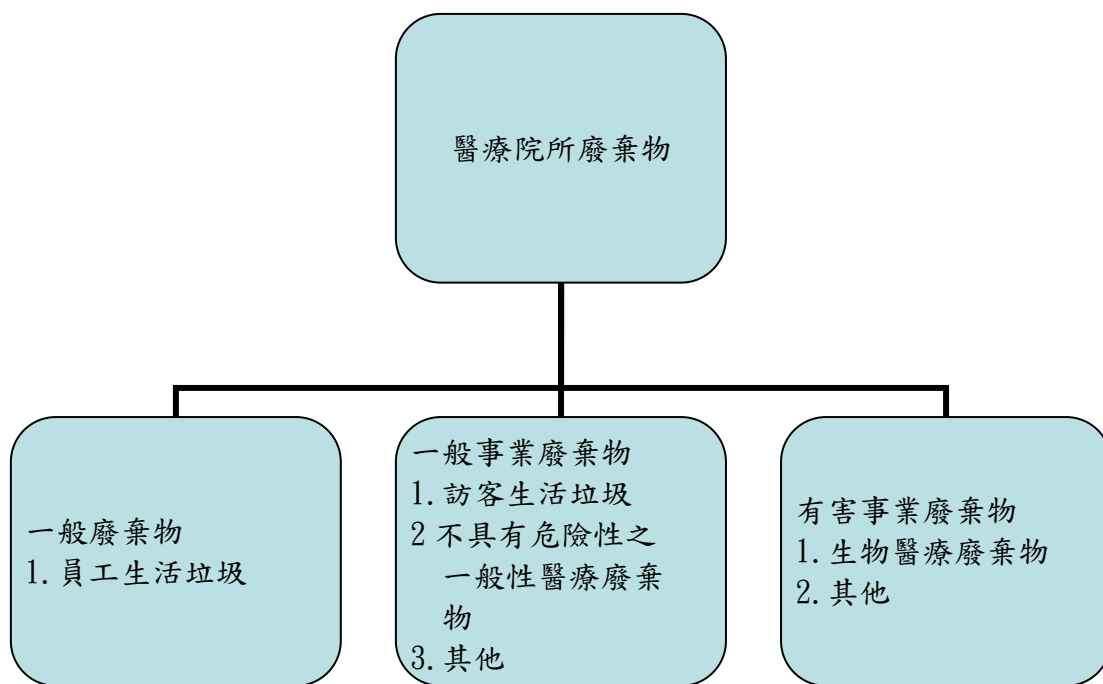


圖 1 醫療院所廢棄物分類

資料來源：作者自行製圖



圖 2 醫療院所廢棄物產出

資料來源：作者自行製圖

貳、生物醫療廢棄物處理勞務採購標案發生爭議所採取法律上手段值得深究

政府機關或政府機關所屬事業委託生物醫療廢棄物處理業者處理生物醫療廢棄物，基於政府採購法之規定，應辦理招標程序，生物醫療廢棄物處理業者並於得標後，應與政府機關或政府機關所屬事業簽訂政府採購契約，在上開招標、審標、決標、簽約等階段中，皆有可能發生爭議及糾紛，容待解決，且應屬於生物醫療廢棄物處理業者經常可能遇到之情形，而屬於生物醫療廢棄物處理業者遇到之最大宗法律相關案件，兼旁論歐洲聯盟內之指標性大國德國政府採購法制上是否有類似或相同之紛爭解決方式。爭議發生之原因不外乎涵蓋招標文件之內容，包括但不限於規格限制及廠商資格限制、開標、審標、決標、簽約等。基於生物醫療廢棄物處理業者可能對於政府機關或政府機關所屬事業辦理委託生物醫療廢棄物處理標案相關投標須知相關文件內容有所疑義及對於決標結果有所不服，而採取法律上手段，有關政府採購契約簽訂前之階段，可能發生之爭議及糾紛，應該如何面對及處置，是一門重要之課題，是本文探討之重心，殊值深入探討，並將在本文研議。

參、生物醫療廢棄物委託處理所簽訂處理契約之法律定性及因應方式容待澄明

依據廢棄物清理法相關規定，委託處理生物醫療廢棄物，應簽訂生物醫療廢棄物處理契約，此是行政院環境保護署之環保管制要求。而依據政府採購法相關規定，委託處理生物醫療廢棄物，應簽訂政府採購契約，法律定性為勞務採購契約類型之一種，此是行政院公共工程委員會之採購管制要求。二法令規定有所不同規範目的，採行作法皆是有簽訂生物醫療廢棄物委託處理之契約，此時產生一問題是當簽訂勞務採購契約後，是否仍依據廢棄物清理法相關規定，委託處理廢棄物，應簽訂生物醫療廢棄物處理契約，亦即前者契約與後者契約同時並行存在，或者前者契約得取代後者契約，當簽訂前者契約後，即不需要簽訂後者契約。有關上開勞務採購契約、生物醫療廢棄物處理契約是否都需要簽訂，涉及是否重複、重疊簽訂之問題，是否必要，簽訂勞務採購契約實屬參與政府採購，經投標、得標後之必然階段及結果，而簽訂生物醫療廢棄物處理契約實屬於國家管制廢棄物妥善清除處理之要求，若違反未再行簽訂後者契約，是否可能遭受環保主管機關裁罰，此是一有趣之問題，殊值深入探討，並將在本文一併討論。

另外，探討政府採購契約時，先需要從探討政府採購行為之法律定性開始著手，政府採購行為究竟屬於公法行為、私法行為或者二階段說，有所爭議，學者見解及實務見解有所不盡相同，各自論述之依據及理由皆有所不同，相互激盪，縱使最後學說通說及實務見解皆採取二階段理論，但學界及實務界仍不時加以討論及研究，因此也影響政府採購契約之法律定性之問題。且由於委託處理生物醫療廢棄物，所簽訂之政府採購契約在法律定性上，屬於勞務提供，究竟屬於委任契約、承攬契約或者混合契約之性質等，亦生疑義。因此，釐清委託處理生物醫療廢棄物採購契約性質，即有其必要性。至於民間之醫療院所或其他機構、單位委託處理生物醫療廢棄物，所簽訂之生物醫療廢棄物處理契約屬於基於私法自治、契約自由之原則，當事人間所簽訂之契約，或為民法上有名之契約或者為非典型之無名契約，仍得依契約之性質及經濟目的而類推適用關於有名契約之規定。由於針對簽約對象及法令依據之不同，國內就生物醫療廢棄物委託處理所簽訂之處理契約有不同之區別，分別為勞務採購契約及生物醫療廢棄物處理契約，該二契約之意義、定性及事業廢棄物處理業者就該二契約之處置，皆有所差異，有關上開勞務採購契約、生物醫療廢棄物處理契約法律定性上有諸多疑義存在，殊值深入探討，並將在本文一併研究。

第二節 研究目的

壹、幫助明瞭生物醫療廢棄物之定義及處理

目前國內廢棄物清理法相關法令就廢棄物之定義及分類似乎太過於細分，產生是否過於複雜之疑義，無法輕易深入了解，透過本文再行探求，希冀幫助明瞭生物醫療廢棄物之定義、分類。適逢國內外 COVID-19（新冠肺炎）疫情方興未艾時期，國內就防疫期間相關防疫廢棄物之處理更為重視，更將相關防疫廢棄物視同生物醫療廢棄物當中之感染性廢棄物，予以嚴謹妥善收集處理，藉由本文一併探討。國內有專門處理生物醫療廢棄物之業者，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司就是其中之一，且各個專門處理生物醫療廢棄物之業者都擁有各自之生物醫療廢棄物處理技術及設備，能協助處理生物醫療廢棄物，於本文一併介紹，俾使一般民眾正視生物醫療廢棄物處理之存在，及對於我國生物醫療廢棄物處理概況有一概略之輪廓。本文即承上開立論而予以出發及開展，勾勒出本文後續內容之發展走向，實屬本文研究不可或缺之要素。

貳、研究生物醫療廢棄物處理勞務採購標案發生爭議所採取法律上手段作為生物醫療廢棄物委託處理實務運作上通用案例使用

基於國內法律學界及其法學論文、期刊減少討論生物醫療廢棄物處理業者之參與勞務採購標案法律爭議問題，而生物醫療廢棄物處理業者常面臨對於政府採購行為前階段一招標、審標、決標提出之採購異議及採購申訴等，基於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司屬於探討生物醫療廢棄物處理業者參與勞務採購標案法律爭議問題最適宜之案例，故本文以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司之觀點來探討及驗證生物醫療廢棄物處理業者之參與勞務採購標案法律爭議問題，以期大家能更能深入了解生物醫療廢棄物處理業者所面臨之參與勞務採購標案法律爭議問題。亦希望能提供政府機關或政府機關所屬事業在未來辦理生物醫療廢棄物處理採購案件時，對於在採購招標文件上應如何設立各項要求，以及在實務運作上，政府機關或政府機關所屬事業應如何為妥適之安排處置，有所依循及參考，以避免生物醫療廢棄物處理業者提出採購異議及採購申訴，徒增提起救濟程序之費時、費力及紛擾，而節省生物醫療廢棄物處理業者、政府機關或政府機關所屬事業勞力、時間、費用之支出。

參、分析生物醫療廢棄物委託處理所簽訂處理契約之定性及因應方式供參考

誠如上述，基於針對簽約對象及法令依據之不同，生物醫療廢棄物委託處理，就契約之簽訂，有區分為簽訂勞務採購契約及簽訂生物醫療廢棄物處理契約，以簽訂勞務採購契約而言，政府機關辦理勞務採購，無非是希望以合理之價格，如期、如質、如數完成生物醫療廢棄物委託處理，滿足施政目標；然而採購作業其程序涉及法令要求與約束甚多，各級採購人員當應恪遵政府採購法及其相關規定據以辦理，其前置階段得加以細分，包括（一）取得政府機關或政府機關所屬事業政府辦理廢棄物委託處理採購標案之資訊，得直接至「政府電子採購網 <http://web.pcc.gov.tw>」，查詢招標公告資訊；（二）領標，即領取投標標案之相關文件；（三）生物醫療廢棄物處理業者參與投標；（四）政府機關或政府機關所屬事業進行審標；（五）決標，生物醫療廢棄物處理業者得標後，政府機關或政府機關所屬事業始與生物醫療廢棄物處理業者進行簽訂勞務採購契約，此為生物醫療廢棄物處理業者取得受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，必經階段，程序相當繁複，而以簽訂生物醫療廢棄物處理契約而言，僅需民間之醫療院所或其他機構、單位與生物醫療廢棄物處理業者就雙方間生物醫療廢棄物處理契約內容經提出、討論、修改、妥協，而無異議後，始簽訂，程序相對比較容易，冀望藉由本文精實之詮釋，對於上開勞務採購契約、生物醫療廢棄物處理契約之意義、定性及生物醫療廢棄物處理業者就該二契約之處置有所差異之地方有更多之認識。也冀望藉由本文之討論及提出建議，能對未來政府採購法修法有所參考及做出貢獻。

第三節 研究方法與研究限制

壹、研究方法

一、文獻分析法

文獻分析法係指根據一定之研究目的或課題，透過蒐集有關資訊、調查報告、圖書、期刊與學術論文等文獻資料，從而以系統、客觀之界定，全面且精準地鑑別和掌握所想要研究之議題現象，並且就上揭資料加以研究歸納、整理分析，以增進對於事實科學有所認識之一種方法¹。

文獻分析法主要目的在於了解過去、洞察現在和預測未來，對此，蒐集內容儘量要求豐富及廣博，經過分析後歸納統整，再分析事件之淵源、原因、背景、影響及其所隱含之結構意義等，除此之外，因為文獻分析法不與文獻中記載的人、事有所接觸，因此，又稱為非接觸性研究方法，至於，文獻分析法包括閱覽與整理(Reading and Organizing)、描述(Description)、分類(Classifying)以及詮釋(Interpretation)等四大步驟。綜合以上，文獻分析法之特性如下：(一)它所研究事件是過去而非目前發生，亦即，文獻分析超越過去時空之限制，紀錄的是過去之社會事實；(二)文獻分析可超越個人之經驗與視野；(三)文獻分析可超越調查互動中之不良影響；以及(四)文獻分析可提供詳實可靠之背景資料²。

本文係參考與本文題目相關之國內論文、期刊、雜誌及書籍之內容，及現行廢棄物清理法相關法令、政府採購法相關法令、民法相關法令、行政法相關法律概念等涉及本文題目者，進行分析，可區分成以下三類：

- (一) 於國家圖書館之「臺灣碩博士論文知識加值系統」、「期刊文獻資訊網—臺灣期刊論文索引系統」及各圖書館，蒐集及整理關於本文題目之國內論文、期刊、雜誌及書籍之內容。

¹ 林淑女整理，189. 文獻分析法 (Document Analysis)，社團法人中華民國晴天社會福利協會，網址：
<https://www.sunnyswa.org.tw/12345/189-%e6%96%8d%bb%e5%88%86%e6%9e%90%e6%b3%95%ef%bc%88document-analysis%ef%bc%89>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。

² 林淑女整理，同前註 1。

- (二) 透過「全國法律資料庫」、「法源法律網」及各政府機關網站，檢索現行廢棄物清理法相關法令、政府採購法相關法令、民法相關法令，就本文題目相關聯之相關規定，探究本文題目之法律面操作。
- (三) 實務上或學界就本文題目之相關概念，包括但不限於對於政府採購契約之定性等，有不同之解釋及觀點，實務上有相關判決、見解可參照，學界有發表之論文、期刊、見解可參考，利用「司法院法學資料檢索系統」及「法源法律網」，取得上開實務上相關判決、見解，及學界發表之論文、期刊、見解，加以研究，對於本文題目之探討有所幫助。

二、比較法研究

引據王梅玲教授於國家教育研究院雙語語詞、學術名稱暨辭書資訊網，比較研究 Comparative research，2012 年 10 月圖書館學與資訊科學大辭典所述：「比較研究 (comparative research) 是社會科學經常運用研究方法。比較是認識事物之基礎，是人類認知、區別和確定事物異同關係之最常用之方法。比較研究方法之運用沒有固定之模式，但仍然有許多學者經常參考美國貝瑞岱之四階段操作模式，他在《Comparative Method in Education》一書將把比較研究法分成四個階段：描述、解釋、併排、與比較，以下說明比較研究的四階段。（一）描述 (description) 研究者首先進行研究事物描述，目的是為了有系統地陳述所探討事物或研究目標之資訊，以使研究者對研究對象有正確而客觀之了解。為了詳細敘述，研究者需要進行廣泛而完整之資料蒐集，資料大致可分為三類：一手資料、次級資料、與輔助資料。（二）解釋 (interpretation) 研究者其次要進行研究事物之解釋，係對描述事物內容中各種現象產生之原因、代表之意義和影響有進一步之了解，研究者需要做解釋之工作，研究者常要掌握事物之歷史發展，從中進行分析與解釋。解釋之正確、客觀與否與研究者所採用之解釋觀點及對問題背景認識詳盡度均有關連。（三）併排 (juxtaposition) 研究者第三階段是將前二階段之描述與解釋所收集之資料進行併排與製作圖表。為了避免研究者作錯誤之比較，必需強調依據共同之事實及問題，以同一觀點分析和判斷。併排有兩個目的：一是根據相同標準分析找出其異同處；二是建立研究假設，以供證實、修正或推翻、導引出研究之結論。（四）比較 (comparison) 比較是最後階段也是比較研究之重點，研究者依照先前之步驟，對假設進行比較研判，以對假設證實、

修正或推翻。研究者需以客觀之態度，詳實之判斷及正確之分析能力，來推斷結論。一般研究者運用比較研究法經常依據上述四階段操作模式進行。比較研究之步驟可具體分為五步驟：（1）確定比較之問題；（2）確定比較之標準與理論；（3）進行收集和整理資料；（4）進行比較分析；（5）最後結論。」³，殊值參考。

本文題目所探究者係以國內生物醫療廢棄物處理業者之參與勞務採購標案法律爭議問題，並以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心，觀諸歐洲聯盟內之指標性大國德國為例，基於德國並未如同我國一樣有一部統一之政府採購法規範，觀諸德國之政府採購法制，尤以德國營業競爭限制防止法為例，是有規範有關政府採購之內容，但其規範內容之重心在於採購爭議救濟途徑，其內並未就政府採購契約予以任何條文明文規範，而我國政府採購法內有專章—履約管理予以規範，雖然條文不多，但仍有給予明文規範，況且我國與德國就採購爭議救濟途徑是有很大的差別，是在本文內連同探究比較兩國制度之不同。

三、實證研究法

所謂實證研究即是基於對真實世界觀察所蒐集而得之資料加以分析，進而完成之研究。易言之，實證研究係將學說理論或假設，透過系統化、科學化之資料收集與分析，加以驗證（validation）其真偽，以為理解真實情狀（real world）之謂⁴。

本文運用「公共工程委員會索引系統」、「台灣採購公報網」或「行政院環境保護署索引系統」，收集與整理本文題目相關之統計資訊資料，尤以運用「公共工程委員會索引系統」及「台灣採購公報網」獲取近年來有關生物醫療廢棄物委託處理標案之開標數量、決標數量，藉此歸納、統整我國對於國內生物醫療廢棄物處理業者受託處理生物醫療廢棄物之態度及趨勢。

貳、研究限制

³ 王梅玲，比較研究 Comparative research，2012 年 10 月圖書館學與資訊科學大辭典，國家教育研究院雙語語詞、學術名稱暨辭書資訊網，網址：
<https://terms.naer.edu.tw/detail/1679273/>（最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日）。

⁴ 劉尚志、林三元、宋皇志，走出繼受、邁向立論：法學實證研究之發展，專題：法實證研究 9，科技法學評論，3 卷，頁 1（2006 年），網址：
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/107690/1/3_2_1.pdf（最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日）。

當初設定探討本文題目時，在於探討有關國內廢棄物處理業者所面臨之政府採購行為全部困難與處境，及其解決方式，作為本文題目，似乎太廣泛，而生物醫療廢棄物處理業者屬於事業廢棄物處理業者其中之一，專門處理生物醫療廢棄物，且由於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司剛好就是專門處理生物醫療廢棄物，故本人就朝著這個方向著手擬定本文題目，且基於國內生物醫療廢棄物處理業者受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物皆需要與政府機關或政府機關所屬事業簽訂生物醫療廢棄物處理勞務採購契約，以符合政府採購法相關規定之要求，屬於重中之重之需要嚴格貫徹之遵守法令義務，故最後決定以國內生物醫療廢棄物處理業者所面臨參與生物醫療廢棄物委託處理之標案時，可能面臨之標案法律爭議問題作為本文題目之設定方向，當然國內生物醫療廢棄物處理業者說多不多，所擁有之處理技術及處理流程或許大同小異，但仍以焚化處理為最大宗之廢棄物處理方式，由於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司係以焚化處理方式處理廢棄物為主，且該公司屬於業界之合法數一數二業者，故以該公司作為探討個案，探討該公司所面臨之標案法律爭議問題，這議題也是其他生物醫療廢棄物處理業者所面臨到之問題，本文之完成將能作為其他生物醫療廢棄物處理業者之指標性參考。故本文爰將研究主題加以限制，僅限於探討生物醫療廢棄物處理業者之參與政府採購標案法律爭議問題，並以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心。

另依據政府採購法第 2 條規定：「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。」，政府採購契約之範疇包括工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等，由於委託處理生物醫療廢棄物，所簽訂之政府採購契約在法律定性上，屬於勞務提供，故於本文研究主題上也專就勞務之提供為研究及分析。亦即本文以研究勞務採購契約為主，對於研究工程採購契約及財物採購契約暫不研究。

最後，政府機關或政府機關所屬事業以辦理採購之方式，經由選商程序，選擇生物醫療廢棄物處理業者以獲取生物醫療廢棄物委託處理，自招標、審標、決標，至簽約等階段，行政機關或政府機關所屬事業與有意投標之生物醫療廢棄物處理業者間可能發生採購爭議，由於以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例

，幾乎沒有發生與招標機關發生簽約後之履約相關爭議，本文侷限以採購之前階段（即招標、審標及決標）及簽約為研究範圍。另因與「投標廠商資格」有關之爭議，為政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物委託處理標案爭議之最大宗，實務上經常發生參與投標之生物醫療廢棄物處理業者，認為政府機關或政府機關所屬事業招標文件所訂「投標廠商資格」之要求符合不當限制競爭，以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，也屬頻繁面對而需解決之問題，是本文以「投標廠商資格」為中心進行探討，及研究其救濟途徑—採購異議制度、採購申訴制度之設計與優點及缺點，其他發生爭議部分不在研究範圍內。



第四節 研究流程與論文架構

壹、研究流程

為明瞭生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約法律爭議問題，勢必先從生物醫療廢棄物、生物醫療廢棄物處理業者之認識先行著手，進而討論勞務採購標案，及介紹因此所衍生之法律爭議問題。本文會以最新之相關文獻資料及資訊，運用文獻分析法、比較法研究、實證研究法，先探討生物醫療廢棄物之定義與種類，並介紹生物醫療廢棄物之處理及採取焚化處理之生物醫療廢棄物處理業者，作為本文後續章節討論之基礎，接著藉由簡要介紹政府採購標案之概念及定性，研究勞務採購標案，探討國內生物醫療廢棄物處理業者所面臨參與勞務採購標案時，可能面臨之標案法律爭議問題。嗣後研究生物醫療廢棄物處理業者勞務採購標案發生紛爭所採取法律上手段。最後，為解決實務上操作生物醫療廢棄物處理業者勞務採購標案之困難，提出解決之方案。

貳、論文架構

一、第一章 緒論

依序說明本文問題提出、研究目的、研究方法與研究限制及研究流程與論文架構，確定本文之探討方向與目標。

二、第二章 我國生物醫療廢棄物處理之現況

本章從生物醫療廢棄物之定義及種類，與採取焚化處理之生物醫療廢棄物處理業者作介紹，作為本文之研究之開端。

三、第三章 我國生物醫療廢棄物處理業者就勞務採購標案之處置

目前政府採購實務運作上，生物醫療廢棄物處理業者參與生物醫療廢棄物處理勞務採購標案有其獨特之地方，也致生不時發生爭議，容待解決，值得探討。當中對於政府採購爭議發生之處理方式，基於國內外政府採購法制之差異，從比較德國營業競爭限制防止法與我國政府採購法之差異，獲得開啟修法之啟示，截長補短，精進完善我國政府採購法制。

四、第四章 我國生物醫療廢棄物處理勞務契約定性之研析

由於勞務採購契約係屬於政府採購契約，所以必須先行了解政府採購契約之定性，並進行分析。進而站在勞務採購契約之觀點，探討生物醫療廢棄物處理勞務契約之定性，並進行細究。

五、第五章 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突

勞務採購契約簽訂之依據係依據政府採購法相關法令，生物醫療廢棄物處理契約簽訂之依據係依據廢棄物清理法相關法令，由於二契約簽訂之依據有所不同，是否需要各別簽訂，或者簽訂其中之一，即不需要再行簽訂另一契約，或者何一契約之效力優先，此係一有趣之爭議問題，殊值進一步探究，於本文一併討論。

六、第六章 結論與建議

綜合本文前面各章提出之內容，得出結論，即探討目前生物醫療廢棄物處理業者所面臨之參與勞務採購標案法律爭議問題，論述範圍包括傳統採購行為之定性及爭議、勞務採購爭議處理、國內外政府採購法制差異之比較、勞務採購契約之定性及勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突等，提供本文之見解及未來修法之走向，供參考。

第二章 我國生物醫療廢棄物處理之現況

第一節 生物醫療廢棄物之定義與種類

第一項 生物醫療廢棄物之定義

依據廢棄物清理法第 2 條規定：「本法所稱廢棄物，指下列能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品：一、被拋棄者。二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。五、其他經中央主管機關公告者。前項廢棄物，分下列二種：一、一般廢棄物：指事業廢棄物以外之廢棄物。二、事業廢棄物：指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。（一）有害事業廢棄物：由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。（二）一般事業廢棄物：由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。前項有害事業廢棄物認定標準，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。游離輻射之放射性廢棄物之清理，依原子能相關法令之規定。第二項之事業，係指農工礦廠（場）、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業。」。基此，廢棄物清理法有就廢棄物之定義及種類予以規範，其中之有害事業廢棄物為農工礦廠（場）、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。且依據行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網有就醫療廢棄物予以定義，俗稱之「醫療廢棄物」則為其中與醫療作業相關聯而特別受重視之部分，在我國法規當中則以「生物醫療廢棄物」之名詞定義此類廢棄物，並歸類為有害事業廢棄物之一種。根據衛生福利部最新統計資料，全國醫療院所共約 2 萬家，另行政院環境保護署統計醫療機構近 5 年之廢棄物平均產量，約為 12 萬公噸/年，其中需特別重視之生物醫療廢棄物（有害）約為 3 萬公噸/年（佔 25%）⁵。

⁵ 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，認識醫療廢棄物，網址：

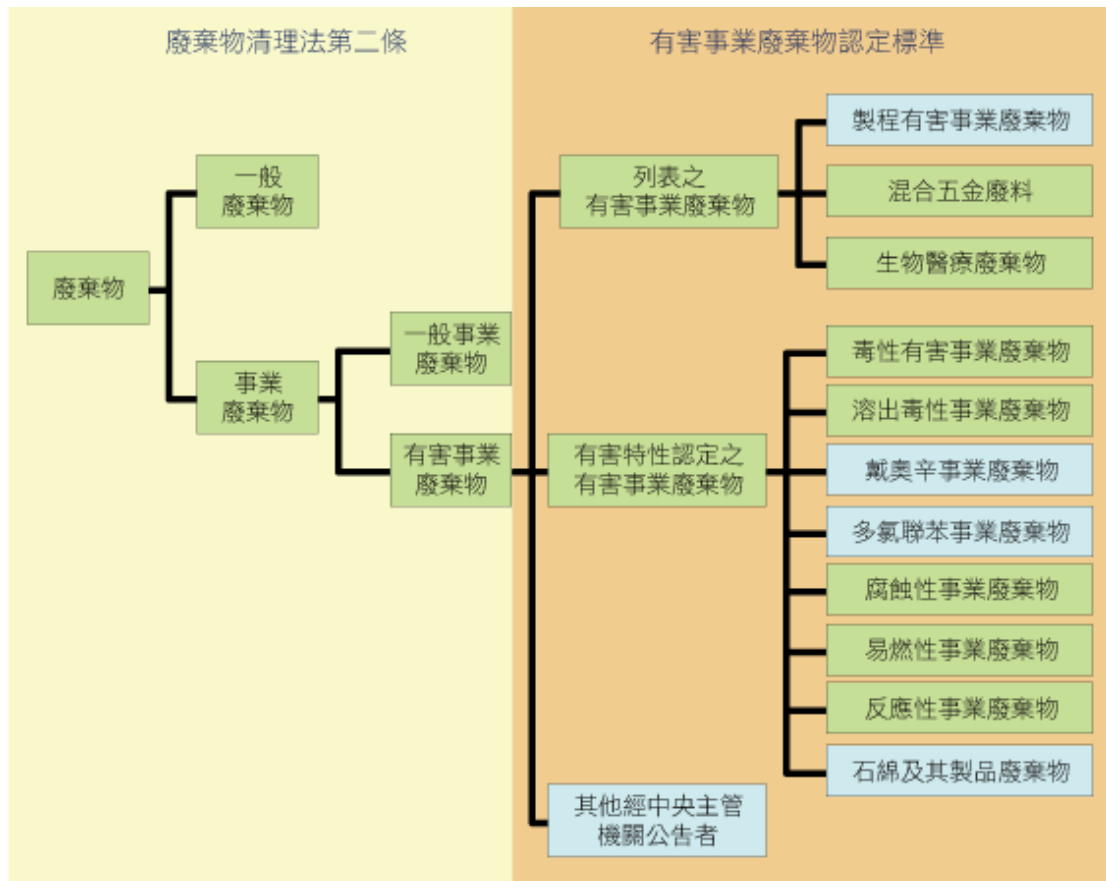


圖 3 醫療廢棄物的種類

資料來源：行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網⁶

醫院廢棄物

有害事業廢棄物

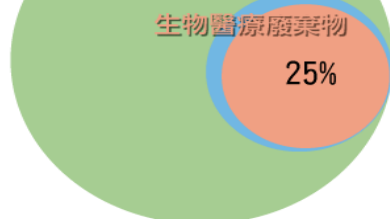


圖 4 醫療廢棄物的種類

資料來源：行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網⁷

<https://medwaste.epa.gov.tw/index3.html> (最後瀏覽日：2022年4月6日)。

⁶ 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，醫療廢棄物的種類，首頁>管理現況>何謂醫療廢棄物>醫療廢棄物的種類，網址：<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J02.html> (最後瀏覽日：2022年4月6日)。

依據有害事業廢棄物認定標準第3條規定：「列表之有害事業廢棄物種類如下：一、製程有害事業廢棄物：指附表一所列製程產生之廢棄物。二、混合五金廢料：依貯存、清除、處理及輸出入等清理階段危害特性判定，其認定方式如附表二。三、生物醫療廢棄物：指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生附表三所列之廢棄物。」。基此，有害事業廢棄物認定標準有就生物醫療廢棄物之定義予以規範，即生物醫療廢棄物係指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生附表三所列之廢棄物。有關其附表三所列之廢棄物內容容後補充介紹。



⁷ 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，同前註6。

醫療廢棄物在世界各國及不同的國際組織有不同之定義方式，世界各國對醫療廢棄物之名稱及涵蓋範圍比較整理如下⁸：

表 1 醫療廢棄物定義

單位	中/英文	說明
WHO 世界衛生組織	衛生保健廢棄物 Healthcare waste	從衛生保健機構產生之廢棄物，包括診斷、治療、預防、復健以及相關研究行為所產生之廢棄物。
UNEP 聯合國環境規劃署	生物醫療及衛生保健廢棄物 Biomedical and healthcare waste	衛生保健行為所產生之固體及液體廢棄物，包括收集之氣態廢棄物（廢罐裝氣體）。
USEPA 美國環保署	醫療廢棄物 Medical waste	所有由醫療設施產生之廢棄物質，包括醫院、診所、醫師辦公室、牙醫、血庫、獸醫院／診所、醫療研究設施及實驗室。
加拿大	生物醫療廢棄物 Biomedical waste	由人或動物的衛生保健機構、醫療或獸醫教學研究機構、衛生保健教學機構、臨床檢驗或研究實驗室以及生產或檢驗疫苗之設施產生之廢棄物。
英國	臨床廢棄物 Clinical Waste	1. 廢棄物包含或部分有人或動物之組織、血液、體液、排泄物、藥物、紗布、衣物、注射筒、針或其它尖銳器具等，接觸會危及個人安全之廢棄物。 2. 醫療、護理、牙醫、獸醫及藥物業務產生之廢棄物，包括調查、治療、照護、教學或研究、血液收集與運送等，任何人接觸會有導致感染之虞之廢棄物。

⁸ 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，醫療廢棄物定義，首頁>管理現況>何謂醫療廢棄物>醫療廢棄物定義，網址：<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J01.html>（最後瀏覽日：2022年4月6日）。

新加坡	醫院廢棄物 Hospital waste	包括感染性廢棄物、病理廢棄物、受污染的廢尖銳器具、例行的臨床廢棄物、細胞毒素廢棄物、放射性廢棄物、藥品廢棄物、化學廢棄物以及一般廢棄物。
香港	臨床廢棄物 Clinical Waste	任何牙醫、醫療、護理、或獸醫的工作，或由於疾病、受傷所提供衛生保健相關服務、病理或藥物研究、以及病理實驗室工作產生之廢棄物。
台灣	生物醫療廢棄物 Biomedical waste	指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生之廢棄物，包括：基因毒性廢棄物、廢尖銳器具、感染性廢棄物。

資料來源：醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(97 年版)⁹

第二項 生物醫療廢棄物之種類

對於生物醫療廢棄物之進一步細分類，美國疾病管制中心（CDC）和美國環境保署（EPA）將其依物種屬性細分為五類：（一）微生物類；（二）病理類；（三）動物類；（四）血液；（五）針頭。而依據我國環保法規之認定，醫療院所特有之生物醫療廢棄物，可大致歸類為三大類，屬於致癌或可能致癌之細胞毒素或其他藥物者，被歸類於基因毒性廢棄物；屬於對人體會造成刺傷或切割傷之廢棄物品，如注射針頭、與針頭相連之注射筒及輸液導管、針灸針、手術縫合針、手術刀、載玻片、蓋玻片或破裂之玻璃器皿等，被歸類為廢尖銳器具；至於廢棄之微生物培養物、菌株及相關生物製品、病理廢棄物、血液廢棄物、受污染動物屍體、

⁹ 醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(2008 年版)，頁 2，網址：
http://www.greenhosp.tw/Fckfile/file/醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊_97年版99更新.pdf
<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J01.html> (最後瀏覽日：2022年4月7日)。

殘肢及墊料、手術或驗屍廢棄物、實驗室廢棄物、透析廢棄物、隔離廢棄物、受血液及體液污染廢棄物等，則被歸類為感染性廢棄物。這些類別之廢棄物都必須依照事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，妥善加以處理¹⁰。

依據有害事業廢棄物認定標準第 3 條規定：「列表之有害事業廢棄物種類如下：一、製程有害事業廢棄物：指附表一所列製程產生之廢棄物。二、混合五金廢料：依貯存、清除、處理及輸出入等清理階段危害特性判定，其認定方式如附表二。三、生物醫療廢棄物：指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生附表三所列之廢棄物。」。其內附表三有就生物醫療廢棄物之種類及其成分與說明予以規範。



¹⁰ 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，生物醫療廢棄物的物種，首頁>管理現況>何謂醫療廢棄物物>生物醫療廢棄物的物種，網址：<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J03.html> (最後瀏覽日：2022年4月6日)。

表 2 「附表三生物醫療廢棄物」

附表三、生物醫療廢棄物

項目	成分與說明
一、基因毒性廢棄物	
(一)屬致癌之細胞毒素或其他藥物	azathioprine, chlorambucil(氮芥苯丁酸), chlornaphazine, ciclosporin, cyclophosphamide(環磷醯胺), melphalan(氮芥苯丙胺酸), semustine, tamoxifen(它莫西芬), thiotepa(沙奧特帕), treosulfan.
(二)可能致癌之細胞毒素或其他藥物	azacitidine, bleomycin, carmustine, chloramphenicol(氯絲菌素), chlorozotocin, cisplatin, dacarbazine, daunorubicin(道諾魯比辛), dihydroxymethylfuratriline, doxorubicin(杜薩魯比辛), lomustine, methylthiouracil(鉀硫脲酮), metronidazole(硝基甲噻唑乙醇), mitomycin, nafenopin, niridazole, oxazepam(歐沙氮平), phenacetin(非那西汀), phenobarbital(苯巴比妥), phenytoin(二苯妥因), procarbazine hydrochloride, progesterone(黃體素), sarcolysin, streptozocin, trichlormethine.
二、廢尖銳器具	指對人體會造成刺傷或切割傷之廢棄物品，包括注射針頭、與針頭相連之注射筒及輸液導管、針灸針、手術縫合針、手術刀、載玻片、蓋玻片或破裂之玻璃器皿等。
三、感染性廢棄物	
(一)廢棄之微生物培養物、菌株及相關生物製品	指廢棄之培養物、菌株、活性疫苗、培養皿或相關用具，及感染性生物材料製造過程產生之廢棄物。
(二)病理廢棄物	指手術或驗屍所取出之人體組織、器官、殘肢、體液等。但不含頭顱、屍體、頭髮、指甲及牙齒。
(三)血液廢棄物	指廢棄之人體血液或血液製品，包括血餅、血清、血漿及其他血液組成分。
(四)受污染動物屍體、殘肢及墊料	指接受微生物感染之實驗動物屍體、殘肢及其墊料，包括經檢疫後廢棄或因病死亡者。
(五)手術或驗屍廢棄物	指使用於外科手術治療、驗屍或解剖行為而廢棄之衣物、紗布、覆蓋物、排泄用具、褥墊、手術用手套。
(六)實驗室廢棄物	1.生物安全等級第三級及第四級實驗室所產生之廢棄物皆屬之。 2.生物安全等級第二級實驗室中與微生物接觸之廢棄物，包括拋棄式接種環及接種針、檢體、手套、實驗衣、拋棄式隔離衣等。
(七)透析廢棄物	指進行血液透析時與病人血液接觸之廢棄物，包括拋棄式導管、濾器、手巾、床單、手套、拋棄式隔離衣、實驗衣等。
(八)隔離廢棄物	指收容患傳染病病人之隔離病房所產出之廢棄物。
(九)受血液及體液污染廢棄物	指其他醫療行為所產生與病人血液、體液、引流液或排泄物接觸之廢棄物，包括各類廢棄之蛇型管、氧氣鼻導管、抽痰管、導尿管、引流管等，及沾有可流動人體血液、精液、陰道分泌物、腦脊髓液、滑液、胸膜液、腹膜液、心包液或羊水且可能導致滴濺之廢棄物。但不含止血棉球、使用過之個人衛生用品、沾有不可流動或不可吸收之人體分泌物的紗布、包紮物、尿布、面紙及廁所衛生紙等。
四、其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定對人體或環境具危害性，並經公告者。	

資料來源：醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(97 年版)¹¹

¹¹ 醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(2008 年版)，同前註 9，頁 6。

第三項 COVID—19（新冠肺炎）廢棄物

引據行政院衛生福利部疾病管制署就COVID—19（新冠肺炎）所述：「2019年12月起中國湖北武漢市發現不明原因肺炎群聚，疫情初期個案多與武漢華南海鮮城活動史有關，中國官方於2020年1月9日公布其病原體為新型冠狀病毒。此疫情隨後迅速在中國其他省市與世界各地擴散，並證實可有效人傳人。世界衛生組織（WorldHealth Organization, WHO）於2020年1月30日公布此為一公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），2月11日將此新型冠狀病毒所造成的疾病稱為COVID-19（Coronavirus Disease-2019），國際病毒學分類學會則將此病毒學名定為SARS-CoV-2（Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2）。為監測與防治此新興傳染病，我國於2020年1月15日起公告「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）為第五類法定傳染病，並於2020年1月21日確診第一起境外移入確診個案，另於1月28日確診第1例本土個案，為境外移入造成之家庭群聚感染。」¹²，此為行政院衛生福利部疾病管制署就COVID—19（新冠肺炎）之介紹。

國內外COVID—19（新冠肺炎）疫情仍持續發生，行政院衛生福利部疾病管制署為因應COVID—19（新冠肺炎）疫情，加強醫療機構、集中檢疫場所、居家隔離/居家檢疫者一般民眾對於其廢棄物能合適地進行處理，而於2020年6月8日訂定「因應COVID—19（武漢肺炎）醫療機構、集中檢疫場所、居家隔離/檢疫及一般民眾之廢棄物分類及清理作業原則」。其內容有分別就（一）醫療機構之廢棄物分類、貯存方式及清理方式；（二）集中檢疫所廢棄物清理方式；（三）居家檢疫或居家隔離者廢棄物處理方式；（四）一般民眾生活廢棄物，予以規範。茲就其四種情形整理如下：

壹、醫療機構之廢棄物分類、貯存方式及清理方式

¹² 衛生福利部疾病管制局，疾病介紹，首頁，傳染病與防疫專題，傳染病介紹，第五類法定傳染病，嚴重特殊傳染性肺炎，網址：
<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/v1eOMKqwuEbIMggaTeXG8A>（最後瀏覽日：2022年4月6日）。

有關COVID—19（新冠肺炎）醫療院所之廢棄物分類及清理方式，依據「醫療機構因應COVID—19（武漢肺炎）感染管制措施指引」建議，仍應遵守行政院環境保護署發布之「廢棄物清理法」相關規定處理，亦即疫情期間，醫療院所之廢棄物分類及清理方式，仍比照廢棄物清理法第2條規定及有害事業廢棄物認定標準第3條規定，予以處理，區分成一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，有害事業廢棄物又包括但不限於生物醫療廢棄物。

貳、集中檢疫所廢棄物清理方式

有關COVID—19（新冠肺炎）集中檢疫所之廢棄物分類及清理方式，為避免COVID—19（新冠肺炎）擴散，故行政院環境保護署依照感染性廢棄物來處理集中檢疫隔離者所產生之廢棄物，並依據行政院環境保護署2020年2月3日「因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理集中檢疫場所被隔離者垃圾收集清運處理作業程序」，由中央流行疫情指揮中心提供名單後，委由甲級廢棄物清除機構及甲級處理機構清除處理。誠如有害事業廢棄物認定標準第3條規定之附表三所載內容，感染性廢棄物屬於生物醫療廢棄物當中之種類，亦即被隔離者所產出之廢棄物一律視為生物醫療廢棄物，由上述甲級廢棄物清除機構及甲級處理機構清除處理。

參、居家檢疫或居家隔離者廢棄物處理方式

有關COVID—19（新冠肺炎）居家檢疫或居家隔離者於居家隔離/檢疫期間因不得外出，故不得外出丟垃圾，若屬於行動方便者，其所產出之垃圾有排出需求，可由行政院環境保護署提供各縣市專線電話聯絡後，由同住家人交給與行政院環境保護署簽約之清除處理業者，亦即應視同COVID—19（新冠肺炎）疑似感染個案，採以感染性廢棄物之標準處理，亦即相同於集中檢疫所被隔離者所產出之廢棄物一律視為生物醫療廢棄物，或於隔離/檢疫結束後，因已排除為COVID—19（新冠肺炎）疑似感染者，其所產出之垃圾可依一般廢棄物處理，即依一般處理垃圾之原則，交由清潔隊垃圾車收運處理。由於COVID—19（新冠肺炎）疫情之持續擴大，致居家隔離及居家檢疫者人數持續增加，已啟動改變採取當居家檢疫或居家隔離者所產出之垃圾有排出需求，依據行政院環境保護署2020年3月24日「各級環保機關因嚴重特殊傳染性肺炎辦理居家隔離或居家檢疫者垃圾收集清運處理作業程

序」，經與行政院環境保護署提供各縣市專線電話聯絡後，由乙級或甲級之廢棄物清除機構先行清運至集中點，再由行政院環境保護署委託之甲級清除機構轉運至甲級廢棄物處理設施處理。

若屬於獨居或行動不便者，其所產出之垃圾有排出需求，視同COVID-19（新冠肺炎）疑似感染個案，採以感染性廢棄物之標準處理，亦即相同於集中檢疫所被隔離者所產出之廢棄物一律視為生物醫療廢棄物，經與行政院環境保護署提供各縣市專線電話聯絡後，由乙級或甲級之廢棄物清除機構先行清運至集中點，再由行政院環境保護署委託之甲級清除機構轉運至甲級廢棄物處理設施處理，避免COVID-19（新冠肺炎）擴散，或於隔離/檢疫結束後，因已排除為COVID-19（新冠肺炎）疑似感染者，其所產出之垃圾可依一般廢棄物處理，即依一般處理垃圾之原則，交由清潔隊垃圾車收運處理。

肆、一般民眾生活廢棄物

有關COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，一般民眾生活廢棄物仍依一般民眾處理生活廢棄物處理方式予以處理，惟因現階段因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，一般民眾普遍都會佩戴口罩，民眾使用後之口罩屬於一般垃圾，即一般廢棄物，向內對折後再直接丟入垃圾袋。當有感冒、發燒、流鼻水等症狀一般民眾應將口罩向內對折先放入塑膠袋密封再丟入塑膠袋，經妥善收集後，將垃圾袋交由垃圾車處理。

伍、小結

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，行政院環境保護署依據中央流行疫情指揮中心分工，結合各縣市環境保護局，委託專業廢棄物清除處理機構辦理防疫廢棄物清理作業。對於醫療機構產出之生物醫療廢棄物、集中檢疫所產出之廢棄物直接交由甲級廢棄物清除機構清除至甲級廢棄物處理機構處理，已如上述，並無疑義。而對於居家隔離、居家檢疫者及防疫旅館之隔離及檢疫者廢棄物，由各縣市政府委託乙級廢棄物清除機構收運送地方設置之集中點，再由行政院環境保護署委託甲級廢棄物清除機構轉運送至甲級廢棄物處理機構處理，落實徹底與清潔隊收運一般家戶垃圾分流，俾使一般民眾丟棄家戶垃圾時，並無傳染COVID-19（新

冠肺炎)之問題，茲區分成法規遵循面及簽訂委託防疫廢棄物清除及處理契約面予以探討。

一、在法規遵循面

誠如上述，行政院環境保護署已訂定上開「因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理集中檢疫場所被隔離者垃圾收集清運處理作業程序」及上開「各級環保機關因嚴重特殊傳染性肺炎辦理居家隔離或居家檢疫者垃圾收集清運處理作業程序」等行政命令，執行隔離及檢疫者之垃圾清運，全力協助防疫工作。

二、簽訂委託防疫廢棄物清除及處理契約面

行政院環境保護署為執行COVID-19(新冠肺炎)防疫工作，特簽訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎之防疫需求廢棄物清理服務開口契約」、「因應嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、居家檢疫者及集中檢疫場所廢棄物清理服務開口契約」等，委託甲級廢棄物清除機構、甲級廢棄物處理機構負責執行居家隔離、居家檢疫者及集中檢疫所隔離者之防疫垃圾收運處理工作；各地方環保局則委託乙級廢棄物清除機構負責收運送地方設置之集中點，再由行政院環境保護署委託甲級廢棄物清除機構轉運送至甲級廢棄物處理機構處理。

誠如上述，行政院衛生福利部疾病管制署為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情，加強醫療機構、集中檢疫場所、居家隔離/居家檢疫者一般民眾對於其廢棄物能合適地進行處理，必透過由相關政府機關或政府機關所屬事業辦理醫療機構、集中檢疫場所、居家隔離/居家檢疫者產出之廢棄物處理勞務採購標案，藉由生物醫療廢棄物處理業者參與投標，進而得標，藉由符合投標廠商資格條件之生物醫療廢棄物處理業者之能力協助妥善處理廢棄物，由於生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司即為甲級廢棄物處理機構，於COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，也透過參與行政院環境保護署辦理「因應嚴重特殊傳染性肺炎之防疫需求廢棄物清理服務開口契約」、「因應嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、居家檢疫者及集中檢疫場所廢棄物清理服務開口契約」等勞務採購標案，於得標後，與行政院環境保護署簽訂上開委託防疫廢棄物處理契約，積極協助國內集中檢疫場所、居家隔離、居家檢疫者產出之廢棄物

妥善處理，盡一份心力。



第二節 採取焚化處理之生物醫療廢棄物處理業者

第一項 生物醫療廢棄物之處理

依據事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第2條規定：「本標準專用名詞定義如下：一、貯存：指事業廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。二、清除：指事業廢棄物之收集、運輸行為。三、處理：指下列行為：（一）中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。（二）最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。（三）再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。四、清理：指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為。五、相容性：指事業廢棄物與容器、材料接觸，或二種以上之事業廢棄物混合，不發生下列效應者：（一）產生熱。（二）產生激烈反應、火災或爆炸。（三）產生可燃性流體或有害流體。（四）造成容器材料劣化，致降低污染防治之效果。六、固化法：指利用固化劑與事業廢棄物混合固化之處理方法。七、穩定法：指利用化學劑與事業廢棄物混合或反應使事業廢棄物穩定化之處理方法。八、熱處理法：（一）焚化法：指利用高溫燃燒，將事業廢棄物轉變為安定之氣體或物質之處理方法。（二）熱解法：指將事業廢棄物置於無氧或少量氧氣之狀態下，利用熱能裂解使其分解成為氣體、液體或殘渣之處理方法。（三）熔融法：指將事業廢棄物加熱至熔流點以上，使其中所含有害有機物質進一步氧化或重金屬揮發，其餘有害物質則存留於熔渣中產生穩定化、固化作用之處理方法。（四）熔煉法：指將事業廢棄物併入金屬高溫冶煉製程中，合併進行高溫減量處理或金屬資源回收之處理方法。（五）其他熱處理法。九、氧化分解法：指利用化學氧化、電解氧化或濕式氧化方式，將事業廢棄物中特定污染物分解之處理方法。十、化學處理法：指利用化學方式處理事業廢棄物者，包括中和法、氧化還原法、萃取法、化學調理法、離子交換法、化學冶煉法、電解法及氣提法等各式處理方法。十一、洗淨處理法：指事業廢棄物貯存容器經水洗或溶劑

清洗後，該貯存容器所含有害成分特性消失之處理方法。十二、物理處理法：指利用物理方式處理事業廢棄物者，包括蒸發、蒸餾、薄膜分離、油水分離、固液分離、破碎、粉碎、拆解、剝離、分選或壓縮等各式處理方法。十三、滅菌法：指在一定時間內，以物理（含微波處理）或化學原理將事業廢棄物中微生物消滅之處理方法，其指標微生物削減率（reduction rate）至少須達百分之九九·九九者；其採高溫高壓蒸氣滅菌者，以嗜熱桿菌芽孢測試；採其他滅菌法者，以枯草桿菌芽孢測試。十四、掩埋法：（一）安定掩埋法：指將一般事業廢棄物置於掩埋場，設有防止地盤滑動、沈陷及水土保持設施或措施之處理方法。（二）衛生掩埋法：指將一般事業廢棄物掩埋於以不透水材質或低滲水性土壤所構築，並設有滲出水、廢氣收集處理設施及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。（三）封閉掩埋法：指將有害事業廢棄物掩埋於以抗壓及雙層不透水材質所構築，並設有阻止污染物外洩及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。十五、自動辨識及資料擷取系統（AIDC）：指藉由不同輸入介面之讀取裝置自動辨識物件，並將擷取資料儲存至電腦系統，達到廢棄物識別之系統。十六、破壞去除效率（DRE）：指主要有害有機物質（POHCs）以熱處理法處理時，其處理前總重量減去煙道排氣所含總重量，除以處理前總重量之百分比。十七、燃燒效率（CE）：指煙道出口之排氣中所含二氧化碳濃度與二氧化碳及一氧化碳濃度總和之百分比。十八、有毒重金屬廢棄物：指含有害事業廢棄物認定標準附表一所列成分為重金屬之事業廢棄物，或經毒性特性溶出程序超過有害事業廢棄物認定標準附表四所列有毒重金屬項目標準之事業廢棄物。」。基此，上開設施標準第2條規範有就事業廢棄物之處理方式予以規範，有關事業廢棄物之處理方式，主要分成中間處理、最終處理及再利用，本文著重於探討事業廢棄物之中間處理方式，尤以對於生物醫療廢棄物之中間處理方式為探討重心。

另觀諸事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第21條規定：「生物醫療廢棄物除中央主管機關另有規定外，應先經中間處理，其處理方法如下：一、基因毒性廢棄物：以熱處理法或化學處理法處理。二、廢尖銳器具：以熱處理法處理或滅菌後粉碎處理。三、感染性廢棄物：以熱處理法處理。但廢棄之微生物培養物、菌株及相關生物製品、手術或驗屍廢棄物、實驗室廢棄物、透析廢棄物、受血液及體液污染廢棄物，得經滅菌後破壞原型處理；未破壞原形者，應於包裝容

器明顯處標示產出事業名稱、滅菌方式、滅菌操作人員或事業名稱、滅菌日期及滅菌效能測試結果。滅菌法之處理標準、操作規定及滅菌效能測試之標準程序，依中央主管機關之規定辦理。」，可得而知生物醫療廢棄物之中間處理方式，包括但不限於熱處理法，但熱處理法應為其主要中間處理方式，且依據上開設施標準第 2 條規定，熱處理法包括但不限於焚化法，基於本文係以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司做為個案研究並為貫穿全文之中心，故本章內容之介紹係以探求生物醫療廢棄物之焚化處理為主。經彙整國內近一年（2021 年）（2021 年屬於最近之完整年度）生物醫療廢棄物之中間處理方式，共 20 筆，可得而知生物醫療廢棄物之中間處理方式，如下：

表 3 生物醫療廢棄物之處理方式

編號	年/月	代碼	廢棄物	處理方式代碼	處理方式	重量
1	2021/1	C-0514	感染性廢棄物（遭污染物品或器具類）	Z04	熱處理（除焚化處理外）	0.7639公噸
2	2021/1	C-0514	感染性廢棄物（遭污染物品或器具類）	Z01	滅菌處理	22.411公噸
3	2021/1	C-0514	感染性廢棄物（遭污染物品或器具類）	R99	作為其他再利用之用途	19.8359公噸
4	2021/1	C-0514	感染性廢棄物（遭污染物品或器具類）	R03	將廢棄物作為再利用之材料、添加物使用	509.896723公噸
5	2021/1	C-0514	感染性廢棄物（遭	R02	將廢棄物作為再利	91.5908公噸

			污 染 物 品 或 器 具 類)		用 之 原 料 使 用	
6	2021/1	C-0513	感 染 性 廢 棄 物 (病 理 、 血 液 、 受 污 染 動 物 屍 體 、 殘 肢 及 墊 料 類)	Z05	焚化處理	157.482564公噸
7	2021/1	C-0513	感 染 性 廢 棄 物 (病 理 、 血 液 、 受 污 染 動 物 屍 體 、 殘 肢 及 墊 料 類)	Z04	熱 處 理 (除 焚 化 處 理 外)	0.0276公噸
8	2021/1	C-0512	基 因 毒 性 廢 棄 物	Z05	焚化處理	52.579578公噸
9	2021/1	C-0512	基 因 毒 性 廢 棄 物	Z04	熱 處 理 (除 焚 化 處 理 外)	0.0007公噸
10	2021/1	C-0504	廢 尖 銳 器 具	Z05	焚化處理	175.128874公噸
11	2021/1	C-0504	廢 尖 銳 器 具	Z04	熱 處 理 (除 焚 化 處 理 外)	0.3417公噸
12	2021/1	C-0504	廢 尖 銳 器 具	Z01	滅菌處理	13.542公噸
13	2021/1	C-0504	廢 尖 銳 器 具	R99	作為其他 再利用之 用途	0.2485公噸
14	2021/1	C-0504	廢 尖 銳 器 具	R03	將廢棄物 作為再利 用 之 材	13.755017公噸

					料、添加物使用	
15	2021/1	C-0504	廢尖銳器具	R02	將廢棄物作為再利用之原料使用	7.14公噸
16	2021/1	C-0599	感染性廢棄物混合物	Z01	滅菌處理	0.1244公噸
17	2021/1	C-0599	感染性廢棄物混合物	Z04	熱處理（除焚化處理外）	2.12859公噸
18	2021/1	C-0599	感染性廢棄物混合物	Z05	焚化處理	1524.040926公噸
19	2021/1	C-0599	感染性廢棄物混合物	X99	其他最終處理方式	0.32公噸
20	2021/1	C-0514	感染性廢棄物（遭污染物品或器具類）	Z05	焚化處理	484.689318公噸

資料來源：政府資訊平臺，經作者整理製表¹³

經探求上開國內近一年（2021 年）生物醫療廢棄物之中間處理方式，可得而知焚化處理及滅菌理皆屬於常使用之生物醫療廢棄物中間處理方式，焚化處理為傳統之生物醫療廢棄物處理業者所採用之生物醫療廢棄物中間處理方式，且歷時已久，而滅菌處理為新興之生物醫療廢棄物處理業者所採用之生物醫療廢棄物中間處理方式，且誠如事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 21 條規定所述，二者最大之差別在於處理種類之不同，焚化處理得處理生物醫療廢棄物當中之所有廢棄物種類，包括基因毒性廢棄物、廢尖銳器具及感染性廢棄物，而就滅菌處理而言，滅菌處理只能得處理生物醫療廢棄物當中之二種廢棄物種類，包括廢尖

¹³ 政府資料平臺網頁－資料集 / 重點事業廢棄物-生物醫療廢棄物之處理方式，網址：
<https://data.gov.tw/dataset/47255> (最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。

銳器具及感染性廢棄物，基因毒性廢棄物並無法採取滅菌處理予以處理，此為二者最大之差異。

本文本在探究生物醫療廢棄物處理業者參與勞務採購標案所發生之法律爭議問題，本文研究之重心之一即圍繞在研析政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，對於標案生物醫療廢棄物中間處理方式要求、生物醫療廢棄物之種類與其代碼、名稱之不同，各自採取不同之投標廠商資格要求，即投標廠商資格條件，致使影響生物醫療廢棄物處理業者能否參與政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案及發生爭議時，所採取之救濟管道，此亦影響生物醫療廢棄物處理業者權利甚鉅，關於此研究議題詳細內容容於本文後面章節予以介紹。

第二項 生物醫療廢棄物處理業者之定義

依據廢棄物清理法第 28 條規定：「事業廢棄物之清理，除再利用方式外，應以下列方式為之：一、自行清除、處理。二、共同清除、處理：由事業向目的事業主管機關申請許可設立清除、處理該類廢棄物之共同清除處理機構清除、處理。三、委託清除、處理：（一）委託經主管機關許可清除、處理該類廢棄物之公營廢棄物清除處理機構清除、處理。（二）經執行機關同意，委託其清除、處理。（三）委託目的事業主管機關自行或輔導設置之廢棄物清除處理設施清除、處理。（四）委託主管機關指定之公營事業設置之廢棄物清除處理設施清除、處理。（五）委託依促進民間參與公共建設法與主辦機關簽訂投資契約之民間機構設置之廢棄物清除處理設施清除、處理。（六）委託依第二十九條第二項所訂管理辦法許可之事業之廢棄物處理設施處理。四、其他經中央主管機關許可之方式。經中央主管機關指定公告之事業，應置專業技術人員，其採自行清除、處理事業廢棄物之事業，其清除機具及處理設施或設備應具備之條件、許可、許可期限、廢止及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之。第一項第二款共同清除處理機構應具備之條件、分級、許可、許可期限、廢止、專業技術人員設置、營運、操作紀錄與其他應遵行事項之管理辦法，由中央目的事業主管機關會同中央主管機關定之。第一項第三款第三目所輔導設置之廢棄物清

除處理設施應具備之專業技術人員設置、營運、操作紀錄與其他應遵行事項之管理辦法，由中央目的事業主管機關會商相關機關定之。第一項第三款第四目及第五目所設置之廢棄物清除處理設施應具備之專業技術人員設置、營運、操作紀錄與其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會商相關機關定之。第一項第三款第二目執行機關受託清除處理一般事業廢棄物，應於處理下列一般廢棄物後，仍有餘裕處理能量，始得為之，並依直轄市、縣（市）主管機關所定事業廢棄物代清除處理收費標準收費，並配合該事業依第三十一條第一項第二款規定辦理申報：一、屬指定清除地區內者。二、屬依第七條及地方制度法第二十四條之一規定之區域性聯合及跨區域合作處理者。三、屬中央主管機關統一調度者。一般廢棄物或一般事業廢棄物之清除處理設施，不得合併清除、處理有害事業廢棄物。中央主管機關於不影響執行機關處理第六項第一款及第二款一般廢棄物情形下，於必要時得統一調度使用現有廢棄物清除處理設施，被調度者不得拒絕。前項統一調度之條件、方式、費用及其他應遵循事項之辦法，由中央主管機關定之。」。基此，事業廢棄物之處理方式有諸多方式，而委託經主管機關許可處理該類廢棄物之民營廢棄物處理機構處理，為其中一種，也為目前國內主要事業廢棄物委託處理之方式之一。

且依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 2 條規定：「本辦法所稱公民營廢棄物清除處理機構，指從事廢棄物清除、處理業務之下列二種公、民營機構：一、廢棄物清除機構（以下簡稱清除機構）：接受委託清除廢棄物至境外或該委託者指定之廢棄物處理場（廠）處理之機構。二、廢棄物處理機構（以下簡稱處理機構）：接受委託處理廢棄物之機構。本辦法所稱廢棄物清除、處理技術員（以下簡稱清除、處理技術員），指取得清除、處理技術員合格證書，設置於清除、處理機構，從事廢棄物清除、處理業務之專業技術人員。本辦法所稱核發機關，指本法第四十一條第一項核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件之直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關。」。

另依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 3 條規定：「本取得核發機關核發廢棄物清除許可證（以下簡稱清除許可證）之清除機構，始得接受委託

清除廢棄物。取得核發機關核發廢棄物處理許可證（以下簡稱處理許可證）之處理機構，始得接受委託處理廢棄物。申請處理許可證者，於設置廢棄物處理場（廠）前，應申請核發機關之同意設置文件（以下簡稱同意設置文件）。但既有之工廠或廢棄物處理設施得於進行試運轉後逕行申請處理許可證。前項所稱既有之工廠，除依法免辦工廠設立登記者外，指於申請處理許可證前，已依相關規定取得工廠登記且有相同產品，並實際運作之工廠。」；廢棄物清理法第 41 條規定，從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務。

基上，生物醫療廢棄物處理業者之意義即為滿足上開廢棄物清理法相關法令之要求，取得處理許可證之接受委託處理生物醫療廢棄物之機構。



第三項 生物醫療廢棄物處理業者之種類

我國國內得處理生物醫療廢棄物之處理機構如下：

表 4 處理生物醫療廢棄物之處理機構

機構名稱	許可證
嘉德創資源股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
環瑋醫療廢棄物處理股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
日友環保科技股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
國鉅環保科技股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
漢杞工程股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
達闢友力股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
日環股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
嘉德技術開發股份有限公司	公民營廢棄物處理機構
高雄醫療廢棄物處理股份有限公司	衛生福利部醫療廢棄物共同處理機構
花蓮縣醫師公會	衛生福利部醫療廢棄物共同處理機構
有限責任臺中市環保科技處理設備利用合作社	衛生福利部醫療廢棄物共同處理機構
水美工程企業股份有限公司觀音廠	經濟部輔導設置
可寧衛蘇伊士環境資源股份有限公司	經濟部輔導設置
日友環保科技股份有限公司彰濱資源回收處理廠	經濟部輔導設置
科技部南部科學園區管理局(台南園區資源再生中心)	科技部輔導設置
吉祥資源科技股份有限公司	衛生福利部再利用許可
丰彩環保科技股份有限公司	衛生福利部再利用許可
丰偉環保科技股份有限公司	衛生福利部再利用許可
丰梵環保科技股份有限公司	衛生福利部再利用許可
醫會環保有限公司	衛生福利部再利用許可
郁傑科技股份有限公司	衛生福利部再利用許可
茂生資源科技有限公司	衛生福利部再利用許可

資料來源：作者自行製表

上開生物醫療廢棄物處理業者之區別除了有關生物醫療廢棄物之處理方式有所未盡相同，誠如上開表 3—生物醫療廢棄物之處理方式所示之外，其機構之成立之法律依據、主管機關或輔導機關也有所不同，或者為行政院環境保護署、行政院經濟部、行政院衛生福利部、行政院科技部等，而以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司而言，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為依據公司法所設立之股份有限公司，就生物醫療廢棄物之處理方式係採取焚化處理，中央主管機關為行政院環境保護署。

雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為國內第一家專業生物醫療廢棄物焚化處理公司，以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司有取得雲林縣政府廢棄物處理許可證(甲級)，許可處理廢棄物種類包括「一般廢棄物及一般事業廢棄物」與「有害事業廢棄物」，「有害事業廢棄物」當中尤以生物醫療廢棄物(廢棄物代碼：C-05)，是以就上開表 3—生物醫療廢棄物之廢棄物代碼所示皆 C-05 而言，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司皆有資格協助上開表 3—生物醫療廢棄物處理，於 2003 年 SARS 爆發之際，更為行政院環境保護署指定為 SARS 廢棄物專責處理廠，於 2012 年取得中區事業廢棄物綜合處理中心經營權，目前主要業務是生物醫療廢棄物與事業廢棄物之處理，目前技術先進，水準領先，已成功將國外技術運用於國內外各類型之有害廢棄物處理領域，同時具備有害廢棄物清運、焚化、固化、物化及掩埋最終處理等項目，有效整合有害廢棄物上、中、下游一條龍式之專業服務，根據行政院環境保護署以及雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司年報可推算，目前全國有害性醫療廢棄物佔全國一年平均垃圾量約 25%，其中雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司之處理量佔了約 40%，可說是國內生物醫療廢棄物處理之龍頭公司之一，也係屬最適宜之研析生物醫療廢棄物處理業者生態之最具有指標之研究標的。

第四項 生物醫療廢棄物處理業者之設備

基於生物醫療廢棄物處理業者就有關生物醫療廢棄物之處理方式之不同，而擁有不同之生物醫療廢棄物之處理設備，一般生物醫療廢棄物處理業者大都採用焚化處理來處理生物醫療廢棄物，且為最大宗之生物醫療廢棄物處理方式，焚化處理完成後較不會有後續問題產生，對醫療院所或其他機構、單位來說也可以不用擔心未來有意外發生。本章節就生物醫療廢棄物處理業者之處理設備之介紹，係以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，並以焚化處理設備作為介紹，茲介紹如下：

壹、法律遵循面

依據事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 23 條規定：「事業廢棄物之中間處理設施，除中央主管機關另有規定外，應符合下列規定：一、應有堅固之

基礎結構。二、設施與廢棄物接觸之表面，採抗蝕及不透水材料構築。三、設施周圍應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設施或措施。四、應具有防止廢棄物飛散、流出、惡臭擴散及影響四周環境品質之必要措施。五、應有污染防治設備及防蝕措施。」、第 24 條規定：「有害事業廢棄物之焚化處理設施，除依前條規定外，並應符合下列規定：一、燃燒室出口中心溫度應保持攝氏一千度以上；燃燒氣體滯留時間，生物醫療廢棄物之廢尖銳器具及感染性廢棄物在一秒以上，其他有害事業廢棄物在二秒以上。二、焚化感染性廢棄物者，燃燒效率達百分之九十九·九以上。三、除焚化感染性廢棄物外，其他有害事業廢棄物之有機氯化物破壞去除效率達百分之九十九·九九以上，多氯聯苯（PCBs）及戴奧辛有害事業廢棄物破壞去除效率達百分之九十九·九九九以上，其他毒性化學物質破壞去除效率達百分之九十九·九以上。四、具有自動監測、燃燒條件自動監測及控制、燃燒室出口中心溫度連續記錄及緊急應變處理裝置。五、其他經中央主管機關公告之事項。流體化床廢棄物焚化爐不受前項第一款及第二款之限制。」。基此，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準有就有有害事業廢棄物之焚化處理設施予以規範要求。

貳、設備運作面

焚化處理為生物醫療廢棄物最佳處理方式，減容性高及對有機物之破壞去除率佳，在我國，常見之焚化爐形式有下列二種：（1）流體化床（Fluidized Bed）；（2）旋轉窯（Rotary Kilns）。雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司於雲林地區擁有二座得處理生物醫療廢棄物之焚化爐，就焚化爐形式皆採取旋轉窯（Rotary Kilns）之焚化爐形式，焚化處理技術採最先進之節能設施，利用熱交換所得之高溫空氣與尾氣混合提升排放溫度，技術領先且節能環保。一般廢棄物焚化系統，其主要構造包括進料系統、焚化爐爐體、燃燒室、降溫塔、洗滌塔、濾袋室、及供排氣設備等。有關旋轉窯焚化爐架構圖如下圖：

Rotary Kiln Incinerator 旋窯式焚化爐

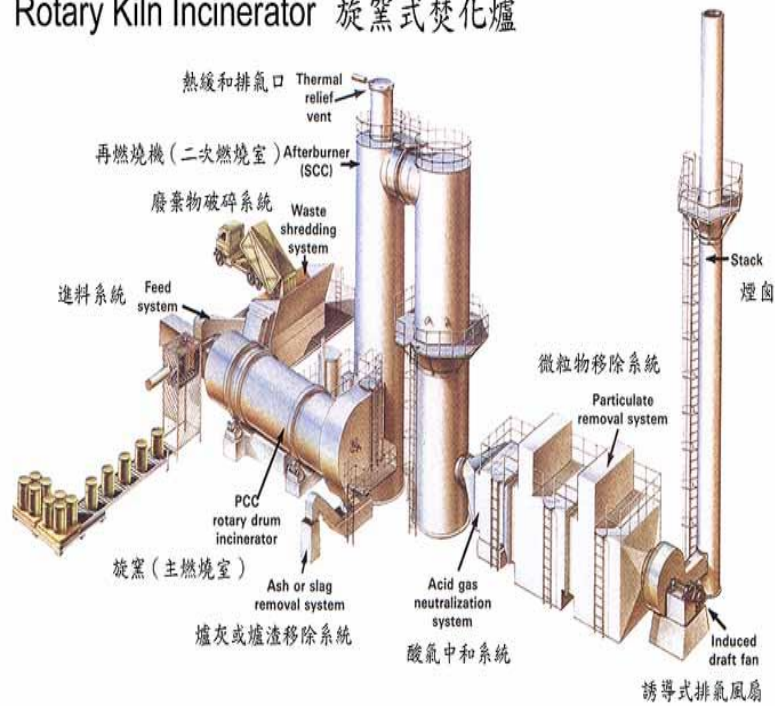


圖 5 旋轉窯焚化爐架構圖

資料來源：能基實業有限公司網頁—旋窯／旋轉乾燥爐—旋轉窯焚化爐架構圖¹⁴

¹⁴ 能基實業有限公司網頁—旋窯／旋轉乾燥爐—旋轉窯焚化爐架構圖，網址：
energytek.tw/tw/a14.html (最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。

第三章 我國生物醫療廢棄處理業者就勞務採購標案之處置

第一節 政府採購行為之介紹

第一項 政府採購行為探究之必要性

基於政府採購行為係政府機關或政府機關所屬事業獲取完善解決、完成行政任務所需之工程、財物及勞務之方式之一，尤屬重要，無論是選擇採購標的和方式、撰擬招標文件、決定得標廠商等，皆為政府機關或政府機關所屬事業行使職權之範疇，除須依循政府採購法之規定外，但仍須考量個案狀況所涉及其他法律以為依據，並以適能、適宜為採購之原則，同樣的，政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，亦須從決定委託處理之廢棄物種類、廢棄物代碼、委託處理廢棄物重量、委託廢棄物處理之方式（包括但不限於焚化處理、熱處理、滅菌處理及再利用等）、廠商需具備主管機關核發之處理許可證種類、擬訂招標文件包括但不限於投標須知、政府勞務採購契約等、招標方式等，也須以政府採購法及廢棄物清理法等相關法令作為準繩，予以採納適用，並衡諸個案狀況之不同，辦理相關生物醫療廢棄物處理勞務採購標案。影響所及，也肇致每一生物醫療廢棄物處理業者並不一定得完全參與投標全部政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，而在符合該標案設定之廢棄物種類、廢棄物代碼、委託處理廢棄物重量、委託廢棄物處理之方式（包括但不限於焚化處理、熱處理、滅菌處理及再利用等）、廠商需具備主管機關核發之處理許可證種類之條件下，才具有基本參與投標該標案之投標資格，可見投標政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，而在符合該標案設定之廢棄物種類、廢棄物代碼、委託處理廢棄物重量、委託廢棄物處理之方式（包括但不限於焚化處理、熱處理、滅菌處理及再利用等）、廠商需具備主管機關核發之處理許可證種類對於生物醫療廢棄物處理業者係屬重要。

有關行政院環境保護署及行政院公共工程委員會有就政府機關或政府機關所屬事業辦理廢棄物清除、處理業務招標應行注意事項，即關於投標廠商資格條件訂定，要求應以廢棄物清理法及政府採購法等相關法令作為依循，此有行政院環境保護署 92 年度 10 月 23 日環署廢字第 0920074650 號函：「主旨：有關孫大千

立法委員九十二年十月三日千字（九二）第一〇〇三〇七號函為中央政府所屬機關及各縣市政府行政單位辦理廢棄物清除、處理工程招標工作應注意事項乙案，本署意見如后，請查照。說明：1. 復貴會九十二年十月十五日工程企字第〇九二〇〇四〇九六三〇號函。2. 依廢棄物清理法第四十一條規定：『從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務。』即如欲從事廢棄物清除處理業務者，應依前述規定取得公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務。3. 另依『公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法』第二條規定，廢棄物清除機構係指接受委託清除廢棄物至境外或該委託者指定之廢棄物處理場（廠）處理之機構。廢棄物處理機構係指接受委託處理廢棄物之機構。廢棄物清理機構係指接受委託清除並處理或處理廢棄物之機構。上述三種公、民營機構因其可從事業務不同，除應分別取得許可外，且應依廢棄物清理法及其相關規定及審查通過之申請文件內容辦理，不得為未經許可之事項，且應自行清除、處理。4. 另依『事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準』第三十七條規定，事業採本法第二十八條第一項第二款至第四款規定之方式清除、處理事業廢棄物者，應先與受託處理者簽訂書面契約或取得執行機關出具同意處理之證明文件，載明事業廢棄物種類、數量及期限，始得自行清除或委託清除至該廢棄物受託處理者處理。亦即，事業應分別與清除、處理或清理機構完成簽訂書面契約後，始得委託清除、處理廢棄物。5. 另依廢棄物清理法第二十八條第一項第三款規定，事業廢棄物之委託清除、處理，除可委託經主管機關許可清除、處理之公民營廢棄物清除處理機構外，尚包含第三款第二目至第六目之清除處理設施。6. 綜上，招標案件如係廢棄物清除、處理業務之委託，應依前開規定明確規範其招標資格及其相關規定，避免造成非法委託清除、處理廢棄物之情事發生。」及行政院公共工程委員會 92 年 10 月 31 日工程企字第 09200433060 號函：「主旨：檢送行政院環境保護署九十二年十月二十三日環署廢字第 0920074650 號函示機關辦理廢棄物清除、處理業務招標應行注意事項（影本如附），請查照並轉知所屬（轄）機關。說明：關於投標廠商資格條件之訂定，投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第二條至第四條已有基本資格之規定。」可資

參考。是以有關政府採購行為之探討，於本文有其必要性，相當於本文前面章節與後面章節串聯之不可或缺之所興建之橋梁，本章之內容即就政府採購行為之研議展開討論。

第二項 政府採購行為探究之重要性

在現代國家中，行政權呈現不斷擴充之趨勢，內容也日益複雜，以行政行為之態樣加以區分，包括公權力行政及私經濟行政。公權力行政亦稱為高權行政，指國家居於統治主體之地位，行使公權力所從事之行政行為，人民與國家或人民與地方自治團體間之權利義務關係事項，均屬公權力之對象，所使用之行政作用方式包括行政命令、行政處分、行政契約、行政指導或地方自治規章等。私經濟行政亦稱之為國庫行政，係相對於公權力行政而言，指國家並非居於公權力主體地位行使其統治權，而係國家居於私人相當之法律地位，並在私法之支配下所為之各種行為，應適用私法規定。兩者簡單判別標準為：上下秩序關係之事項（亦即強制與服從關係），屬公權力行政，平等關係之事項則為私經濟行政。

現代國家與人民關係日益密切，國家為維持本身政務運作或施政需求，多向私人添購所需物資¹⁵，包括但不限於工程、財物及勞務，基於國家需求廣泛，採購金額自然龐大，動支之預算來自國家對人民稅捐之收入，且具一定之經濟與政策功能¹⁶，而畢竟與私人間交易而有所差別，也與國家與人民權力服從關係有所不同，因此政府採購有其法制化之必要，進而催生政府採購法之制定，是以政府採購究竟屬於公權力行政或私經濟行為，殊值探討。

第三項 政府採購行為之意義、基本原則、特色及影響

本文探討之重心之一在於在探討政府採購契約法律定性，而在探討政府採購契約之前，必須明瞭政府採購之意義、性質及政府採購法之訂定緣由。政府採購係國家動支預算，向民間購買所需之物資與勞務之行為¹⁷。隨著社會分工日漸精細

¹⁵ 李旭銘，政府採購法不良廠商爭議問題之研究，輔仁大學法律學研究所碩士論文，2004年，頁8。

¹⁶ 洪宗暉，政府採購法因契約責任所導致停權處分之研究—以爭議之多重解決機制間之適用關係為中心，國防大學管理學院法律學系碩士論文，2009年，頁14。

¹⁷ 洪宗暉，同前註16。

與國家任務之不斷擴張，政府機關向民間購取所需已為常態，因而國家需求廣泛且多樣，政府採購有其大量、高額之特性，在國內經濟市場甚至是國際市場上均具重要性。且有認為政府採購乃是指，政府機關、公立教育單位或公營事業這些機關，以及有接受前述機關補助半數採購金額，並補助額在公告金額以上之團體或法人，辦理工程、財物和勞務採購案¹⁸。另有認為政府採購可定義為政府支付相當價金以獲得物品或服務之過程，是指政府機關、公立學校及公營事業所辦理之工程、財物與勞務採購¹⁹。或有認為政府採購，乃政府機關為應推動政務、服務民眾之需要，而以私經濟手段，對外所為之工程定作、財物或勞務之獲得行為²⁰。甚至有認為政府採購，乃政府機關、公立學校或公營事業為取得推行行政事務所需物質或勞務上之支援，而透過政府採購法規定之招標、審標、決標及簽約等程序，所為之工程定作、財物買受、定製、承租及勞務委任或僱傭等行為²¹。簡言之，機關基於達成採購之目的，經一定之程序，與提供採購標的之廠商所簽訂之契約，是為政府採購契約²²。

政府採購與國計民生有相當大之關聯，然政府採購之招標作業與政府採購執行之成效，又有極為密切之關係。我國已於1998年5月27日正式頒布政府採購法，並於1999年5月正式實施，以建立一公平、公開、透明、競爭之採購程序，確保採購品質，提升效率並兼具興利防弊之政府採購長久制度²³。政府採購法實施前，有關政府各部門辦理營繕工程及採購事項，未有統一之法制，而是援用審計法及審計法施行細則，並透過自律之方式，輔以行政機關各自制定之行政命令加以規範²⁴。亦即在政府採購法公佈實行之前，政府採購制度建構在審計稽查制度之

¹⁸ 傅家瑋，政府採購招標決標與爭議處理之研究—以台南科學工業園區減振工法規劃技術服務採購案為核心，中國文化大學法律學院法律學研究所碩士論文，2010年6月，頁1。

¹⁹ 方星淵，政府採購法中押標金之制度與法律性質研究，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，1999年，頁15。

²⁰ 唐迪俊，政府採購爭議處理之法律經濟分析，玄奘大學法律學系碩士在職專班碩士論文，2011年，頁2。

²¹ 尹章華、邱奕澄、倪文興，政府採購法實務與運作，文笙書局股份有限公司，1996年3月，頁1。

²² 潘秀菊、張祥暉，政府採購法契約解除與終止規定之探討，法學新論，月旦法學雜誌，第44期，1999年1月，頁95。

²³ 蕭念祖，政府採購法實務—以基隆港務局為例，國立海洋大學航運管理學系碩士論文，2000年，頁6。

²⁴ 陳櫻琴、陳希佳、黃仲宜，工程與法律，新文京開發出版股份有限公司，2004年3月，頁42。

下，各機關營繕工程及購置訂製財物業務，悉以審計部主管之「審計法」、「審計法施行細則」及「機關營繕工程暨購置訂製變賣財物稽察條例」為各機關辦理採購行政作業之主要依據，另勞務採購以行政命令作為各機關辦理之規範²⁵。自政府採購法公布後，政府採購之事宜均係依此法為依據，舉凡政府機關、公立學校、公營事業、接受機關補助辦理採購之法人或團體、機關委託代辦採購之法人或團體，辦理工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之任用或僱傭等行為，均應依政府採購法所規定之程序辦理²⁶。各機關辦理各項工程、財物及勞務性採購，接受政府採購法之限制²⁷。而政府採購法制定之背景，一方面在配合我國加入世界貿易組織(WTO)，並且為簽署政府採購協定(Agreement On Government Procurement，簡稱 GPA)預做準備，在簽署 GPA 之前，有先完成與其配合之國內立法之必要，以爭取各會員國支持我國入會；而另一方面，則為取代實施已久之採購三法令，即審計法、稽察條例以及行政院暨所屬各級行政機關營繕工程招標注意事項²⁸。政府採購協定之主要目的，在於減少或消除非關稅貿易障礙，或對此等障礙施以有效之國際規範；並藉對政府採購之相關法令、規章、程序及運作，建立國際架構之權利義務，俾擴大國際貿易及促使世界貿易自由化²⁹。我國政府採購法，也將該協定之相關規定及精神予以納入，承襲其規定，我國政府採購法第 2 條規定就採購之定義，包括工程、財物、服務之採購³⁰，也是參照該協定之規定而予以規範。簡言之，政府採購法係參酌世界貿易組織之政府採購協定，並因應我國國情所訂定，是一與國際接軌之採購制度，以其所規定之招標方式及決標原則之多樣性，已可因應機關不同性質之採購，依其實際需要選擇合適之方式辦理，以達到預期之採購功能及效益。政府採購法制定之目的，即在建構公平、公開之採購程序，

²⁵ 林益年，從制度主義觀點論公共工程採購制度之困境，國立中山大學中國與亞太區域研究所博士論文，2012 年，頁 73。

²⁶ 呂金鑫，公共工程履約爭議處理機制之研究—以政府採購法第 85 條之 1 第 2 項為核心—，玄奘大學法律學系碩士班碩士論文，2012 年 7 月，頁 11。

²⁷ 趙修華，人力派遣採購最有利標評選項目與權重之研究，佛光大學公共事務學系碩士在職專班碩士論文，2012 年 6 月，頁 3。

²⁸ 許耀昇，政府採購法對科技專案影響評估之研究，國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士論文，1999 年，頁 5—6。

²⁹ 何應朋，政府採購法爭議處理程序之研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，1999 年，頁 8。

³⁰ 林松金，民間參與港埠建設與政府採購法之適用研究，國立海洋大學海洋法律研究所碩士論文，2000 年，頁 90。

期使競爭激烈之政府採購之所有參與者，透過此一規範之運作，均能獲致合理之對待以保障其權益。

我國就新版政府採購協定於 2012 年 12 月 18 日已完成國會批准，並通知 WTO，故於新版政府採購協定生效之時將同時對我國生效，而美國及歐洲聯盟就新版政府採購協定完成國會相關批准程序，並相繼於 2013 年 12 月 2 日及同年月 3 日通知 WTO，晚於我國，政府採購協定委員會於同年月 3 日作出聲明表示新版政府採購協定將於 2014 年第一季內正式生效。陸續有會員國於 2014 年 3 月 31 日前就新版政府採購協定完成國會批准，並通知 WTO。

我國政府採購法於 2011 年 1 月 26 日完成最後一次修正，WTO 於 2012 年 3 月 30 日採認新版政府採購協定，已如上述，造成我國政府採購法與新版政府採購協定之間產生內容之衝突，而我國政府採購法是否應進行調整之必要，有學者見解認為除了配合再行修法之外，似可參考我國招標期限標準第 2 條第 1 項但書除外規定及同標準第 2 條第 1 項但書除外規定，於我國政府採購法內增訂「除我國締結之契約或協定另有規定者」³¹之但書除外之規定，作為引用政府採購協定作為我國政府採購法之部分內容，使得我國政府採購法與新版政府採購協定之間產生內容之衝突時，自動得優先適用政府採購協定之規定，以避免我國政府採購法面臨政府採購協定修正時，來不及修改、違反政府採購協定之爭議發生。

第四項 政府採購行為之主體、客體

我國一般就政府採購契約意義之了解，簡言之，政府採購契約就是機關基於達成採購之目的，與提供採購標的之廠商所簽訂之契約，一方當事人為機關，另一方當事人為廠商，綜觀政府採購法第 2 條規定：「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。」、政府採購法第 3 條規定：「政府機關、公立學校、公營事業（以下簡稱機關）辦理採購，依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。」、政府採購法第 4 條規定：「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在

³¹ 王耀誠、顏志昇，試析我國政府採購法規與新版政府採購協定之合致性，經貿法訊第 156 期（2014 年 1 月 10 日），網址：<http://www.tradelaw.nccu.edu.tw/epaper/no156/2.pdf>（最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日）。

公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。藝文採購不適用前項規定，但應受補助機關之監督；其辦理原則、適用範圍及監督管理辦法，由文化部定之。」、政府採購法第 5 條規定：「機關採購得委託法人或團體代辦。前項採購適用本法之規定，該法人或團體並受委託機關之監督。」、政府採購法第 7 條規定：「本法所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。本法所稱財物，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。」、政府採購法第 8 條規定：「本法所稱廠商，指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人、機構或團體。」，有就政府採購行為主體，即政府採購契約訂約雙方當事人及政府採購行為客體，即政府採購契約之態樣予以定義及規範。惟實務上乃擴大廠商定義尚應包括投標廠商之分包商、投標廠商之營業代理人在內³²，此有臺北高等行政法院 97 年度訴字第 3264 號判決：「…參以政府採購法第 8 條對於『廠商』係採廣義定義，…政府採購法第 31 條所稱『廠商』，除投標廠商外，尚應包括投標廠商之分包商、投標廠商之營業代理人在內，始符該條規定之本旨。再參諸該等違反採購公正之行為，本為政府採購法所欲規範之行為，倘將政府採購法第 31 條之適用，限於『投標廠商』，而不包括『投標團隊』，如此一來，無異助長廠商以脫法行為規避法律規範，與政府採購法之立法目的旨在建立政府採購制度，依公平公開之採購程序，提升採購效率與功效，確立採購品質目的相悖。」可稽，亦即除了投標廠商之外，尚且包括投標廠商之分包商、投標廠商之營業代理人。茲就政府採購行為主體之定義予以簡要介紹，如下，另有關政府採購契約之態樣容於本文後面章節加以介紹。

³² 林清強，政府採購法申訴廠商償付請求權之探討—兼論其償付數額之計算基礎及舉證，東吳大學法律學系碩士在職專班法律專業組碩士論文，2011 年 8 月，頁 5。

表 5 採購主體類別及定義

類別	定義
政府機關	依據目前實務上作法，須符合下列四種要件方得稱之為機關，一、有組織條例或章程等 ³³ 。二、有獨立之預算。三、有獨立之人員編制。四、有關防或印信能以機關名義對外行文。包括中央政府機關及地方政府機關。
公立學校	由政府所開辦之學校，其辦學資金全部或主要由政府撥付。包括公立大專院校、公立中小學、公立幼兒園等。
公營事業	政府全資或出資超過半數之公司或事業機構。
接受機關補助之法人或團體	法人或團體接受機關獎助、捐助或以其他類似方式動支機關經費之給付。
受機關委託代辦採購之法人或團體	機關之採購，由其他具有專業能力之法人或團體機關受託代辦。
廠商	凡公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人、機構或團體等，均係政府採購法所稱之廠商。

資料來源：作者自行製表

以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司參與投標或得標生物醫療廢棄物處理採購案件之辦理招標採購機關幾乎以政府機關、公立學校為主，減少遇有接受機關補助之法人或團體、受機關委託代辦採購之法人或團體之情形，蓋通常會產出生物醫療廢棄物交付處理，絕大部分為政府機關附設醫療院所或實驗室、公立學校附設醫療院所或實驗室為主，以政府機關附設醫療院所或實驗室而言，比方行政院衛生福利部附設醫療院所、行政院國軍退除役官兵輔導委員會附設醫療院所、行政院國防部附設醫療院所等，有關辦理生物醫療廢棄物處理採購案件之招標採購機關之介紹，容於本文後面章節予以補充。

政府採購行為客體包括工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等，區分成工程採購、財物採購、勞務採購等三大類，上開政府採購法第 7

³³ 林鴻銘，政府採購法之實用權益，永然文化出版，2003 年 4 月，頁 13。

條規定已就工程採購、財物採購、勞務採購之定義，有作原則性之定義，茲不再贅述，惟採購實務運作上包括但不於行政院公共工程委員會函釋有就政府採購法第 7 條規定之工程、財物及勞務之定義分別予以進一步解釋，比方地面上下施作之工程包括水中進行之工程、財物中之各種物品不包括具腐性及具有生命現象，品質在短時間內易生變化之生鮮農漁產品，但經加工或冷凍之食品，尚不得認定為生鮮農漁產品，勞務範圍包括各機關委任律師提供服務、廣告服務之選擇、委託金融機構代收款、辦理薪資轉帳、選擇金融機構聯合發行簽帳卡或聯合卡、選擇承辦公營事業民營化之證券承銷商及機關投保各種保險等，不一而足。簡言之，政府採購法第 7 條規定之工程、財物及勞務之定義仍須靠採購實務運作上包括但不限於政府採購法相關規範之遵循及行政院公共工程委員會行政函釋之尊重不斷之累積及推疊而成。以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司參與投標或得標政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理採購案件之標案標的分類性質直接經行政院公共工程委員會定性為勞務承攬契約，更經實務上定性為屬於其他經主管機關認定之勞務一類，有關雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司參與政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案之介紹，容於本文後面章節予以補充。

至於行政院公共工程委員會除也就政府採購行為客體之定義有做出函釋之外，亦有就政府採購行為主體之定義及其他政府採購行為其他事項做出函釋，此時涉及行政院公共工程委員會所做出之相關函釋效力為何之問題，有關行政院公共工程委員會函釋之定性為何，實屬一有趣之議題，容後於本章我國生物醫療廢棄處理業者就勞務採購標案之處置第一節政府採購行為之介紹第八項行政院公共工程委員會函釋之效力予以介紹。

第五項 政府採購行為之性質

在討論政府採購契約之前，必須先了解政府採購行為，我國政府採購法即有就何為政府採購行為予以定義，政府採購行為之定義即為政府機關、公立學校、公營事業辦理工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。由於政府採購行為包括招標、決標、訂約、履約、驗收等過程，如何去定義政府採購行為之法律性質是一門重要之學問，政府採購行為本身即為一行政機關之行政

行為，因此了解政府採購行為之前，必須從政府機關之行政行為予以探究，進而得以了解政府採購行為及政府採購契約。

按照行政機關為達成其行政目的，原則上享有選擇其行為形式之自由，此即學說上所稱之「行政行為選擇自由理論」³⁴。大法官會議解釋釋字第 540 號解釋有謂國家為達成行政上之任務，得選擇以公法上行為或私法上行為作為實施之手段，可資足參。且按照行政機關之行政行為，以適用法規之性質而論，包括公權力行政及私經濟行政。公權力行政又稱高權行政，係指國家居於公權力主體適用公法規定所為之各種行政行為。私經濟行政，又稱國庫行政，是指國家非居於公權力主體地位行使其公權力行為，而處於與私人相當之法律地位，並在私法支配下所為之各種行為。兩者簡單區別標準為上下秩序關係之事項該當於權力行政，平等關係之事項該當於私經濟行政。

引據行政院法務部 110 年 11 月 3 日法律字第 11003513720 號函之說明二謂：「按行政機關之行為，可區分『公權力行為』與『私經濟行為』兩大類，公權力行為是公法行為，私經濟行為是私法行為，又稱國庫行為。所謂『公權力行為』，係指公務員居於國家機關之地位，行使統治權作用之行為而言；並包括運用命令及強制等手段干預人民自由及權利之行為，以及提供給付、服務、救濟、照顧等方法，增進公共及社會成員之利益，以達成國家任務之行為；所謂『私經濟行為』（國庫行為），係行政機關立於私法主體地位，以私法手段實現行政上之任務（本部 108 年 11 月 19 日法律字第 10803517360 號函參照）。又私經濟行政可大別為四類：1. 為達成行政上之任務，所採取之私法形態的行為；2. 以私法組織形態或特設機構方式所從事之營利行為；3. 私法形態之輔助行為；4. 參與純粹之交易行為。是以，判斷一種事項為公權力行使，抑私經濟活動，須按個別情況，就行政作用之內容及外觀加以推求，藉以確定行政機關主觀上究欲採取公法行為或私法行為作為手段（吳庚著，行政法之理論與實用，增訂 13 版，第 10 頁至第 15 頁

³⁴ 法務部行政執行署民國 105 年 12 月 22 日行執綜字第 10530010070 號之說明二前段謂：「按行政機關為達成其行政目的，原則上享有選擇其行為形式之自由，此即學說上所稱之『行政行為選擇自由理論』」。

參照)」，此行政院法務部函釋已將公權力行政與私經濟行政之定義及私經濟行政之種類介紹得很清楚及明瞭，殊值可參。

另公權力行政受依法行政原則之拘束，私經濟行政以私法自治為依循，公權力行政與私經濟行政同受組織法之拘束，但在行為法方面，私經濟行政除受相關法規之規範外，較少其他限制，惟並非完全免除公法上之拘束，尤其是憲法保障基本權利之規定亦有拘束力。惟公權力行政直接受法保障基本權利之規定所拘束，而私經濟行政必須透過第三人效力理論始得受憲法保障基本權利之規定之間接拘束。而政府採購行為究竟為公法行為或者私法行為，是有疑義，殊值予以深入探討。

第六項 政府採購行為之定性

第一款 學說上及實務上之見解

傳統大陸法系學理上會將法領域區分為公法及私法，我國亦係大陸法系，因此也採取「公私法區分」之法律體系。公法、私法之區別實益在於：

表 6 公私法區別之實益

	公法	私法
基本權效力之拘束性	接受基本權所拘束	必須透過第三人效力理論或是間接立法之方式（例如：以違反公序良俗為原理原則之過渡體現）始得受基本權效力之間接拘束。
基本原則	有依法行政原則之要求	講求私法自治、契約自由
強制執行之方法	行政執行法之規定	依強制執行法之規定
救濟爭訟之管道	由行政院所審理	由普通法院所審理
損害賠償	依國家賠償法請	依民法損害賠償處

	求	理
--	---	---

資料來源：作者自行製表

目前區分公法、私法並未有一個統一之標準理論，目前之學說上通說係採取新主體說，茲就晚近判斷公法關係與私法關係之區別理論，介紹如下：

表 7 公私法區別之理論

區別準據	意義	影響	缺點
利益說	以法規範所與保護的利益作為區分標準，認為公法為保護公共利益之法律；私法為保障個人利益之法律。	涉及公共利益之法律關係為公法關係；涉及個人利益之法律關係為私法關係。	公益與私益並非能夠絕對截然劃分，且公法之規定雖大部分以追求公益為目的，但仍有保護私益為重心之法規。有時一部法律除了保護私益之目的以外亦蘊含保護公益之意旨在內；另外，公益應如何界定，亦是一困難之問題，並非多數人之利益即謂之為公益。
從屬說	又稱權利說、隸屬說。以法規範所涉關係之當事人地位作為區分，如果為規範上下服從關係者屬於公法；而規範對等關係者即屬私法。	涉及上下隸屬關係為公法關係；涉及平等關係為私法關係。	雖能適用於多數情形，但私法中亦有權利服從關係；公法中亦有對等權利義務關係，諸如行政事實行為、行政契約等，皆無法被此說涵括在公法之列。
舊主體說	法律關係主體之一方為行政主體或國家機關者為公法；若法律關係主體者皆為私人屬私法。	涉及一方為行政主體或國家機關，為公法關係；涉及雙方為私人為私法關係。	範圍過廣，如多認為私經濟行政屬於私法範疇，但此說將私經濟行政分屬於公法關係，完全排除了國家可以立於私人地位從事私經濟行為之可能。雖然提供簡單明確之判斷標準，但在

			邏輯上有許多矛盾之處，使得法律秩序運作易陷於混亂與不確定，並非目前多數見解所支持之學說 ³⁵ 。
新主體說	1. 以個別法律條文規範之「對象或主體」為判斷基礎，若法規賦予權利或課予義務之對象僅限於公權力主體或其機關者，即屬公法；若任何人均得為該法規之主體者，即屬私法。 2. 一個法律關係中，出現的法律主體其中一方是以公權力姿態出現之國家主體，那麼適用在這個法律關係中之法律，就是公法；反之，如果雙方沒有出現這樣之主體，就是私法。	涉及法規僅對行政機關賦予權利或課予義務，依據該法規所形成之法律關係為公法關係；涉及法規對任何人均有可能造成權利義務關係，依據該法規所形成之法律關係為私法關係。	目前之通說。

資料來源：作者自行製表

有認為除了上述 4 種學說之外，判斷公法或私法得援用二項輔助標準，一係傳統說，主張判斷個別事件究屬公法性質或私法性質，除有制定新法或變更前例之司法判決外，應遵循約定成俗之規範；另一係事件關聯說，主張個別事件之一部事實關係係屬公法關係者，事件整體均視為公法關係³⁶。

近來多數學者有鑑於上開公法及私法之區別理論多數針對單一行為，而行政主體或機關締結契約屬持續性之行政行為，二者本質上有所差異，故主張另啟一套區別標準。德國學說及判例見解主張以「契約標的理論」區分行政契約與私法

³⁵ 林水波，政府採購撤銷決標後採購契約效力之探討，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2020 年 6 月，頁 7。

³⁶ 吳庚，行政法之理論與實用，三民出版有限公司，6 版，2015 年，頁 29—30。

契約，原則上以「契約標的」為準，判斷個別契約之基礎事實內容是否涉及公法法規，其次如契約標的性質上非私法契約或公法契約所獨佔，則兼以「契約目的」為準，判斷契約雙方或多方當事人致力履行契約之法律效果，亦即契約追求之目的所涉權利義務法律關係是否依據公法法規而定³⁷。亦即行政契約與私法契約之劃分，原則上應以「契約標的」為準，若僅依契約標的仍然無法決定其法律性質時，則兼採契約目的加以衡量。此有前司法院大法官吳庚教授於司法院大法官會議解釋字第 533 號之協同意見書指出：「…辨別此類行政契約，首須契約之一造為代表行政主體之機關，其次，凡行政主體與私人締約，其約定內容亦即所謂契約標的，有下列四者之一時，即認定其為行政契約：（一）作為實施公法法規之手段者，質言之，因執行公法法規，行政機關本應作成行政處分，而以契約代替；（二）約定之內容係行政機關負有作成行政處分或其他公權力措施之義務者；（三）約定內容涉及人民公法上權益或義務者；（四）約定事項中列有顯然偏袒行政機關一方或使其取得較人民一方優勢之地位者。若因給付內容屬於「中性」，無從據此判斷契約之屬性時，則應就契約整體目的及給付之目的為斷，例如行政機關所負之給付義務，目的在執行其法定職權，或人民之提供給付目的在於促使他造之行政機關承諾依法作成特定之職務上行為者，均屬之。」可稽，此亦有行政院法務部 103 年 12 月 17 日法律字第 10303512060 號函：「行政契約與私法契約之區別，應以『契約標的』判斷契約之公法或私法性質，而其約定內容即所謂契約標的有下列四者之一時，即認定其為行政契約：（一）作為實施公法法規之手段者，質言之，因執行公法法規，行政機關本應作成行政處分，而以契約代替；（二）約定之內容係行政機關負有作成行政處分或其他公權力措施之義務者；（三）約定內容涉及人民公法上權益或義務者；（四）約定事項中列有顯然偏袒行政機關一方或使其取得較人民一方優勢之地位者。若因給付內容屬於『中性』，無從據此判斷契約之屬性時，則應就契約整體目的及給付之目的為斷（本部 102 年 4 月 11 日法律字第 10200043730 號書函意旨參照）。依現行司法實務判決見解，多基於補助款契約約定與行政機關相關補助作業要點所定內容相契合，補助款發放之條件亦皆由行政機關單方決定，由申請人提出申請，經行政機關核准後，兩造始

³⁷ 嵇珮晶，政府採購爭議之處理制度-兼論仲裁制度適用於公共工程爭議及改進之道，國立臺北大學法學系碩士論文，2003 年，頁 85。

簽訂該契約，其後續之補助契約可視為該核准行政處分之執行行為，兩者應整體觀察而視為一個公法法律關係之行為，故個案上曾認為締約雙方如對契約內容發生爭議，應屬公法上之爭訟事件（最高法院 95 年度台抗字第 341 號裁定、最高行政法院 96 年度裁字第 1531 號裁定意旨參照）。」予以肯認。是以，近年來，我國似認為在判斷私法契約與行政契約時，原則應以契約標的作為判斷，如無法因此而認定其法律性質時，則兼採行政目的來予以衡量³⁸。茲受上揭區分公法、私法之理論影響所及，有關政府採購行為屬於公法行為或私法行為，有所爭議，學說上及實務上向來有公法行為說、私法行為說及雙階段理論說等三種見解，有關採取採購行為為雙階段理論之見解之知名學者包括但不限於學者郭介恆教授、學者程明修教授及學者林家祺教授等人。目前學說上之通說、政府採購實務及司法實務皆採取雙階理論說。

另有認為政府採購行為在決標以前，與行政機關之裁量有較明顯關係，及政府採購法對於決標前之爭議提供異議、申訴之救濟管道³⁹，有別於民事性質之救濟管道，且以政府採購法第 83 條規定：「審議判斷，視同訴願決定。」與政府採購法第 85-1 條第 1 項規定：「機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理：一、向採購申訴審議委員會申請調解。二、向仲裁機構提付仲裁。」相比較，招標階段之爭議屬於公法性質，其審議判斷，視同訴願決定，締約、履約乃至於驗收階段之爭議，依私法爭議途徑解決，可資推論出政府採購法之立法上應屬採取雙階理論。又有認為稱之為可謂一種法律明訂之雙階理論之法律關係⁴⁰。

另有認為雙階理論說最受批評之缺失即易造成邊界案件歸屬行政法院或普通法院之管轄爭議，所生法安定性之問題，而有關此問題，有其解決之道，即民事訴訟法第 182 條規定：「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。前項規定，於應依行政爭

³⁸ 陳萬愷，政府採購契約之司法管制—以定型化契約管制為中心，國防大學法律學系碩士論文，2019 年，頁 10。

³⁹ 王天健，政府採購法決標程序及相關爭議之探討及修正建議，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2004 年，頁 13。

⁴⁰ 林水波，同前註 35，頁 15。

訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定者，依其規定。」，在政府採購領域中，普通法院與行政法院之見解可能有歧異之虞時，行政法院應視情形，分別適用行政訴訟法第 177 條規定：「行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。除前項情形外，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。」及行政訴訟法第 178 條規定：「行政法院就其受理訴訟之權限，如與普通法院確定裁判之見解有異時，應以裁定停止訴訟程序，並聲請司法院大法官解釋。」，而不致於最後發生普通法院之見解與行政法院之見解相歧異之情形發生。因此，縱使採取雙階理論說之見解，亦不致於發生行政法院之判決與普通法院之判決相歧異，致使有妨礙法安定性之問題。

另有引據政府採購法訂定時，行政院之說明略以政府採購行為一向被認定係私經濟行為，廠商與機關之間如有爭議，本應循民事程序解決，惟因廠商於招標、決標階段，與機關並無契約關係存在，難有可供提起訴訟之訴因，故為增加廠商之救濟與保護，訂定異議及申訴程序，及政府採購法第 74 條規定於 2002 年 2 月 6 日修正為：「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。」，其修正理由為：「一、政府採購行為一向被認定為「私經濟行為」，故已有契約關係之履約或驗收爭議應循民事爭訟途徑解決，使救濟制度單純化；且本法設有調解制度，已足可提供救濟管道。本條原規定履約或驗收之私法爭議，得由得標廠商自由選擇適用申訴程序或仲裁、起訴，將造成救濟體系積極衝突，實有不宜。爰予刪除。二、關於履約或驗收爭議得提出異議、申訴規定及第八十三條視同調解方案規定既經刪除，本條但書已無實益。爰移列於第八十五條之一第一項規範之。」；政府採購法第 83 條規定於 2002 年 2 月 6 日修正為：「審議判斷，視同訴願決定。」，其修正理由為：「一、第七十四條既已修正有關申訴之情形，不包括履約或驗收之爭議，則可使審議判斷賦予單一效力，使其視同訴願決定，爰刪除視同調解方案規定，使相關救濟程序較為明確、單純可行。另有關之附記，於訴願法第九十條第九十二條已有完整及詳細之規定，故予刪除。二、第一項後段既經刪除，第二、三項已無規定必要，爰予刪除。」，由此推演出立

法設計上以較能保護人民權利為由，將廠商於招標、決標階段之法律性質定性為公法性質，至於履約階段因有契約關係之存在，具有私法行為之性質，自得循民事爭訟途徑解決，故以政府採購法之規定運作而論，對於政府採購行為之性質應以「雙階理論」說明，應較妥切⁴¹。

有關法院實務見解有肯認就採購爭議之性質，係採所謂雙階理論，以廠商與機關間是否進入訂約程序，而分別適用行政爭訟及民事訴訟之救濟途徑。相關判決及裁定如下：

表 8 判決及裁定彙整表

判決（裁定）字號	內容評析	備註
臺北高等行政法院 90 年度訴字第 6810 號裁定	立法者對於採購爭議之解，已採取雙階理論。	左揭 2 判決及 2 裁定之共同點皆為引用政府採購法於 91 年 2 月 6 日修正前後之轉變，作為佐證，而做出判決。
臺北高等行政法院 91 年度訴字第 1971 號裁定	由政府採購法於 2002 年 2 月 6 日修正前後之轉變，立法者對於採購爭議之解決，已採取雙階理論。	另最高行政法院 93 年 2 月份庭長法官聯席會議，最高行政法院 97 年 5 月庭長法官聯席會議決議，以行政機關為推行行政事務，常以私法方式取得物質或勞務支援。行政機關依政府採購法所為之採購行為採用學理上之雙階理論，前階段招標、決標為公法事件；後階段締約、履約為私法事件，可資參照。另有大法官會議解釋釋字第 540 號，就處理國宅申購之公私法性質歸屬時，依不同之階段，區分定性為公法行為及私法行為，亦有論及雙階段理論。
高雄高等行政法院 91 年度訴字第 1105 號判決	政府採購法於 2002 年 2 月 6 日修正後採取雙階理論。	
高雄高等行政法院 91 年度訴字第 456 號判決	政府採購法於 2002 年 2 月 6 日修正後採取雙階理論。	
最高法院 94 年度台上字第 1792 號民事判決	廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，係屬公法上	最高法院之見解亦認為，政府採購行為之性質應採雙階理論 ⁴² 。

⁴¹ 蔡秋聰，政府採購法救濟制度之分析，國立高雄大學法律學系碩士班碩士論文，2007 年，頁 29。

⁴² 林水波，同前註 35，頁 27。

	之爭議。	
最高法院 95 年度台上字第 1468 號民事判決	政府採購之招標、審標、決標行為係行政處分	最高法院雖未明言對政府採購行為之性質採雙階理論，然其實質上已採雙階理論之見解 ⁴³ 。
最高行政法院 96 年度裁字第 934 號裁定	採雙階理論判斷政府採購行為之性質	在訂約前之採購行為性質係「公法行為」，而訂約後之採購行為性質係「私法行為」 ⁴⁴ 。

資料來源：作者自行製表

經探求前司法院大法官吳庚教授於其著作「行政法之理論與實務中之文義，前司法院大法官吳庚教授肯認採購行為前階段之招標公告、招標、決標屬於公法性質，採購行為後階段之訂約、履約、驗收屬於私法性質，頗值參考。

依據政府採購法第 74 條規定：「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。」、政府採購法第 83 條規定：「審議判斷，視同訴願決定。」、政府採購法第 85—1 條規定：「機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理：一、向採購申訴審議委員會申請調解。二、向仲裁機構提付仲裁。前項調解屬廠商申請者，機關不得拒絕。工程及技術服務採購之調解，採購申訴審議委員會應提出調解建議或調解方案；其因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。採購申訴審議委員會辦理調解之程序及其效力，除本法有特別規定者外，準用民事訴訟法有關調解之規定。爭議調解規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。」。揆諸上開條文規範之意旨，可見立法者立法之用意肯認就採購爭議之性質，係採所謂雙階理論，以廠商與機關間是否進入訂約程序為界線，分割成公法及私法兩領域，進入訂約程序前適用異議、申訴制度，並以行政爭訟作為救濟途徑，進入訂約程序後依政府採購法調解，或其他民事爭議解決機制(如仲裁或民事訴訟)作為救濟途徑。

第二款 雙階段理論扮演之角色

⁴³ 林水波，同前註 42。

⁴⁴ 林水波，同前註 42。

無論學說上或實務上見解就政府採購行為一概採取私法性質或公法性質，雖有其立論之依據，惟皆與目前政府採購法(2002年2月6日修正後)體系架構設計上相歧異，且與現行實務運作上大相逕庭，除非透過再行修法之途徑予以解決，否則僅淪為空談，由於通說及實務大多數見解就政府採購行為肯認政府採購行為之定性採取雙階段理論，即採購行為之態樣，包括前階段之招標公告、招標、決標之公法行為及後階段之訂約、履約、驗收之私法行為，亦即劃分為公法、私法二個階段。若屬於公法行為，發生紛爭時，應循行政爭訟程序尋求救濟；若屬於私法行為，發生紛爭時，應循民事爭訟程序尋求救濟。且一般認為採購行為後階段之訂約、履約、驗收之性質係屬於機關立於私法主體地位從事國庫行政之行政輔助行為，而屬於私法法律行為，故政府採購契約係屬於私法契約，得依民法契約相關規定處理。縱使有見解以為舉凡政府採購行為之發生，衍生招標、公告、招標、決標、訂約、履約、驗收等行為，是故政府採購行為係由多項行為所組成，此些行為均得以單獨探討分析，採購行為前後階段皆有發生有些行為屬於公法性質，有些行為屬於私法行為，不論單純將政府採購行為，以既存之學說定性為公法行為或私經濟行為⁴⁵，或雙階理論單粹以前階段之招標公告、招標、決標之公法行為及後階段之訂約、履約、驗收之私法行為作為區分，將造成個別行為之本質仍未被評價，並未深入探究，太過於簡約予以區分，況且在整個政府採購行為過程中，每一階段皆係由政府機關與廠商共同進行、時而相對，時而相輔相成⁴⁶、緊密互動行為所組成，無法加以籠統區分為前階段之招標公告、招標、決標之公法行為及後階段之訂約、履約、驗收之私法行為，並不合理，引此，應以個別行為之本質加以探討，做更細緻之定性，該見解甚為有理，甚至仍有見解認為欲將政府採購行為視為單一行為而認定係公法行為或私法行為實有困難，故有必要應跳脫公法、私法二元論之架構，承認政府採購行為兼具公法及私法之性質，且同時具備行政法、程序法、行政刑法及實體法之特性，為別樹一幟之法領域，而應揚棄以政府採購行為視為單一行為，認為政府採購行為究係公法行為或私法行為，應分就個案加以理解，亦即分就行政機關各次採購行為之內容及外觀綜合分析，確定行政機關主觀上究係採取公法行為或私法行為為手段，定其屬於公法行為或

⁴⁵ 王天健，同前註 39，頁 35。

⁴⁶ 王天健，同前註 39，頁 34。

私法行為之性質⁴⁷，又稱之為特殊行為說，亦為有理。另有認為依據雙階段理論，政府採購契約原則上固屬於私法契約，然採政府採購契約之定性，仍應依照公私法區別理論，依契約之標的及目的認定其屬性，而不宜逕就所有依政府採購所締結之契約均認定屬於私法契約，應有行政契約存在之空間，然基於賦予廠商救濟途徑之立場，就依政府採購法簽訂之契約，無論其性質為何，均應許其以政府採購法所設履約爭議調解方式以解決履約爭議⁴⁸。易言之，政府採購行為之本質應以特殊行為說或公私法並存說較能確切剖析政府採購行為之屬性，也就是政府採購行為中間雜公私法行為之性質，基於採購爭議之處理需有明確標準以資遵循，不妨引用雙階段理論之精神，區分成前階段之招標公告、招標、決標之公法行為及後階段之訂約、履約、驗收之私法行為，分別以公法爭議處理及民事救濟途徑處理。惟基於通說及實務大多數見解就政府採購行為肯認政府採購行為之定性採取雙階段理論為時勢所趨，且已政府採購法第六章(爭議處理)所肯認，已如上述，從而本人以為仍以雙階段理論作為前提進行探討本文所涉及有關政府採購契約相關爭議之議題。

第七項 公法與私法相互影響

雖然公法與私法二分受到肯定，但是仍不能忽略這兩個領域彼此之間會不停相互滲透。事實上，公法與私法正相互彼此逼近當中⁴⁹，私法之概念會轉化為公法所引用，比方私法（包括但不限於民法）對於公序良俗、誠實信用、情事變更、定型化契約之解釋，所做解釋較多，因此常見引用於公法上，公法之概念會轉化為私法所引用，比方公法（包括但不限於行政法）對於公共利益之解釋，所做解釋較多，因此常見引用於私法上。且隨著國家權力之行使和加強，公法不斷介入私法領域，私人權利之領域日漸受到來自公法之影響乃至限制。進而隨著社會發

⁴⁷ 嵇珮晶，同註 37，頁 64—65。

⁴⁸ 周瑤敏，政府採購法異議及申訴制度之研究，國立政治大學法律學研究所 碩士論文，2004年1月，頁32。

⁴⁹ 陳思宏，雙階關係中前階行為效力對後階行為之影響—以政府採購為中心，東吳大學法律學系碩士論文，2011年，頁19。

展、國家任務演進，公領域與私領域不斷出現交錯、重疊之現象，國家透過法律針對私法關係進行行政規制之情況亦越來越為常見⁵⁰。

私法自治與國家管制這兩種理念看似對立，但在現實之立法中，以各種私權及基於自由意思形成之法律行為建構私人間之法律關係，卻與國家管制理念不但不對立，反而有某種微妙之牽連。當事人意思自由只是在國家設定之高低不同之柵欄中流動，私法自治領域事實上自始充滿了各種國家強制。表面上和任意規範對立之強制規範，實際上只是在強制性上顯著不同而已，就其功能而言，則在大多數情形下，只是從另一個角度去支撐私法自治而已⁵¹。

以政府採購行為為例，誠如上述，基於依據通說及實務上肯認雙階理論及政府採購法之立法設計採取雙階理論，且引據行政院公共工程委員會政府採購法使用手冊頁壹-8 所述，政府採購契約，既具私法契約之性質，故於民事慣用之契約自由、契約嚴守、誠實信用、比例原則等，於政府採購均有適用外，鑑於政府採購，為機關遂行其行政政策取得 外部資源之主要手段之一，政府採購法第 6 條第 1 項規定爰明定：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」以強調政府採購契約之執行過程及履約結果，對於公共利益及公平合理原則之注重。是以政府採購之行為，除了確保招標、投標、開標、決標等程序公平，維護政府採購標的之品質，促進公益以外，機關與廠商訂約後，仍有契約之細節應如何執行、債務不履行責任、請求損害賠償等諸多私法問題。顯然在政府採購中，公法與私法目的已相互融入，私法之行為帶有公法之目的，公法之處分又可繫於私法之行為⁵²。

本人以為無論政府採購程序前階段或後階段應皆有民法原理原則及行政法原理原則之適用，較為妥適，此觀諸行政院公共工程委員會 88 年 7 月 29 日(88)

⁵⁰ 計畫主持人陳建文助理教授、協同主持人劉素吟律師，行政院法規委員會委託研究計畫，私法關係行政規制之法制體例研究 公寓大廈管理條例、消費者保護法與勞動契約法制發展經驗之觀察比較，2009 年 11 月，頁 1-1。

⁵¹ 計畫主持人陳建文 助理教授、協同主持人劉素吟律師，行政院法規委員會委託研究計畫，同前註 50，頁 3-29。

⁵² 「政府採購法第 59 條第 2 項之性質」鑑定意見書，網址：
<https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzc1L3J1bGZpbGUvMTkwMjEvODEyOTA1Ny91MzIyNmI4YS0yMGU3LTrkZGI0ODExMi05ZDQyOTU4M2EwZGUucGRm&n=6Zmz6Yym6IqzLe0AjoaUv%2BW6n0aOoeizvOazleesrDU55qkd56ysMumgheS5i%2BaAp%2Bizqu0Ajs3ms5X1vovpqpKZh1rprmhI%2Fopovmm7gucGRm&icon=.pdf>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 6 日)。

工程企字第 8810874 號函釋說明三：「廠商投標文件如就標價僅記載一項文字或號碼時，應不致影響其報價之意思表示；倘招標機關未於招標文件明定此情形為無效，則其投標文件應為有效。」可明，亦即廠商之投標屬於民法所稱之「要約」，屬「意思表示」，若合於民法之成立要件，逕予認定有效。而政府採購後階段之履約，基於政府採購事項，具有維護公益之精神，除受到一般民事法律規範外，尚受到政府採購相關法規之規範，且政府採購之相關法規，非僅以契約當事人之權利義務關係加以考量，更包括採購行為之效率性及對相關供應商公平性之考量⁵³，也就是政府採購契約具有公益維護之性質，不無仍應遵守行政法之依法行政原則及法律保留原則，也就是仍有行政法原理原則之拘束。簡言之，政府採購契約雖經認定為私法契約，但與私人間私法契約仍有所不同，私人間私法契約僅有民法之規定或民法原理原則之適用，而政府採購契約基於具有公益之色彩，本質上仍屬於行政行為之一環，政府採購契約仍無法跳脫政府採購法原理原則及行政法原理原則之限制，無法像私人間私法契約單純受私法自治、契約自由之拘束。且依據政府採購法第 3 條規定：「政府機關、公立學校、公營事業（以下簡稱機關）辦理採購，依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。」，也就是政府採購法具有政府採購基本法之性質，在政府採購法未規定時，得補充適用其他相關法令予以解決，可得而知我國就政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購採購之法令適用之態度，仍以適用政府採購法為最優先，其他法律作為補充，包括但不限於民法之規定，至於基於政府採購法所授權制定之相關法規命令，應擴大解釋涵蓋於政府採購法之規定之內，亦即基於政府採購法所授權制定之相關法規命令應優先於民法之規定而適用，甚至基於政府採購契約本質上仍屬於行政行為之一環，已如上述，況且行政程序法第 4 條規定：「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。」，即行政行為本應受行政法原理原則之拘束，作為前提，衍生出行政法原理原則之適用應優先於民法之適用，是以就政府採購契約遇有發生契約解釋爭議時，同時具有政府採購法、政府採購法所授權

⁵³ 羅昌發著，政府採購法與政府採購協定論析，元照，三版，第一刷，2008 年 11 月，頁 77。

制定之相關法規命令、行政法原理原則、政府採購契約內容與民法適用之衝突時，應先後依序以優先適用政府採購法、政府採購法所授權制定之相關法規命令做判斷，其次依據行政法原理原則做判斷，嗣後以有無違反民法上強制規定或禁止規定做判斷，然後依據政府採購契約內容作判斷，最後再依民法做判斷，始為妥適。

且基於司法院大法官會議解釋釋字第 457 號解釋：「中華民國人民，無分男女，在法律上一律平等；國家應促進兩性地位之實質平等，憲法第七條暨憲法增修條文第十條第六項定有明文。國家機關為達成公行政任務，以私法形式所為之行為，亦應遵循上開憲法之規定。」，且政府採購屬於私經濟行為（國庫行為），政府採購契約亦屬之，推行出就政府採購契約遇有發生契約解釋爭議時，仍以遵守憲法之規定，作為最高指導原則，是以任何政府採購契約之任何契約解釋都應符合憲法之規定暨憲法之原理原則作為前提，基於憲法之規定暨憲法之原理原則不能直接適用，而透過基本權第三人效力理論之解釋，間接透過私法規範，當作轉介條款，發揮媒介之功能，仍發生間接效力，可得而知任何政府採購契約之任何契約也不能抵觸憲法之規定暨憲法之原理原則，自不待言。

第八項 行政院公共工程委員會函釋之效力

有關探究行政院公共工程委員會所做出之相關函釋效力為何，首先應了解行政函釋之定性，行政函釋又稱行政函示，在我國法律之制定及通過，必須經過立法院三讀通過，總統公布才完成。法規命令、行政規則之制定，亦需滿足其制定之程序，實屬當然，另有關行政規則之發布有其處理程序，此有行政程序法第 160 條規定：「行政規則應下達下級機關或屬官。行政機關訂定前條第二項第二款之行政規則，應由其首長簽署，並登載於政府公報發布之。」及行政院法務部 90 年 3 月 22 日(90) 法律字第 000147 號函：「…二依前開行政院秘書處函釋，茲說明各機關依行政程序法第一百六十條第二項規定，發布同法第一百五十九條第二項第二款行政規則之處理原則如下：(一)各機關對於非主管法規所為之解釋，以函答復即可，不必刊登公報。(二)各機關對於主管法規所為之解釋，如係關於具體個案之法律適用疑義者，須以函答復，並刊登公報；如非具體個案，而係抽象之法律解釋者，處理方式同上。(三)上述所列二種情形，如認有全體機關一體適用之必要者，應以「令」發布，其方式有二：一為以令發布，受文者為機關辦理

刊登公報事宜之單位，並另以函回復來函機關；二為以令發布，受文者正本為機關辦理刊登公報事宜之單位，副本列各有關機關，並以括弧說明(兼復○○機關○○年○○月○○日○○字第○○號函)。…」」。然而無論法律、法規命令或行政規則之內容不可能鉅細靡遺將所有事項都規範在內，此時即可透過行政函釋來補充法規之內容及意涵，有其必要性及需求性。

依據司法院大法官會議解釋釋字第 287 號解釋之解釋文：「行政主管機關就行政法規所為之釋示，係闡明法規之原意，固應自法規生效之日起有其適用。惟在後之釋示如與在前之釋示不一致時，在前之釋示並非當然錯誤，於後釋示發布前，依前釋示所為之行政處分已確定者，除前釋示確有違法之情形外，為維持法律秩序之安定，應不受後釋示之影響。」，且依據上開司法院大法官會議解釋釋字第 287 號解釋之理由書：「行政機關基於法定職權，就行政法規所為之釋示，係闡明法規之原意，性質上並非獨立之行政命令，固應自法規生效之日起有其適用。惟對同一法規條文，先後之釋示不一致時，非謂前釋示當然錯誤，於後釋示發布前，主管機關依前釋示所為之行政處分，其經行政訴訟判決而確定者，僅得於具有法定再審原因時依再審程序辦理；其未經訴訟程序而確定者，除前釋示確屬違法，致原處分損害人民權益，由主管機關予以變更外，為維持法律秩序之安定，應不受後釋示之影響。」，於此，行政函釋之出現係用來充實法規之內容及意涵，包括但不限於法規之構成要件、法律效果、認定事實或適用法規之過程，不論行政機關及人民理應尊重，遑論對於政府採購行為之雙方，政府機關或政府機關所屬事業及廠商對於行政院公共工程委員會所做出之相關函釋效力理應予以尊重。

有認為除了可透過行政函釋來充實法規之內容及意涵之外，尚包括可透過行政函釋來擴張法規之內容及意涵，但本人以為基於行政機關基於法定職權，就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，不得任意擴張法規之內容及意涵，是以行政函釋係用來充實法規之內容及意涵而已，頂多係在法規之原意範圍內予以擴張，簡言之，稱之為有限制之擴張，始為恰當。

依據行政程序法第 159 條規定：「本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象之規定。行政規則包括下列各款之規定：一、

關於機關內部之組織、事務之分配、業務處理方式、人事管理等一般性規定。二、為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。」，基此，在我國行政程序法第 159 條規定已就行政規則之定義及種類有所明文規範，故不再詳細介紹，而一般就行政規則種類之認知，簡言之，分類上包括組織性行政規則、作業性行政規則、解釋性行政規則及裁量基準四大類，如前司法院大法官吳庚教授即採取此見解。

當中基於行政函釋在於用來充實法規之內容及意涵，而與上級機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定相當，故行政函釋之定性得定性為解釋性行政規則，效力面依據行政程序法第 159 條之規定，非直接對外發生法規範效力，及依據行政程序法第 161 條規定：「有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。」，侷限行政規則效力拘束之對象包括訂定機關、其下級機關及屬官，故發生內部效力。有認為行政函釋除了發生內部效力外，無可避免會對人民發生產生影響，然非直接對人民發生效力，又稱發生間接外部效力，外部效力之發生，有認為基於 1. 行政自我拘束原則、2. 信賴保護原則等，影響所及，無論行政機關或人民仍應遵守為是。知名學者蔡茂寅教授提供判定行政函釋法律性質之標準，其認為「按函釋係指行政機關就其主管法令之適用疑義所作成之解釋函，而分別發布、下達或回復者而言。欲判斷函釋或函復之法律性質，首先應就該函釋或函復之內容判斷，是否具有抽象規範之性質，以憑判斷是否屬（解釋性）行政規則。其次則應由其函釋或函復之對象是否僅為單一機關或個人，其踐行之程序是否使該釋復因之具有通案拘束之效果判斷其屬性。至於行政機關之釋示是否依職權主動為之？抑或依請求被動為之，則僅具輔助判斷其法律性質之功能，並非決定性之要素。」，始足可參，行政院公共工程委員會函釋扮演之角色也是如此，在於補充政府採購法相關規範之不足，但不能跳脫政府採購法相關規範之原意，等同於行政院公共工程委員會作出之解釋性行政規則。行政院公共工程委員會之態度也認為行政院公共工程委員會函釋係解釋性行政規則，至於其效力有認為並無拘束司法之效力，法官仍得不採用，換言之，依循行政院公共工程委員會函釋所為之政府採購行為，仍有可能受法院不利之判決。並有經行政院法務部確認其效力範圍，即並無拘束無隸屬關係或無業務監督之機關或法院之效力，此有行政院法務部 104 年 8 月 13

日法律字第 10403509200 號函之要旨：「主管機關因基於職權執行特定法律規定而依據行政程序法第 159 條作出必要之釋示供下級機關或屬官行使職權依據，並無違背法律保留原則及處罰法定原則，但此種解釋性行政規則並無拘束無隸屬關係或無業務監督之機關或法院之效力」及司法院大法官會議解釋釋字第 216 號解釋之解釋文：「法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨；司法行政機關所發司法行政上之命令，如涉及審判上之法律見解，僅供法官參考，法官於審判案件時，亦不受其拘束。惟如經法官於裁判上引用者，當事人即得依司法院大法官會議法第四條第一項第二款之規定聲請解釋。」可稽，本人以為行政院公共工程委員會函釋之定位已有清楚，行政院公共工程委員會就政府採購法相關規範所為之函釋而言，除了定性屬於解釋性行政規則之外，於效力面並有發生內部效力及間接之外部效力，誠如上述，惟揆諸上開行政院法務部 104 年 8 月 13 日法律字第 10403509200 號函之要旨及司法院大法官會議解釋釋字第 216 號解釋之解釋文，可得而知行政院公共工程委員會函釋之拘束對象不包括無隸屬關係或無業務監督之機關或法院，易言之，得稱之為發生有限度之間接之外部效力才是。

第二節 勞務採購招標方式

依據政府採購法第 18 條第 1 項規定：「採購之招標方式，分為公開招標、選擇性招標及限制性招標。」，適用之時機則分別規定於政府採購法第 19 條規定、政府採購法第 20 條規定、政府採購法第 21 條規定及政府採購法第 22 條規定之中。茲就政府採購法第 19 條規定、政府採購法第 20 條規定、政府採購法第 21 條規定及政府採購法第 22 條規定之內容，臚列如下：

表 9 法條介紹

條號	內容
政府採購法第 19 條規定：	「機關辦理公告金額以上之採購，除依第二十條及第二十二條辦理者外，應公開招標。」
政府採購法第 20 條規定：	「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採選擇性招標： 一、經常性採購。 二、投標文件審查，須費時長久始能完成者。 三、廠商準備投標需高額費用者。 四、廠商資格條件複雜者。 五、研究發展事項。」
政府採購法第 21 條規定：	「機關為辦理選擇性招標，得預先辦理資格審查，建立合格廠商名單。但仍應隨時接受廠商資格審查之請求，並定期檢討修正合格廠商名單。 未列入合格廠商名單之廠商請求參加特定招標時，機關於不妨礙招標作業，並能適時完成其資格審查者，於審查合格後，邀其投標。 經常性採購，應建立六家以上之合格廠商名單。 機關辦理選擇性招標，應予經資格審查合格之廠商平等受邀之機會。」
政府採購法第 22 條規定：	「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標： 一、以公開招標、選擇性招標或依第九款至第十一款公告程序辦理結果，無廠商投標或無合格標，且以原定招標內容及條件未經重大改變者。 二、屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替代標的者。 三、遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者。」

	四、原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者。 五、屬原型或首次製造、供應之標的，以研究發展、實驗或開發性質辦理者。 六、在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。 七、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。 八、在集中交易或公開競價市場採購財物。 九、委託專業服務、技術服務、資訊服務或社會福利服務，經公開客觀評選為優勝者。 十、辦理設計競賽，經公開客觀評選為優勝者。 十一、因業務需要，指定地區採購房地產，經依所需條件公開徵求勘選認定適合需要者。 十二、購買身心障礙者、原住民或受刑人個人、身心障礙福利機構或團體、政府立案之原住民團體、監獄工場、慈善機構及庇護工場所提供之非營利產品或勞務。 十三、委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展。 十四、邀請或委託具專業素養、特質或經公告審查優勝之文化、藝術專業人士、機構或團體表演或參與文藝活動或提供文化創意服務。 十五、公營事業為商業性轉售或用於製造產品、提供服務以供轉售目的所為之採購，基於轉售對象、製程或供應源之特性或實際需要，不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者。 十六、其他經主管機關認定者。 前項第九款專業服務、技術服務、資訊服務及第十款之廠商評選辦法與服務費用計算方式與第十一款、第十三款及第十四款之作業辦法，由主管機關定之。 第一項第九款社會福利服務之廠商評選辦法與服務費用計算方式，由主管機關會同中央目的事業主管機關定之。 第一項第十三款及第十四款，不適用工程採購。」
--	---

資料來源：全國法規資料庫，經作者整理製表⁵⁴

依據政府採購法第 18 條第 2 項規定：「本法所稱公開招標，指以公告方式邀請不特定廠商投標。」及政府採購法第 19 條規定：「機關辦理公告金額以上之採購，除依第 20 條及第 22 條辦理者外，應公開招標。」，基此，我國政府採購法之公開招標是「無為資格預審」單獨招標之程序，且一定要以公告方式為之。謂只要廠商符合公告招標文件之要求，就可依其意願來投標⁵⁵。誠如上述，以我國為例，政府採購原則應以公開招標方式為之，只有在合於政府採購法第 20 條規定及第 22 條規定之情形下，採購機關才可以選擇以選擇性招標或限制性招標之招標方式，其立法目的在由於公開招標得有最多量廠商得以參與投標，在競爭激烈之情形下，有助於採購機關花費較少之預算或者可獲取較高品質之採購標的⁵⁶。然為增進採購效能，政府採購法對於對於不同規模之採購案件，依其採購金額大小順序區分為鉅額採購（工程案新臺幣二億元以上；財物案新臺幣一億元以上；勞務案新臺幣二千萬元以上）、查核金額（工程、財物案為新臺幣五千萬元以上；勞務案新臺幣一千萬元以上）、公告金額（工程、財物及勞務案均為新臺幣一百萬元以上）、未達公告金額之案件（工程、財物及勞務案均為逾新臺幣十萬元未達新臺幣一百萬元）及小額採購（其金額不得逾公告金額之十分之一，得不訂底價，中央機關小額採購工程、財物及勞務案均為新臺幣十萬元以下，直轄市、縣（市）政府另有規定者，應從其規定，未規定者則比照中央規定辦理。）等五種類型，分有不同之適用限制規範及監督機制。

承上，另我國有就政府採購契約價值之估算有所規範，此有政府採購法施行細則第 6 條規定：「機關辦理採購，其屬鉅額採購、查核金額以上之採購、公告金額以上之採購或小額採購，依採購金額於招標前認定之；其採購金額之計算方式如下：一、採分批辦理採購者，依全部批數之預算總額認定之。二、依本法第五十二條第一項第四款採複數決標者，依全部項目或數量之預算總額認定之。但

⁵⁴ 全國法規資料庫，網址：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030057>（最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日）。

⁵⁵ 傅家瑋，同前註 18，頁 8。

⁵⁶ 林宜興，我國政府採購法爭議招標爭議問題之研究—以評選程序為中心，國立中正大學法律所碩士論文，2008 年，頁 74。

項目之標的不同者，依個別項目之預算金額認定之。三、招標文件含有選購或後續擴充項目者，應將預估選購或擴充項目所需金額計入。四、採購項目之預算案尚未經立法程序者，應將預估需用金額計入。五、採單價決標者，依預估採購所需金額認定之。六、租期不確定者，以每月租金之四十八倍認定之。七、依本法第九十九條規定甄選投資廠商者，以預估廠商興建、營運所需金額認定之。依本法第七條第三項規定營運管理之委託，包括廠商興建、營運金額者，亦同。八、依本法第二十一條第一項規定建立合格廠商名單，其預先辦理廠商資格審查階段，以該名單有效期內預估採購總額認定之；邀請符合資格廠商投標階段，以邀請當次之採購預算金額認定之。九、招標文件規定廠商報價金額包括機關支出及收入金額者，以支出所需金額認定之。十、機關以提供財物或權利之使用為對價，而無其他支出者，以該財物或權利之使用價值認定之。」可稽。

政府機關或政府機關所屬事業辦理上開有關生物醫療廢棄物處理之相關標案幾乎以公開招標方式為之，採購金額通常為查核金額、公告金額為主，也有遇有採購金額為巨額採購之情形，茲就政府採購法就政府採購招標方式與對於不同規模之採購案件，在採購金額上如何區分及其作業特質如何分別予以介紹如下：

表 10 招標方式介紹

類別	定義
公開招標	以公告方式邀請不特定廠商投標(政府採購法第 18 條規定)。 機關辦理公告金額以上之採購，除依第 20 條及第 22 條辦理者外，應公開招標(政府採購法第 19 條規定)。 公開招標應以公告之方式為之，機關應將招標資訊刊登於由採購機關所發行之政府採購公報，並公開於資訊網路⁵⁷。
選擇性招標	以公告方式預先依一定資格條件辦理廠商資格審查後，再行邀請符合資格之廠商投標(政府採購法第 18 條規定)。

⁵⁷ 黃榆楹，競爭法與政府採購法對於圍標、綁標行為規範之比較研究，國立臺北大學法學系碩士論文，2003 年，頁 15。

限制性招標	不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請一家廠商議價(政府採購法第 18 條規定)。
公開取得報價單或企劃書	未達公告金額採購之招標，其金額逾公告金額十分之一，依本法第 49 條之規定，將公開徵求廠商提供書面報價或企劃書之公告，公開於主管機關之資訊網路或刊登於政府採購公報，以取得三家以上廠商之書面報價或企劃書，擇符合需要者辦理比價或議價(中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 3 款規定)。
小額採購	公告金額十分之一以下採購之招標，得不經公告程序，逕洽廠商採購，免提供報價或企劃書(中央機關未達公告金額採購招標辦法第 5 條規定)。

資料來源：作者自行製表

表 11 標案類別介紹

類別	定義
巨額採購(工程案二億元以上；財物案一億元以上；勞務案二千萬元以上)	規範廠商特定資格(政府採購法第 36 條)，與瞭解、查核完成採購後使用期間之使用情形及效益之門檻金額(政府採購法第 111 條)。機關辦理巨額採購，應於使用期間內，逐年向主管機關提報使用情形及其效益分析。主管機關並得派員查核之。主管機關每年應對已完成之重大採購事件，作出效益評估；除應秘密者外，應刊登於政府採購公報。
查核金額(工程、財物案為五千萬元以上；勞務案一千萬元以上)	上級機關執行事前、事中監督之門檻金額。查核金額以上之案件，辦理過程須受上級機關監督(政府採購法第 12 條)。機關辦理查核金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收時，應於規定期限內，檢送相關文件報請上級機關派員監辦；上級機關得視事實需要訂定授權條件，由機關自行辦理。機關辦理未達查核金額之採購，其決標金額達查核金額者，或契約變更後其金額達查核金額者，機關應補具相關文件送上級機關備查。
公告金額(工程、財物及勞務案均為一百萬元以上)	機關將採購資訊公開、廠商申訴等之門檻金額。公告金額以上之案件，為採購法所欲規範之主要範圍。機關辦理公告金額以上之採購，除依採購法第 20 條規定採選擇性招標及第 22 條採限制性招標辦理者外，應公開招標(政府採購法第 19 條)。

未達公告金額之案件	其招標方式由主管機關、直轄市或縣(市)政府定之(政府採購法第 23 條)。主管機關行政院公共工程委員會業依規定訂有「中央機關未達公告金額採購招標辦法」頒行。直轄市、縣(市)政府另有規定者，應從其規定，未規定者則比照中央規定辦理。
小額採購	其金額不得逾公告金額之十分之一，得不訂底價。小額採購之金額上限，由主管機關、直轄市或縣(市)政府定之(政府採購法第 47 條)。目前中央機關小額採購金額訂為十萬元，依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第 5 條規定，得不經公告程序，逕洽廠商採購，免提供報價或企劃書。直轄市、縣(市)政府另有規定者，應從其規定，未規定者則比照中央規定辦理。

資料來源：作者自行製表

另依據政府採購法施行細則第 52 條規定：「機關訂定底價，得基於技術、品質、功能、履約地、商業條款、評分或使用效益等差異，訂定不同之底價」、政府採購法施行細則第 53 條規定：「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。但重複性採購或未達公告金額之採購，得由承辦採購單位逕行簽報核定。」，基於此，以我國就招標機關辦理政府採購標案以有訂定底價為原則，政府機關或政府機關所屬事業辦理上開有關生物醫療廢棄物處理之相關標案幾乎皆會訂定底價。

就政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理採購案件而言，基於採取最低標之決標方式有開標過程簡單、決標價最低及符合公平競爭原則等優點，其決標方式幾乎仍以採取最低標之方式，決定最後得標之生物醫療廢棄物處理業者。

第三節 勞務採購之共同投標

依據政府採購法第 25 條規定：「機關得視個別採購之特性，於招標文件中規定允許一定家數內之廠商共同投標。第一項所稱共同投標，指二家以上之廠商共同具名投標，並於得標後共同具名簽約，連帶負履行採購契約之責，以承攬工程或提供財物、勞務之行為。共同投標以能增加廠商之競爭或無不當限制競爭者為限。同業共同投標應符合公平交易法第十五條第一項但書各款之規定。共同投標廠商應於投標時檢附共同投標協議書。共同投標辦法，由主管機關定之。」、共同投標辦法第 8 條規定：「機關允許共同投標時，應於招標文件中規定共同投標廠商之投標文件應由各成員共同具名，或由共同投標協議書指定之代表人簽署。投標文件之補充或更正及契約文件之簽訂、補充或更正，亦同。」及共同投標辦法第 10 條規定：「共同投標廠商於投標時應檢附由各成員之負責人或其代理人共同具名，且經公證或認證之共同投標協議書，載明下列事項，於得標後列入契約：一、招標案號、標的名稱、機關名稱及共同投標廠商各成員之名稱、地址、電話、負責人。二、共同投標廠商之代表廠商、代表人及其權責。三、各成員之主辦項目及所占契約金額比率。四、各成員於得標後連帶負履行契約責任。五、契約價金請（受）領之方式、項目及金額。六、成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意將其契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受。七、招標文件規定之其他事項。前項協議書內容與契約規定不符者，以契約規定為準。第一項協議書內容，非經機關同意不得變更。」，基此，政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購標案時，得視個別政府採購標案之特性，採取共同投標之方式為之，誠如上述，政府機關或政府機關所屬事業辦理上開有關生物醫療廢棄物處理之相關標案時，基於標案之名稱常包括生物醫療廢棄物委託之「清除」及「處理」之字樣，如表 14—生物醫療廢棄物標案介紹及表 16—2021 年得標標案所示，由於生物醫療廢棄物處理業者並不能執行生物醫療廢棄物之清除工作，是以生物醫療廢棄物處理業者不能單獨參與投標該等標案，此時即需生物醫療廢棄物清除業者共同參與投標，故採購實務運作上常發生生物醫療廢棄物處理業者為代表廠商，生物醫療廢棄物清除業者為其他成員，共同參與投標，並於

得標後共同具名與政府機關或政府機關所屬事業簽訂生物醫療廢棄物清除處理勞務採購契約，連帶負履行生物醫療廢棄物清除處理勞務採購契約之責。

以生物醫療廢棄物處理業者與生物醫療廢棄物清除業者共同投標並得標政府機關或政府機關所屬事業辦理之生物醫療廢棄物清除處理勞務採購標案為例，基於共同具名投標、共同具名簽約及連帶負履行採購契約之責，且一般採購實務上認為共同投標之情形核與聯合承攬相當，是以應以聯合承攬法律關係解決衍生之相關爭議，本人以為聯合承攬得區分為內部關係及外部關係，單純就完成生物醫療廢棄物清除處理工作，取得報酬而言，屬於外部關係，至多屬於勞務採購契約之當事人一方為多數，依據民法承攬之相關規定，定性為承攬契約應無疑義，而就生物醫療廢棄物處理業者與生物醫療廢棄物清除業者間之法律關係，屬於內部關係，知名學者黃立教授認為，有合夥說及偶然性之共同經營契約說，且認為偶然性之共同經營契約說屬於無名契約，以偶然性之共同經營契約說比較有說服力，知名學者林誠二教授認為關於聯合承攬之法律定性，得區分為內部法律關係及外部法律關係，內部法律關係有合夥契約關係、類似合夥之無名契約關係及偶然性共同合作經營之無名契約關係等見解，並主張以採取偶然性共同合作經營之無名契約關係之見解較為妥適，至於外部法律關係，經推敲林誠二教授之見解，簡言之，即採取依據民法第二編債第二章各種之債第八節承攬之相關規定及民法第二編債第一章通則之第三節債之效力、第四節多數債務人及第五節債權人、債之移轉相關規定處置。

至於生物醫療廢棄物處理業者與生物醫療廢棄物清除業者共同投標並得標政府機關或政府機關所屬事業辦理之生物醫療廢棄物清除處理勞務採購標案或生物醫療廢棄物處理業者單獨投標並得標政府機關或政府機關所屬事業辦理之生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，並簽訂勞務採購契約後，基於生物醫療廢棄物處理業者處理量能之不足，必須由其他生物醫療廢棄物處理業者緊急支援協助處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，此情形與共同投標之情形有所不同，致生此時即涉及是否合法之爭議，並於本節一併討論。

依據政府採購法第 65 條規定：「得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包。前項所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行。廠商履行財物契約，其需經一定履約過程，非以現成財物供應者，

準用前二項規定。」、政府採購法第 66 條規定：「得標廠商違反前條規定轉包其他廠商時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。前項轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。」、政府採購法施行細則第 87 條規定：「本法第六十五條第二項所稱主要部分，指下列情形之一：一、招標文件標示為主要部分者。二、招標文件標示或依其他法規規定應由得標廠商自行履行之部分。」，此三條文為政府採購法就轉包之定義、適用情形及違反效果之明文化規定，另依據政府採購法第 67 條規定：「得標廠商得將採購分包予其他廠商。稱分包者，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。分包契約報備於採購機關，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，民法第五百十三條之抵押權及第八百十六條因添附而生之請求權，及於得標廠商對於機關之價金或報酬請求權。前項情形，分包廠商就其分包部分，與得標廠商連帶負瑕疵擔保責任。」，此條文為政府採購法就分包之定義及適用情形之明文化規定，且政府採購實務上，政府機關或政府機關所屬事業辦理勞務採購標案時通常會於投標須知內載明規定：「依採購法第 65 條及採購法施行細則第 87 條之規定，本採購標之下列部分及依其他法規規定應由得標廠商自行履約之部分，不得由其他廠商代為履行，本採購標之主要部分為：無。」，因此並無政府採購法第 65 條規定之主要部分，及於勞務採購契約履約管理一項約定「轉包及分包：1. 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第 103 條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。2. 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。3. 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。5. 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收全部保證金，並得要求損害賠償。6. 前項轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。」等文字，應係同意得標廠商得分包，於此，生物醫療廢棄物處理業者與生物醫療廢棄物清除業者共同投標並得標政府機關或政府機關所屬事業辦理之生物醫療廢棄物清除處理勞務採購標案或生物醫療廢棄物處理業者單獨投標並得標政府機關或政府機關所屬事業辦理之生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，並簽訂勞務採購契約後，基於生物醫療廢棄物處理業者處理量能之不足，必須由其他生

物醫療廢棄物處理業者緊急支援協助處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，生物醫療廢棄物處理業者如交付全部受託處理之生物醫療廢棄物或勞務採購契約約定之主要部分予其他生物醫療廢棄物處理業者處理，此時涉及違反政府採購法第 65 條不得轉包之規定，若僅交付部分受託處理之生物醫療廢棄物予其他生物醫療廢棄物處理業者處理，且該交付之部分生物醫療廢棄物未涉及主要部分時，此時依據政府採購法第 67 條得分包之規定，係屬合法之行為。

由上可知，有關聯合承攬與分包之不同地方，聯合承攬之情形在於多數廠商共同投標並得標政府機關或政府機關所屬事業辦理之政府採購標案，並完成簽訂政府採購契約，進行履行政府採購契約之整個行為而言，分包之情形係在多數廠商共同投標或單獨廠商單獨投標政府機關或政府機關所屬事業辦理之政府採購標案，於得標及簽訂政府採購契約後，履約過程中將政府採購契約之部分且非主要履行義務交由其他廠商協助履行，而廠商本身仍自行履行未交付政府採購契約之剩餘部分且主要履行義務，故有所不同。



第四節 勞務採購投標廠商資格爭議

第一項 勞務採購投標廠商資格要求

政府機關或政府機關所屬事業辦理有關生物醫療廢棄物處理之相關採購標案時，投標文件規範廠商資格係為保障機關所決標之廠商具有足夠能力完成採購標的⁵⁸，政府機關或政府機關所屬事業辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格及投標廠商之特定資格，此有政府採購法第 36 條規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，得就實際需要另行規定，附經公證或認證之中文譯本，並於招標文件中訂明。第一項基本資格、第二項特定資格與特殊或巨額採購之範圍及認定標準，由主管機關定之。」可稽。另觀諸投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準有就投標廠商之基本資格與投標廠商之特定資格之範圍及定性作規範，主要規範在其第 2 條規定、第 3 條規定、第 4 條規定及第 5 條規定，其第 2 條規定至第 4 條規定之立法重點在於明定機關得依採購案件之特性及實際需要訂定與提供招標標的或與履約能力有關之基本資格及應附具之證明文件；其第 5 條規定之立法重點在於列舉可得列為特殊或巨額採購之特定資格及應附具之證明文件。進言之，特定資格之要求僅適用於機關辦理特殊或巨額採購，對於投標廠商資格之設定，至於機關辦理特殊或巨額採購以外之採購，對於投標廠商資格之設定，僅必須符合基本資格之要求。茲析述如下：

表 12 投標廠商資格要求

	範圍	條文依據
基本資格	1. 與提供招標標的有關者。 2. 與履約能力有關者。	第 2 條規定： 「機關辦理採購，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項訂定投標廠商之基本資格，並載明於招標文件： 與提供招標標的有關者。 二、與履約能力有關者。」

⁵⁸ 陳冠樺，政府採購決標制度之研究—以審標時機關採用次低標之裁量空間為探討中心，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2013 年 1 月，頁 9。

基本資格 (一)－與 提供招標 標的有關	1. 廠商登記或設立之證明。 2. 廠商納稅之證明。 3. 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明。	第3條規定： 「機關依前條第一款訂定與提供招標標的有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件： 一、廠商登記或設立之證明。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。 二、廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅。 三、廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明。如會員證。 前項第一款證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，機關得允許廠商列印該最新資料代之。 第一項第一款證照，依法令係按一定條件發給不同等級之證照或並定承包限額者，依其規定。 第一項第一款登記或設立之證明，機關規定須具有特定營業項目方可參與投標者，其所規定之營業項目，不得當限制競爭，並應以經濟部編訂之公司行號營業項目代碼表所列之大類、中類、小類或細類項目為基準。該特定營業項目非屬許可業務者，廠商所營事業之登記，如載明除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務者，視為包括該特定營業項目。 第一項第二款納稅證明，其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營
---	--	--

		業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。 第一項第三款加入工業或商業團體之證明，除法令另有規定外，不得限制由特定區域之團體出具；投標廠商為外國廠商者，得免附具。」
基本資格 (二)－與履約能力有關	1. 廠商具有製造、供應或承做能力之證明。 2. 廠商具有如期履約能力之證明。 3. 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明。 4. 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明。 5. 廠商信用之證明。 6. 其他法令規定或經主管機關認定者。	第 4 條規定： 「機關依第二條第二款訂定與履約能力有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件或物品： 一、廠商具有製造、供應或承做能力之證明。如曾完成與招標標的類似之製造、供應或承做之文件、招標文件規定之樣品、現有或得標後可取得履約所需設備、技術、財力、人力或場所之說明或品質管制能力文件等。 二、廠商具有如期履約能力之證明。如迄投標日止正履行中之所有契約尚未完成部分之總量說明、此等契約有逾期履約情形者之清單、逾期情形及逾期責任之說明、律師所出具之迄投標日止廠商涉及賠償責任之訴訟中案件之清單及說明或廠商如得標則是否確可如期履約及如何能如期履約之說明等。 三、廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明。如政府機關或其授權機構核發之專業、專技或特許證書、執照、考試及格證書、合格證書、檢定證明或其他類似之文件。 四、廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明。如維修人員經專業訓練之證明、設立或具有或承諾於得標後一定期間內建立自有或特約維修站或場所之證明等。 五、廠商信用之證明。如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀

		錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。 六、其他法令規定或經主管機關認定者。 前項第三款證明，除依法令就一定專門技能人員之人數為規定者外，不得對其人數予以限制。 第一項第五款無退票紀錄證明，如有退票但已辦妥清償註記者，視同無退票紀錄。機關有證據顯示廠商於截止投標期限前，係拒絕往來戶或有退票紀錄者，依證據處理。」
特定資格 (機關辦理 特殊或巨 額採購)	1. 具有相當經驗或實績者。 2. 具有相當人力者。 3. 具有相當財力者。 4. 具有相當設備者。 5. 具有符合國際或國家品質管理之驗證文件者。 6. 其他經主管機關認定者。	第5條規定： 「機關辦理特殊或巨額採購，除依第二條規定訂定基本資格外，得視採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定投標廠商之特定資格，並載明於招標文件： 一、具有相當經驗或實績者。其範圍得包括於截止投標日前五年內，完成與招標標的同性質或相當之工程、財物或勞務契約，其單次契約金額或數量不低於招標標的預算金額或數量之五分之二，或累計金額或數量不低於招標標的預算金額或數量，並得含採購機關（構）出具之驗收證明或啟用後功能正常之使用情形證明。 二、具有相當人力者。其範圍得包括投標廠商現有與承包招標標的有關之專業或一般人力證明。 三、具有相當財力者。其範圍得包括實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一，或經會計師簽證或審計機關審定之上一會計年度或最近一年度財務報告及其所附報表，其內容合於下列規定者： (一)權益不低於招標標的預算金額十二分之一。 (二)流動資產不低於流動負債。 (三)總負債金額不超過權益四倍。但配合民營化政策之公營事業參加投標者，不在此限。 四、具有相當設備者。其範圍得包括完成與招

		標標的同性質或相當之工程、財物或勞務所需之自有設備。其尚無自有者，得以租賃、租賃承諾證明或採購中或得標後承諾採購證明代之。 五、具有符合國際或國家品質管理之驗證文件者。 六、其他經主管機關認定者。 前項第一款及第三款所定期間、數量、金額或比例，機關不得縮限。但得視採購之性質及需要予以放寬；第三款所稱實收資本額，於有限公司、無限公司或兩合公司指資本總額。第三款第三目之總負債金額，應扣除依其他法律政府獎勵民間投資金額。 機關依第一項第一款及第三款以預算金額訂定資格條件者，應於招標公告或招標文件載明預算金額。履約期間逾一年之勞務採購，其以提供勞力為主，且工作內容重複者，以第一一年之預算金額訂定資格條件。」
--	--	--

資料來源：作者自行製表

國內對於機關辦理採購，得依採購案件之特性及實際需要，訂定投標廠商之基本資格及特定資格，並規定在投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準之內，且行政院公共工程委員會又有提供 4-3 常用之投標廠商基本資格供機關及投標廠商參考，引據行政院公共工程委員會提供之 4-3 常用之投標廠商基本資格—3. 勞務採購資格，對於廢棄物處理之投標廠商基本資格之要求，如下：

表 13 廢棄物處理之投標廠商基本資格之要求

標的類別	投標廠商設立登記或履約能力	應繳證件	法令依據
廢棄物處理	1. 廢棄物處理業(J101040)甲級：從事一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物處理業務。乙級：從事一般廢棄物及一般事業廢棄物處理業務。 2. 廢棄物清理業(J101090)	廢棄物處理許可證。	1. 廢棄物清理法。 2. 公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 3 條及第 6 條。

資料來源：公共工程委員會網頁⁵⁹

引據台灣採購公報網，依採購資訊綜合查詢，以關鍵字「生物醫療廢棄物」進行檢索，因此所得資訊，以 2021 年度為例(2021 年度屬於最近之完整年度)，政府機關或政府機關所屬事業辦理有關生物醫療廢棄物處理之相關標案共 40 筆，由於 40 筆筆數太龐大，擇其中(2021 年度下半年)之 10 筆，作為參考使用，其中包括生物醫療廢棄物之委託處理招標採購，當中尤以「廠商投標摘要」關乎生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司能否參與有關生物醫療廢棄物處理之相關標案之投標，係屬重要，如下：

表 14 生物醫療廢棄物標案介紹

項次	種類	機關名稱	標案案號/標案名稱/廠商資格摘要	招標公告日期
1	招標公告	衛生福利部疾病管制署	CL110035 「111 年度本署實驗室生物醫療廢棄物委外清除處理」採購案 廠商資格摘要	2021/12/8 更新

⁵⁹ 公共工程委員會網頁，網址：

<https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzQyL3JlbGZpbGUvMzY5NjcvODE1MTI4NC83NWYyMWJ1Ny1hZjhlLTQ0ZGMtOTgwOC1kYTMyMTh1Y2NhMDEucGRm&n=My71uLinlkjkuYv mipXmqJnlu6D11Ybln7rmnKzos4fmoLxbMV0ucGRm&icon=..pdf>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。

			1. 廠商須具有環保主管機關核發之甲級廢棄物清除及處理許可證，該證須具備廢棄物代碼 C-05 類:生物醫療廢棄物。2. 本採購允許合作社參與投標，投標廠商為合作社者，應附具合作社章程，且該章程業務項目需涵蓋本採購委託工作項目。3. 依廢棄物清理法第二十八條第四項規定訂立之「經濟部輔導設置事業廢棄物清除處理設施管理辦法」設置之廠商(需含廢棄物清除業及廢棄物處理業等)。	
2	招標公告	衛生福利部金門醫院	. KM110B020 111 年生物醫療廢棄物委託清除處理 廠商資格摘要 (一)投標廠商基本資格(具下列資格之一者): 1. 主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證(具有生物醫療廢棄物 C-05 清除許可項目)，並檢附主管機關核發之甲級廢棄物處理許可證(具有生物醫療廢棄物 C-05 處理許可項目)配合廠商(處理機構)之合作承諾書。2. 主管機關核發之甲級廢棄物處理許可證(具有生物醫療廢棄物 C-05 處理許可項目)，並檢附主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證(具有生物醫療廢棄物 C-05 清除許可項目)配合廠商(清除機構)之合作承諾書。3. 主管機關核發之甲級廢棄物清理許可證(須具有生物醫療廢棄物 C-05 清理許可項目)。4. 依廢棄物清理法第二十八條第四項規定取得「經濟部輔導設置	2021/12/9 更新

			事業廢棄物清除處理設施管理辦法」輔導設置文件(具有生物醫療廢棄物 C-05 清除處理許可項目)之廠商。(二)投標廠商應檢附之資格證明文件：1. 廠商設立登記或設立證明。2. 廠商納稅證明。3. 處理生物醫療廢棄物廠商均須符合環保法規取得清除或處理許可證，投標廠商資格須符合下列條件其中一項，並提供清除、處理技術員證明文件(4)依『經濟部輔導設置事業廢棄物清除處理設施管理辦法』輔導設置文件。4. 其餘應檢附文件請詳閱廠商資格審查表。	
3	招標公告	中央研究院	ESH1101208 中央研究院 111-112 年度生物醫療廢棄物清除及處理勞務採購案 廠商資格摘要 [詳細內容請詳閱本案招標文件之投標須知第 64 點及投標文件審查表之規定]基本資格及應附具之證明文件如下：1. 廠商登記或設立之證明。2. 廠商納稅之證明。3. 廠商信用證明文件。4. 清除、處理或清理相關文件等。(具 C-0504、C-0513、C-0514、C-0599、D-2399 及 D-2499 等廢棄物代碼)5. 清除機構及處理機構共同投標者應檢附經公正或認證之共同投標協議書。6. 清除機構單獨投標者應檢附具 C-0504、C-0513、C-0514、C-0599、D-2399 及 D-2499 等廢棄物代碼處理機構同意書之相關證明文件。7. 處理機構單獨投標者應檢附廢棄物委由具 C-0504、C-0513、C-0514、C-0599、D-2399 及 D-2499 等廢	2021/12/9 更新

			棄物代碼清除機構清除之相關證明文件。	
4	招標公告	衛生福利部疾病管制署	HZ110015 111 年度疾病管制署北區管制中心生物醫療廢棄物委外清除處理 廠商資格摘要 (一)廠商登記或設立之證明。 (二)廠商納稅之證明。(三)廠商具有製造、供應或承做能力之證明。請詳閱本案附件投標須知內容。(四)請詳閱本案附件規格說明內容。	2021/12/13 更新
5	招標公告	連江縣立醫院	MH111001 生物醫療廢棄物委託清除(運)及處理 廠商資格摘要 (1)營業登記項目須與本投標項目相符合：須提供廠商登記或設立之證明：如商業登記證明文件、設立或營業登記證等或其他由政府機關或其授權機關核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(2)具環保主管機關核發之廢棄物清理許可證，須符合下列條件其中一項：1. 投標廠商為清除業者：環保主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證，並檢附環保主管機關核發之甲級廢棄物處理許可證配合廠商(處理機構)之甲級廢棄物處理許可證與合作承諾書。2. 投標廠商為處理業者：環保主管機關核發之甲級廢棄物處理許可證，並檢附環保主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證配合廠商(清除機構)之甲級廢棄物清除許可證與合作承諾書。3. 投標廠商同為清	2021/12/16 更新

			除與處理業者：環保主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證與甲級廢棄物處理許可證。(3)最近一期納稅證明。(4)票據交換機構所或金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄證明（影本）。	
6	招標公告	國防部軍醫局	ND11012P018 111-114 年國軍桃園總醫院新竹分院生物醫療廢棄物清除處理 廠商資格摘要 1. 登記或設立證明（營利事業登記證不得視為公司登記之證明文件）。2. 最近一期或前一期納稅證明 3. 須檢附環保主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證、甲級廢棄物處理許可證、甲級廢棄物清理許可證文件之任一證明文件，並依採購計畫清單備註 1 項 2 款條件辦理。不需會員文件證明	2021/12/16 更新
7	招標公告	國防醫學院	HE11028P030PE 111 年生物醫療廢棄物清除處理 廠商資格摘要 身心障礙福利機構團體或庇護工場得參加投標。(1)廠商登記或設立證明，如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(2)廠商納稅之證明，如營業稅或所得稅。(3)餘如投標須知第 24 頁。	2021/12/17 更新

8	招標公告	法務部矯正署高雄第二監獄	KSSP111005 生物醫療廢棄物委託清運處理 廠商資格摘要 身心障礙福利機構團體或庇護工場得參加投標。(一)廠商登記或設立之證明：如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(二)廠商納稅之證明：其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。(三)設立許可證：環保主管機關核可之甲級廢棄物清除許可證(或操作許可證照)或依廢棄物清理法第二十八條第四項規定訂定之「經濟部輔導設置事業廢棄物清除處理設施管理辦法」之廠商(或上述二者同意代清除、處理之證明文件)，並檢附環保主管機關核可之甲級廢棄物處理許可證，若非自營者請一併提供配合廠商(清	2021/12/17 更新
---	------	--------------	---	---------------

			除或處理商)之配合承諾書。	
9	招標公告	國防醫學院	NG11059P048P 生物醫療廢棄物清除處理及醫療事業廢棄物資源化再利用處理等 2 項 廠商資格摘要 身心障礙福利機構團體或庇護工場得參加投標。1. 公司或商業登記或設立證明。2. 廠商納稅證明。3. 餘詳如國防醫學院三軍總醫院松山分院工程、財物暨勞務採購投標須知第 42 條。	2021/12/20
10	招標公告	國防醫學院	NP11018P018 111-113 年生物醫療廢棄物清除處理 廠商資格摘要 身心障礙福利機構團體或庇護工場得參加投標。(一)廠商登記或設立證明文件。(二)近一期納稅證明。(三)環保主管機關核發之甲級廢棄物清除許可證、甲級廢棄物處理許可證、甲級廢棄物清理許可證文件之任一證明文件，其核准之「每月許可量」應高於本案標的每月預估最大處理量。(A)若為甲級廢棄物清理業者，檢附許可證單獨投標，其核准之「每月許可量」，應高於本案標的每月預估最大處理量。(B)若為甲級廢棄物處理(或清除)業者，則須與甲級廢棄物清除(或處理)業者，檢附各業者許可證並採共同投標方式簽署	2021/12/24 更新

			共同投標協議書及切結書，且須經公證或認證，並於開標時檢附，「每月許可量」其要求標準同(A)後段所述。(C)廠商如採共同投標方式投標，其代表廠商需為處理業者。	
--	--	--	--	--

資料來源：作者自行製表

承上，政府機關或政府機關所屬事業辦理上開有關生物醫療廢棄物處理之相關標案時應先依其本身需求擬定招標文件，藉以邀請生物醫療廢棄物處理業者參與投標，以生物醫療廢棄物處理業者之角度觀之，招標文件之內容乃其參與投標時所須參考之必要資料，而招標文件內容應包括招標投標及契約文件、投標須知、投標標價清單、投標廠商聲明書、契約條款、招標規範等⁶⁰，且行政院公共工程委員會為協助政府機關或政府機關所屬事業製作招標文件，特別訂定有「招標投標及契約文件」範本，其中最重要的便是「採購標的規格」及「參標廠商資格」⁶¹，上開有關生物醫療廢棄物處理相關標案招標文件之投標廠商應具備之資格條件包括但不限於「廠商資格摘要」，係屬於生物醫療廢棄物處理業者能否投標標案之資格要求，不同標案會對投標廠商有不同之資格要求，或要求提出相關證明，以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司最近得標之生物醫療廢棄物處理採購標案為例，要求投標廠商須具備與招標標的有關之基本資格時，參標廠商須檢附環保主管機關核發之甲級廢棄物處理許可證，內容須有招標標的之廢棄物代碼、該許可證核准每月許可處理數量應高於招標標的每月預估數量，是為明顯例證，影響廠商權益甚鉅，也衍生後續生物醫療廢棄物處理業者對於上開有關生物醫療廢棄物處理相關標案招標文件之投標廠商應具備之資格條件有所不服時，予以提起政府採購法之採購異議、採購申訴，以資救濟。

以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，引據台灣採購公報網—決標公司資料庫所得資訊，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司近年來參與政府機關或

⁶⁰ 政府採購法使用手冊(2019年)，頁貳—12。

⁶¹ 黃榆楹，同前註 57，頁 25。

政府機關所屬事業辦理有關生物醫療廢棄物處理之相關標案或許可處理之其他廢棄物，取得勞務採購契約，如下：

表 15 歷年得標數量統計

台灣採購公報網決標公司資料庫

公司名稱：日友環保科技股份有限公司

公司地址：655 雲林縣元長鄉元東路 1-20 號

公司電話：(05) 7885788

公司統編：89922041

日友環保科技股份有限公司 歷年得標數量統計

決標年度	得標件數	得標總金額
2013	2	5,803,991
2014	19	106,985,282
2015	8	18,379,817
2016	7	17,925,445
2017	8	16,058,920
2018	7	24,768,288
2019	13	23,743,078
2020	20	123,085,253
2021	19	232,459,576

資料來源：台灣採購公報網決標公司資料庫⁶²

表 16 2021 年得標案件

台灣採購公報網決標公司資料庫

公司名稱：日友環保科技股份有限公司

公司地址：655 雲林縣元長鄉元東路 1-20 號

公司電話：(05) 7885788

公司統編：89922041

日友環保科技股份有限公司 2021 年得標案件共 19 件：

編號	2021 年得標案件
#1	111 年生物醫療廢棄物清除處理
#2	111 年實驗場所廢溶劑清除處理案
#3	111 年實驗場所廢化學藥品清除處理案
#4	生物醫療廢棄物清除處理等 4 項
#5	生物醫療廢棄物清除處理等 4 項
#6	111 年度全校實驗室廢棄物(液)委託清運處理一式
#7	111 年度「TFDA 生化性廢棄物委外清除處理」
#8	110-111 年高濃度化學廢液(25 公升/桶)處理，預估 21 噸

⁶² 台灣採購公報網決標公司資料庫，網址：
https://www.taiwanbuying.com.tw/QueryCloseCase_Terminate.ASP(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。

#9	111 年度醫學院及生科學院固體可燃廢棄物處理及清運
#10	有害事業廢棄物清除處理
#11	有害事業廢棄物清除處理
#12	生物醫療廢棄物清除處理暨再利用委外採購案
#13	因應 COVID-19 防疫廢棄物清理服務開口契約(中南區)
#14	因應 COVID-19 防疫廢棄物清理服務開口契約(北區)
#15	110 年度「研檢組感染性廢棄物委外清除」
#16	彰化縣和美鎮 110 年焚化廠暫存飛灰委外清理開口契約
#17	110 年度有害事業廢棄物緊急清除處理計畫
#18	因應新型冠狀病毒肺炎之防疫廢棄物清理服務開口契約（中南區）增購
#19	110 年度醫學院及生科學院固體可燃廢棄物處理及清運

資料來源：台灣採購公報網決標公司資料庫⁶³

第二項 勞務採購投標廠商資格爭議發生

設定投標廠商資格之目的，在保障採購品質、提高採購效率、節省採購成本。為了確保得標廠商具有足夠之能力和資格完成投標標的，招標機關必須在採購標的決標前對投標廠商進行資格審查，利用設定投標廠商資格之方式，將廠商過濾篩選，排除沒有具備履約能力之廠商，以保障採購品質具有一定水準⁶⁴。亦即政府機關或政府機關所屬事業可以針對招標標的之特性及需求，設定投標廠商資格，對投標廠商進行篩選，以確保其具有足夠履約能力⁶⁵，適當訂定規格與標準，將能

⁶³ 台灣採購公報網決標公司資料庫，同前註 62。

⁶⁴ 張永富，政府採購招標審標決標之研究——以標價偏低顯不合理之處置為中心，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2011 年 1 月，頁 25。

⁶⁵ 柯寧寧，政府採購投標廠商資格設定之研究，國立中央大學營建管理研究所碩士論文，2006 年 7 月，頁 27。

達成採購品質及效益，反之，則會造成限制廠商投標或得標之權益⁶⁶。比如設定較高之投標廠商資格，將導致只有一家或兩家廠商符合投標廠商資格，此時有意願投標之廠商可能會認為有損及或造成限制有意願投標之廠商投標之權益，形成不當限制及造成綁標〔綁資格〕之爭議⁶⁷，不論係質疑招標機關訂定之廠商資格、採購標的規格為特定廠商量身訂做（即所謂「綁標」），造成不當限制競爭⁶⁸，亦即實務上經常發生廠商認為機關對「廠商資格」或「採購標的規格」作非必要、不合理之限制，造成廠商無法參與投標，甚至使特定廠商得標獲利之結果，招標機關因而受到綁標之質疑⁶⁹，此亦為有意願投標之廠商提起異議之原因。此並有政府採購法第 37 條規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得有不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。投標廠商未符合前條所定資格者，其投標不予受理。但廠商之財力資格，得以銀行或保險公司之履約及賠償連帶保證責任、連帶保證保險單代之。」、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 13 條規定：「機關訂定投標廠商之特定資格時，應先評估可能符合特定資格之廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形。」及行政院公共工程委員會於 109 年 9 月 14 日頒佈之「政府採購錯誤行為態樣」中臚列十三大類之政府採購錯誤行為，當中即有包括資格限制競爭在內，除了於法律面要求政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購時，注意避免違反不當限制競爭，且提醒政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購時隨時注意資格限制競爭之政府採購錯誤行為態樣，以免發生違失。

有認為按「綁標」，是工程上慣用之用語，僅在政府採購法第 26 條、政府採購法第 88 條之立法說明出現過，並非法律專業用語，就政府採購法而言，綁標指的是「不當限制競爭」，意即承辦政府採購之公務員，就招標文件之廠商資格、技術規格或其他條件等，訂定不利競爭之條款，造成圖利特定廠商，或不利廠商

⁶⁶ 陳膺，聯合採購發包機制之風險管控成效—以臺北市公立學校工程採購為例，國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士論文，2021 年 2 月，頁 89。

⁶⁷ 黃俊通，政府採購法下工程統包之研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，2001 年，頁 33。

⁶⁸ 施欣好，政府採購選商決定之司法審查—以採購標的規格與廠商資格之審查為中心，國立臺北大學法律學系碩士論文，2019 年 8 月，頁 1。

⁶⁹ 施欣好，同前註 68，頁 18。

投標，並可能造成費用增加之結果⁷⁰。另有認為「綁標」即機關或規畫設計者為期有利於特定廠商得標或獲得分包之機會，訂定特殊之技術、工法、材料或設備之招標規範，或對投標廠商之資格、等標期、履約期限為不當之限制，以減少競爭者或限制廠商得標後尋求分包商之機會⁷¹。招標機關以不當資格限制或規格限定而有導致相關事業或商品受到歧視之差別待遇，或因不當之限定對於特定事業或產品予以較優惠之競爭，而妨礙事業間之公平競爭，其類型大致可分為「不當限制採購標的之規格或性能」與「不當限制投標廠商之資格」兩大類⁷²。綁標之成因，可能係由於官商勾結，辦理採購之人員為圖利特定廠商，故意在規格或資格條件之制定上排除其他競爭者參予之機會，其次可能係因為採購相關規範不明確或採購人員對採購法規不熟悉之故⁷³，無意間造成綁標現象之發生⁷⁴。另有論及綁標之方式亦可分為兩類：（一）廠商事先知悉機關即將辦理採購案，而預先與承辦人員對廠商資格、施工方法、設備規格等各項標準達成約定，以利具有這些施廠商資格、施工方法與設備規格之廠商參與投標並得標。此乃廠商與不肖承辦人員相互勾結之違法行為。（二）現今之公共工程日益龐大、複雜且規劃、設計、監造通常需要委由具有特殊專長技術之廠商辦理；因此受機關委託辦理規劃、設計與管理之廠商，利用設計特殊之施工方法即設備規格，以使特定廠商得以順利投標並得標，而達成綁標之目的⁷⁵，殊值可參。又有提及所謂綁標，係指承辦採購之人員在招標文件中，對採購標的之技術、工法、材料或設備之招標規範，作出了不合法或不當之限制，使得能夠參與標案之廠商受到限制，僅有一家或少數幾家廠商合於標準，而此舉顯然違反市場上公平競爭之原則，無正當理由對他事業給予差別待遇，而為政府採購法所限制。而實務上常見之綁標態樣，有針對採購標的之規格或性能為不當之限制（綁規格），如超出需求或與需求無關之規格等，亦有

⁷⁰ 璞實法律事務所網頁，政府採購法上的綁標概念，傅建中結構技師，法務室，中興工程顧問股份有限公司，2016年1月12日，網址：<https://www.cawlawfirm.com/cawlawfirm/2016/>（最後瀏覽日：2022年6月13日）。

⁷¹ 廖傳賀，圍標犯罪之研究—以政府採購法第八十七條規定為中心，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2011年，頁36。

⁷² 張祥暉，政府採購之綁標、圍標防制研究及建言，立法院院聞第31卷第4期，2003年4月，頁69—70。

⁷³ 廖傳賀，同前註71，頁36—37。

⁷⁴ 黃榆楹，同前註57，頁46。

⁷⁵ 潘秀菊，政府採購法，新學林出版股份有限公司，一版一刷，2009年8月，頁290。

對投標廠商之資格為不當限制(綁資格)，如過當之資格⁷⁶。且有論析綁標行為一般係指在採購實務上之一種「不公平」情況產生之態樣，亦即採購機關或規劃設計者為了要有利於特定廠商以使其得標或獲得分包之機會，而訂定特殊之技術、工法、材料或設備之招標規範，或是對投標廠商之資格、等標期、履約期限為不當之限制，以減少競爭者或限制廠商得標後尋找分包商之機會，並使綁標者得從中獲利⁷⁷，前者係不當限制採購標的之規格或性能，一般稱之「綁規格標」，後者係不當限制投標廠商之資格，一般稱之「綁資格標」⁷⁸。

「綁標」在我國雖無任何法律予以明確定義，但依據公平交易委員會公研釋字○八九號函釋，係指：「無正當理由對他事業給予差別待遇」之行為。亦有以「招標機關以不當資格限制或規格限定而有導致相關事業或商品受到歧視的差別待遇，或因不當之限定對於特定事業或產品予以較優惠之競爭，而有妨礙公平競爭之虞」者稱之。

依據政府採購法第 36 條第 1 項規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格」。且依據政府採購法第 37 條規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得有不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。投標廠商未符合前條所定資格者，其投標不予受理。…」，及依據政府採購法第 50 條規定：「投標廠商有下列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商：一未依招標文件之規定投標。……決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。…」。再依據政府採購法第 74 條規定：「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。」、政府採購法第 75 條規定：「廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定（以下合稱法令），致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向招標機關提出異議：一、對招標文件規定提出異議者，為自公告或邀標之次日

⁷⁶ 林濬詮，政府採購貪瀆犯罪法律規範及防制作為之研究，銘傳大學法律學系碩士在職專班碩士論文，20017 年 6 月，頁 33。

⁷⁷ 蘇明通，政府採購之不法不當行為及其防治，律師雜誌，249 期，2000 年，頁 22—23。

⁷⁸ 林勇麒，從保護法益論政府採購法之刑事責任——國家法益假象下的競爭秩序守護者，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2014 年，頁 24。

起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。二、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。三、對採購之過程、結果提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。其過程或結果未經通知或公告者，為知悉或可得而知悉之次日起十日。但至遲不得逾決標日之次日起十五日。招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。其處理結果涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。」。基此，就政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物清除、處理或清除處理勞務採購案件而言，有時政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物清除、處理或清除處理勞務採購案件時，有就投標須知內設定之投標廠商資格內容及門檻，過度嚴格或不合理及不公平，未符合實際需要，甚至有資格綁標⁷⁹、不當限制競爭之情形發生，或者有為特定生物醫療廢棄物處理業者量身製作，訂定過嚴過苛資格排除其他廠商參與公平競爭機會⁸⁰，對於有意願投標之生物醫療廢棄物處理業者而言，屬於重中之重之政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物清除、處理或清除處理勞務採購案件發生違失，此時生物醫療廢棄物處理業者只要符合「機關之採購行為違反法令」及「其權利或利益因而受損害」二要件⁸¹，即得據以提起異議，尋求權益之維護，以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，常就上開情形提出異議。本文就政府採購行為前階段之招標公告、招標、決標所發生之爭議而言，也係以探討招標機關違反不當限制競爭之爭議作為探討重心及展開。

⁷⁹ 柯寧寧，同前註 65，頁 29。

⁸⁰ 蕭念祖，同前註 23，頁 48。

⁸¹ 唐迪俊，同前註 20，頁 80。

另有針對資格限制競爭提供錯誤行為態樣予以彙整，如下：

表 17 資格限制競爭提供錯誤行為態樣

序號	錯誤行為態樣	依據法令
(一)	訂定之廠商資格為「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」(以下簡稱資格標準)所無或違反或較該標準更嚴格之規定	採購法第三十六條、第三十七條，資格標準。
(二)	非特殊或巨額採購卻規定特定資格。	採購法第三十六條第二項，資格標準第五條。
(三)	訂定特定資格未依該標準評估廠商家數及檢討有無限制競爭。	資格標準第十三條。
(四)	過當之資格，例如：乙等營造業承攬限額內之工程卻限甲等 營造業方可投標。	採購法第三十七條第一項，資格標準第三條第三項。
(五)	限非屬法規規定之團體之會員方可投標，例如：某協會之會員。	採購法第三十七條第一項，資格標準第三條至第五條。



(六)	限公部門(政府機關、公營事業、公立學校)之實績	資格標準第十四條。
(七)	限國內之實績。	
(八)	限特定地區公會之會員。	採購法第三十七條第一項，資格標準第三條第一項第三款、第六項。
(九)	不當限制特定公會之會員方可投標。	
(十)	繳納營業稅證明限當期者。	資格標準第三條第五項。
(十一)	信用證明限公告日後所取得者。	資格標準第四條第一項第五款。
(十二)	資本額限公告日前者。	資格標準第五條第一項第三款。
(十三)	非屬特殊或巨額採購，限取得 ISO9000 系列驗證者。	資格標準第五條第一項第五款。
(十四)	投標當時即必須於指定地區設有分公司或維護站。	資格標準第四條第一項第四款。
(十五)	限定投標廠商之所在地。	資格標準第十五條。
(十六)	投標當時即必須擁有指定之設備。	資格標準第五條第一項第四款。
(十七)	不考慮資格文件之性質而規定廠商檢附正本	資格標準第十條第一項。
(十八)	限開標當時必須攜帶資格文件正本。	
(十九)	以已停止使用之投標比價證明書為廠商資格文件。	非屬資格標準第二條至第五條 規定範圍。
(二十)	投標時須檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠願意 供應證明、原廠品質保證書。	非屬資格標準第二條至第五條 規定範圍，採購法第三十七條。
(二十一)	以小綁大，例如：規定重要項目之分包廠商必須具備某一特定之資格條件，而具備該資格條件之分包廠商甚少；規定投標廠商投標時須取得特定材料供應商之授權同意書。	採購法第六條、第三十七條。
(二十二)	依據法令規定之資格與履約能力無關。	採購法第三十七條。

(二十三)	限定國內廠商投標時須檢附與國外廠商技術合作之證明。(註:招標文件如未作強制規定,而係由投標廠商自行決定之合作,非屬此一情形)	採購法第三十七條第一項,資格標準第三條至第五條
-------	--	-------------------------

資料來源：公共工程委員會網頁⁸²

以行政院衛生福利部 2021 年度上半年(1 月-6 月)政府採購錯誤行為態樣及 2021 年度下半年(7 月-12 月)政府採購錯誤行為態樣為例,經行政院衛生福利部採購稽核小組 2021 年度上半年(1 月-6 月)及 2021 年度下半年(7 月-12 月)辦理採購稽核監督結果,經彙整發現 2021 年度之一完整年度發生頻率較多之政府採購錯誤行為態樣,於採購階段錯誤次數共 1513 筆(789 筆+724 筆=1513 筆),當中招標階段之錯誤共 719 筆(383 筆+336 筆=719 筆),其中有關廠商資格/資格訂定為 107 筆(58 筆+49 筆=107 筆),可見除了行政院衛生福利部辦理政府採購案件常發生有關廠商資格/資格訂定之錯誤行為外,更可推知於其他政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件中發生有關廠商資格/資格訂定之錯誤行為屢見不鮮,其情形有包括 1. 廠商基本資格訂定符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 3 條及第 4 條規定(非屬特殊或巨額採購,不得訂定第 5 條之特定資格)。2. 特殊或巨額採購,廠商特定資格訂定符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 5 條規定。3. 特殊或巨額採購,廠商特定資格訂定,已先行評估可能符合特定資格之廠商家數,並檢討有無不當限制競爭之情形。4. 個別行業廠商資格,依各該行業相關法規應具備之資格條件訂定等情形。

另依據政府採購法第 76 條規定：「廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服,或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者,得於收受異議處理結果

⁸² 公共工程委員會網頁,網址:

<https://esvc.fnp.gov.tw/download/4d46cda90fac449d879c6aea73c355e4>(最後瀏覽日:2022 年 6 月 13 日)。

或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會申訴。地方政府未設採購申訴審議委員會者，得委請中央主管機關處理。廠商誤向該管採購申訴審議委員會以外之機關申訴者，以該機關收受之日，視為提起申訴之日。第二項收受申訴書之機關應於收受之次日起三日內將申訴書移送於該管採購申訴審議委員會，並通知申訴廠商。爭議屬第三十一條規定不予發還或追繳押標金者，不受第一項公告金額以上之限制。」；政府採購法第 77 條規定：「申訴應具申訴書，載明下列事項，由申訴廠商簽名或蓋章：一、申訴廠商之名稱、地址、電話及負責人之姓名、性別、出生年月日、住所或居所。二、原受理異議之機關。三、申訴之事實及理由。四、證據。五、年、月、日。申訴得委任代理人為之，代理人應檢附委任書並載明其姓名、性別、出生年月日、職業、電話、住所或居所。民事訴訟法第七十條規定，於前項情形準用之。」；政府採購法第 78 條第 1 項規定：「廠商提出申訴，應同時繕具副本送招標機關。機關應自收受申訴書副本之次日起十日內，以書面向該管採購申訴審議委員會陳述意見。」。如招標機關認定雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司之主張為無理由時，將決定是否向採購申訴審議委員會提起申訴。且依據政府採購法第 78 條第 2 項規定：「採購申訴審議委員會應於收受申訴書之次日起四十日內完成審議，並將判斷以書面通知廠商及機關。必要時得延長四十日。」；政府採購法第 78 條規定：「申訴逾越法定期間或不合法定程式者，不予受理。但其情形可以補正者，應定期間命其補正；逾期不補正者，不予受理。」；政府採購法第 80 條規定：「採購申訴得僅就書面審議之。採購申訴審議委員會得依職權或申請，通知申訴廠商、機關到指定場所陳述意見。採購申訴審議委員會於審議時，得囑託具專門知識經驗之機關、學校、團體或人員鑑定，並得通知相關人士說明或請機關、廠商提供相關文件、資料。採購申訴審議委員會辦理審議，得先行向廠商收取審議費、鑑定費及其他必要之費用；其收費標準及繳納方式，由主管機關定之。採購申訴審議規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。」；政府採購法第 82 條規定：「採購申訴審議委員會審議判斷，應以書面附事實及理由，指明招標機關原採購行為有無違反法令之處；其有違反者，並得建議招標機關處置之方式。採購申訴審議委員會於完成審議前，必要時得通知招標機關暫停採購程序。採購申訴審議委員會為第一項

之建議或前項之通知時，應考量公共利益、相關廠商利益及其他有關情況。」；政府採購法第 83 條規定：「審議判斷，視同訴願決定。」；政府採購法第 84 條規定：「廠商提出異議或申訴者，招標機關評估其事由，認其異議或申訴有理由者，應自行撤銷、變更原處理結果，或暫停採購程序之進行。但為應緊急情況或公共利益之必要，或其事由無影響採購之虞者，不在此限。依廠商之申訴，而為前項之處理者，招標機關應將其結果即時通知該管採購申訴審議委員會。」；政府採購法第 85 條規定：「審議判斷指明原採購行為違反法令者，招標機關應自收受審議判斷書之次日起二十日內另為適法之處置；期限屆滿未處置者，廠商得自期限屆滿之次日起十五日內向採購申訴審議委員會申訴。採購申訴審議委員會於審議判斷中建議招標機關處置方式，而招標機關不依建議辦理者，應於收受判斷之次日起十五日內報請上級機關核定，並由上級機關於收受之次日起十五日內，以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由。審議判斷指明原採購行為違反法令，廠商得向招標機關請求償付其準備投標、異議及申訴所支出之必要費用。」。基此，倘若雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司提起申訴，在採購申訴審議委員會審議雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司所提起之申訴，做出審議判斷，審議判斷之效力視同訴願決定，經審議認為申訴有理由時，招標機關將會配合更改其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻，以符合實際需要，避免資格綁標、不當限制競爭之情形發生，若經審議認為申訴無理由時，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司仍將會基於採購申訴審議委員會之組成，係由公正人士所擔任，所作成之審議判斷應為合理、公正，而願意尊重該審議結果，而不再行提起後續之行政訴訟等程序，以節省提起訴訟之浪費勞力、時間及費用。

為杜絕招標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻，以符合實際需要，避免資格綁標、不當限制競爭之情形不斷發生，本人以為不妨得先由從頭研議政府採購投標廠商資格設定下手，必須符合合理性、公平性及競爭性，有認為除應視採購案件之特性及實際需要，衡諸目前國內符合投標廠商資資格及門檻之廠商數量，並包括仍應將廠商是否具有相關經驗、履約實績、相當人力、相當財力、相當設備擴大範圍作為評估符合投標廠商資格及門

檻，至所有政府採購案件，作為設定投標廠商資資格及門檻之原則⁸³，而非只侷限專就特殊或巨額之採購，並進而有修法之建議，即修正政府採購法第 36 條規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，得就實際需要另行規定，附經公證或認證之中文譯本，並於招標文件中訂明。第一項基本資格、第二項特定資格與特殊或巨額採購之範圍及認定標準，由主管機關定之。」，經修正後之政府採購法第 36 條規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，得就實際需要另行規定，附經公證或認證之中文譯本，並於招標文件中訂明。第一項基本資格、第二項特定資格，由主管機關定之。」⁸⁴及修正投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 5 條第 1 項規定：「機關辦理特殊或巨額採購，除依第二條規定訂定基本資格外，得視採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定投標廠商之特定資格，並載明於招標文件：……」，修正後之投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 5 條第 1 項規定：「機關辦理採購，除依第二條規定訂定基本資格外，得視採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定投標廠商之特定資格，並載明於招標文件：……」，甚至基於已刪除「特殊或巨額」之文字，投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 6 條規定、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 7 項規定、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 7-1 條規定、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 8 條規定及投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 9 條規定，皆涉及特殊採購或巨額採購之定義性規定，理應全部刪除之提議，殊值可參。

雖然目前政府採購法相關法令之規定已完善，政府採購法制上已完備，已能解決投標廠商資格符合公平及合理之要求，但本人仍認為目前之政府採購法相關法令之訂定或修改仍屬不足夠，本人建議不妨透過再度修法之方式，面對解決招

⁸³ 柯寧寧，同前註 131，頁 51。

⁸⁴ 柯寧寧，同前註 65，頁 49。

標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻之爭議。

承上，本人支持得透過修法之方式，面對解決招標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻之爭議，惟本人有不同之修法見解，本人認為政府採購法第 36 條規定應修正成「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，得就實際需要另行規定，附經公證或認證之中文譯本，並於招標文件中訂明。第一項基本資格、第二項特定資格，由主管機關定之。」⁸⁵，並無疑義，但有關上開投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準之修正是有疑義，倘基於上開「形同取消特殊採購及巨額採購」見解，將造成我國就特殊採購或巨額採購之定義已無認定標準，整個投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準形同空洞化，甚至牽一髮而動全身，影響全面政府採購法相關法令之應配合修正，影響甚鉅，是應加以斟酌，本人以為得參照其他法令之相關立法之方式，即以影響最小、變動最小、最佳化之法規條文修改方式，得將投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 2 條規定內，新增第 2 項之規定，即新增「本標準第 5 條規定，於政府辦理採購，準用之。」之文字，亦即修正後之投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 2 條規定為「機關辦理採購，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項訂定投標廠商之基本資格，並載明於招標文件：一、與提供招標標的有關者。二、與履約能力有關者。本標準第 5 條規定，於政府辦理採購，準用之。」，即可解決及化解上開過度修法之爭議，並可同時達到相同修法之效果。

另有認為投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 13 條規定：「機關訂定投標廠商之特定資格時，應先評估可能符合特定資格之廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形。」，亦應配合修正，而主張應刪除「特定」之文字，以擴大至所有政府採購案件⁸⁶皆有適用先行評估目前國內符合投標廠商資格及門檻之廠商數量作為投標廠商資格及門檻之廠商數量之參考，本人以為既然投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 2 條規定得修正為「機關辦理採購，得依採購案件

⁸⁵ 柯寧寧，同前註 84。

⁸⁶ 柯寧寧，同前註 83。

之特性及實際需要，就下列事項訂定投標廠商之基本資格，並載明於招標文件：

一、與提供招標標的有關者。二、與履約能力有關者。本標準第 5 條規定，於政府辦理採購，準用之。」，亦即政府辦理政府採購案件除得適用投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 5 條規定之特定資格要求外，想當然耳，政府辦理政府採購案件當然得一體適用投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 13 條規定之特定資格要求，不待修正，自不待言。

另本人以為依據政府採購法第 6 條第 2 項規定：「辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。」及政府採購法第 95 條規定：「機關辦理採購宜由採購專業人員為之。但一定金額之採購，應由採購專業人員為之。前項採購專業人員之資格、考試、訓練、發證、管理辦法及一定金額，由主管機關會商相關機關定之。」，且行政院公共工程委員會 95 年 11 月 3 日工程企字第 09500420310 號函：「主旨：有關政府採購法第 15 條第 1 項執行疑義，復如說明，請查照。說明：一、復貴局 95 年 10 月 30 日市政字第 0951001373 號函。二、來函說明一，旨揭條項所稱『承辦採購人員』，包括處理訂定招標文件、招標、開標、審標、比價、議價、決標、訂約、履約管理、驗收及爭議處理之人員；所稱『監辦採購人員』指監視機關辦理採購之開標、比價、議價、決標及驗收之人員；另承辦、監辦採購人員之主官、主管亦適用之。三、來函說明二，機關辦理採購，如認定投標廠商僱用人員符合旨揭條項規定情形，得認定該廠商符合政府採購法第 50 條第 1 項第 7 款規定；併請查閱公務員服務法第 14 條之 1 及第 22 條之 1 規定。」，於此，招標機關採購人員扮演之角色係屬重要，尤於招標機關在辦理政府採購案件時，其投標須知內設定投標廠商資格內容及門檻，有賴該採購人員憑採購專業予以訂定，亦即採購人員應注意招標機關於投標須知內設定投標廠商資格內容及門檻之合理性且無限制競爭之情事發生⁸⁷，目前行政院公共工程委員會有制定採購專業人員資格考試訓練發照及管理辦法與採購專業人員訓練計畫，對採購人員進行基礎訓練、進階訓練、經考試及格，領有及格證書及管理，充實採購人員智識，提升政府採購效率及品質，預防採購缺失之發生，且有制定採購人員倫理準則，尤以採購人員倫

⁸⁷ 彭楚榮，政府採購弊案之探討，國立雲林科技大學會計系碩士論文，2015 年 6 月，頁 8。

理準則第 7 條規定：「採購人員不得有下列行為：…六、未公正辦理採購。…十七、意圖為私人不正利益而高估預算、底價或應付契約價金，或為不當之規劃、設計、招標、審標、決標、履約管理或驗收。…」，要求採購人員應致力於公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，並促使採購制度健全發展，使採購人員更能勝任招標機關辦理政府採購案件時，符合公平、公正、公開、合理之要求，亦即除了於政府採購法之法規面落實修改外，更於政府採購法之運作及操作面落實就採購人員之培訓及養成，二者兼備，以達招標機關辦理政府採購案件賦與之任務完滿成功，目前採購實務上，雖然行政院公共工程委員會制定「內部控制制度共通性作業範例標準化作業流程及控制重點—採購業務」、「『採購業務』內部控制制度共通性作業範例之『公共工程施工品質管理』作業項目」及「內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例」⁸⁸以供政府機關或政府機關所屬事業遵循，建構辦理各項政府採購業務之標準作業程序，惟政府機關或政府機關所屬事業擔任採購之人員非專職，造成採購人員時常變動，無法長久擔任採購之職務，基於採購人員具有專業性及熟悉政府採購法相關規定與各種民事、刑事、行政相關法規之規定，不妨參照國家考試之針對法制人員之錄取取材，設計採購人員之公務員國家考試制度，錄取符合專業需求之人才，參與承辦政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件，使有效降低或杜絕政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件於投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻之現象發生之風險，確保採購品質及提升採購效率⁸⁹，建構公平、公正、公開、合理之採購程序，滿足政府機關或政府機關所屬事業、人民及廠商之最大利益與需求⁹⁰，始為妥適。影響所及，不至於發生政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件之過程中，發生政府採購行為錯誤之情形發生，而肇致遭受行政院公共工程委員會、採購稽核小組、審計機關、主管機關、主(會計)單位、政風單位等執行稽核監督，指出政府採購行為發生政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件於投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻等錯誤之情形，要求改善等結果，也得避免廠商主張其權益因政府採購行為發生

⁸⁸ 鄭敏伶，健全政府採購作業—以個案機關為例，東吳大學會計學系碩士在職專班碩士論文，2013 年 8 月，頁 26。

⁸⁹ 彭楚榮，同前註 87，頁 7。

⁹⁰ 彭楚榮，同前註 89。

政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件於投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻等受到損害，為維護自身權益，而提起採購異議及採購申訴救濟之。甚至得避免違反政府採購法相關規定之法定義務或違反、逾越、怠於行使政府採購法相關規定給予之權限，除了依據採購人員倫理準則第12條規定：「機關發現採購人員有違反本準則之情事者，應審酌其情狀，並給予申辯機會後，迅速採取下列必要之處置：一、依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法及其他相關規定處置。其觸犯刑事法令者，應移送司法機關處理。二、調離與採購有關之職務。三、施予與採購有關之訓練。採購人員違反本準則，其情節重大者，機關於作成前項處置前，應先將其調離與採購有關之職務。機關未依前二項規定處置或處置不當者，主管機關得通知該機關或其上級機關另為適當之處置。」，予以處置外，且由於違反政府採購法之規定或刑事法律之相關規定，而有遭致觸及法網，遭受檢調機關偵辦、移送起訴及法院判處刑罰之制裁。

且於政府採購行為稽核監督面向，本人以為基於行政院公共工程委員會、採購稽核小組、審計機關、主管機關、主(會計)單位、政風單位等皆具有執行稽核監督之權限，承如上述，基於落實採購人員勇於任事，先由政府機關或政府機關所屬事業內部自主稽核機制做起，負起事先隨時提醒採購人員辦理採購業務之盲點與採購缺失所在，適時給予招標機關輔導，並導正其不當之採購行為，比如政府採購錯誤行為之發生，包括但不限於招標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻，除了減少政府機關或政府機關所屬事業與廠商之間採購爭議外，更能減少政府採購人員違法脫序之採購行為，以期減少採購人員違犯未依政府採購法令規定憑辦事項之行為，並減少可能發生營私舞弊之情形。

第三項 實務上勞務採購爭議處理

第一款 我國政府採購爭議救濟途徑

由於政府採購行為中，從招標文件、廠商資格、採購規格、招標公告、開標、審標、決標到履約、驗收等，都是政府採購法所規範，此些採購程序，招標機關

與廠商之爭議處理，實為至要⁹¹，基於在本節第二項所述之政府採購爭議，日益多樣龐雜，且頻繁發生，急需就採購爭議管道予以明確化，我國為提供廠商適時之救濟管道，以維護其權益，特於政府採購法第六章創設「爭議處理」制度，使因採購所生之爭議，得以迅速、公平、公正地解決。內容包括「異議、申訴」與「履約爭議調解」兩大部分，異議、申訴制度是廠商與機關在招標、審標、決標階段，即機關與廠商間還未有契約關係之救濟制度；而履約爭議調解則是廠商與機關在履約、驗收階段，亦是機關與廠商已發生契約關係後之爭議處理機制。然有認為政府採購法第六章創設「爭議處理」制度，原則上係屬於「選擇」及「非排他性」之爭議處理機制，其僅為解決爭議之一種方法，而非謂政府採購爭議均應依政府採購法之爭議處理制度解決⁹²，但基於政府採購法已於第六章創設「爭議處理」制度，廠商面對政府採購爭議發生時，仍願意依據上開政府採購爭議解決途徑尋求救濟。

揆諸行政院於1996年12月23日函請立法院審議「政府採購法草案」案之政府採購法草案總說明第21點所述：「為使採購公開化、透明化得以落實，進而公平有效的處理招標、決標過程發生之爭議，保障廠商權益，爰參酌政府採購協定之規定，創設異議及申訴制度，供廠商利用。（草案第五十六條至第五十九條）」。
基此，我國於政府採購法制定之時，即就處理招標、決標過程發生之爭議，建構提起異議及申訴之救濟管道。我國係採取先異議，後申訴之制度設計⁹³，一言以蔽之，我國係採取異議先行程序，或稱之為異議前置主義，廠商就招標、決標過程發生之爭議先行向招標機關提出異議，由招標機關自我審查，作出異議處理結果，廠商若有不服招標機關所作出之異議處理結果，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，分別向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設置公正、客觀之採購申訴審議委員會提起申訴，由採購申訴審議委員會作出審議之判斷。採購申訴審議委員會係以公正第三人立場，對於機關與廠商間招標、審標、決標之爭議，依其專業判斷是非曲直，因採購申訴審議委員會委員多係具法律或採購專業知識，且與

⁹¹ 朗世瑀，因可歸責廠商事由致解除或終止政府採購契約所生爭議問題研究，國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士學位論文，2012年7月，頁32。

⁹² 吳庚，同前註36，頁33。

⁹³ 莊賀元，政府採購法先調後仲機制之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，2009年6月，頁16。

當事人間並無隸屬、委任或其他關係，故對爭議之處理自然較為公正、客觀，所為之審議判斷，當易為爭議雙方當事人所接受。

按照政府採購法第 74 條規定：「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。」。且按照政府採購法第 85—1 條規定：「機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理：一、向採購申訴審議委員會申請調解。二、向仲裁機構提付仲裁。前項調解屬廠商申請者，機關不得拒絕。工程及技術服務採購之調解，採購申訴審議委員會應提出調解建議或調解方案；其因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。採購申訴審議委員會辦理調解之程序及其效力，除本法有特別規定者外，準用民事訴訟法有關調解之規定。履約爭議調解規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。」。基此，政府採購法已將關於招標、審標、決標之爭議及履約爭議分別以不同救濟管道予以解決。何況揆諸行政院公共工程委員會 91 年 2 月 6 日總統華總一義字第〇九一〇〇〇二五六一〇號令修正公布政府採購法修正條文修正理由說明：「1. 政府採購行為一向被認定為『私經濟行為』，故已有契約關係之履約或驗收爭議應循民事爭訟途徑解決，使救濟制度單純化；且本法設有調解制度，已足可提供救濟管道。本條原規定履約或驗收之私法爭議，得由得標廠商自由選擇適用申訴程序或仲裁、起訴，將造成救濟體系積極衝突，實有不宜，爰刪除履約或驗收爭議得提出異議及申訴規定。2. 關於履約或驗收爭議得提出異議、申訴規定及第八十三條視同調解方案規定既經刪除，於本條但書規定『得標廠商與機關間之私法爭議，已提付仲裁、申(聲)請調解或提起民事訴訟者，不在此限』已無實益。爰予刪除」。可徵行政院公共工程委員會之態度已認為有關政府採購契約履約爭議應循民事訴訟程序予以解決。

細究政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序之規定，乃我國政府採購制度之新創，亦係該法之精髓所在。蓋就廠商而言，政府採購法對於廠商權益保障，有賴異議及申訴制度予以維護。廠商對於機關關於招標、審標、決標之過程，認為涉有不公或違法失當之處，廠商得以提起異議及申訴之方式尋求救濟。有認為

政府採購法之立法設計上，將廠商就招標、審標、決標及停權等事項，定性為招標機關之行政作為⁹⁴，廠商如有不服，得提起異議及申訴，以資救濟。

在政府採購法制定之前，由於規範較不明確，導致較易黑箱作業，倘若採購人員心懷不軌或有意優惠、歧視其中某些廠商，則法律上較無直接而明確可以適用之法律可以處理，當廠商受到委屈時，常無正當之管道向採購機關或其上級機關申訴，以致於廠商往往必須訴諸請託，以便影響採購人員。而在政府採購法制定後，廠商有正常之申訴管道，在較為透明合理之規則下與採購機關進行往來，一方面減少廠商受到不當待遇之機會，另一方面由於程序之公開透明而可以減少廠商之相關交易成本。

另有以政府採購因其利益龐大，易引起政府官員或民意代表之請託關說，或黑道勢力之介入，如機關承辦採購人員，無法承受此一壓力，故意訂定特殊之規格與條件，藉以逼退其他競爭者；或機關承辦採購人員心懷不軌，故意訂定鬆散之規格與條件，以便讓目標廠商過關，達到圖利特定廠商之目的；或因採購機關未詳細規劃，致有錯誤或疏失之情形，爭議之發生在所難免，此為關於招標、審標、決標之爭議，政府採購法立法設計上，廠商得藉由提起異議及申訴，以維護權益。

由於採購申訴審議委員會就招標、決標過程發生之爭議作出之審議判斷，該審議之判斷依據政府採購法之規定，視同訴願決定，不服審議判斷結果，得循行政爭訟程序解決，至於後續履約階段，誠如上述，依據雙階理論，屬於私法行為，故應以民事法律為權利義務關係之依據，所生爭議屬私法性質，得循民事爭訟程序解決。亦有認為此階段發生之爭議，與私法契約所發生之糾紛無異，機關與廠商間互有私法契約上權利義務及存有私法契約上債權債務關係，若發生契約履行上糾紛，以契約是否明文約定為準據，若契約未有約定，仍無法解決糾紛時，即得援引民法相關規定補充適用及作為判斷依據。依據行政院公共工程委員會之統計，2020 年採購爭議案件主要類型及件數，申訴案件(316 件)，對採購過程、結果之申訴就佔了 151 件，已近半數，為申訴案件中最常見者。有關我國政府採購異議處理流程及申訴處理流程如下：

⁹⁴ 李玉卿，政府採購停權制度之剖析－從預防性與裁罰性行政處分之區別出發，東吳大學法學院法律學碩士在職專班公法組碩士論文，2020 年 8 月，頁 2。

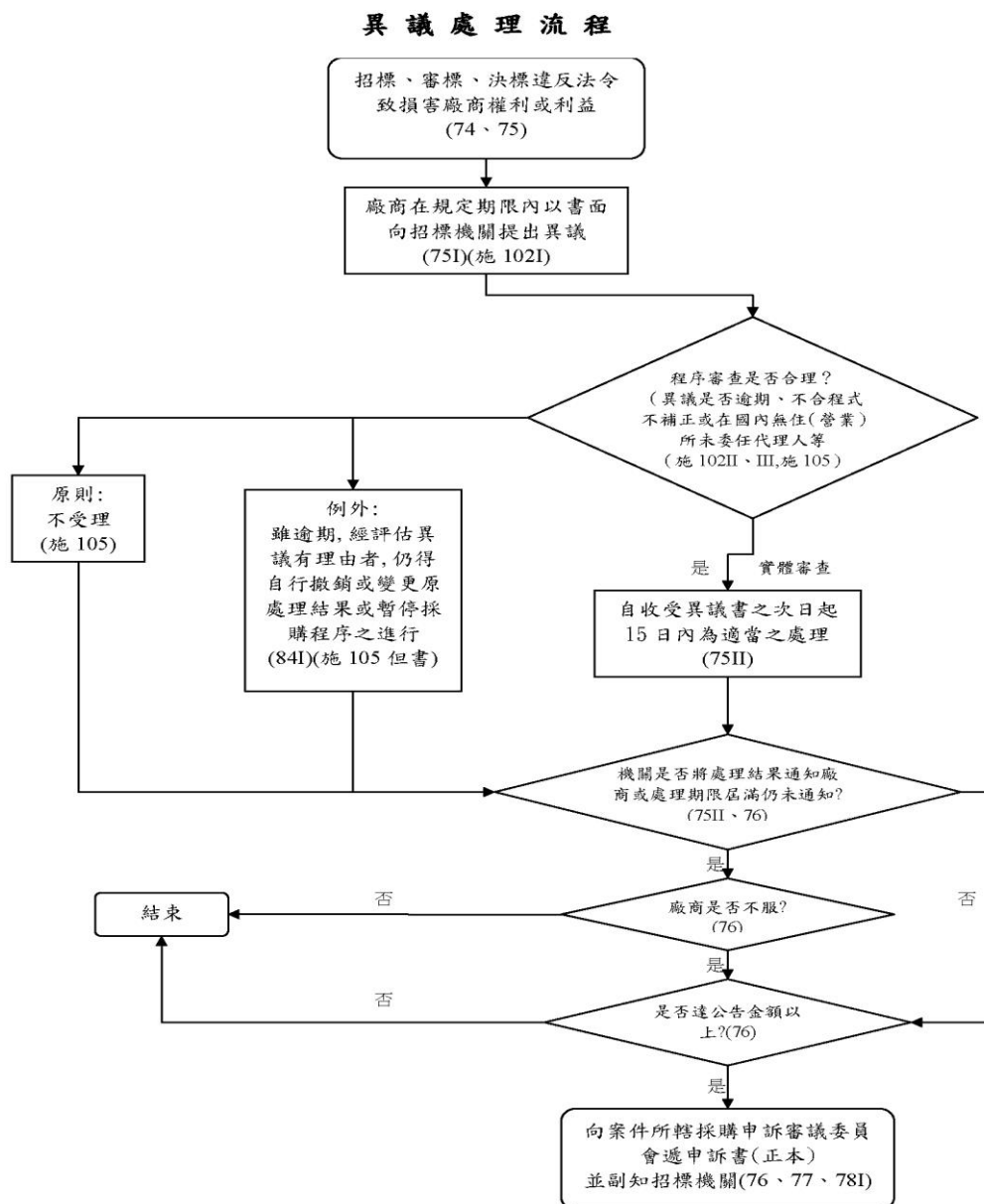


圖 6 異議處理流程圖

資料來源：中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網－

申訴調解之書類表格與流程－異議申訴流程圖⁹⁵

⁹⁵ 中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網－申訴調解之書類表格與流程－異議申訴流程圖，
網址：
<https://ws.pcc.gov.tw/001/upload/old/oldupload/upload/article/0e47bf54a6e921d50d1f>

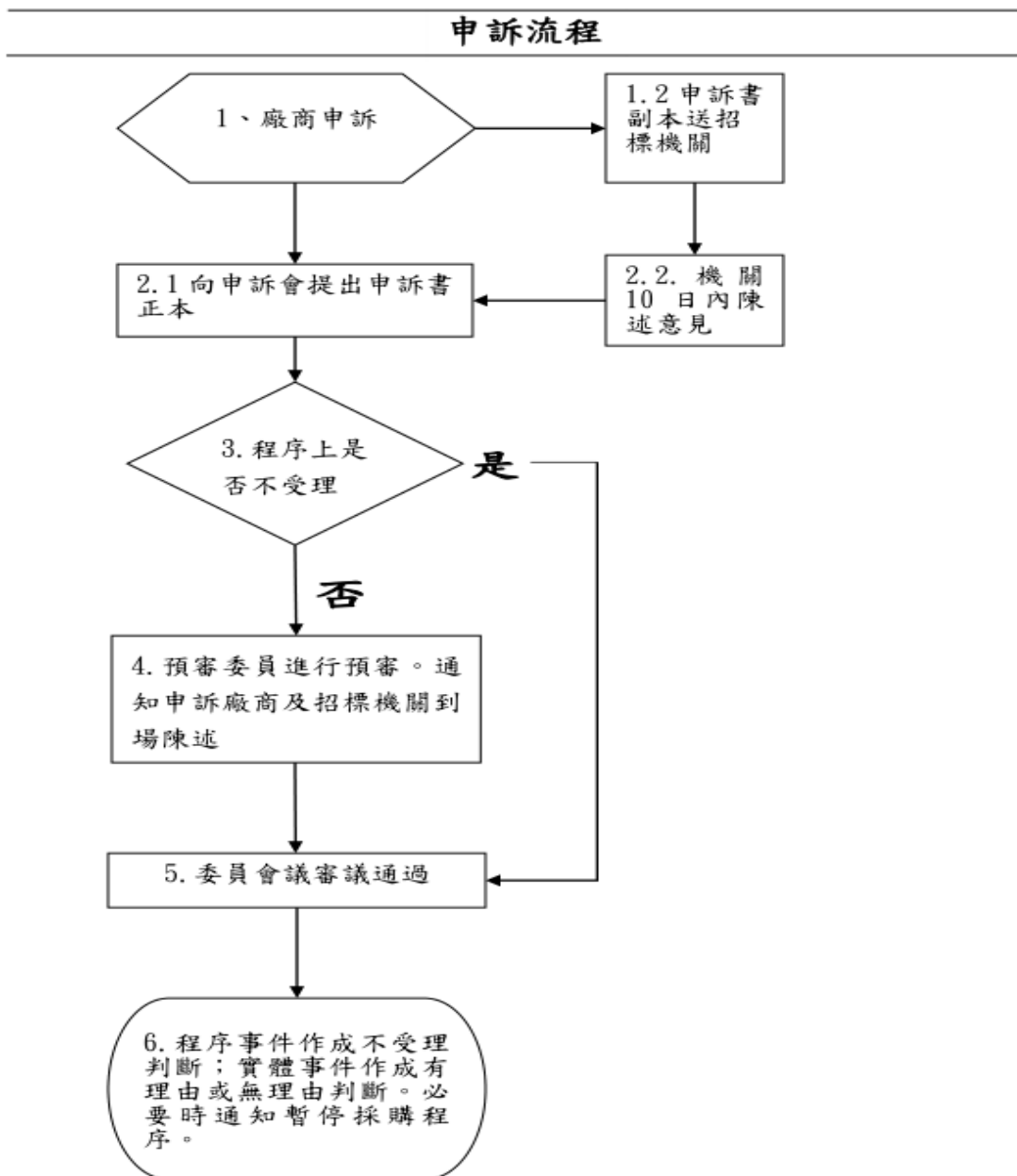


圖 7 申訴處理流程圖

資料來源：新北市政府法制局網頁－採購申訴調解

－爭議處理程序－申訴案件流程⁹⁶

[e9473ff0e3c.pdf](#) (最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。

⁹⁶ 新北市政府法制局網頁－採購申訴調解－爭議處理程序－申訴案件流程，網址：
<https://www.law.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=2838c99ae3b46b5f>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。

亦有認為政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序之規定，可說是整部政府採購法之重心所在之一。對於廠商來說，政府採購法中許多條文關於其權益之保障，都必須依據異議、申訴之程序之規定來維護。就政府採購制度之正當運作而言，讓參與廠商得以異議及申訴之方式提出救濟，實質上使得廠商協助監督政府採購程序，對於採購程序能夠公平進行具有正面性之意義⁹⁷。惟近年來，亦有不少主張認為有關政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序是否應朝向整合之提出，其理由為採購爭議有其特殊性，宜快速解決，故應將異議、申訴等爭議處理程序做一整合，取消異議制度⁹⁸，或有以一般認為廠商向招標機關提出異議，少有機關認為異議有理由，並自行撤銷或變更原處理結果⁹⁹，異議程序之存在影響廠商救濟時間，無助於爭議之解決，可考慮刪除「異議」程序，而使廠商直接進行「申訴」，增進爭議解決之效率¹⁰⁰，且對採購機關並無不利之影響，或亦有以受理處理異議提起之權責，落在兼具當事人身分之招標機關時，其處理結果未必與審議判斷具備同等公信力，而按其客觀性既有欠缺，爭議處理之機關採購承辦人員，倘不具充分專業性，異議處理結果除非利於廠商，否則顯難令廠商心服，從而申訴即成為廠商不二之選擇，造成時效延宕或進一步爭議之雙輸局面¹⁰¹，甚至有認為招標機關於受理異議後，決定廠商異議有理由不只自承違法，質言之，由機關受理異議實徒耗時間，無實質上之意義，廠商藉異議而欲獲得滿意之結果可能性微乎其微，「申訴」幾乎成為廠商必然選擇之途徑，其次，如果廠商之申訴有理由，採購申訴審議委員會做成之審議判斷須指明機關違反法令之處以及處置方式，對機關產生拘束力，故使廠商願向客觀之第三者之採購申訴審議委員會提起申訴，不僅較具實效，亦較機關之異議處理結果更亦令廠商接受¹⁰²，是以異議制度有不夠客觀及程序過於簡約之缺點¹⁰³，而有廢止異議制度之主張出現，而申訴制度基

⁹⁷ 吳庚，同前註 36，頁 35。

⁹⁸ 周瑤敏，同前註 48，頁 69。

⁹⁹ 蕭仁瑚，我國政府採購法異議申訴制度之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，2006 年，頁 63。

¹⁰⁰ 周瑤敏，同前註 98。

¹⁰¹ 陳漢瑩，政府採購法爭議處理機制之研究-以教學醫院為例，銘傳大學公共事務學系碩士在職專班碩士論文，2005 年，頁 179。

¹⁰² 陳漢瑩，同前註 101，頁 183。

¹⁰³ 胡宗鳴，政府採購救濟制度之比較研究-以招標爭議之救濟機制為重心，國立臺北大學法學系碩

於有設計採購申訴審議委員會進行審議之機制之客觀性、公正性及獨立性，且程序較為嚴謹，運作上較能發揮保障廠商權益之功效，受到實務上肯定。另有一看法為由於採購申訴審議委員會所做成之審議判斷，其性質視為訴願決定，依行政訴訟法之規定，其救濟程序尚有兩個審級，亦即向高等行政法院提起行政訴訟，不服訴訟結果再向最高行政法院提起上訴，故採購爭議之救濟已有三級三審，若加上異議程序成為四級四審，反增加時間之耗費，實無另設異議程序之必要。再者，若取消異議制度，政府採購法上尚有第 84 條之規定供招標機關進行自我監督之可能，招標機關於收受申訴時，即可自行評估其事由而為撤銷、變更或暫停採購程序等適法之處置，不一定要透過異議程序來完成¹⁰⁴，而不妨參考訴願法第 58 條規定：「訴願人應繕具訴願書經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願。原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關。原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。原行政處分機關檢卷答辯時，應將前項答辯書抄送訴願人。」，即由廠商直接繕具申訴書經由招標機關向採購申訴審議委員會提起申訴，招標機關對於廠商之申訴應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認廠商之申訴為有理由時，得自行撤銷或變更原處理結果，並陳報採購申訴審議委員會，招標機關不依廠商之申訴撤銷或變更原處理結果，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於採購申訴審議委員會，招標機關檢卷答辯時，應將答辯書抄送廠商。如此除了可以保留招標機關自行更正之機會，亦可縮短救濟程序¹⁰⁵，此一建議修法方向雖完善，但仍有見解仍肯認異議程序之性質為行政體系自省之救濟程序¹⁰⁶，在立法上是不錯之構想，招標機關有最直接之資料，作最快速、正確之判斷，如果其能自行處理，即應由其先為適法之處置，而不是所有問題都要由申訴來解決¹⁰⁷，更有認為異議程序之功能雷同訴願先行程序，訴願先行程序係在立法政策上，針對所為中較具專業性、科技性或大量集體作成之處分不服，要求人民

士論文，2003 年，頁 85。

¹⁰⁴ 蕭仁瑚，同前註 99，頁 64。

¹⁰⁵ 蕭仁瑚，同前註 104。

¹⁰⁶ 林宜興，同前註 56，頁 114。

¹⁰⁷ 周瑤敏，同前註 98。

再向原處分之上級機關提起訴願前，先向原處分機關尋求補救與改進之行政救濟制度，其目的在使行政機關更慎重進行自我省察程序，若不服原處分機關之決定，方得依訴願法提起訴願，常見之訴願先行程序如全民健保之爭議審議、集會遊行法之申復、商標法之異議，而稅法上之復查，亦屬訴願先行程序之一種，而有「加強人民權利保障、行政自我審查、減輕法院負荷」之三大優點，且目前未達公告金額(新臺幣一百萬元以下)採購案招標爭議之救濟途徑，廠商只能依據異議程序去尋求救濟，貿然刪除將有損人民權益，故主張小幅修正、提昇功能即可¹⁰⁸，頗值參考。本人以為是可參酌行政程序法 102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」，及在行政程序中給予相對人陳述意見之機會，其目的在於保障相對人之權益，以及防止行政機關之專斷，人民陳述意見權利作為行政程序基本權，只要是「人民依法申請事件」均應保障其陳述意見權利，而應賦予當事人陳述意見之機會，或許不妨可以將異議之程序定位為一特殊類型之給予當事人享有陳述意見之權利。

本人以為政府採購法設計異議及申訴之救濟途徑，係屬行政救濟途徑，主要目的在於廠商對於政府機關辦理採購(招標、審標、決標)行為之爭議，得提出異議及申訴，以主張其權益可獲得適當之確保；機關亦可藉由此一規定促使因採購所衍生之爭議得以早日解決，有利於採購事務順利推動，畢竟與司法救濟途徑，主要目的在於鑒於司法是作為最後一道守護人民權益之防線，而有所不同，且行政訴訟制度救濟上本設計有高等行政法院及最高行政法院之二個審理層級，此為司法制度設計上之使然，而強扣我國就政府機關辦理採購(招標、審標、決標)行為之爭議之權益保障，於採購爭議之救濟已有三級三審，若加上異議程序成為四級四審，反增加時間之耗費，實無另設異議程序之必要，作為廢止異議程序之理由，實無法說服大眾，反倒是，應從政府採購法設計異議之救濟途徑，對於解決採購爭議是否有所幫助來予以探討才是，而非一直琢磨於探討對於解決採購爭議是否有效，若政府採購法設計異議之救濟途徑，對於解決採購爭議仍有所幫助

¹⁰⁸ 陳漢瑩，同前註 102。

之下，縱使仍有缺點，但優點多於缺點，仍不妨讓政府採購法設計異議之救濟途徑繼續存在，即政府採購法設計異議之救濟途徑仍有存在之必要性，且由於政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序之規定，實施已久，倘有發生窒礙難行之地點，即有針對政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序之規定修正草案之提出，惟近年來並見政府採購法之主管機關行政院公共工程委員會或立法院就政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序之規定提出任何修正之建議，大多屬於學者專家提出之修正建議，尚未落實於修正草案之提出，是可推論出政府採購實務運作上對於政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序仍多泰半持肯認及支持之態度。

既然政府採購實務運作上對於政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序仍多泰半持肯認及支持之態度，有些學者專家仍堅持異議制度對於爭議解決顯無助益，而需思考應否存廢之論點，包括但不限於有認為應參照訴願法第 58 條規定：「訴願人應繕具訴願書經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願。原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關。原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。原行政處分機關檢卷答辯時，應將前項答辯書抄送訴願人。」，由廠商應繕具書狀經由招標機關向採購申訴審議委員會提起救濟。招標機關對於廠商提起之權利救濟應先行重新審查是否合法妥當，其認廠商提起之權利救濟為有理由者，得自行撤銷或變更原政府採購爭議事項之內容，並陳報採購申訴審議委員會。招標機關不依廠商之請求撤銷或變更原政府採購爭議事項之內容，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於採購申訴審議委員會。招標機關檢卷答辯時，應將前項答辯書抄送廠商，如此除得給予機關更正之機會外，又可縮短爭議處理之時程¹⁰⁹等，喋喋爭議不休，於此，本人以為不妨讓政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序仍同時存在，而讓廠商擁有程序之處分權、程序之選擇權，得選擇循序漸進經由提起異議後，招標機關不接受廠商之提起異議之理由後，再行提起申訴，或者得直接逕行向採購申訴審議委員會提起申訴，以資救濟，此為

¹⁰⁹ 朗世瑀，同前註 91，頁 136。

本人提出本人獨特奇想之見解，此見解可能並未有任何人提出，但應值得省思。本人以為甚至得於透過修法方式，於政府採購法第 76 條規定(申訴之提起)增訂「廠商得不經向招標機關提出異議，直接提起申訴，並適用提起申訴之規定」之相關文字，亦即政府採購法第 76 條之規定得修改為「廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣(市)政府所設之採購申訴審議委員會申訴。地方政府未設採購申訴審議委員會者，得委請中央主管機關處理。廠商得不經向招標機關提出異議，直接提起申訴，適用第一項之規定。廠商誤向該管採購申訴審議委員會以外之機關申訴者，以該機關收受之日，視為提起申訴之日。第三項收受申訴書之機關應於收受之次日起三日內將申訴書移送於該管採購申訴審議委員會，並通知申訴廠商。爭議屬第三十一條規定不予發還或追繳押標金者，不受第一項公告金額以上之限制。」，即可有效解決有關採購異議制度是否存廢之爭論不休，不失為一良善之解決方法。

又基於政府採購法第 76 條之規定，僅限於廠商對於公告金額以上(含)之採購案件，提起採購異議，廠商對於採購異議之處理結果不服，才可提起採購申訴，造成公告金額以下之採購案件無法尋求以採購申訴制度予以救濟，進而肇致無法尋求之後提起行政訴訟救濟之機會，容有觸及是否侵犯憲法第 16 條規定之訴訟權保障之爭議發生，揆諸政府採購法第 76 條之規定當初制定時之立法理由為「因政府採購繁多，如均得提起，採購申訴審議委員會恐難以負荷，且金額較小者已有異議程序之處理，爰參酌『政府採購協定』第一條門檻金額之規定，明定須公告金額以上之採購始得提出申訴，俾使廠商權益保護與相關作業成本、採購效率間，能取得平衡。」，亦即行政院公共工程委員會當初立法設計時，考量基於行政作業人力量能不足及減輕作業成本，採取限制公告金額以下之採購案件提起採購申訴，尋求救濟之機會，對此，行政院公共工程委員會晚近之態度為公告金額以下之採購案件，雖然不能提出申訴，但仍得循求向上級機關反映或向政府採購稽核小組提出檢舉。亦即站在行政機關之立場，仍固守就公告金額以下之採購案件，不得提出採購申訴之主張，惟此一主張遭受諸多學者比如知名學者林家祺教授等人所批評。本人以為由於國家本係為人民而存在，政府機關係為人民服務，政府

機關不能基於行政作業之便宜行事，而剝奪掉人民提起權利救濟之最基本之訴訟權保障，是以限制公告金額以下之採購案件提起採購申訴，尋求救濟之機會，形同剝奪基本訴訟權，而有違憲之疑慮，惟一解決之途徑，即透過修法之途徑予以放寬解決。亦即於政府採購法第 76 條第 1 項規定(申訴之提起)刪除「公告金額以上」之文字，而政府採購法第 76 條第 1 項之規定得修改為「廠商對於採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣(市)政府所設之採購申訴審議委員會申訴。」，即可賦與公告金額以下之採購案件仍得提起採購申訴，進而提起行政訴訟之機會。至於配套措施為增加採購申訴審議委員會之行政作業人力配置之需求，即可滿足達到減輕作業成本之目的，方為妥適。由於政府機關或府府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案，減少遇有採購金額遇有公告金額以下之情形，故本文研究之重心著重採購金額遇有公告金額以上之情形，進行討論。

另公告金額以下之採購案件既然無法尋求以採購申訴制度予以救濟，是否得提起訴願，以資救濟，容有爭議，有認為基於憲法第 16 條規定之訴訟權保障，而建議公告金額以下之採購案件既然無法尋求以採購申訴制度予以救濟，仍得賦與直接提起訴願之救濟管道，並透過修法予以解決，亦即有認為應於政府採購法第 76 條之規定內，增訂「廠商對於未達公告金額採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依訴願法之規定提起訴願。」¹¹⁰之文字，以利廠商對於未達公告金額採購異議之處理結果不服時，有同等公平對待之救濟管道，惟行政院公共工程委員會之態度仍固持否認之見解，蓋依據訴願法第 1 條第 1 項規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」及訴願法第 77 條規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為不受理之決定：…八、對於非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願者。」，行政院公共工程委員會認為機關對於異議之處理結果，非屬行政處分，故不得提起訴願，且已賦與廠商得循求向

¹¹⁰ 李振宏，沒收與追繳押標金在政府採購行為之爭議探討，國立高雄大學法律學系研究所碩士論文，2015 年 1 月，頁 140。

上級機關反映或向政府採購稽核小組提出檢舉之權益保障機制，此有行政院公共工程委員會 94 年 8 月 11 日工程企字第 09400290420 號函釋：「主旨：所詢政府採購法第 76 條第 1 項執行疑義說明：…二、由於政府採購案件繁多，政府採購法（以下簡稱本法）第 76 條參酌 WTO『政府採購協定』第 1 條門檻金額及第 20 條廠商救濟之規定，明定須公告金額以上之採購始得提出申訴，俾使廠商權益保護與相關作業成本、採購效率間，能取得平衡。三、未達公告金額之採購，如機關未依規定期限為異議之處理，或廠商對於機關之異議處理結果，不服者，雖不能依本法提出申訴，惟仍得循其他作業機制處理（例如：向其上級機關反映，或向採購稽核小組提出檢舉）。」、行政院公共工程委員會 96 年 3 月 8 日工程企字第 09600043690 號函釋：「主旨：關於廠商對於未達公告金額採購之異議處理結果不服，該廠商是否得依訴願程序辦理疑義…說明：…三、政府採購法…第 6 章納入異議、申訴之救濟程序規定，係基於廠商於招標、審標、決標階段，與機關尚無契約關係，如循民事訴訟程序，難有可提起訴訟之訴因，為維護其權益，並為符合我國擬申請加入之 WTO 政府採購協定（GPA）之規範，而參酌該協定訂定之爭議處理機制。機關對於異議之處理結果，非屬『行政處分』…。」可稽，往後招標機關或招標機關之上級機關遇有廠商就公告金額以下採購案件之爭議提起訴願，招標機關或招標機關之上級機關所設之訴願審議委員會皆以參酌前揭訴願法之規定、政府採購法之規定及上開行政院公共工程委員會函釋，仍應遵循政府採購法等相關規定辦理，而非屬訴願審議範圍，廠商提起之訴願，揆諸訴願法之規定及上開函釋意旨，自非法之所許，廠商提起之訴願為程序不合，做出不受理之裁決，並為目前政府機關或政府機關所屬事業遇有廠商就公告金額以下之採購案件提起訴願時，以上開訴願程序不合之理由，做出不受理之裁決，本人以為行政院公共工程委員會之所以持公告金額以下之採購案件不得提起訴願之看法，在於政府採購法已明文規定公告金額以下之採購案件不得提起採購申訴，且申訴經審議之結果等同於訴願決定，若給予公告金額以下之採購案件得提起訴願救濟之，等同於造成政府採購法設置採購申訴制度暨制定採購申訴之相關規定形同虛設及空洞化，可以解釋，唯一解決藥方即透過影響最小之修法方式，鬆綁公告金額以下之採購案件無法尋求以採購申訴制度予以救濟之限制，較為妥適。惟有認為基於司法院大法官會議解釋釋字第 485 號解釋之解釋文：「憲法第七條平等原則並非

指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上地位之實質平等，立法機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之區別對待。」，政府採購法就公告金額以下之採購案件無法尋求以採購申訴制度予以救濟係基於立法院綜合各方提議之立法、修法之意見及建議，予以考量各種因素包括但不限於廠商權益維護保護、政府採購作業成本、政府採購行政效率之有效提升，而分別選擇採取不同之採購救濟途徑設計，不失為屬於可得容許之合理差別處遇之立法手段，本於立法裁量權行使所制定，仍屬於立法裁量之範疇，此為立法機關之立法裁量空間，未有違憲之疑義。在未進行修法前，公告金額以下之採購案件無法以採購申訴制度予以救濟，是否觸及侵犯憲法第 16 條規定之訴訟權保障之爭議，只能留待司法院大法官作成違憲之解釋，促請行政院公共工程委員會及立法院進行修法之動作，但為避免修法之延宕，導致違憲之狀態無限期持續，而司法院大法官應於其解釋文內更明文責令指出修法機關應於限期完成修法，始為恰當。

依據政府採購法第 1 條規定：「為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，爰制定本法。」、政府採購法第 6 條第 1 項規定：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」及政府採購法第 37 條第 1 項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」，於此，我國政府採購制度建構在公平競爭之上，目的之一在於排除不當限制競爭及不公平競爭，並創設政府採購法第六章之「爭議處理」之相關規定，給予廠商維護權益救濟之管道，誠如上述，基於政府採購契約之一方當事人為國家，另一方當事人為人民，在簽訂採購契約前之招標、決標階段，人民得對政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件之招標、決標過程有所爭議發生時，提出異議，甚至申訴，大部分情形都發生在政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件之招標時，有對招標進行公告，使人民得知政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件之投標須知等文件內容，由於該投標須知等文件內容有所疑義，人民對此提出異議，甚至申訴，或者由於決標結果有所疑義，人民對此提出異議，甚至申訴，除此之外，人民比較不會對政府機關或政府機關所

屬事業辦理簽訂採購契約前之招標、決標階段其他過程提出異議，甚至申訴，就雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司而言，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司遇不服勞務採購案件投標須知等文件內容，也常提出異議及申訴。茲就雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司遇不服勞務採購案件投標須知等文件內容，提出異議及申訴之採購異議書及採購申訴書之內容，如下：

表 18 採購異議書

採購異議書

標的名稱：年度兩分院醫療作業程序感染性廢棄物(遭汙染物品或器具類 C-0514、廢尖銳器具 C-0504)清除及處理採購案號：M105103)

招標方式：公告金額以上未達查核金額之採購

金 額：新台幣 1,460,160 元

異議廠商：

設

法定代理人：

住

招標機關：

設



為不服 貴院年度兩分院醫療作業程序感染性廢棄物(遭汙染物品或器具類 C-0514、廢尖銳器具 C-0504)清除及處理，本件採購標的名稱、臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院規格審查表(以下稱規格審查表)及廠商資格證件審查表之內容，爰於法定期限內，依政府採購法第七十五條規定，提出異議如下：

請 求

取消本次採購招標，重新招標。

事實及理由

一、首按本件採購標的名稱：「106-107 年度兩分院醫療作業程序感染性廢棄物(遭汙染物品或器具類 C-0514、廢尖銳器具 C-0504)清除及處理」。次按本件規格審查表規定：「投標廠商應檢附衛福部醫療廢棄物再利用許可證(遭汙染物品或器具類 C-0514 及廢尖銳器具 C-0504)及主管機關核可之甲級廢棄物清除許可證。(若投標

廠商非自營者請檢附配合廠商（清除或處理商）之配合承諾書（或合約）及其核可許可證」。復按本件廠商資格證件審查表規定：「廠商應檢附衛福部醫療廢棄物再利用許可證（遭汙染物品或器具類 C-0514 及廢尖銳器具 C-0504）及主管機關核可之甲級廢棄物清除許可證。（若投標廠商非自營者請檢附配合廠商（清除或處理商）之配合承諾書（或合約）及其核可許可證）」。據此，貴院對於貴院生物醫療廢棄物之處理採取分別辦理本件生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504 及 C-0514）之清除及處理標案與生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0513 及 C-0599）之清除及處理標案，且就本件生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504 及 C-0514）之處理採取再利用處理方式，本案投標廠商之特定資格之一，以取得衛福部醫療廢棄物再利用許可證（遭汙染物品或器具類 C-0514 及廢尖銳器具 C-0504）之處理機構同意下，領有甲級廢棄物清除許可證之清除機構，或領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證（遭汙染物品或器具類 C-0514 及廢尖銳器具 C-0504）之處理機構，先予敘明。

二、再按「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。……」、「機關不得意圖規避本法之適用，分批辦理公告金額以上之採購。其有分批辦理之必要，並經上級機關核准者，應依其總金額核計採購金額，分別按公告金額或查核金額以上之規定辦理。」、「本法第十四條所定意圖規避本法適用之分批，不包括依不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目所分別辦理者。機關分批辦理公告金額以上之採購，法定預算書已標示分批辦理者，得免報經上級機關核准。」政府採購法第六條規定、同法第十四條規定及政府採購法施行細則第十三條規定分別定有明文。且按「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」（差別處遇原則）、「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」（行政程序對當事人有利及不利之情形），行政程序法第六條規定及同法第九條規定分別定有明文。

三、再按貴院產出之生物醫療廢棄物包括廢棄物代碼C-0504、C-0513、C-0514及C-0599等種類，上開四種類代碼之生物醫療廢棄物皆可委由領有甲級廢棄物處理許可證（焚化處理方式）之處理機構處理，而其中代碼C-0504及C-0514可委由領有甲級廢棄物處理許可證（焚化處理方式）之處理機構處理或領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證（再利用處理方式）之處理機構處理，且上開四種類代碼之生物醫療廢棄物由貴院一起、同時、同一地點產出，同屬同一標的，並無分批辦理本件生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504及C-0514）之清除及處理標案與生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0513及C-0599）之清除及處理標案之必要，貴院分批先後辦理二標案不無意圖規避政府採購法適用之嫌，先行辦理本件生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504及C-0514）之清除及處理標案，並限制採取再利用處理方式，國內領有甲級廢棄物處理許可證（焚化處理方式）之處理機構則有10

家，國內領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證（再利用處理方式）之處理機構僅有5家，不無顯有圖利該領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證（再利用處理方式）之處理機構之嫌，亦即若 貴院就生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504及C-0514）之處理仍堅持採取再利用處理方式，本案投標廠商之特定資格之一，以取得衛福部醫療廢棄物再利用許可證之處理機構同意下，領有甲級廢棄物清除許可證之清除機構，或領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證之處理機構，已如上述， 貴院就 貴院產出之生物醫療廢棄物得採取一次辦理聯合承攬清除及處理標案方式即可，其中廢棄物代碼C-0513及C-0599委由領有甲級廢棄物處理許可證（焚化處理方式）之處理機構處理；廢棄物代碼C-0504及C-0514委由領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證之處理機構處理；委由同一甲級廢棄物清除許可證之清除機構清除即可， 貴院生物醫療廢棄物危害環境安全無需堪慮，並分別簽訂廢棄物委託處理契約或廢棄物委託清除契約，並須將前開二契約妥善保存供各自環保主管機關備查，使環保主管機關得以追蹤監廢棄物清運處理過程及流向，以免危害環境安全。

四、未按廢棄物清理法第30條規定：「事業委託公民營廢棄物清除處理機構清除、處理其事業廢棄物，未符合下列條件者，應與受託人就該事業廢棄物之清理及環境之改善，負連帶責任：一、依法委託經主管機關許可清除、處理該類事業廢棄物之公民營廢棄物清除處理機構或執行機關清除、處理，且其委託種類未逾主管機關許可內容。二、取得受託人開具之該事業廢棄物妥善處理紀錄文件。」，若 貴院就 貴院產出之生物醫療廢棄物得採取一次辦理聯合承攬清除及處理標案方式，當發生 貴院產出之生物醫療廢棄物無法妥善處理，領有甲級廢棄物處理許可證（焚化處理方式）之處理機構應負連帶責任，較能保障 貴院之權益，若 貴院就 貴院產出之生物醫療廢棄物先行辦理本件生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504及C-0514）之清除及處理標案，並限制採取再利用處理方式，當發生 貴院產出之生物醫療廢棄物無法妥善處理，該領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證之處理機構不須負連帶責任，未較能保障 貴院之權益。且 貴院就 貴院產出之生物醫療廢棄物採取一次辦理聯合承攬清除及處理標案方式，因 貴院提供之生物醫療廢棄物重量較大，故參與 貴院生物醫療廢棄物採購案之生物醫療廢棄物之清除及處理機構家數更多，透過彼此競爭， 貴院清除處理 貴院產出之生物醫療廢棄物成本相對降低，更能維護 貴院權益。

五、未，貴院強求對於生物醫療廢棄物之清除及處理採取分批辦理標案，本案生物醫療廢棄物（廢棄物代碼：C-0504及C-0514）之處理採取再利用處理方式，本案投標廠商之特定資格之一，以取得衛福部醫療廢棄物再利用許可證之處理機構同意下，領有甲級廢棄物清除許可證之清除機構，或領有衛福部醫療廢棄物再利用許可證之處理機構之不當投標資格限制之內容，要難令本案投標廠商信服；要難謂非以「不當限制競爭」限制本案投標廠商之家數，顯有圖利特定投標廠商之嫌，有違上揭政府採購法及行政程序法規定。

六、綜上所述，本件採購標名稱、規格審查表及廠商資格證件審查表之內容實有疑義，未符合上揭政府採購法規定意旨，為此，爰依政府採購法第七十五條規定提出異議。

謹 呈

公鑒

異議廠商：

法定代理人：

中 華 民 國 年 月 日

資料來源：作者自行製表

表 19 採購申訴書

申訴書

標的名稱：化學性廢棄物委託清除處理勞務委外二年採購(採購案號：)

招標方式：公開招標

金 額：

申訴廠商：

設

法定代理人：

住

招標機關：

設

申訴廠商因招標機關辦理「採購案號『化學性廢棄物委託清除處理勞務委外二年採購』」案件，不服招標機關民國年月日之異議處理結果，爰於法定期限申訴如下：

請求

原異議處理結果撤銷。

事實及理由

一、本標案業於民國(以下同) 年月日公告，並於年月日開標。

二、招標機關認定得標廠商(以下簡稱公司)共同投標廠商資格符合規定，顯有



違誤。

三、經申訴廠商於 年月日向招標機關提出異議(申證一、二)，招標機關於 109 年 4 月 6 日函復，略以申訴廠商所異議事項為無理由(申證三)，申訴廠商爰於法定期限內提出申訴。

理由

- 一、首按「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。」、「機關訂定前條投標廠商之資格，不得當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。投標廠商未符合前條所定資格者，其投標不予受理。…」、「投標廠商有下列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商：一未依招標文件之規定投標。……決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。…」，政府採購法第 36 條第 1 項、第 37 條、第 50 條分別定有明文，先予敘明。
- 二、次按招標機關「-投標須知範本」第 18 條規定：「本採購：■(1) 依採購法第 25 條規定允許廠商共同投標(招標文件已附共同投標協議書範本)；廠商家數上限為□2 家；■3 家；□4 家；□5 家。□(2) 不允許廠商共同投標。」(申訴四)。此亦為招標機關民國年月日來函所引據之本案投標須知第 18 條訂有允許廠商共同投標之規定，招標機關確認得標廠商共同投標廠商資格符合規定之規範內容(同申訴三)，惟按上開條款僅為規範允許共同投標廠商家數上限之規定，並未規範到本案投(得)標廠商之資格，而應綜觀本案其他其他招標文件內容對本件投(得)標廠商資格之要求才是，招標機關逕引據上開條文認定得標廠商共同投標廠商資格符合規定之規範內容，顯屬違誤。
- 三、復按招標機關「公開招標公告之廠商資格摘要」-3.、4. 規定：「3. 甲級廢棄物處理許可證或甲級廢棄物清理許可證或經濟部輔導設置之事業廢棄物清除處理設施(需有核准營運文件資料)，如屬甲級廢棄物處理許可證之廠商請併提供與清除商間之配合合約。4. 廠商其許可處理廢棄物種類代碼必須包含 C-0149、C-0301……」(申訴五)。且招標機關「-投標須知範本」第六十四條(投標廠商之基本資格及應附具之證明如下)規定：「……■甲級廢棄物處理許可證或甲級廢棄物清理許可證或經濟部輔導設置之事業廢棄物清除處理設施(需有核准營運文件資料)，如屬甲級廢棄物處理許可證之廠商請併提供與清除商間之配合合約。■廠商其許可處理廢棄物種類代碼必須包含 C-0149、C-0301……」(申訴六)。據此，此二條款才係本案其他其他招標文件內容對本件投(得)標廠商資格之要求，且招標機關就本案投(得)標廠商應為屬於領有甲級廢棄物處理許可證之處理廠商或領有甲級廢棄物清理許可證之清理廠商及經濟部輔

導設置之事業廢棄物清除處理設施(需有核准營運文件資料)，並不包括領有甲級廢棄物清除許可證之清除廠商。

四、已如申訴廠商採購異議書所述，經查本案得標廠商為領有甲級物清除許可證之清除廠商，並不屬於領有甲級廢棄物處理許可證之處理廠商或領有甲級廢棄物清理許可證之清理廠商及經濟部輔導設置之事業廢棄物清除處理設施(需有核准營運文件資料)，本不具備投標廠商之資格，卻仍參與投標招標機關本案招標案件，進而得標，核不符合招標機關「公開招標公告之廠商資格摘要」-3.、4.規定及招標機關「-投標須知範本」第六十四條(投標廠商之基本資格及應附具之證明如下)規定之要求，本案得標廠商不得參與投標本件採購案件，其得標為無效，依上揭政府採購法規定，應不決標予本案得標廠商，招標機關辦理本件採購案件之招標程序違反上揭政府採購法規定，至為明顯。

五、綜上所陳，申訴廠商認為招標機關認定得標廠商共同投標廠商資格符合規定，已經損及其他投標廠商之權益，因此申訴廠商對此提出申訴，敬請 貴會審議，判定如請求事項。

證據名稱及件數

申證一：申訴廠商公司執照(或營利事業登記證)及負責人身份證影本各乙份。

申證二：申訴廠商民國年月日採購異議書影本乙份。

申證三：招標機關民國年月日字北總補字第 號函影本乙份。

申證四：招標機關-投標須知範本第18條規定影本乙份。

申證五：招標機關公開招標公告之廠商資格摘要-3.、4.規定影本乙份。

申證六：招標機關-投標須知範本第六十四條(投標廠商之基本資格及應附具之證明如下)規定影本乙份。

謹 呈

行政院公共工程委員採購申訴審議委員會 公鑒

申訴廠商：

法定代理人：

中 華 民 國 年 月 日

資料來源：作者自行製表

揆諸雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司遇不服勞務採購案件投標須知等文件內容，提出異議及申訴之採購異議書及採購申訴書之內容，不無的確係以投標須知內設定之投標廠商資格內容有所資格限制競爭，而據以表示不服，此亦為其他生物醫療廢棄物處理業者有意參與政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案絕大部分面臨之政府採購錯誤行為當中重中之重之行為態樣，誠如上述，而提出異議及申訴程序，以維權益，提起異議經招標機關審查之結果有包括異議不受理、撤銷原處理結果—認定廠商提起之異議為有理由及異議駁回—認定異議為無理由等情形，提起申訴經採購申訴審議委員會審議之結果有包括申訴不受理、撤銷原異議處理結果—認定廠商提起之申訴為有理由及申訴駁回—認定招標機關原異議處理結果適法，申訴為無理由等情形，而尋求進行採購申訴途徑救濟不符合期待時，即申訴遭駁回時，基於採購申訴審議委員會對於申訴之審議判斷，視同訴願決定，且依據採購申訴審議規則第 22 條第 1 項規定：「審議判斷書應附記如不服審議判斷，得於審議判斷書送達之次日起二個月內，向行政法院提起行政訴訟。」，採購申訴審議委員會於審議判斷書內有應提醒廠商不服審議判斷之結果時，得提起行政訴訟，以資權益救濟之記載義務，是以生物醫療廢棄物處理業者進而得向各地方高等行政法院提起行政訴訟之撤銷訴訟，若對於各地方高等行政法院之判決結果有所不服時，得向最高行政法院提起訴訟。以晚近最高行政法院 110 年度上字第 28 號判決為例，涉及內政部營建署辦理「經濟部南港展覽館新建工程」採購案件，得標廠商得標該採購標案，嗣經內政部營建署得知該得標廠商涉及有影響採購公正之違反法令行為，追繳得標廠商給付之押標金，經得標廠商提出異議，經內政部營建署認定異議處理結果維持原決定，得標廠商仍表不服，向行政院公共工程委員會申訴，經審議判斷駁回，遂提起行政訴訟，訴請撤銷原處分、異議處理結果及申訴審議判斷。案經原審法院以 99 年度訴字第 1422 號判決駁回得標廠商之訴。得標廠商仍不服，提起上訴，經最高行政法院 100 年度判字第 1985 號判決(最高行政法院第 1 次發回判決)，將原判決廢棄，發回原審法院更為審理，經原審法院 100 年度訴更一字第 227 號判決駁回。得標廠商仍不服，再提起上訴，經最高行政法院 101 年度判字第 839 號判決(最高行政法院第 2 次發回判決)，將原判決廢棄，發回原審法院更為審理，嗣經原審法院以 101 年度訴更二字第 137 號判決駁回其訴後，提起本件上訴。最後經最高行

政法院審理結果，內政部營建署作成原處分，有所違誤，原判決疏未依職權釐清，遽予維持申訴審議判斷、異議處理結果及原處分，即有不合，已可自為判決，做出「原判決廢棄。申訴審議判斷、異議處理結果及原處分均撤銷。第一審及上訴審訴訟費用均由內政部營建署負擔。」之判決結果。雖然最高行政法院 110 年度上字第 28 號判決之個案判決情形與生物醫療廢棄物處理業者以政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案之投標須知內設定之投標廠商資格內容有所資格限制競爭，而據以表示不服之情形，有所差異，但尋求救濟之途徑皆相同，為提起異議、申訴及行政訴訟，且本人以司法院「法學資料檢索系統」輸入關鍵字「勞務採購」連同「廠商資格」、「申訴」一併同時輸入檢索，得出最高行政法院對於招標機關辦理勞務採購案件之廠商資格爭議發生有所不服，同樣得循序漸進提起異議、申訴及行政訴訟予以救濟，最後走到至最高行法院進行審理之相關判決，共 19 筆，亦持相同之看法，故最高行政法院 110 年度上字第 28 號判決有關救濟途徑之提起過程可做為通案最佳之參考，殊值可參。

另觀諸臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1173 號判決，涉及行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院辦理「台北榮民總醫院及受委託經營台北市立關渡醫院生物醫療廢棄物委託代清除處理」採購案件，並決標予博宇電漿科技股份有限公司，水美工程企業股份有限公司亦參與該次投標，不服決標結果，提出異議，經行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院通知異議處理結果為維持原決標，水美工程企業股份有限公司遂向行政院公共工程委員會提起申訴，經行政院公共工程委員會以博宇電漿科技股份有限公司所提送之投標文件內容確實不符招標文件工作規範說明書之規定，且博宇電漿科技股份有限公司亦屬未依招標文件之規定投標，乃為撤銷原異議處理結果。博宇電漿科技股份有限公司不服，遂提起本件行政訴訟。歷經臺北高等行政法院認定博宇電漿科技股份有限公司所提送之投標文件內容確實不符招標文件工作規範說明書之規定，且博宇電漿科技股份有限公司亦屬未依招標文件之規定投標，行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院不察，決標予博宇電漿科技股份有限公司，尚有未妥，原異議處理結果為相同處理，於法亦有未合，行政院公共工程委員會於受理申訴程序中獲悉上情，撤銷行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院之異議處理結果，於法無違，應予維持。博宇電漿科技股份有限公司訴請撤銷申訴審議判

斷，為無理由，應予駁回。此判決即有涉及政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案發生得標之生物醫療廢棄物處理業者是否符合該標案所要求之投標廠商資格內容爭議，未得標之生物醫療廢棄物處理業者據以主張得標之生物醫療廢棄物處理業者之處理生物醫療廢棄物方式，不符合該標案投標廠商資格要求之處理方式，因此不具有投標廠商之資格，而提起不服之主張，可見有關投標廠商資格之擬定、認定及要求於政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購標案時係屬重要，也常因此動輒得咎發生爭議及糾紛，生物醫療廢棄物處理業者尋求救濟之管道即為行政救濟途徑之提起異議、申訴及司法救濟途徑之行政訴訟。

承上，藉由最高行政法院 110 年度上字第 28 號判決、臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1173 號判決，得看出政府採購實務上堆疊出對於政府採購前階段關於招標、審標、決標之爭議包括但不限於本文探討之重心之一，即投標廠商資格爭議採取爭議救濟途徑之具體步驟，包括但不限於在行政訴訟上之訴訟種類之選擇應提起撤銷訴訟等，當廠商有意參與政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件，遇有政府採購爭議時，有效提供廠商能從容不迫地勇於面對，提起權益維護之最佳參考方案，使權益得獲得確保。

第二款 外國政府採購爭議救濟途徑

壹、德國營業競爭限制防止法立法過程

德國「營業競爭限制防止法」，又稱卡特爾法，制定於 1957 年，並於 1958 年 1 月 1 日生效至今，是規範德國市場經濟秩序最重要之一部法律，歷年經過多次修訂。其中以 1998 年 8 月修訂，並於 1999 年 1 月 1 日實施之內容，稱之為第六次修正內容，其目的在於調和德國法與歐盟法之差距，強化自由競爭之原則，以及改進營業競爭限制防止法之立法技術，而最大之變化則是引進有關公務發包（或稱政府採購）（Vergaberecht）之相關法律規定，而聯邦卡特爾署就其主管事務也因此由對限制競爭行為之管制，擴張至公務發包之審核¹¹¹。

¹¹¹ 競爭法與能源法，德國營業競爭限制防止法—第六次修正，網址：
<https://www.angile.com.tw/File/Try/5D172RA-3.pdf>（最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日）。

德國「營業競爭限制防止法」就公務發包之規範規定於第四章，自第 97 條至第 129 條，包括發包之審議、決定、異議和損害賠償程序。第 7 次修法，主要原因係在回應及配合歐洲聯盟競爭法之發展，以使德國法與歐盟法取得統一，增進競爭法適用之一致性，避免產生複雜甚至不利德國事業之情形；同時也修改數項規定，以完善德國之競爭法制。

德國「政府採購規則」涵蓋德國「營業競爭限制防止法」之一般規定及有許多詳細之規定，並將許多法律規章合併彙整，也就是德國之政府採購法規有更清楚明確之法律架構。且適用於超過歐洲聯盟規定門檻值之政府採購。德國「政府採購規則」係德國「營業競爭限制防止法」第四章政府採購之具體規定，自 2016 年 4 月起取代原有之德國「建築招標與契約條例」之第二部分規定、德國「貨物及服務招標與契約條例」之第二部分規定及「自由職業服務招標條例」之部分規定，德國「政府採購規則」之內容包含七章，即（1）一般規定與公告之概括規定，特別是電子公告；（2）採購招標程序，包括挑選程序類型之許可條件、個別程序類型之流程、廠商資格與其他要求、新之單一歐洲自我聲明(EEE)之法律架構、招標提出、形式與處理規定、參與申請、有興趣參與公告及確認、招標審查與金額等規定；（3）德國「政府採購規則」並特別規定採購社會與其他特別之勞務、長期架構協議之簡化規定、決標標準與最低期限；（4）轉換歐洲聯盟公用事業採購指令，德國「政府採購規則」對於採購耗能相關之勞務與道路車輛有特別之規定；（5）施行規劃競爭之基本規定，且不限於在工程規劃之領域；（6）應特別考慮建築師與工程師勞務採購之特性，特別是應進行參與競爭之協商程序與競爭對話作為一般之程序，應考慮工程規劃競爭之特性；（7）最後係過渡條款與最終條款，政府採購機關應採用電子方式公告與提供投標文件¹¹²。

隨著應適用歐洲聯盟之政府採購指令門檻值之改革，德國亦改革低於門檻值適用德國政府採購法之法規，2017 年 2 月公布「低於門檻值之採購規定」，並於 2017 年 9 月生效，取代原有之德國「建築招標與契約條例」之第一部分規定、德國「貨物及服務招標與契約條例」之第一部分規定及「自由職業服務招標條例」

¹¹² 財團法人中技社，政府採購法修訂與落實之研討，專題報告 2020-5，頁 28，網址：
<https://www.ctci.org.tw/media/8711/2020-05-政府採購法修訂與落實之研討.pdf>（最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日）。

之部分規定，2017 年 9 月日修訂聯邦預算法第 55 條規定，「低於門檻值之採購規定」亦適用於聯邦層級之採購，各邦亦隨著「低於門檻值之採購規定」調整其預算法規，德國並公布一個適用低於門檻值之「商品供應與勞務政府採購程序法」，也就是低於門檻值之政府採購仍適用預算法，即應適用聯邦預算法與各邦之預算法或邦採購法¹¹³。

貳、德國營業競爭限制防止法與我國政府採購法之比較

德國政府採購法制上並無一部統一之政府採購法規範，而是散見於各個相關政府採購規範內，而就我國而言，我國有一部統一之政府採購法規範，且以我國而言，相較於德國營業競爭限制防止法，我國有制定公平交易法，相較於德國聯邦卡特爾署作為審查機關，我國係以公平交易委員會作為主管機關，而就德國營業競爭限制防止法之公務發包（或稱政府採購），我國另有專法予以規範，規範在我國政府採購法內，並由行政院公共工程委員會作為主管機關。

德國營業競爭限制防止法之公務發包（或稱政府採購），有就德國政府採購爭議救濟途徑予以規範，主要制度設計為再審查程序，並區分由聯邦(中央)、邦(地方)設置招標複審會予以受理及審查，德國政府採購爭議救濟途徑之開啟，申請人為對於申請具有利益之事業，且其主張其依德國營業競爭限制防止法第 97 條第 7 項之權利因招標人不遵守招標規定而受侵害，事業對於招標複審會之決定有所不服，得向專屬於對於招標複審會登記所在地有關轄權之高等邦法院提起立即抗告，由高等邦法院進行裁判，高等邦法院應有設置招標法庭，相當於在我國廠商不服提起採購申訴之申訴決定，而向高等行政法院提起撤銷訴訟，是以德國政府採購爭議救濟途徑與我國政府採購爭議救濟途徑具有相同之地方，即皆有前階段之行政救濟管道及後階段之司法救濟管道，然而就前階段之行政救濟管道而言，德國政府採購爭議救濟途徑與我國政府採購爭議救濟途徑，尤以採購申訴、採購申訴之制度設計，有所不同，德國僅設計再審查程序之一階段程序，我國設計採取採購異議制度及採購申訴制度之二階段程度，最後皆走到司法救濟管道，尋求救濟，各有優點及缺點，但德國就政府採購爭議救濟途徑之制度設計仍值得我國效法，擇優採納，作為未來修法之參考，為瞭解德國政府採購爭議救濟途徑，必須從瞭

¹¹³ 財團法人中技社，同前註 112，頁 27。

解德國業競爭限制防止法之公務發包（或稱政府採購）整個規範內容予以出發，引據德國限制競爭防止法 2015 年最新翻譯（國立成功大學法律學系林易典副教授譯），第 4 部分公共採購之招標翻譯內容¹¹⁴，並與我國政府採購法之規定做比較，如下：

一、一般原則

德國採購機關、廠商就採購程序過程中有所依循、得主張之基本原則，不外乎包括競爭原則、透明原則、平等原則（參照德國限制競爭防止法第 97 條規定）。就我國而言，我國政府採購法第 6 條規定：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。司法、監察或其他機關對於採購機關或人員之調查、起訴、審判、彈劾或糾舉等，得洽請主管機關協助、鑑定或提供專業意見。」，其目的亦係為使廠商公平競爭為出發點，禁止不當之限制競爭。

二、招標人

德國就採購主體之類型及限制作定義，屬於較精確之規定方式（參照德國限制競爭防止法德國第 98 條規定）。就我國而言，我國政府採購法第 3 條規定：「政府機關、公立學校、公營事業（以下簡稱機關）辦理採購，依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。」，亦即我國係以較概括之方式就採購主體作定義。

三、公共採購

德國就採購客體之類型及限制作定義，屬於較精確之規定方式（參照德國限制競爭防止法第 99 條規定）。就我國而言，我國政府採購法第 2 條規定：「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。」，政府採購法第 7 條規定：「本法所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。本法所稱財物，

¹¹⁴ 林易典副教授，德國限制競爭防止法 2015 年最新翻譯，德國限制競爭防止法，網址：
<https://www.ftc.gov.tw/upload/6488ee19-7b9a-4caf-b78a-f41ed39Da5af5>（最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日）。

指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。」，亦即我國係以較概括之方式就採購客體作定義。

四、適用領域

德國就適用第 4 部分公共採購之適用對象作定義，即該法之適用僅限於已達成或超出門檻價額之採購案件(參照德國限制競爭防止法第 100 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並未有類似規定，亦即無論採購金額之大小，原則上皆有我國政府採購法之適用空間。

五、就非特定產業與非國防或安全性關聯之採購的特殊例外

德國特有之規定(參照德國限制競爭防止法第 100a 條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 105 條規定：「機關辦理下列採購，得不適用本法招標、決標之規定。一、國家遇有戰爭、天然災害、瘟疫或財政經濟上有重大變故，需緊急處置之採購事項。二、人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項。三、公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者。四、依條約或協定向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購，其招標、決標另有特別規定者。前項之採購，有另定處理辦法予以規範之必要者，其辦法由主管機關定之。」，也有就排除適用政府採購法之情形予以規範。

六、產業領域之特別例外

德國特有之規定(參照德國限制競爭防止法第 100 b 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並未有排除特定產業適用我國政府採購法之類似規定。

七、於國防或安全領域之特別例外

德國特有之規定（參照德國限制競爭防止法第 100 c 條規定）。就我國而言，我國政府採購法第 104 條規定：「軍事機關之採購，應依本法之規定辦理。但武器、彈藥、作戰物資或與國家安全或國防目的有關之採購，而有下列情形者，不在此限。一、因應國家面臨戰爭、戰備動員或發生戰爭者，得不適用本法之規定。二、機密或極機密之採購，得不適用第二十七條、第四十五條及第六十一條之規定。三、確因時效緊急，有危及重大戰備任務之虞者，得不適用第二十六條、第

二十八條及第三十六條之規定。四、以議價方式辦理之採購，得不適用第二十六條第三項本文之規定。前項採購之適用範圍及其處理辦法，由主管機關會同國防部定之，並送立法院審議。」，也有就軍事機關之採購予以原則適用政府採購法之規定，例外得不採用政府採購法之規定。

八、招標之種類

德國就招標之類型作定義，包括公開程序、不公開程序、協商程序、以競爭對話之方式。而採購程序部份，以德國政府採購種類原本分為公開招標、不公開招標及協商招標三種，自 2006 年起則多增加了競爭招標。為了達到公平競爭之原則，公開招標為採購程序之優先選擇，其次為不公開招標，最後為協商招標。所謂公開招標就是只要符合招標要求之歐洲聯盟公司皆可參加投標，沒有參與投標公司數量限制，越多公司參與投標越好。不公開招標必須要發標之機關指定之公司才能參與投標。協商招標則是要招標之機關直接跟公司取得聯繫並要求其投標，這種方式最不符合市場自由競爭原則，所以只能用於特殊狀況，例如當時間很緊急時，或是牽涉到專利問題等等。自 2006 年才增加之競爭招標為結合市場自由競爭和高度機動性之一種招標方式，適用於複雜之標案，首先招標者邀請適合廠商參加會談，在會談中協商標案之細節，會談之後請參加之廠商投標。不過這種投標方式之爭議還很多，不是很普遍之方式（參照德國限制競爭防止法第 101 條規定）。就我國而言，我國政府購法第 18 條規定：「採購之招標方式，分為公開招標、選擇性招標及限制性招標。本法所稱公開招標，指以公告方式邀請不特定廠商投標。本法所稱選擇性招標，指以公告方式預先依一定資格條件辦理廠商資格審查後，再行邀請符合資格之廠商投標。本法所稱限制性招標，指不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請一家廠商議價。」，亦即我國就招標之類型包括公開招標、選擇性招標及限制性招標。並於我國政府採購法第 19 條之規定起至第 22 條之規定止，有就公開招標、選擇性招標及限制性招標作定義性之規定。我國之公開招標與德國之公開招標類似。我國之選擇性招標與德國之不公開招標類似。我國之限制性招標為我國所獨有，德國未有類似設計。德國之協商招標及競爭招標為德國所獨有，我國未有類似設計。

九、資訊義務與等待義務

德國就招標過程提供資訊義務與等待義務之規定（參照德國限制競爭防止法第 101a 條規定）。就我國而言，我國政府採購法第 11 條規定：「主管機關應設立採購資訊中心，統一蒐集共通性商情及同等品分類之資訊，並建立工程價格資料庫，以供各機關採購預算編列及底價訂定之參考。除應秘密之部分外，應無償提供廠商。機關辦理工程採購之預算金額達一定金額以上者，應於決標後將得標廠商之單價資料傳輸至前項工程價格資料庫。前項一定金額、傳輸資料內容、格式、傳輸方式及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。財物及勞務項目有建立價格資料庫之必要者，得準用前二項規定。」，也有規範行政院公共工程委員會提供資訊義務與等待義務。

十、不生效力

德國就招標所簽訂契約發生不生效力之情形予以規範（參照德國限制競爭防止法第 101b 條規定）。就我國而言，我國政府採購法並未有類似規定。

十一、原則

德國就採購之招標之制度設計一再審查程序。聯邦（中央）、邦（地方）所設置招標複審會（聯邦卡特爾署內、邦自行決定）加以審查（參照德國限制競爭防止法第 102 條規定），包括受理政府採購爭議之審議。就我國而言，我國政府採購法第 74 條規定：「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。」，我國就採購發生爭議時，得提起異議及申訴。

十二、招標複審會

德國就採購之主辦單位有區分成聯邦(中央)主辦及邦(地方)主辦而分別於聯邦(中央)、邦(地方)設置招標複審會加以審查(參照德國限制競爭防止法第 104 條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 75 條規定：「廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定（以下合稱法令），致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向招標機關提出異議：一、對招標文件規定提出異議者，為自公告或邀標之次日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。二、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。三、對採購之過程、結果提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。其過程或結果未經通知或公告者，為知悉或可得而知悉之次日起十日。但至遲不得逾決標日之次日起十

五日。招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。」；同法第 76 條規定「廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會申訴。地方政府未設採購申訴審議委員會者，得委請中央主管機關處理。廠商誤向該管採購申訴審議委員會以外之機關申訴者，以該機關收受之日，視為提起申訴之日。第二項收受申訴書之機關應於收受之次日起三日內將申訴書移送於該管採購申訴審議委員會，並通知申訴廠商。爭議屬第三十一條規定不予發還或追繳押標金者，不受第一項公告金額以上之限制」，我國就採購發生爭議時，踐行先向招標機關提出異議，對招標機關異議處理結果不服時，得再向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會申訴。故兩國就採購發生爭議時，救濟方式設計上有不同。

十三、組成、獨立性

德國就招標複審會之組成、獨立性作規範（參照德國限制競爭防止法第 105 條規定）。就我國而言，我國政府採購法並未就招標機關受理異議之審查成員組成及其獨立性作規範，但有就主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會受理申訴之審查成員組成及其獨立性作規範。

十四、設立、組織

德國就聯邦招標複審會設置於聯邦卡特爾署內；邦招標複審會設置由邦決定（參照德國限制競爭防止法第 106 條規定）。就我國而言，我國政府採購法並未有類似規定。

十五、招標複審會管轄之界定

德國就聯邦招標複審會除了管轄原則上聯邦之招標程序外，尚包括例外性得管轄之案件。另就邦招標複審會之管轄為界定（參照德國限制競爭防止法第 106a 條規定）。就我國而言，我國政府採購法並未有類似規定。

十六、開啟、申請

德國就再審查程序之發動係基於申請人提出申請(參照德國限制競爭防止法第 107 條規定)。申請人提出申請再審查程序，必須以書面(內容包括事實及理由等)為之(參照德國限制競爭防止法第 108 條規定)。就我國而言，我國政府採購法有所規定，異議、申訴係由廠商所提出。廠商就提出異議，會出具採購異議書；廠商就提出申訴，會出具採購申訴書。

十七、程序當事人、參加人

德國就再審查程序之當事人、參加人作規範(參照德國限制競爭防止法第 109 條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 80 條規定：「採購申訴得僅就書面審議之。採購申訴審議委員會得依職權或申請，通知申訴廠商、機關到指定場所陳述意見。採購申訴審議委員會於審議時，得囑託具專門知識經驗之機關、學校、團體或人員鑑定，並得通知相關人士說明或請機關、廠商提供相關文件、資料。採購申訴審議委員會辦理審議，得先行向廠商收取審議費、鑑定費及其他必要之費用；其收費標準及繳納方式，由主管機關定之。採購申訴審議規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。」，我國於異議程序上採取書面審理；於申訴程序上得採取書面審理或通知廠商、招標機關陳述意見，故我國就申訴程序上僅有當事人之概念，並無參加人之概念。

十八、調查之原則

德國就再審查程序一招標複審會進行調查之原則作規範(參照德國限制競爭防止法第 110 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並未就異議程序上、申訴程序上招標機關、採購申訴審議委員會進行審理時之應如何調查之原則作規範。

十九、機密文件之保管

德國就再審查程序一招標複審會就機密文件課以保密及保管義務作規範(參照德國限制競爭防止法第 110a 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並未有類似規定。

二十、檔案之閱覽

德國就再審查程序一當事人得閱覽檔案之原則及例外作規範(參照德國限制競爭防止法第 111 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並未有類似規定。

二十一、言詞審理

德國就再審查程序一以言詞審理為之作規範(參照德國限制競爭防止法第 112

條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 75 條規定：「廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定（以下合稱法令），致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向招標機關提出異議：一、對招標文件規定提出異議者，為自公告或邀標之次日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。二、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。三、對採購之過程、結果提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。其過程或結果未經通知或公告者，為知悉或可得而知悉之次日起十日。但至遲不得逾決標日之次日起十五日。招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。其處理結果涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。」；同法第 80 條規定：「採購申訴得僅就書面審議之。採購申訴審議委員會得依職權或申請，通知申訴廠商、機關到指定場所陳述意見。採購申訴審議委員會於審議時，得囑託具專門知識經驗之機關、學校、團體或人員鑑定，並得通知相關人士說明或請機關、廠商提供相關文件、資料。採購申訴審議委員會辦理審議，得先行向廠商收取審議費、鑑定費及其他必要之費用；其收費標準及繳納方式，由主管機關定之。採購申訴審議規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。」，我國於異議程序上採取書面審理；於申訴程序上得採取書面審理或通知廠商、招標機關到場陳述意見(相同於言詞審理)。

二十二、加速

德國就再審查程序—審理期限(五周內)及例外作規範(參照德國限制競爭防止法第 113 條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 75 條規定：「廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定（以下合稱法令），致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向招標機關提出異議：……招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。其處理結果涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。」；同法第 78 條規定：「廠商提出申訴，應同時繕具副本送招標機關。

機關應自收受申訴書副本之次日起十日內，以書面向該管採購申訴審議委員會陳述意見。採購申訴審議委員會應於收受申訴書之次日起四十日內完成審議，並將判斷以書面通知廠商及機關。必要時得延長四十日。」，我國就提異議處理結果期限、申訴完成審議期限有作規範，分別為 15 日、40 日(必要時得延長 40 日)。

二十三、招標複審會之決定

德國就再審查程序一招標複審會所作出之決定內容、效力及性質等作規範，包括招標複審會對於申請人之權利有無受侵害，應作成裁決；並應採取適當措施，以排除權利之侵害，並防止相關利益之遭受損害。上述之適當措施不受申請之拘束，其得獨立於申請內容之外，而影響招標程序之合法性。已作成之決標不得廢止。審查程序因決標、招標程序之廢止或停止，或因其他情事而終了者，招標複審會仍應依參與人之申請，確認有無權利侵害之事實。德國限制競爭防止法第 113 條第 1 項之規定，於此不適用之。招標審議會之裁決，應以行政處分為之。裁決之強制執行，包括向高權主體所為者，應依聯邦及各邦之行政強制執行法為之。德國限制競爭防止法第 61 條之規定，準用之(參照德國限制競爭防止法第 114 條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 82 條規定：「採購申訴審議委員會審議判斷，應以書面附事實及理由，指明招標機關原採購行為有無違反法令之處；其有違反者，並得建議招標機關處置之方式。採購申訴審議委員會於完成審議前，必要時得通知招標機關暫停採購程序。採購申訴審議委員會為第一項之建議或前項之通知時，應考量公共利益、相關廠商利益及其他有關情況。」；同法第 83 條規定：「審議判斷，視同訴願決定。」，我國就採購申訴審議委員會所作出審議判斷之內容及審判判斷之性質有作規範，而審議判斷，視同訴願決定，該訴願判斷本身亦為一行政處分。

二十四、招標程序之暫停

德國就再審查程序一招標程序之暫停作規範(參照德國限制競爭防止法第 115 條規定)。就我國而言，我國政府採購法第 82 條規定：「採購申訴審議委員會審議判斷，應以書面附事實及理由，指明招標機關原採購行為有無違反法令之處；其有違反者，並得建議招標機關處置之方式。採購申訴審議委員會於完成審議前，必要時得通知招標機關暫停採購程序。採購申訴審議委員會為第一項之建議或前項之通知時，應考量公共利益、相關廠商利益及其他有關情況。」，我國採購申

訴審議委員會於完成審議前，必要時得通知招標機關暫停採購程序。

二十五、偏離之邦法的排除

德國就再審查程序—邦法不得違反本法規定(參照德國限制競爭防止法第 115 條 a 規定)。就我國而言，我國政府採購法未有類似規定。

二十六、適法性、管轄

德國就若對於招標複審會之決定不服時，得向招標複審會登記所在地有關管轄權之高等邦法院(設置招標法庭)提起立即抗告，請求進行裁判(參照德國限制競爭防止法第 116 條規定)。有關德國限制競爭防止法第 116 條規定是否仍存在「招標複審會就再審查決定之爭議，其法律關係涉及社會福利法典第 5 冊第 69 條之規定者，由邦社會法院管轄」之規定，而影響當事人之尋求救濟途徑，經本人查證德國社會法院法第 107 條規定，得知其內有「招標複審會就再審查決定之爭議，其法律關係涉及社會福利法典第 5 冊第 69 條之規定者，於 2010 年 12 月 28 日繫屬於邦社會法院，以當時案件進行之階段移轉至招標複審會登記所在地有關管轄權之高等邦法院…」之規定，故可推敲出德國限制競爭防止法第 116 條規定已無規定當事人得向社會法院尋求救濟之途徑。就我國而言，我國政府採購法並未有相同於德國立即抗告制度上之設計，基於我國就採購申訴審議委員會所作出審議判斷之性質有作規範，而審議判斷，視同訴願決定，故若廠商不服該審議判斷時，得依行政訴訟法之規定，向採購申訴審議委員會所在地之管轄法院—高等行政法院提起撤銷訴訟。

二十七、立即抗告之期間、形式

德國就提起立即抗告之期限、程式(抗告書狀內容、律師簽署等)作規範(參照德國限制競爭防止法第 117 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟上原則上採取應以律師為訴訟代理人，但有例外情形。

二十八、立即抗告之效力

德國就提起立即抗告發生之效力作規範(參照德國限制競爭防止法第 118 條規定)。簡言之，立即抗告對於招標複審會之裁決，有停止執行之效力。停止執行之效力，自抗告期間屆滿 2 週後失其效力。招標複審會駁回審議之申請者，抗告法院得依抗告人之聲請，延展停止執行之效力至作成抗告裁判為止。且抗告法院應審酌所有可能受損之利益及程序迅速終結之公共利益後，認為延遲至作成抗告裁

判後始行招標之不利益，大於其所得之利益者，應駁回延展停止執行效力之聲請。就我國而言，我國行政訴訟法第 116 條規定：「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。行政訴訟繫屬中，行政法院認為原處分或決定之執行，將發生難於回復之損害，且有急迫情事者，得依職權或依聲請裁定停止執行。但於公益有重大影響，或原告之訴在法律上顯無理由者，不得為之。於行政訴訟起訴前，如原處分或決定之執行將發生難於回復之損害，且有急迫情事者，行政法院亦得依受處分人或訴願人之聲請，裁定停止執行。但於公益有重大影響者，不在此限。行政法院為前二項裁定前，應先徵詢當事人之意見。如原處分或決定機關已依職權或依聲請停止執行者，應為駁回聲請之裁定。停止執行之裁定，得停止原處分或決定之效力、處分或決定之執行或程序之續行之全部或部份。」，我國有就於行政訴訟進行中，賦與得停止執行之制度設計。

二十九、抗告程序之當事人

德國就抗告程序之當事人作規範(參照德國限制競爭防止法第 119 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法第 23 條規定：「訴訟當事人謂原告、被告及依第四十一條與第四十二條參加訴訟之人。」；同法第 24 條規定：「經訴願程序之行政訴訟，其被告為下列機關：一、駁回訴願時之原處分機關。二、撤銷或變更原處分時，為撤銷或變更之機關。」，我國有就行政訴訟程序之當事人作規範。

三十、抗告程序之程序規定

德國就立即抗告程序之程序規定(強制律師代理及例外等)作規範(參照德國限制競爭防止法第 120 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法第 49 條規定：「當事人得委任代理人為訴訟行為。但每一當事人委任之訴訟代理人不得逾三人。行政訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者，亦得為訴訟代理人：一、稅務行政事件，具備會計師資格。二、專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人。三、當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務。四、交通裁決事件，原告為自然人時，其配偶、三親等內之血親或二親等內之姻親；原告為法人或非法人團體時，其所屬人員辦理與訴訟事件相關業務。委任前項之非律師為訴訟代理人者，應得審判長許可。第二項之非律師為訴訟代理人，審判長許其為本案訴訟行為者，視為已有前項之許可。前二項之許可，審判長得隨時

以裁定撤銷之，並應送達於為訴訟委任之人。訴訟代理人委任複代理人者，不得逾一人。前四項之規定，於複代理人適用之。」，我國就行政訴訟程序原則上採取應以律師為訴訟代理人，但有例外情形。

三十一、就拍定得標之先決判決

德國就拍定得標之先決判決作規範(參照德國限制競爭防止法第 121 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法第 193 條規定：「行政訴訟進行中所生程序上之爭執，達於可為裁判之程度者，行政法院得先為裁定。」，基於行政訴訟進行中，賦與得停止執行之制度設計，屬於行政訴訟進行中所生程序上之爭執，若發生應讓其繼續執行時，屬於達於可為裁判之程度者，行政法院得先為裁定。

三十二、抗告裁判後招標程序之終結

德國就抗告裁判後招標程序之終結作規範(參照德國限制競爭防止法第 122 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法並未有類似規定。

三十三、抗告之裁判

德國就抗告之裁判作規範(參照德國限制競爭防止法第 123 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法第 195 條規定：「行政法院認原告之訴為有理由者，除別有規定外，應為其勝訴之判決；認為無理由者，應以判決駁回之。撤銷訴訟之判決，如係變更原處分或決定者，不得為較原處分或決定不利於原告之判決。」，我國就行政訴訟程序上(撤銷訴訟)之判決結果有作規範。

三十四、拘束效果與提交義務

德國就立即抗告之發生拘束力作規範(參照德國限制競爭防止法第 124 條規定)。換言之，因招標規定之違反而發生損害賠償請求，且已進入招標審議程序者，普通法院應受拘束於招標複審會之確定裁決、邦高等法院之抗告裁判，及聯邦最高法院依德國限制競爭防止法第 124 條第 2 項規定所為關於抗告之裁判。就我國而言，我國行政訴訟法第 206 條規定：「判決經宣示後，為該判決之行政法院受其羈束；其不宣示者，經公告主文後，亦同。」，我國行政訴訟之判決具有拘束力。

三十五、權利濫用時之損害賠償

德國就提起抗告顯屬權利濫用時，負損害賠償責任作規範(參照德國限制競爭防止法第 125 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法並無類似規定。

三十六、信賴損害之賠償請求權

德國就賦與事業發生信賴遭受損害，招標人負損害賠償責任作規定(參照德國限制競爭防止法第 126 條規定)。就我國而言，我國行政訴訟法並無類似規定。

三十七、授權

德國就聯邦政府經聯邦參議院同意，有權以法規命令發布之有關採購事項規定作規範(參照德國限制競爭防止法第 127 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並無類似規定。

三十八、根據產業法規命令之評審報告與意見書之費用

德國就規費作規範(參照德國限制競爭防止法第 127a 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並無類似規定。

三十九、招標複審會程序之費用

德國就招標複審會程序之費用作規範(參照德國限制競爭防止法第 128 條規定)。就我國而言，廠商提起異議並不需要繳納規費或任何費用，而廠商提起申訴，需繳納審議費。

四十、歐洲聯盟執委會之矯正機制

德國就必須依循歐盟執委會於公共採購領域之歐盟法辦理，不得違反作規範(參照德國限制競爭防止法第 129 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並無類似規定。

四十一、再審查機關之通知義務

德國就課以再審查機關通知義務(再審查程序之數量與其結果)作規範(參照德國限制競爭防止法第 129a 條規定)。就我國而言，廠商提起異議或申訴並無課以招標機關、採購申訴委員會通知(包括異議或申訴數量及結果)之義務。

四十二、對於聯邦礦業法招標人之規定

德國就對於聯邦礦業法招標人之規定，必須遵照歐盟法辦理作規範(參照德國限制競爭防止法第 129b 條規定)。就我國而言，我國政府採購法並無類似規定。

參、小結

由上可知，德國政府採購法制後續發展過程受歐洲聯盟相關政府採購指令影響很深，且已將歐洲聯盟相關政府採購指令內容轉化植入德國相關政府採購法令規範之內，且由於德國之政府採購制度於法律位階上並無單一之「政府採購法」

專法，其對政府採購之規範係採雙軌制。依標案金額是否達到歐盟門檻（Schwellenwerte），即德國營業競爭限制防止法第 100 條之規定，區分有無德國營業競爭限制防止法之適用，或者僅能適用德國其他國內法，影響所及，發生爭議時之救濟方式亦有所不同，前者得循德國營業競爭限制防止法所規範之再審查程序尋求救濟，後者循一般民事救濟途徑解決。德國政府採購法制有其優點及缺點，我國政府採購法得就立法不足之地方予以取長截短，使我國政府採購法得更加完備。



第四章 我國生物醫療廢棄物處理勞務契約定性之研析

第一節 政府採購契約之成立與生效

政府採購契約屬於私法契約，已如前述，但因政府採購契約係由行政機關與廠商所締結之契約，涉及國家預算與公共利益，不同於一般私法契約之締結方式，政府採購契約之締結方式係經過行政機關辦理招標及決標之過程，有其特殊性，因此，政府採購契約之成立與生效之時間點如何認定，有所爭議，實屬重要，於本文予以探討。

第一項 招標、投標、決標之法律性質

第一款 要約之引誘說

有關政府採購契約之成立與生效於學說及實務上有所爭論，晚近司法實務上見解，有最高法院 95 年度台上字第 1003 號民事判決：「原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求上訴人給付九百二十一萬六千九百五十二元本息之訴，改判令上訴人如數給付，並維持第一審所為命上訴人給付一千四百六十六萬八千元本息之判決，無非以：…查招標固為招標機關對投標廠商要約之引誘，但決標則為招標機關對投標廠商之承諾，故一旦決標，招標機關與得標廠商間已有合致之意，契約關係應已成立生效。」、最高法院 98 年度台上字第 331 號民事判決：「原審維持第一審所為上訴人敗訴部分之判決，駁回其上訴，無非以：…又公共工程契約之法律性質，係以主辦機關之招標行為為要約之誘引，廠商之投標行為為要約，而最後之決標乃主辦機關之承諾。」，可資參照，並有最高行政法院 98 年判字第 38 號判決：「…在締結採購契約的過程中，應僅屬於要約引誘性質，而並非要約…」、最高行政法院 90 年裁字第 646 號判決：「…本件拆除大樓工程之「招標公告」，其性質係屬私法上之要約引誘，相對人為上開招標公告，僅係藉此公告誘引合格廠商日後與之成立私法上之承攬契約，故該公告並未對抗告人產生規制作用。」可稽，可得而知司法實務上見解大致上肯認招標文件之公告為要約引誘，廠商投標為要約，機關決標為承諾，政府採購契約之成立，在機關決標時就成立。且於政府採購實務上亦有採取政府採購契約於主標人宣布決標時成立，於簽立書面時生效。

現行政府採購案件程序中，招標機關於招標文件之公告後，尚須審查投標廠商之投標文件是否符合招標文件，包括但不限於投標廠商是否符合投標廠商資格或提出之標的是否符合規格需求等等，招標文件內存有許多投標條件及限制，待審查完畢後，始得決定得標廠商，故並非招標機關於招標文件之公告後，招標機關即受其拘束而與投標廠商成立契約。可徵招標文件之公告應理解成要約之引誘。

第二款 要約說

當然也有就政府採購契約之成立與生效之時間點採取不同之見解，認為招標公告經公布後，通常不容任意變更或更改，廠商依據該招標公告為投標，招標機關依據該招標公告之條件為審標，不得任意變更，若認招標公告僅為要約之引誘，如何能有此一效力？廠商又何須受招標公告之限制？何況於一般政府採購案件中，皆有收取及沒收押標金之設計，若解釋廠商投標為要約，機關決標為承諾，在廠商投標時，政府採購契約尚未成立，招標機關又如何有收受押標金及沒收押標金之權利，依此見解，招標機關之招標公告應解釋為要約，廠商之投標應解釋為承諾，雙方成立一附解除條件之政府採購契約，以廠商未得標之結果為解除條件，若廠商未得標之結果發生時，將使該政府採購契約向後發生效力，此亦有最高法院 90 年度台上字第 1262 號判決：「按公開招標，若係採取「最低標」或「最高標」之方式決標者，招標單位所為招標之意思表示應屬「要約」，投標者為最低標或最高標之表示即係承諾，於決標時意思表示合致，契約因而成立。本件被上訴人於招標須知中載明投標金額最高者得標，則上訴人得標時，雙方意思表示即達成合致。」可資參照。

第三款 小結

惟採取要約說之見解，若有二家以上廠商參與投標之下，將造成二個政府採購契約之存在，縱使在民法上之債之關係相對性原則下，比方一屋得二賣，理論上得予允許成立二個政府採購契約之情形發生，但站在招標機關之立場上，及揆諸政府採購法宗旨與目的在於建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質等，政府採購行為更應嚴謹，有別於一般私法行為才是，雖然就政府採購契約之解釋上為一附解除條件之政府採購契約，但若

廠商就未得標之結果有所不服，尋求救濟時，此時將造成政府採購契約已成立，解除條件是否生效之問題，而廠商能否先行請求招標機關履行政府採購契約權利義務之疑義發生，將致使對於政府採購契約之成立與生效之認定衍生之結果更形複雜，應為我國政府採購制度建構上所不樂見，及造成法秩序之不穩定。

再者，政府採購法第 27 條第 1 項規定：「機關辦理公開招標或選擇性招標，應將招標公告或辦理資格審查之公告刊登於政府採購公報並公開於資訊網路。公告之內容修正時，亦同。」、政府採購法第 41 條規定：「廠商對招標文件內容有疑義者，應於招標文件規定之日期前，以書面向招標機關請求釋疑。機關對前項疑義之處理結果，應於招標文件規定之日期前，以書面答復請求釋疑之廠商，必要時得公告之；其涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標得以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。機關自行變更或補充招標文件內容者，亦同。」，基此，上開二條文給予招標機關公布招標公告後，產生疑義時，仍有補充修正之可能。且於政府採購實務運作上亦常發生補充修正投標須知或招標公告內容之情形發生。且所謂要約引誘係引誘相對人對自己為要約，故要約引誘之表意人仍保有最終決定締約與否之權利，可以避免意外締結超過其履約能力之契約，相對的，要約之表意人經相對人為承諾後，即須受其要約內容拘束，招標機關公布招標公告之作用本係吸引符合投標之廠商前往進行投標，滿足招標機關辦理採購標案之需求，故更類似要約之引誘。何況有關招標機關收受押標金及沒收押標金之爭議，有認為招標機關收受押標金及沒收押標金係基於押標金契約，與政府採購契約分屬不同及獨立之契約，故與政府採購契約成立與與生效無涉。

目前通說皆認為，投標為廠商契約要約之意思表示；決標為機關契約承諾之意思表示，機關於宣布決標時契約即已成立，並不以簽訂書面契約為必要。決標後所簽訂之書面契約性質，有學者認為，基於招標機關與得標廠商間之契約關係，於機關宣布決標後即已成立，書面契約僅為雙方將已成立之契約關係，簽訂較為正式之書面文件而已。或者有認為僅是為使契約之內容更加明確，證明雙方之契約關係而已，並非到訂定書面契約時契約始為成立，亦即政府採購契約之成立，非以簽訂書面為必要，且一般於決標時雙方意思表示合致，契約即行成立，並無

待另行簽訂書面契約¹¹⁵。此並有最高行政法院 98 年度判字第 38 號判決：「…以招標公告為要約引誘，廠商之投標為要約，而採購機關之決標，為承諾性質，且以決標時點意思合致為雙方契約成立時點。準此，採購契約內容於決標時即已確定，而嗣後契約之簽訂僅係將投標須知及公告相關事項，另以書面形式為之，故簽約手續並非契約成立或生效要件，且雙方對締約內容並無任何磋商空間，自不能將形式上之簽約日期視為契約實際成立時點，而應以決標日為契約成立日」可稽。

惟有認為基於通說及實務大多數見解就政府採購行為肯認政府採購行為之定性採取雙階段理論，即採購行為之態樣，包括前階段之招標公告、招標、決標之公法行為及後階段之訂約、履約、驗收之私法行為，既然招標公告係屬於公法之性質，且依據政府採購法第 74 條規定：「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。」、政府採購法第 76 條第 1 項規定：「廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會申訴。地方政府未設採購申訴審議委員會者，得委請中央主管機關處理。」、政府採購法第 83 條規定：「審議判斷，視同訴願決定。」及訴願法第 1 條第 1 項規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」之相互參照，在提起訴願及訴願決定作成前以有行政處分存在為前提，是可得推知招標公告應認為係行政處分，始得於發生爭議時，提起訴願，而有訴願決定之作成，又於發生爭議時，救濟途徑設計上得尋求行政訴訟以資救濟，不同於民事糾紛發生爭議時，救濟途徑設計上得尋求民事訴訟以資救濟，故無法運用民法上之要約之引誘或要約之概念予以理解，不妨將招標公告定性為行政處分始為妥適。

¹¹⁵ 謝說容，淺談政府採購法第 59 條，司法周刊②，2020 年 7 月 24 日。

第二項 招標契約之法律性質

有關招標公告之法律性質，於學說上及實務上爭論不休，而有要約說、要約之引誘說之爭論，對於後續承諾時間點之認定也有所不同，進而討論若有承認招標契約之出現，有關招標契約之法律性質，又有本約說、預約說之爭論，由於採取不同之見解結果，影響政府採購契約之成立與生效時間點之認定。

第一款 本約說

採取本約說之見解認為，招標機關開標後，即有義務依照招標規範所訂定之條件，決標給符合投標資格之廠商，決標當時，廠商與招標機關成立招標契約，屬於本約，並經知名學者之學者黃立教授、學者姚志明教授等人所肯認，並已成立政府採購契約之關係，而經知名學者羅昌發教授所認同。嗣後廠商與招標機關所簽訂之採購契約，僅係使招標契約之內容更加明確，具有證明之作用而已，並非以簽訂書面契約時政府採購契約才成立。又有稱該簽訂書面契約僅係就契約細節詳為訂定以確保契約之履行。此見解亦有最高行政法院 98 年度判字第 38 號判決所述，最高行政法院之見解有持原則上採取決標時為採購契約之成立時點，殊值參照。並有最高法院 86 年台上字第 319 號民事判決：「本件上訴人之綜合大樓新建工程，於八十三年三月三日公開招標，由被上訴人以最低價得標，兩造自己成立承攬契約。至兩造需契約成立後七日內完成簽約手續，此所稱簽約，應指承攬契約成立後，就承攬細節如工程進度之約定、違約時之處理等情形，詳為訂定，以確保工程之順利進行而已，並非於決標後另訂承攬契約。」可資佐參。此亦有行政院公共工程委員會對於契約生效日期的認定，於 2012 年 1 月 11 日以工程企字第 10100013140 號函提出：「一、本會旨揭函說明二之(二)所載：『招標文件或契約未明定前揭契約生效需經雙方簽署方為有效者，可考慮以決標日為生效日。』自即日起修正為：『招標文件或契約未明定契約生效需經雙方簽署方為有效者，以決標日為生效日。』即刪除『前揭』及『可考慮』之文字。二、上開修正係參照最高行政法院 98 年度判字第 38 號判決：『…以招標公告為要約引誘，廠商之投標為要約，而採購機關之決標，為承諾性質，且以決標時點意思合致為雙方契約成立時點。準此，採購契約內容

於決標時即已確定，而嗣後契約之簽訂僅係將投標須知及公告相關事項，另以書面形式為之，故簽約手續並非契約成立或生效要件，且雙方對締約內容並無任何磋商空間，自不能將形式上之簽約日期視為契約實際成立時點，而應以決標日為契約成立日』。」，可作為契約成立生效之參考依據。

第二款 預約說

惟有學者則認為，決標當時，廠商與機關間僅成立採購契約之預約，必須嗣後簽訂書面文件後，始成立本約。蓋因其認為，廠商於投標時所檢附之標單及投標資格等文件，機關最後決標之原因，係因廠商出具之資格適當、符合且標價為採購機關所接受，而並非契約內容本身符合機關需求。因此，持此說學者認為，決標為雙方合意於未來期間內，以廠商所出具之資格、投標金額及招標契約內容等為前提，簽定機關所擬定之契約書。此見解亦有最高法院 84 年度台上第 848 號判決：「…是決標後上訴人與得標廠商所成立者係招標契約，得標廠商僅取得者與上訴人訂立工程承攬契約之權利，必上訴人與得標廠商另行簽訂工程承攬契約，其承攬關係始行發生。」、臺灣高等法院臺南分院 92 年上字第 99 號民事判決：「招標為要約引誘，投標為要約，決標為承諾，公共工程契約決標後所成立關係之法律關係為具預約性質之招標契約，得標之上訴人僅取得與被上訴人簽訂如招標公告及招標所有文件內容之工程承攬契約。」、臺灣高等法院臺中分院 88 年度上字第 675 號民事判決：「當事人所締結之承攬契約雖非要式行為，惟對於承攬契約之必要之點，諸如承攬工作期間與契約一般條款如結算付款辦法等等，均未確定，且是否曾經採購部門之稽核通過，亦尚在未定之數，是為免驟然成立本約肇至解約時回復原狀之困難，對於重大工程，自應將決標解為預約之成立生效而已，是上訴人台電公司所辯承攬契約於決標時已經成立生效云云，實不足採。」可資參照。

亦有認為基於政府採購法第 50 條第 2 項規定：「決標或簽約後發現得標廠商於決標前有第一項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。」，可得而知立法者將「決標」及「簽約」予以並列規範於同一條文內，

其用意在於立法者認知上認定「決標」不同於「簽約」，若強求論斷「決標」之具有契約性質，唯一只能將「決標」解釋成廠商與機關間僅成立政府採購契約之預約，而「簽約」解釋成廠商與機關間成立政府採購契約之本約。

且政府採購法第 101 條第 1 項第 7 款有所約定，得標後無正當理由而不訂約者，其係機關辦理採購，發現廠商有該情形，應將其事實、理由及依第 103 條第 1 項所定期間通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報，亦係認為「決標」不同於「簽約」，並可得而知立法者認知上認定倘若未簽約，政府採購行為無法續行，強調簽約之必要性，可徵在我國政府採購法之立法設計上並不採納本約說之立場。

第三款 小結

為解決前述學說對於契約成立時點問題所產生之爭議，行政院公共工程委員會有提供「招標投標及契約文件範本」，供各機關參酌使用。主要供各機關於辦理採購時，將該文件範本與招標文件，於招標時一併公告；廠商投標時使用該文件投標欄位，並依據招標文件規定之內容，備齊投標文件後投標；機關宣布決標後，使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續。此一文件之使用，一方面可使決標後，避免因未簽定書面契約，產生契約成立生效與否之爭議；再者，廠商使用投標欄位投標，可作為認定廠商要約之意思表示內容，機關於決標用印後為承諾，契約關係即告成立。

另有認為契約之雙方得合意約定契約於何時成立及生效，由此推論，在招標文件未載明契約須經雙方簽訂契約始生效力，以決標日為生效日，反之，若在招標文件載明契約須經雙方簽訂契約始生效力，依據民法第 166 條之規定，於雙方簽訂完成簽訂書面後，始生效力。此有行政院公共工程委員會對於契約生效日期之認定，於 1999 年 5 月 15 日以工程企字第 8805761 號函提出：「1. 招標文件或契約明定契約需經雙方簽署方為有效者，以契約經當事人雙方完成簽署之日為生效日。至簽約日期，除招標文件或契約另有規定者外，指當事人雙方共同完成簽署之日；雙方非同一日簽署者，以在後者為準。2. 招標文件或契約未明定前揭契

約生效需經雙方簽署方為有效者，可考慮以決標日為生效日。」，可作為契約成立生效之參考依據。並有稱此見解為折衷說。

又有認為應就招標機關宣布決標之結果現場狀況，區分不同之情形而論斷，基於政府採購法第 52 條第 3 項規定：「決標時得不通知投標廠商到場，其結果應通知各投標廠商。」，且承諾屬於意思表示，意思表示發生效力之時點，立法例上有包括表示主義、發信主義、了解主義、到達主義，在我國，就民法第 94 條規定：「對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人了解時，發生效力。」係屬於採取對話之意思表示之立法，也採用了解主義，而就民法第 95 條第 1 項規定：「非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力。但撤回之通知，同時或先時到達者，不在此限。」係屬於採取非對話之意思表示之立法，也採用到達主義，要約之意思表示與承諾之意思表示達成意思表示合致時，契約始為成立，於此，決標時依法並不需要投標廠商到場，決標之結果亦應「通知」各投標廠商，故在招標文件未載明契約須經雙方簽訂契約始生效力之情形下，若招標機關當場宣布決標之結果時，得標廠商有到場或得標廠商未到場，但於決標時立即可得而知決標之結果時，似乎得按照民法第 94 條規定，經得標廠商明瞭、知悉決標之結果時，即發生承諾之效力，而得標廠商未到場，且於決標時無法可得而知決標之結果時，屬於事後得知¹¹⁶，似乎得按照民法第 94 條規定，經得標廠商明瞭、知悉決標之結果時，即發生承諾之效力或按照民法第 95 條第 1 項規定，決標結果之通知「到達」得標廠商時，始發生承諾效力，此見解亦同被歸納為折衷說之一種，知名學者姚志明教授似乎係採取此一見解。

另引據臺灣高等法院臺南分院 92 年度上字第 99 號判決，上訴人有所主張，不應以民法概念解釋政府採購行為，其謂：「又觀諸判決全文，原審係以民法之觀念為判斷之依據，以此分析招標、投標、決標行為之法律性質及公共工程契約決標後所成立關係之法律性質。惟查，政府採購法係為建立政府採購制度，提升採購效率與功能而制訂，基於其特殊之立法目的，自不可單純以傳統民法概念論之。由原審判決第四點所引最高法院八十六年度台上字第三一九號判決及八十四年度台上字第八四八號判決，針對招標、投標、開標之法律性質與工程契約間之

¹¹⁶ 林水波，同前註 35，頁 57。

關係所為見解仍有歧異，益足徵政府採購相關規定之特殊性。原審不察，遽以民法概念解釋政府採購法之行為，實屬率斷。」殊值參考。

惟有認為基於通說及實務大多數見解就政府採購行為肯認政府採購行為之定性採取雙階段理論，即採購行為之態樣，包括前階段之招標公告、招標、決標之公法行為及後階段之訂約、履約、驗收之私法行為，已如上述，有關招標公告、招標、決標，不應套用民法之概念予以區分為要約或要約之引誘，及預約或本約，來理解，否則將違背了「一個法律關係應單一考察」，在法解釋學上，很難將同一個行為同時解釋為具有完全不同之法律意義，甚至同時具有公法及私法性質¹¹⁷之情形發生，為求在雙階理論下對於公開招標程序在學理上亦有合理之解釋¹¹⁸，既然招標公告、招標、決標屬於公法行為，僅能解釋為單方行政行為，以決標為例，得將決標解釋成招標機關所為之行政處分較為妥適，亦即得視為一行政處分，其作用僅係使得廠商取得其後可以與招標機關訂約之資格罷了，如此解釋，亦較符合學理以及現行政府採購法之規定¹¹⁹，至於政府採購契約之成立與生效之時點應以廠商得標，取得與招標機關訂約之資格後，而為簽約之時點以為認定，在此之前，雙方並無任何契約關係存在。

本人以為政府採購契約係屬於機關辦理採購之重要文件之一，政府採購契約有些重要內容並未規範在投標須知文件內，得標廠商得標，僅代表得標廠商符合簽訂政府採購契約之資格，且履約過程時屬於重要之過程，故本人認為政府採購契約之成立與生效實應以雙方簽訂政府採購契約為準。又依據行政院公共工程委員會所訂頒勞務採購契約範本第1條第5項第3款規定：「契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。」及同契約範本第15條第5項規定：「契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。」。是以，揆諸行政院公共工程委員會訂頒之上開勞務採購

¹¹⁷ 黃培誠，工程採購契約遲延問題之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2011年7月，頁27。

¹¹⁸ 吳庚，同前註36。

¹¹⁹ 吳庚，同前註36。

契約範本，足見政府採購契約之成立及生效除雙方合意外，尚以具備書面為必要，更有甚者，契約之變更倘未具書面及簽名或蓋章，更將使發生契約變更之部分無效之法律效果，更能代表政府採購契約之成立與生效實應以雙方簽訂政府採購契約為準。本文即以政府採購契約之成立與生效實應以雙方簽訂政府採購契約為準而展開後續討論及探討。



第二節 政府採購契約之履約規範

政府採購法本身及各子法，比如政府採購法施行細則、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準等，皆有相關履約之規定，於政府採購法相關履約之規定當中，尤以第四章(履約管理)內之相關規定即屬之，是以政府採購法本身及各子法亦屬於政府採購契約之履約規範，且政府採購法屬於政府採購契約履約規範當中最上位階之履約規範。

除此之外，按照政府採購法第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」。且行政院公共工程委員會於88年5月25日以(88)工程企字第8807106號函發佈採購契約要項，以作為機關訂定各項採購契約之參考。

依據採購契約要項第1條(訂定依據及目的)規定：「一、本要項依政府採購法(以下簡稱本法)第六十三條第一項規定訂定之。本要項內容，由機關依採購之特性及實際需要擇訂於契約。」、採購契約要點第2條(契約得載明之事項)規定：「二、機關得視採購之特性及實際需要，就下列事項擇定後載明於契約：(一)機關及廠商之名稱、地址及電話。(二)機關及廠商聯絡人之姓名及職稱。(三)契約所用名詞定義。(四)契約所含文件。(五)廠商工作事項或應給付標的。(六)機關辦理事項。(七)契約所用文字。(八)度量衡制。(九)簽約日期。(十)得標廠商應自行履行之主要部分及分包事項。(十一)履約標的之產地。(十二)證照之取得。(十三)履約場所管理、進度管理、環境保護、工作安全與衛生、工地環境清潔與維護、交通維持或工作界面配合等事項。(十四)品質管理。(十五)履約監督。(十六)災害處理。(十七)履約標的須標示之文字或符號。(十八)履約處所或財物之收受地點及時間。(十九)運輸方式。(二十)包裝方式。(二十一)當事人雙方通知方式。(二十二)契約變更。(二十三)契約之轉讓。(二十四)查驗、測試或驗收之程序及期限。(二十五)履約標的之項目、數量、單價、分項金額及總價。(二十六)付款條件。(二十七)廠商應提出之文件。(二十八)保證金及其他擔保之種類、額度、繳納、不發還、退還及終止等事項。(二十九)契約價金依物價指數調整。(三十)稅捐、規費及關稅之負擔。(三

十一) 履約期限。(三十二) 逾期違約金。(三十三) 保固或維修之期限及責任。(三十四) 零配件供應。(三十五) 權利及責任。(三十六) 保險之種類、額度、投保及理賠。(三十七) 契約之終止、解除或暫停執行。(三十八) 履約爭議之處理。(三十九) 準據法。(四十) 其他與履約有關之事項。」，基此，雖然採購契約要項並非強制性規定，而由機關依採購之特性及實際需要事先擬訂政府採購契約之內容，但機關於擬定政府採購契約時，泰半皆會遵守，而擬訂政府採購契約。

目前行政院公共工程委員會並已擬具「工程採購契約範本」、「財物採購契約範本」、「勞務採購契約範本」、「資訊服務採購契約範本」、「公共工程專案管理契約範本」、「災害搶險搶修開口契約範本」、「統包工程採購契約範本」等，以供採購機關於擬定採購契約時之參考內容，制定一份較為完善之政府採購契約。採購機關皆會遵循上開政府採購契約範本而擬定所需之政府採購契約內容，且並於採購機關辦理採購招標時，檢附於投標須知內齊同公告予大眾知悉，由於投標人皆業已知悉及明瞭政府採購契約之內容，而接受之，才會進行投標之動作，亦即得標人通常對於採購機關提供之政府採購契約之內容幾乎不會再行爭執。

第三節 勞務採購契約之探究

依據民法第 153 條第 1 項規定：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」，據此，一般認為契約係指經過當事人雙方互相意思表示一致，且經過當事人雙方充份瞭解而願意接受此互相一致意思表示之拘束，即為契約成立。一般而言，契約是指私法上之法律行為，可分為債權契約（比方買賣、僱傭、委任、承攬）、物權契約（比方動產之交付、不動產所有權移轉登記）及身分契約（比方親屬關係、繼承關係、婚姻關係）等，不過在公法上也存在契約關係（比方行政契約）。亦有認為，契約得以廣義契約和狹義契約作為區分。廣義契約係指以發生私法上效果為目的之一切合意，包括：債權契約、物權契約及身份契約。狹義契約則單指以發生債之效果為目的之合意，即債權契約。我國就債權契約之類型規範在我國民法債編各論之內，即民法第二編債一第二章各種之債中，包含第一節買賣、第二節互易、第三節交互計算、第四節贈與、第五節租賃、第六節借貸（包括第一款使用借貸及第二款消費借貸）、第七節僱傭、第八節承攬、第八節之一旅遊、第九節出版、第十節委任、第十一節經理人及代辦商、第十二節居間、第十三節行紀、第十四節寄託、第十五節倉庫、第十六節運送（含第二款物品運送及第三款旅客運送）、第十七節承攬運送、第十八節合夥、第十九節隱名合夥、第十九節之一合會、第二十節指示證券、第二十一節無記名證券、第二十二節終身定期金、第二十三節和解、第二十四節保證、第二十四節之一人事保證，共計有 27 種契約類型。

基於契約是以雙方當事人互相對立合致之意思表示所構成，其中包括要約及承諾兩個基本之意思表示。要約是表意人所發出，欲得到相對人承諾而發生一定私法上效力之意思表示。承諾則是針對要約所為願使契約成立所為之意思表示，且依據民法第 156 條規定：「對話為要約者，非立時承諾，即失其拘束力。」、民法第 157 條規定：「非對話為要約者，依通常情形可期待承諾之達到時期內，相對人不為承諾時，其要約失其拘束力。」及民法第 158 條規定：「要約定有承諾期限者，非於其期限內為承諾，失其拘束力。」，以承諾期限為要約之存續期限，確保雙方利益之衡平。承諾之內容必須和該要約之內容完全一致，否則即為新要約而非承諾。而應與要約區分是要約之引誘，此可見於民法第 154 條第 1 項

後段規定：「但要約當時預先聲明不受拘束，或依其情形或事件之性質，可認當事人無受其拘束之意思者，不在此限。」，有認為其並非意思表示，而是觀念通知，為準法律行為之一種，不生要約拘束力。有關要約與要約之引誘之區別實益已於本文前面章節略有提及，於此不再予以介紹。

我國就契約可依各種標準分為許多類型，下表為常見之法律分類類型：

表 20 契約分類方式

分類方式		類型
1.	有名契約又稱典型式契約。民法中所明文規定、設有特別規定並賦予一定名稱之契約。	
	無名契約又稱非典型式契約。	
2.	雙務契約是指契約當事人雙方對於對方互負債務、互有債權之契約。完全雙務：雙方負給付義務，然雙方給付義務具有對價性。不完全雙務：雙方負給付義務，然雙方給付義務不具有對價性。又雙務契約依法可適用同時履行抗辯、不安抗辯之權利（參見民法第 264 條、第 265 條）及危險負擔之規定，單務契約則不能適用。	買賣、互易、合夥、租賃、雇傭、運送、和解等。
	單務契約，又稱片務契約，契約當事人僅有一方向對方負有債務，而他方享有債權者，則稱為「單務契約」。	贈與、保證、使用借貸、消費借貸、無償之委任等。
3.	諾成契約又稱不要物契約，僅須契約當事人意思表示合致，即可成立而不須目的物交付之契約。	大多數債權契約、婚約。
	要物契約，又稱踐成契約，為須意思表示合致及現物之交付才能成立之契約。	使用借貸、消費借貸等。
4.	有償契約為當事人之一方為給付，並約定他方須為對價給付之契約。	買賣、互易、及附利息之消費借貸。
	無償契約為僅一方當事人負擔債務之契約，而負擔債務之當事人不自他方當事人取得對價給付之契約。	如贈與、使用借貸等。
5.	要式契約為須具備一定方式才能夠成立之契約。	民法規定終身定期金契約(730 條)、期限逾 1 年之不動產租賃契約(420 條)。

	非要式契約又稱不要式契約，為僅須當事人意思表示之合致，而不須具備任何方式即能成立之契約形式。	近代民法隨契約自由之原則發展，多數契約皆屬非要式契約。如婚約。
6.	要因契約為以給付為成立原因(取得財產上利益為目的)之契約。	民法上之典型契約。
	不要因契約為不受原因欠缺使效力受影響之契約。	物權契約、票據行為、債務拘束、債務承認等。
7.	主契約為不須以其他契約的存在為前提，而能獨立存在之契約。	一般契約均屬之。
	從契約為須以其他契約存在前提之契約。	利息契約、定金契約、違約金契約、保證契約等。
8.	本約為履行預約而訂立的契約，本約中之基本要素及權利義務關係皆須明確規定。	
	預約為約定將來訂立特定契約之契約。	婚約。
9.	一時性契約為經一次之給付即可實現債之關係之契約。	買賣、贈與。
	繼續性契約為須當事人持續的履行才能實現契約關係之契約。	委任、承攬、僱傭、租賃、終身定期金等。
10.	債權契約為發生債之動的關係為目的之契約。	
	物權契約為發生物之靜的關係為目的之契約。	
	身分契約為融合人格之靜的關係為目的之契約。	
11.	附合契約為契約一方當事人僅能選擇接受既有契約內容與否之選擇，而無法議約內容之契約。	一般定型化契約、盟約
	非附合契約為契約雙方當事人均能協議內容之契約。	

資料來源：作者整理製表

私法自治是指個人得依其意思創造私法上權利義務關係¹²⁰。然契約自由原則亦有其限制，除契約必須符合法規範方生效力，如行為能力、意思表示無瑕疵、遵守一定形式、未違反法律強制規定或是禁止規定及公序良俗等¹²¹。且亦如司法院大法官會議解釋釋字第 576 號解釋所述，契約自由為個人自主發展與實現自我之重要機制，並為私法自治之基礎，除依契約之具體內容受憲法各相關基本權利規定保障外，亦屬憲法第 22 條所保障其他自由權利之一種。惟國家基於維護公益之必要，尚非不得以法律對之為合理之限制。易言之，契約自由係屬於私法自治之重要原則，但也應受到民法規範及限制，諸如民法第 71 條規定：「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」、民法第 72 條規定：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」、民法第 73 條規定：「法律行為，不依法定方式者，無效。但法律另有規定者，不在此限。」及民法第 148 條規定：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」等規範，對契約自由發生拘束之效力。而凡有效成立之契約，為維持法律生活之安定性，自應嚴格遵守之，當事人應依從該契約之內容或本旨而履行，此為「契約嚴守原則」，並有最高法院 18 年上字第 127 號判例、18 年上字第 484 號判例、18 年上字第 1495 號判例、19 年上字第 985 號判例、20 年上字第 632 號判例、20 年上字第 1941 號判例意旨可供參照¹²²。簡言之，依據「契約自由原則」，個人可以依據其自由意思，決定是否締結契約，與何人締結契約，以及締結何種內容之契約。只要契約內容不違反法律強制規定、公共秩序或善良風俗，國家即承認當事人訂定之契約為有效之約定，當事人違反契約約定時，個人可以至法院起訴，請求契約相對人履行契約或請求損害賠償。再者，契約之締結，既是雙方當事人，基於自由意思而訂立，且契約條款，係當事人謹慎思考後，對於當事人利益與社會生活之理性規劃，當事人即需嚴格遵守契約約定之內容，此即「契約嚴守原則」。在契約自由原則與契約嚴守原則下，任何人簽訂契約後，均受契約條款之拘束，而不得任意毀約，否

¹²⁰ 王澤鑑，民法總則，頁 264—265。

¹²¹ 朗世瑀，同前註 91，頁 10。

¹²² 碩豐法律事務所，民法詞彙—契約神聖/契約嚴守，法律辭典，網址：
https://shuofeng.com.tw/newsdetail_3_143.html（最後瀏覽日：2022 年 5 月 3 日）。

則即需負擔損害賠償責任。契約自由原則，對於保障個人社會生活之活動自由，以及資本主義之經濟發展具有貢獻¹²³。有關契約自由原則之內容，有下列四點：

表 21 契約自由原則類型

類型	意義
1. 締結契約之自由	就是否訂立契約，當事人有其自由，不能予以強制，如果不願意訂立契約，任何一方不能強制脅迫他方訂立契約。
2. 選擇契約相對人之自由	契約當事人一方可以自由選擇與任何人訂立契約，不受限制。
3. 決定契約內容之自由	契約當事人對契約內容可以自由訂立，但契約內容不得違反法律強行規定、禁止規定、公序良俗、公共利益、誠實信用。
4. 契約方式之自由	契約方式的自由：契約方式除依法律規定外，任何方式皆可由契約當事人自由訂定

資料來源：作者整理製表

以生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司所簽立之廢棄物處理契約而言，有包括依據政府採購法，與政府機關或政府機關所屬事業簽訂之生物醫療廢棄物委託處理之契約，因必須經過政府採購程序，予以簽訂，故又稱為政府採購契約，另一為純粹依據廢棄物清理法相關法令，與政府機關或政府機關所屬事業、私人機構所簽立之生物醫療廢棄物委託處理之契約，純粹稱之為生物醫療廢棄物處理契約。

政府採購契約之成立除生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司與政府機關或政府機關所屬事業意思表示合致之外，尚須符合政府採購法之規定，經過招標、投標、審標、開標、決標等程序¹²⁴。歷經上開政府採購法規定之程序後，即由生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲

¹²³ 聯晟法網，契約自由原則，網址：<https://www.rclaw.com.tw/post-274-8180>(最後瀏覽日：2022年5月6日)。

¹²⁴ 呂金鑫，同前註26，頁16。

級生物醫療廢棄物處理公司與政府機關或政府機關所屬事業簽訂政府採購契約。
茲就政府採購各階段之作業流程，臚列如下：



2

圖 8 採購作業流程

資料來源：投標須知及招標文件製作(報告人：行政院公共工程委員會劉彩霞)ppt¹²⁵

¹²⁵ 投標須知及招標文件製作(報告人：行政院公共工程委員會劉彩霞)ppt，網址：
<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vhSLuAYT&id=AF58FB029DC31ACD B167D6DE1E0B2BC735399BB3&thid=OIP.vhSLuAYTSXJWZDHkAtYoIwHaFP&mediaurl=https%3a%2f%2fimage.slidesharecdn.com%2fpur001-1213973996747759-8%2f95%2fpur001-11-728.jpg%3fcb%3d1213950848&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.be148bb806134972566431e402d62823%3frik%3ds5s5NccrCx7elg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&expf=728&expw=1030&q=採購流程圖&simid=608022105096528738&FORM=IRPRST&ck=2C0E46FCE5FFF4905DF9B23A8635A61E&selectedIndex=99&ajaxhist=0&ajaxserp=0>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 6 日)。

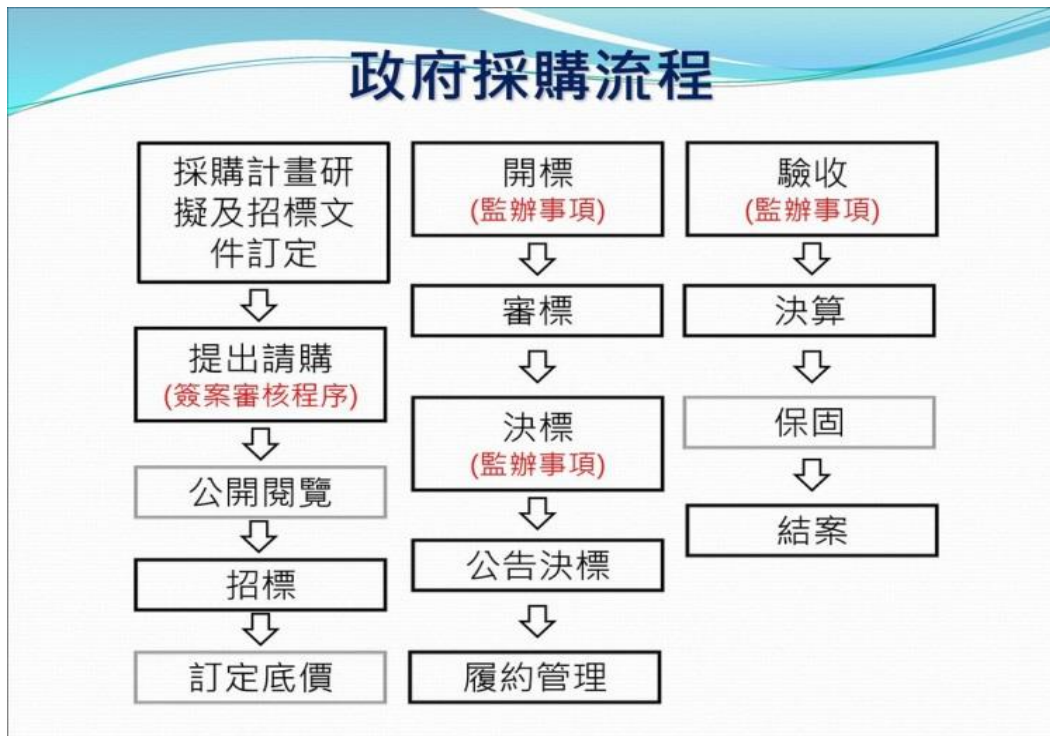


圖 9 政府採購流程

資料來源：政府採購法主(會)計人員應行注意事項(報告人：洪澤仁，104 年 10 月 29 日)ppt¹²⁶

私法自治，是民事法律之重要原則，政府採購契約如經歸類為私法行為之性質者，即與一般私法契約相同，固均應尊重當事人意思之自主，但政府採購契約與一般買賣、承攬等民事契約，雖均屬有償之交易行為，然一般契約原則上僅受到民事法規之拘束，但政府採購事項，具有維護公益之精神，除受到一般民事法律規範外，尚受到政府採購相關法規之規範，且政府採購之相關法規，非僅以契約當事人之權利義務關係加以考量，更包括採購行為之效率性及對相關供應商公平性之考量¹²⁷，二者並不完全相同，又有稱之為政府採購契約具有公益維護之性質。

然而有認為政府機關或政府機關所屬事業與廠商簽訂政府採購契約，藉由簽訂契約規範雙方之權利義務關係，除此之外，政府機關或政府機關所屬事業與廠商建立契約關係之目的，係基於滿足政府施政之需要而發動之交易行為，契約之

¹²⁶ 政府採購法主(會)計人員應行注意事項(報告人：洪澤仁，2015 年 10 月 29 日)ppt，網址：<https://slidesplayer.com/slide/11409417/>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 6 日)。

¹²⁷ 謝說容，同前註 115。

建立，除交易雙方就契約內容之合意外，更受到相關法令規章之規範¹²⁸，據此，政府機關或政府機關所屬事業與廠商於簽訂政府採購契約時，對於契約如何簽訂，並非擁有完全自主性，而受政府採購法規範下為之，有關採購標的之定性，影響契約可能之形式、內容、履約方式、步驟及廠商之資格條件限制，限縮了契約自由之空間，已非單純之私法契約，不能完全適用契約自由原則，故有稱其已非百分之百之契約自由。

生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司依據廢棄物清理法相關法令，與政府機關或政府機關所屬事業、私人機構所簽立之生物醫療廢棄物委託處理之契約，法律性質上定性為屬於雙方合意成立之一般私法契約，並無疑義，茲不再贅述，生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，基於政府採購法之規定，政府機關或政府機關所屬事業應辦理招標程序，全份招標文件包括廠商投標報價單、採購計畫清單、契約條款、契約附加條款及投標須知等文件資料，生物醫療廢棄物處理業者包括但不限於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司並於得標後，依據招標相關文件所附之勞務採購契約書進行簽約，整個招標文件之擬訂包括但不限於勞務採購契約之擬訂、招標決標作業、履約管理皆有獨特之地方，值得深入研究之地方，本章以下之內容即就此展開。

¹²⁸ 吳權原，政府採購貪瀆犯罪防制之研究，逢甲大學交通工程與管理所碩士論文，2007年，頁12。

第四節 勞務採購契約定性探討

第一項 勞務採購契約內容

生物醫療廢棄物處理業者參與投標並於得標後，受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，基於政府採購法之規定，政府機關或政府機關所屬事業應先與生物醫療廢棄物處理業者簽立政府採購標案之生物醫療廢棄物處理勞務採購契約書，該標案勞務採購契約書內容，幾乎以依據政府採購法及其主管機關訂定之規定為準繩，包括但不限於行政院公共工程委員會之「勞務採購契約範本」，而政府機關或政府機關所屬事業仍得衡酌個案情形於辦理該標案之招標時決定該標案勞務採購契約書內容。該標案勞務採購契約書之內容不外乎包括契約文件及效力、履約標的、契約價金之給付、契約價金之調整、契約價金之給付條件、稅捐、履約期限、履約管理、履約標的品管、保險、保證金、驗收、遲延履約、權利及責任、契約變更及轉讓、契約終止解除及暫停執行、爭議處理及其他等項目。此外，招標文件比如招標公告、投標須知等、投標文件比如投標書等及決標文件等皆視為該標案勞務採購契約書內容之一部分。

第二項 勞務採購契約定性爭議

通常所稱採購係指有償取得動產之行為，而政府採購法擴大了通常所稱採購之涵蓋範圍，除了財物之外，還增加了「工程」及「勞務」二大類，這是參酌「政府採購協定」之規定¹²⁹，亦有認為政府採購係指以政府機關預算款換取民間提供物品或勞務、服務而言，為一個動態之過程，始於政府機關認定有採購之需要，而終於採購契約履行完畢，政府機關本身依法定程序辦理結案為止。換言之，政府機關為達成施政目的，透過計畫之擬定、預算之編列，依據政府採購法規辦理採購，以取得工程、財物或勞務之整體作為¹³⁰。且按照政府採購法第 2 條規定：「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。」、政府採購法第 7 條規定：「本法所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、

¹²⁹ 許耀昇，同前註 28，頁 45。

¹³⁰ 吳權原，同前註 128。

環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。本法所稱財物，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。」，且有認為其他經主管機關認定之勞務包括仲介、廣告、調查、檢查、徵信、統計、認證、技術性測驗分析、保全、清潔、攝影、包裝、印刷、出版、會議、快遞、電信、視聽、銷售、教育、廢水處理、廢棄物清理、環境衛生、金融、保險、人體健康、旅遊、餐飲、娛樂、文化、體育、運輸、加工及其他與農、林、漁、牧、礦、製造、能源等業有關之勞務¹³¹。基此，一般認為政府採購法就政府採購契約之態樣可分為承攬契約（工程之定作、財物之定製）、買賣契約（財物之買受）、租賃契約、委任契約及僱傭契約。基於其性質得分別以民法中之承攬契約、買賣契約、租賃契約、委任契約及僱傭契約作定性，在當事人間發生債權債務關係，其性質屬於債權契約¹³²，因此本文就政府採購契約之本質之探討，即以定性為債權契約作為探究。既然政府採購契約為債權契約，政府採購契約包括但不限於勞務採購契約之本質仍不跳脫債權契約之成立要件及生效要件之解析。另就政府採購契約包括但不限於勞務採購契約之本質上予以定性，如下：

表 22 政府採購契約之本質

契約本質	意義	略要
私法契約	私行政經濟（國庫行政）中私法型態之輔助行為	
雙務契約	政府機關給付廠商契約價金，廠商給付行政機關契約標的。	
有償契約	政府機關給付廠商契約價金，廠商給付行政機關	

¹³¹ 何應朋，同前註 29，頁 26。

¹³² 王天健，同前註 39，頁 41。

	契約標的，互為相等對應之對價關係。	
諾成契約	依意思表示之合致即可成立。	
要式契約	採購作業，必須依據政府採購法之規定方式辦理。	另有以政府採購法並未明定政府採購契約須以書面為之始生效力 ¹³³ ，書面契約僅作證明之用，故為不要式契約。
繼續性契約	繼續性完成採購標的，而非一次性完成採購標的	

資料來源：作者自行製表

至於政府採購契約包括但不限於勞務採購契約是否屬於定型化契約，存有爭議，定型化契約又稱附合契約，於學說、實務各有己見，而依據消費者保護法第 2 條第 7 款規定：「定型化契約條款：指企業經營者為與多數消費者訂立同類契約之用，所提出預先擬定之契約條款。定型化契約條款不限於書面，其以放映字幕、張貼、牌示、網際網路、或其他方法表示者，亦屬之。」、消費者保護法第 2 條第 9 款規定：「定型化契約：指以企業經營者提出之定型化契約條款作為契約內容之全部或一部而訂立之契約。」，基於企業經營者為節省交易成本，勢必無法逐一與消費者磋商契約條款內容，遂開始大量使用定型化契約。由於此種交易不重視交易相對人之個人因素，企業經營者得以同等之交易條件迅速與消費者締結大量契約，進而節省成本，並合理規劃生產及服務¹³⁴，此即為消費者保護法就定型化契約有所規範之立法背景。另依據民法第 247 條之 1 規定：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。」，基於當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，該契約適用於多數不特定人間，此即為民法就附合契約

¹³³ 潘秀菊、張祥暉，同前註 22。

¹³⁴ 詹森林，私法自治原則之理論與實務—臺灣法制發展之情形，國立臺灣大學法學論叢，第 22 卷第 2 期，1993 年 6 月，頁 367。

有所規範之立法背景。消費者保護法與民法有關定型化契約條款規定最大之差別，在於我國消費者保護法上有關定型化契約之規定，因受消費者保護法之目的（保障消費者權益）、性質（限為消費關係）所限，僅能適用於與消費者有關之定型化契約，其範圍較窄¹³⁵。有認為定型化契約，大致區分為消費性定型化契約、非消費性定型化契約，而政府採購契約包括但不限於勞務採購契約屬於非消費性定型化契約之型態。由於就大部分之政府採購契約包括但不限於勞務採購契約而言，實務上招標機關多係採用行政院公共工程委員會訂定之範本，符合「契約條款由一方當事人單方面所擬定」之特徵¹³⁶，不無可認定政府採購契約包括但不限於勞務採購契約符合定型化契約之特徵。然而有關司法實務上對於政府採購契約包括但不限於勞務採購契約是否定性為定型化契約，有所分歧，本人以司法院「法學資料檢索系統」輸入關鍵字「政府採購契約」連同「定型化契約」一併同時輸入檢索，得出法院對於政府採購契約包括但不限於勞務採購契約是否定性為定型化契約之相關判決，分別有採取肯定說及否定說，分述如下：

表 23 法院判決

壹、肯定說

最高法院 92 年度台上字第 1671 號民事判決

判決要旨：

按八十九年五月五日修正施行之民法第二百四十七條之一之規定，依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。

又依民法債編施行法第十七條規定，前揭規定於民法債編修正施行前訂定之契約，亦適用之。查上訴人於事實審辯稱：系爭契約係被上訴人事先預定之定型化契約之條款，其第五條第三款約定：「因故延期：如因甲方（即被上訴人）之原因，或人力不可抗拒等因素，致須延長完工日期時，乙方（即聯統公司）

¹³⁵ 黃明陽，定型化契約之簽約規制——以消費者保護法為中心，《消費者保護研究》第 20 輯，頁 1—44，頁 4。

¹³⁶ 陳萬愷，同前註 38，頁 59。

得以書面向甲方申請延期，甲方視其實際影響之情形酌予延期，乙方對甲方最後核定之延期，不得提出異議。」則履行契約無論是否可歸責聯統公司之事由而肇致之延誤工期，均應以被上訴人所為核定為依據，而不得提出異議，顯失公平，該條款係屬無效云云（見第一審卷第二宗二一六頁、原審卷六二頁），係屬重要之防禦方法，原審恕置不論，自有判決不備理由之違法。

臺灣臺中地方法院 109 年度建字第 34 號民事判決

判決要旨：

按依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者，民法第 247 條之 1 定有明文。系爭工程之回收瀝青黏度試驗採用「CNS 14186 無填充料瀝青黏度測定法（布魯克熱力黏度計法）」，系爭契約附件之施工說明書（甲證 16）第 02742 章「表 02742-1」規定回收瀝青黏度之檢驗、依據方法、規範之要求、頻率（見不爭執事項 3、4.），施工說明書就回收瀝青黏度之「規範之要求」為「檢驗結果偏差值：AC-20 或針入度 60-70 之新料瀝青混凝土不得超過 1. 每工程至少一批次。5,000poises $\pm$ 35%。AC-10 或針入度 85-100 之新料瀝青混凝土不得超過 3,000poises $\pm$ 35%。減價收受：檢驗結果超過 $\pm$ 35%，但在 $\pm$ 70%以下者；每超出 1%該批次檢驗代表數量減價 1%」。查被告自承系爭契約所附施工說明書第 02742 章「表 02742-1」規定係公路總局所採路面維修規範，為普遍採用之檢驗方式，亦行之多年等語（見本院卷一第 79 頁、第 81 頁），可認上開規定為被告預定於一般採購契約之共通條款，因此原告主張施工說明書 02742-10 頁回收瀝青黏度「規範之要求」規定，屬定型化契約條款，可以採信。

臺灣臺中地方法院 101 年度訴字第 2844 號民事判決

判決要旨：

系爭採購案之契約條款，固係由原告單方擬訂用於同種類契約之條款，而由參與投標並得標之廠商，依照該預定條款而訂立之定型化契約。惟系爭契約之重購價差條款，殆係原告參酌工程會訂定之財物採購契約範本第 17 條第 1 款第 8 目、第 3 款之規定擬訂；另綜觀卷附之招標投標文件所示，契約條款之字體大小均相同，並未特別將重購價差條款之字體縮小，顯無字體過小無法辨識之情形；又系爭契約之契約條款有關重購價差之約定，係民法債務不履行中損害賠償態樣之明文化規定，亦有如前述；復被告在參與投標前，已購買完整之招標投標文件，系爭採購案決標後，兩造所應簽立之書面合約內容，與被告事先購買者並無任何差異，被告在投標前就參與投標及決標之契約權利義務，已有相

當時閱覽知悉。是以，系爭採購案之定型化契約條款中有關重購價差約定，應無對被告顯失公平，應依民法第 247 條之 1 規定認為無效之情事。

臺灣南投地方法院 99 年度簡上字第 69 號民事判決

判決要旨：

按民法債編於 88 年 4 月 21 日增訂第 247 條之 1 規定「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：(1)免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。(2)加重他方當事人之責任者。(3)使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。(4)其他於他方當事人有重大不利益者。」，其立法理由係為使社會大眾普遍知法、守法，而於法文中明定附合契約之意義，並為防止此類契約自由之濫用及維護交易之公平，列舉四款有關他方當事人利害之約定，如按其情形顯失公平者，明定該部分之約定為無效。其中第 1 款、第 3 款所規定，係指一方預定之該契約條款，為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之。而所稱「按其情形顯失公平者」，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形而言，最高法院 98 年度台上字第 2075 號、1793 號判決意旨可供參照。查依卷附系爭契約所附行政院衛生署草屯療養院「大里地區房屋租賃採購案」公開徵求投標須知第 40 條記載：全份招標文件包括：…(5) 契約條款；又被上訴人自承招標文件中已載明被上訴人租用房屋之用途、租用期限及租金之起算日。則被上訴人以其單方所擬定包含租用期限及租金起算日在內之契約條款為招標文件，參與投標之廠商均須同意依該契約內容，並於得標後依契約內容與被告簽訂租約，而無參與形成契約內容之可能性，自屬定型化契約。

臺灣雲林地方法院 96 年度訴字第 102 號民事判決

判決要旨：

再者，定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋，消費者保護法第 11 條第 2 項亦有明文規定。本件兩造均為企業，雖非上開規定適用之對象。然系爭採購案契約等條款，既為被告單方預先擬定而提出供投標廠商取用投標，投標人並無事先與被告商討之餘地，核與上開規定定型化契約之情況無異。因此，上開規定定型化契約條款之解釋原則，即有以法理適用於系爭採購案相關規定之必要，即有疑義時，應為有利於投標者之解釋。

臺灣高等法院臺南分院 95 年度重上更(一)字第 16 號民事判決

判決要旨：

況上揭採購契約第二十三條第四項之約定，參諸民法第二百四十七條之一規

定：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二加重他方當事人之責任者。三使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四其他於他方當事人有重大利益者。」等語，應堪認上述採購契約第二十三條第四項之約定，顯在片面免除被告一方自身之責任，並使與其訂約之他方拋棄權利，應屬顯失公平之定型化契約約定無訛，則依民法第二百四十七條之一之規定，該部分契約約定條款應屬無效條款，上訴人台電公司新營區處之賠償責任仍無從因而卸免。

貳、否定說

臺灣臺中地方法院 102 年度訴字第 1161 號民事判決

判決要旨：

原告雖辯稱系爭契約第 21 條約定終止契約被告可向原告追還款項，不啻加重原告之責任，明顯失之公平，並使被告不需給付任何報酬即可獲得利益，使原告拋棄其原可行使之權利；且契約終止後，可追償前已撥付之款項，亦對於原告有重大不利益，依民法第 247 條之 1 第 2、3、4 款規定，該約定應屬無效云云。惟查，系爭契約係兩造針對特定之「推動農村再生－農村再生規劃」計畫所訂定之契約，其契約內容因委託服務之項目內容不同而有差異，已難認系爭契約屬定型化契約；況依系爭契約第 21 條第(三)項之約定，亦僅在可歸責於原告之事由而終止契約時，原告始負有返還前受領報酬之義務，尚無顯失公平之情形，是上開契約約定自非無效。原告上開抗辯，要非可採。

臺灣嘉義地方法院 101 年度訴字第 5 號民事判決

判決要旨：

所謂定型化契約應受衡平原則限制，係指締約之一方之契約條款已預先擬定，他方僅能依該條款訂立契約，否則，即受不締約之不利益，始應適用衡平原則之法理，以排除不公平之「單方利益條款」，避免居於經濟弱勢之一方無締約之可能，而忍受不締約之不利益，是縱他方接受該條款而締約，亦應認違反衡平原則而無效，俾符平等互惠原則。茲保證人既係擔保他人間之債務清償責任，並非經濟之弱者，且未自保證契約獲取任何利益，如認保證契約有違民法保護保證人之任意規定，自可不訂定保證契約，並不因其未為保證人而生不利益，或經濟生活受制於銀行不得不為保證之情形。是保證人如因同意某條款而訂定保證契約，該條款又屬當事人得依特約排除之任意規定，除另有其他無效之原因外，保證人即不得任指該契約條款為無效。上訴人執此抗辯保證契約顯失公平而無效，自不可取。（最高法院 93 年度台上字第 710 號判決意旨參照）被告

主張系爭契約不適用物價指數調整，且僅賦予原告意定解除之權利，反觀被告解除事由卻付之闕如，顯屬定型化契約，有違公平原則云云，為原告所否認。查，系爭契約並非原告一方預定用於同類契約而預先訂定之契約，自非定型化契約。縱認系爭契約不適用物價指數調整，及僅規定原告系爭契約解除權，然基於契約自由原則，被告可選擇是否締約與否，被告基於自由意思簽訂系爭契約，實難於簽約後再以有失公平之情事遽稱系爭契約為定型化契約，其主張委不足取。

臺灣花蓮地方法院 96 年度訴字第 258 號民事判決

判決要旨：

況依系爭條款規定意旨觀之，核非屬免除或減輕預定契約條款之當事人之責任，或加重他方當事人之責任，或限制他方當事人行使其權利之情形，該約定主要目的應在敦促投標人應理智謹慎評估將其欲投標金額納入最大風險考量，防杜投標人未做正確評量即以低價搶標，於得標後，再執工人短缺、工資、物價上漲及地區性（季節性）物價上漲為由，要求增加合約價格，而造成原本參與投標廠商競爭力不公平情形，致影響工程品質，並避免將得標廠商誤判工人短缺、工資、物價變動趨勢及地區性（季節性）等不利益，加諸於較投標專業廠商更無法評估前揭風險之定作人身上，進而減少採購機關與廠商間不必要之洽商、談判過程，以減少爭議等，以達工程風險控管之實益。故此系爭條款約定僅為兩造透過私法自治之精神，就系爭銅門溪口段角鋼桿更換工程施工期間物料、勞務等之價格或匯率波動為契約風險分配，該條款尚無對定型化契約條款之他方當事人有重大不利益而顯失公平情形。是原告主張系爭條款，加重原告負擔因岩盤之不可預見因素之風險責任，使原告原告拋棄請求增加工程款之權利，於原告有重大不利益，免除被告就工程款應負追加或變更之責任，顯失公平、合理等語及被告就系爭契約權利之行使違反誠信原則等語，洵無足採。

臺灣臺中地方法院 97 年度建字第 31 號民事判決

判決要旨：

兩造於系爭工程及追加工程完工後，因原告請求延展工期，經兩造協議後簽定系爭工期檢討彙整明細表，是系爭工期檢討彙整明細表非被告提供給各承包廠商簽訂之定型化契約。本案被告同意工程延展 18 天（原告原遲延天數為 21 天，依契約第 22 條之約定，逾期罰款為 2,520,657 元，後經兩造協議僅計算逾期 3 天，逾期罰款為 360,094 元，亦即被告同意原告延展 18 天），原告則同意放棄增加工程之工程款 1,721,774 元，顯見兩造因互相讓步而達成上開協議，並無不公平之情事，依上開系爭工期檢討彙整明細表之協議內容，原告自不得再向被告請求新增工程之工程款。至於證人吳獻成、乙○○雖於本院詰證稱若不答

應放棄增加工程之一切費用，將無法取得系爭工程之尾款云云，為被告所否認。經查，證人吳獻成、乙○○均為原告公司之員工，其所為之證述難免偏頗，且兩造互相讓步之情形已如上述，是證人所述不足採信。

資料來源：作者自行製表

本人以為雖然就大部分之政府採購契約包括但不限於勞務採購契約而言，招標機關多係採用行政院公共工程委員會訂定之範本，作為參考，並無疑義，但基於辦理標案情形之需求不同，行政院公共工程委員會訂定之範本未能符合辦理標案之具體狀況，仍會略作調整以符合招標機關需求，此其一。且行政院公共工程委員會不是政府採購契約最後契約內容之擬訂及提供者，即並非上開消費者保護法規定或民法規定之契約擬訂及提供者，而係招標機關本身，亦即並非契約當事人一方，於定型化契約適用主體上，已有疑義，此其二。政府採購契約包括但不限於勞務採購契約之訂定目的在於與單一廠商簽訂，每一政府採購契約會因採購標的、採購金額之不同，而有不同之契約內容變化出現，而該內容實屬契約之重要部分，而非能一體適用，硬要將政府採購契約包括但不限於勞務採購契約定性為定型化契約，未免有所過度強求，殊值商榷，此其三。最高法院 107 年度台上字第 1653 號民事判決肯認：「…按民法第 247 條之 1 第 1 款、第 3 款規定，依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。…三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。所稱『免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者』、『使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者』，係指一方預定之該契約條款，為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之。所謂『按其情形顯失公平者』，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形而言。系爭工程係經公開招標，被上訴人則為營造業者，其於參與投標前，對於系爭工程之工程圖說、投標須知、標單、合約書及其附件等，非無充足之時間詳細審閱，以了解得標後雙方之權利義務，倘其認契約條款對其不利，非不得提出異議或請求釋疑，亦可拒絕投標。似此情形，能否謂系爭第 18 點付款辦法，有民法第 247 條之 1 第 1 款、第 3 款所定情形而無效，即不無研求之餘地。原審遽謂該約定有上開法條所定情形，應為無效，進而為上訴人不利之判決，亦有未合。」，最高法院以有意投標之廠商就政府採

購相關招標資料文件是有充足之時間詳細審閱，以了解得標後雙方之權利義務，倘其認契約條款對其不利，非不得提出異議或請求釋疑，亦可拒絕投標，即最高法院之見解有肯認政府採購契約非全然屬於定型化契約¹³⁷，此其四。政府採購實務上為推動公共工程招標作業公開化、透明化，藉由政府採購相關案件相關招標資料文件公開閱覽，徵求廠商或民眾意見，提升公共工程規劃設計品質，以減少招標及履約爭議，此有行政院公共工程委員會公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點之相關規定可稽，且若政府採購案件相關招標資料文件不利，政府採購法設計提出異議或請求釋疑之制度，以資救濟，倘若就如部分之見解持縱使提供政府採購案件相關招標資料文件公開閱覽，僅係使廠商有知悉內容而已，仍無事前決定該內容之機會¹³⁸，及雖然政府採購法設計提出異議或請求釋疑之制度，以資救濟，但經廠商提出異議或請求釋疑，期待招標機關同意修正內容，機會甚少，作為肯認政府採購契約係屬於定型化契約之理由，將使得行政院公共工程委員會公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點及政府採購法設計之提出異議、申訴或請求釋疑之制度，形同虛設，此其五。再者，揆諸民法第 245 條之 1 規定之立法理由：「一、本條新增。二、當事人一方預定契約之條款，而由需要訂約之他方，依照該項預定條款簽訂之契約，學說上名之曰「附合契約」(contrat d'adhésion)。此類契約，通常由工商企業者一方，預定適用於同類契約之條款，由他方依其契約條款而訂定之。預定契約條款之一方，大多為經濟上較強者，而依其預定條款訂約之一方，則多為經濟上之較弱者，為防止契約自由之濫用，外國立法例對於附合契約之規範方式有二；其一，在民法法典中增設若干條文以規定之，如義大利於一九四二年修正民法時增列第一千三百四十一條、第一千三百四十二條及第一千三百七十條之規定；其二，以單行法方式規定之，如以色列於一九六四年頒行之標準契約法之規定是。以上兩種立法例，各有其優點，衡之我國國情及工商業發展之現況，為使社會大眾普遍知法、守法起見，宜於民法法典法中列原則性規定，爰增訂本條，明定附合契約之意義，為依照當事人之一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，此類契約他方每無磋商變更之餘地。為防止此類契約自

¹³⁷ 陳瑞柱，我國政府採購契約法律適用之研究－以綠化工程契約為核心，亞洲大學財經法律學系碩士論文，2020 年，頁 30。

¹³⁸ 陳萬愷，同前註 38，頁 58。

由之濫用及維護交易之公平，列舉四款有關他方當事人利害之約定，如按其情形顯失公平者，明定該部分之約定為無效。至於所謂「按其情形顯失公平者」，係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷而有顯失公平之情形而言。例如以在他人土地上有建築物而設立地上權，約定地上權期間為一年或約定買受人對物之瑕疵擔保之契約解除權為十年等是。」，似乎已將附合契約之提供者限定於工商企業者，蓋政府機關係處高權之地位，未必係屬經濟上較強者，且此條文之立法係由行政院、司法院所推動，由此可推知我國對於政府採購契約包括但不限於勞務採購契約之定性並非附合契約，僅可推論出政府採購契約包括但不限於勞務採購契約類似於定型化契約，且行政院公共工程委員會為國家中央二級政府機關，制定政府採購法時，不可能知法違法，行政院公共工程委員會訂定之政府採購契約範本必經行政院公共工程委員會考量未違反民法第 247 條之 1 規定之情形下所擬訂，已事先排除該條文規定之按其情形顯失公平者，該部分約定無效之適用機會，何況縱使有肯認政府採購契約包括但不限於勞務採購契約符合定型化契約之特徵之見解，但在我國政府採購法等法律並未賦與任何法律上之效果，果真得以適用民法第 247 條之 1 規定之法律效果，已有疑義。因此本人建議政府採購契約不妨採取視具體狀況認定是否屬於定型化契約之看法，端視締約之目的，締約之目的在於若政府採購契約係針對不特定之多數相對人所擬訂，具有反覆使用之性質，且具有降低政府採購成本、提升政府採購效率及加速政府採購過程之功能，即應歸類於具有定型化契約之性質，若政府採購契約係不針對不特定之多數相對人所擬訂，不具有反覆使用之性質，比如偏遠地區規模較小之機關或是公立學校而言¹³⁹，數年之久才辦理政府採購案件一次，即不應歸類於具有定型化契約之性質。

依據政府採購法第 7 條規定：「本法所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。本法所稱財物，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、

¹³⁹ 陳萬愷，同前註 38，頁 59。

資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。」，另分別就勞務當中之專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展之定義於機關委託專業服務廠商評選及計費辦法第3條規定、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第3條規定、機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第3條規定、政府採購法第22條第1項第13款規定定有明文，至於營運管理、維修、訓練、勞力從文字上做解釋，自可明瞭，不待法律再做定義性解釋，而就其他經主管機關認定之勞務，基於法律並未予以做定義性解釋及未能從文字上做解釋，有所缺漏，尚待政府採購實務予以補充解釋。茲就勞務當中之專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展之定義、主管機關認定之勞務於政府採購實務之解釋，分述如下：

表 24 主管機關認定之勞務於政府採購實務之解釋

	類別	定義	法條依據
一	專業服務	專業服務指提供專門知識或技藝之服務；包括法律、會計、財務、地政、醫療、保健、防疫或病蟲害防治、文化藝術、研究發展、社會福利及其他與提供專門知識或技藝有關之服務	機關委託專業服務廠商評選及計費辦法第3條規定
二	技術服務	指工程技術顧問公司、技師事務所、建築師事務所及其他依法令規定得提供技術性服務之自然人或法人所提供與技術有關之可行性研究、規劃、設計、監造、專案管理或其他服務。	機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第3條規定
三	資訊服務	指提供與電腦軟體或硬體有關之服務；包括整體規劃、系統整合、系統稽核、系統管理、網路管理、軟體開發、軟體驗證、軟體維護、硬體維護、硬體操作、機房設施管理、備援服務、網路服務、顧問諮詢、資料庫建置、資料處理、資料登錄或訓練推廣等服務。	機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法第3條規定
四	研究發展	委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研	政府採購法第22條第1項第13款規定

		究發展。	
五	主管機關認定之勞務	包括租賃、廣告、市場調查、民意調查、技術性測試分析、偵查、保全、清潔、照相、包裝、印刷、出版、會議、郵遞、快遞、電信、視聽、銷售、教育、廢水及廢棄物處理、環境衛生、金融保險、人體健康、旅遊、娛樂：文化、體育、運輸及其他與農、林、漁、牧、礦、製造、能源等有關之服務 ¹⁴⁰ 。	

資料來源：作者自行製表

誠如上述，廢棄物清理屬於其他經主管機關認定之勞務，並經實務上予以肯認廢棄物處理¹⁴¹屬於其他勞務，而應歸納為屬於政府採購法規範之「勞務採購」範圍，因此必須依據相關規定辦理之¹⁴²。目前我國就廢棄物清理歸類在行政院公共工程委員會所提供之「政府採購標的分類代碼表」裡之分類：勞務類—代碼：94—分類名稱(中文)：污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務內，政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理之採購案件，即定性為勞務之採購，所簽訂之政府採購契約即為勞務採購契約。

我國民法規定之勞務契約有僱傭、承攬及委任¹⁴³，性質上各有所差異且各有不同之條文予以規範，而就生物醫療廢棄物之委託清除、處理，所簽訂之勞務採購契約，於契約定性上應歸納為屬於勞務之委任，而屬於委任契約，或屬於清除、處理工作完成，而給付報酬之承攬，而屬於承攬契約，而有所疑義。更有認為勞務之僱傭應擴大解釋包括勞務之承攬¹⁴⁴，惟若單純按照政府採購法第2條規定之文義加以解釋，政府採購法僅將勞務採購分成兩種，包括勞務之委任及勞務之僱傭，並不包括勞務之承攬，故上開勞務採購契約似乎係屬於委任契約。亦有認為至於所謂勞務之「委任」，依民法第528條之定義，謂當事人約定，一方委託他方處

¹⁴⁰ 唐國盛律師，政府採購法律應用篇，台北永然文化出版，5版，2005年7月，頁63—64。

¹⁴¹ 陳瑞柱，同前註137，頁79—81。

¹⁴² 許耀昇，同前註28，頁6。

¹⁴³ 梁錦文，公共工程採購代辦法律關係之探討—以法律行為主體之認定及其權利(力)義務為中心，國立高雄大學法律學系研究所碩士論文，2013年1月，頁56。

¹⁴⁴ 羅昌發著，同註53，頁71。

理事務，他方允為處理之契約¹⁴⁵。惟勞務之承攬雖未明訂於政府採購法中，於實務上仍常見，將之認定為勞務之承攬，且行政院勞動部於2016年2月4日有制定政府機關（構）運用勞務承攬參考原則，其規範意旨為為使政府機關（構）、公立學校及公營事業（以下簡稱各機關）依政府採購法規定辦理勞務採購時，合理運用勞務承攬，並保障承攬人派駐勞工之權益，特訂定本參考原則，且有就勞務承攬及勞務承攬契約之定義予以規範，勞務承攬係指各機關與承攬人約定，由承攬人為各機關完成一定之工作，各機關俟工作完成，於驗收符合履約項目後，給付報酬予承攬人；勞務承攬契約係指承攬人與各機關就勞務承攬所訂立之契約，由於承攬契約重視一方完成一定之工作，他方給付報酬，故上開勞務採購契約似乎係屬承攬契約較為妥適。何況在行政院就政府採購法草案中，就勞務採購部分，採取「勞務之委任或獲得」，而非「勞務之委任或僱傭」，探究其理由在於政府機關並非單純僅以取得勞務為目的，更重視一定工作之完成，因此勞務之取得，並未僅限於勞務之委任及勞務之僱傭，勞務之承攬也屬於勞務取得方式之一¹⁴⁶，所以行政院才有上開採取「勞務之委任或獲得」之立法主張。亦有認為政府勞務採購契約有其獨占性，政府機關委請廠商進行專業技術服務，並非單純消費行為，其標準應較高，採「承攬契約說」能提高服務廠商之注意義務¹⁴⁷。又以在司法實務上，一般普遍認為應視當事人主觀意思而定，如重在工作物之完成時則應為承攬契約¹⁴⁸，此有最高法院89年台上字第831號判決：「…應探求當事人之真意，如當事人之意思重在財產權之移轉，則適用買賣之規定；當事人之意思如重在工作之完成，則適用承攬之規定。」可資參酌。且有認為如果政府機關若將勞力委由供應商處理，待供應商處理後，始給付相當報酬之採購行為型態，並不屬於勞務之委任，亦不是勞務之僱傭，而應是勞務之承攬¹⁴⁹，並提出政府機關委由民間業者進行清潔工作及委由民間業者進行噴灑消毒藥水進行滅蚊工作¹⁵⁰，作為佐例，

¹⁴⁵ 梁靜媛，政府採購稽核制度之研究，國立交通大學管理學院(管理科學學程)碩士班碩士論文，2004年1月，頁11。

¹⁴⁶ 唐國盛律師，同前註140，頁48。

¹⁴⁷ 郭希得，公立學校勞務採購契約之研究~以校外教學旅遊服務為例，國立成功大學科技法律研究所碩士論文，2008年，頁74。

¹⁴⁸ 郭希得，同前註147。

¹⁴⁹ 廖宗聖，WTO架構下政府採購協定適用範圍之研究---兼論我國政府採購法相關規定，世新大學法律學系碩士論文，2001年，頁143。

¹⁵⁰ 廖宗聖，同前註149。

而可得推知政府機關委由民間業者進行處理生物醫療廢棄物工作，亦類屬之。另有認為勞務之委任或僱傭，依民法上之概念，可能係委任契約、僱傭契約或承攬契約，同樣必須依具體情形個案判斷之¹⁵¹。本人以為基於政府採購法中並無勞務承攬之具體明文，不無顯有疏漏，而應予以納入才是，以杜爭議，且基於我國加入世界貿易組織(WTO)，並簽署政府採購協定(Agreement On Government Procurement，簡稱GPA)，在政府採購協定中採取服務之字樣，服務所包含之範圍較廣泛，服務之型態即包括但不限於勞務在內，為求政府採購法與國際經貿法規接軌¹⁵²，得以服務取代勞務。另有認為就勞務僱傭之情形觀之，所有僱傭關係都牽扯政府採購法以外之人事法規，屬於政府機關組織體本身之問題，而非對外之採購行為，只要經過一定甄選程序即可，並不需適用政府採購法¹⁵³，而有建議刪除僱傭之文字之主張，本人以為目前實務上就機關僱傭臨時人力之採購程序，行政院公共工程委員會有以95年2月23日工程企字第09500066431號函頒「機關依政府採購法僱用臨時人力參考作業方式」，其內之第壹條規定：「適用情形一、適用於以機關名義僱用自然人之採購案件。二、依人事法規、科學技術基本法第6條第3項規定辦理者，不適用政府採購法（以下簡稱採購法）」，嗣又以95年7月5日工程企字第09500243340號令發布：「機關非以人事經費僱用自然人為非正式編制臨時人員，其比照人事法規進用程序辦理，且訂有管理、考核規定者，不適用政府採購法。」，重申行政院公共工程委員會對於機關僱傭臨時人力之採購程序之看法，亦即行政院公共工程委員會之立場為依人事法規、科學技術基本法第6條第3項規定辦理，不適用政府採購法，非以人事法規、科學技術基本法第6條第3項規定辦理者，則屬於勞務僱傭，應依政府採購法辦理，是以既然行政院公共工程委員會已開宗明義宣示以機關名義僱用自然人得適用政府採購法之空間，有關建議刪除僱傭之文字之主張，得作參考，但本人傾向採取繼續維持僱傭文字之存在，較為妥適。故得透過修法方式，將勞務之委任或僱傭修改成「服務之委任、僱傭、承攬或其他以有償契約對指定服務之採購」¹⁵⁴，亦即政府採購法第2條之規定得修

¹⁵¹ 陳柏涵，政府採購法圖標罪之研究-以實務判決為中心，國立中正大學法律學系碩士論文，2020年7月，頁11。

¹⁵² 廖宗聖，同前註149，頁142。

¹⁵³ 廖宗聖，同前註149。

¹⁵⁴ 廖宗聖，同前註149。

改為「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及服務之委任、僱傭、承攬或其他以有償契約對指定服務之採購」，較為適宜及妥當。甚有認為勞務採購契約應定性為「無名契約」，而視實際狀況適用債法各論各項契約之規定，此有司法院院字第 2287 號解釋：「委任與承攬於契約履行之過程中，皆以提供勞務給付作為手段，在性質上同屬勞務契約。然受任人提供勞務旨在本於一定之目的，為委任人處理事務，其契約之標的重在『事務之處理』；至於承攬人提供勞務乃在為定作人完成一定之工作，其契約之標的重在『一定工作之完成』。因此，民法各種之債乃將委任與承攬分別規定為兩種不同之有名契約（民法第四百九十條第一項、第五百二十八條）。苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，且各具有一定之分量時，其既同時兼有『事務處理』與『工作完成』之特質，即不能再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約。」可稽。實際上，各種政府採購契約於民法上之定性，在實務上亦有許多爭議¹⁵⁵，茲就有關僱傭、委任、承攬之契約之比較，如下：

表 25 僱傭、委任、承攬之契約性質比較

	僱傭	委任	承攬
契約歸類	勞務契約	勞務契約	勞務契約
目的	給付勞務	工作完成	事務處理
性質	雙務有償契約	雙務單務 有償/無償	雙務有償契約
勞務專屬性	無獨立裁量權	有獨立裁量權	有獨立裁量權
書面	諾成契約	諾成契約	諾成契約
契約期間	繼續性契約	繼續性契約	繼續性契約
請求權時效	5 年	15 年	2 年

資料來源：作者自行製表

基於在法律上有加以規定其名稱之契約稱為「有名契約」，亦稱為「典型契約」，我國民法債編第二章各種之債中，所列之有名契約，計有：買賣、互易、

¹⁵⁵ 陳柏涵，同前註 151。

交互計算、贈與、租賃、借貸、僱傭、承攬等；另外，其他法律所規定之契約亦為有名契約，例如海商法所規定各種運送契約，保險法所規定之保險契約，均屬有名契約；上述有名契約以外，而法律未加以規定者，則稱為「無名契約」，或稱為「非典型契約」，蓋世事萬變，法律有窮，法律所未規定之契約，只要不違背公序良俗和其他強制法規，在契約自由之原則下，當事人間可自由創設、約定成立新契約種類，這類契約常混合數個有名契約，因此，這類契約也稱為「混合契約」。常見之無名契約有：簽帳卡契約、合建契約、代理店契約、廣告契約及醫療契約¹⁵⁶。而混合多種類型之無名契約，必須輔以民法債編各論之條文來加以定性¹⁵⁷。

有認為就「非典型契約」仍可分為純粹之非典型契約、混合契約及契約聯立三類。純粹非典型契約係以典型契約以外之事項為內容，在性質上係屬於一個契約；混合契約係數個典型或非典型契約之部分而構成之契約，在性質上亦係屬於一個契約，當中又有區分為典型契約附其他種類之從契約、典型結合契約、雙種典型契約（又稱混血兒契約）、類型融合契約（又稱狹義混合契約）等四類型，法律適用上有採取吸收說、結合說及類推適用說，有認為採取吸收說，可能面臨存在不容易區別及判斷主要部分與非主要部分之缺點，採取結合說亦面臨存在忽視各個典型契約各自獨立目的與作用之弊端，採取類推適用說，就混合契約之各個構成部分類推適用關於典型契約所設置之規定，在類推適用時，應斟酌當事人訂立契約時所欲達成之經濟上之目的與社會上之機能，目前學者通說即採取類推適用說；契約聯立係數個典型或非典型契約具有相互結合之關係，又包括單純外觀結合及具有一定依存關係之結合，在性質上亦係屬於複數契約，前司法院大法官王澤鑑教授之著書「債法原理第一冊（自刊）」亦採取此一見解¹⁵⁸。有時契約聯立具有一定依存關係之結合與混合契約不易區別，而必須透過當事人意思表示之解釋始能獲致答案。也就是倘若當事人締約之經濟目的並不重視契約個別特性時，

¹⁵⁶ 聯晟法網，同前註 123。

¹⁵⁷ 洪佳如，論公共工程採購契約之違約金條款，國立成功大學法律學研究所碩士論文，1996 年，頁 71。

¹⁵⁸ 王澤鑑，債法原理第一冊，自刊，頁 122—126。

不無將之視為一整體而以混合契約看待¹⁵⁹，頗值參考。又有認為政府採購契約，尤以勞務採購契約，重視工作之完成，基本上具有承攬契約之性質，只是在承攬契約以外，兼具有其他有名契約之性質，但是只占契約中之一小部分¹⁶⁰，殊值可參。

本人以為，綜觀勞務採購契約之內容，應不僅包括一種契約法律關係，通常亦有包括數種契約法律關係在內，也就是可以稱之為混合契約，若以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，其與政府機關或政府機關所屬事業簽訂勞務採購契約後，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司處理生物醫療廢棄物完成，而政府機關或政府機關所屬事業給付報酬，即似乎係屬於承攬契約，其他遵守法令、投保等又似乎屬於委任契約，依據學說見解，混合契約為民法無名契約之一種。相較於有名契約，無名契約法律上並未賦予特定名稱，而係由當事人基於契約自由，於不違反法律強行規定或善良風俗前提下，由當事人自行創設，又稱為非典型契約。且依據司法院 31 年 1 月 27 日院字 2287 號解釋有謂：「混合契約，係由典型契約構成分子與其他構成分子混合而成之單一債權契約。若其契約係屬複數而於數契約間具有結合關係者，則為契約之聯立。」。簡而言之，所謂混合契約係指有兩種以上契約類型內容之契約。雖然此種契約類型包含兩個以上契約內容，惟其性質上仍為單一契約。此與數個契約互相併存，性質上各自獨立之聯立契約仍屬有間。且遇到存在一契約存在混合契約之態樣而發生糾紛時，須端視糾紛之發生所牽扯之契約條文規定，涉及有所符合民法上何一契約類型，而依據該符合之民法上契約類型之規定來處置。此有最高法院 103 年度台上字第 560 號民事判決：「當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，且各具有一定之分量時，其既同時兼有『事務處理』與『工作完成』之特質，即不能再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約（司法院院字第二二八七號解釋參照），而成為一種法律所未規定之無名勞務契約。」及最高法院 107 年台上字第 1428 號民事判決：「次按混合契約係以二個以上契約應有之內容合併為其內容之單一契約，當事人負有數個不同類型權利義務，應分別適用各該權利義務所屬契約之類型之法律規定，以判斷其效力。」可資參照。

¹⁵⁹ 黃俊通，同前註 67，頁 112。

¹⁶⁰ 陳瑞柱，同前註 137，頁 76。

亦有認為以勞務採購契約而論，通常可能具有承攬契約之內容，也有可能包括委任契約之內容，若屬於由委任契約及承攬契約兩種勞務契約之成分所組成之混合契約，遇有彼此間之成分特徵不易截然分解及辨識時，得以適用民法委任之相關規定，判斷當事人間權利義務關係，此有最高法院 107 年度台上字第 1394 號民事判決：「按基於私法自治原則，當事人間之契約不限於民法上之有名契約，其他非典型之無名契約，仍得依契約性質而類推適用關於有名契約之規定。而委任與承攬於契約履行之過程中，皆以提供勞務給付作為手段，性質上同屬勞務契約。然受任人提供勞務旨在本於一定之目的，為委任人處理事務，其提供勞務，應依委任人之指示，其契約之標的重在『事務之處理』；至於承攬人提供勞務乃在為定作人完成一定之工作，其服勞務具有獨立性，不受定作人之指揮監督，其契約之標的重在『一定工作之完成』。因此，民法各種之債乃將委任與承攬分別規定為兩種不同之有名契約（民法第 490 條第 1 項、第 528 條）。苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，並各具有一定之分量，且各該成分之特徵彼此不易截然分解及辨識，而當事人復未就法律之適用加以約定時，其既同時兼有『事務處理』與『工作完成』之特質，自不應再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約（司法院院字第 2287 號解釋參照），成為一種法律所未規定之無名勞務契約，以利於法律之適用，俾符合當事人之利益狀態及契約目的。復以委任契約為最典型及一般性之勞務契約，為便於釐定有名勞務契約以外之同質契約所應適用之規範，俾契約當事人間之權利義務關係有所依循，民法第 529 條乃規定：『關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。』故有關由委任與承攬兩種勞務契約之成分所組成之混合契約，而彼此間之成分特徵不易截然分解及辨識時，其整體之性質既屬於勞務契約之一種，自應依該條之規定，適用關於委任之規定，庶當事人間之權利義務關係得以確立。」，殊值可參。亦即該判決肯認勞務採購契約之定性的確有屬於混合契約之可能，若個別契約之內容能定性為屬於民法承攬契約之性質或能定性為符合民法委任契約之性質，分別從其民法承攬契約相關規定或民法委任契約相關規定，若無法判別時，而統一適用民法委任契約相關規定。至於其他態樣之政府採購契約，諸如工程購契約、財物採購契約，如遇有契約類型屬於混合契約之情形時，仍有比照辦理之可能性。

又最高法院 109 年度台上字第 1021 號判決：「按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係。倘當事人所訂定之契約，其性質究係屬成文法典所預設之契約類型（民法各種之債或其他法律所規定之有名契約），或為法律所未規定之契約種類（非典型契約，包含純粹之無名契約與混合契約）有所不明，致造成法規適用上之疑義時，法院即應為契約之定性（辨識或識別），將契約內容或待決之法律關係套入典型契約之法規範，以檢視其是否與法規範構成要件之連結對象相符，進而確定其契約之屬性，俾選擇適當之法規適用，以解決當事人間之紛爭。而當事人訂定不能歸類之非典型契約，於性質相類者，自仍可類推適用民法或其他法律相關之規定。此項契約之定性及法規適用之選擇，乃對於契約本身之性質在法律上之評價，屬於法院之職責。」，該判決肯認當事人得創造出新型態之契約，以滿足當事人間不同之需求，以因應資訊經濟交易或網路社會活動之千變萬化。

至於有關勞務採購契約之定性，影響所及，最主要在於報酬請求權之請求時效之問題，依據民法第 125 條規定：「請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。」、民法第 127 條規定：「左列各款請求權，因二年間不行使而消滅：一、旅店、飲食店及娛樂場之住宿費、飲食費、座費、消費物之代價及其墊款。二、運送費及運送人所墊之款。三、以租賃動產為營業者之租價。四、醫生、藥師、看護生之診費、藥費，報酬及其墊款。五、律師、會計師、公證人之報酬及其墊款。六、律師、會計師、公證人所收當事人物件之交還。七、技師、承攬人之報酬及其墊款。八、商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價。」，基此，上開民法之規定為報酬請求權之消滅時效之規定，在勞務採購契約未定性之前，實無法判定其報酬請求權之時效，勞務採購契約如定性為承攬契約，則其報酬請求權之時效為 2 年，勞務採購契約定性為委任契約或其他類型，則其報酬請求權之時效或為 15 年，罹於報酬請求權時效，報酬請求權消滅，當廠商仍主張請求報酬，而機關即可主張時效抗辯，拒絕給付，影響廠商權益甚鉅，尤以得於訴訟上作為攻擊或防禦之方法，影響訴訟之勝敗¹⁶¹。

¹⁶¹ 陳柏涵，同前註 151。

本人以為目前我國關於勞務採購之型態千變萬化，具有多樣性，不適合無差別予以定性，若強加予以定性，恐怕窒礙難行，因此本人肯認應勞務採購之定性多樣性。惟就廢棄物清理之單一模式，本人建議就廢棄物清理，基於保障廠商之權益，得於勞務採購契約內明訂報酬或其他主張之請求權時效期限，以供招標機關或廠商有所遵循。

另經本人整理目前國內就勞務採購契約定性之判決，本人以司法院「法學資料檢索系統」輸入關鍵字「勞務採購契約」連同「定性」一併同時輸入檢索，基於國內對於勞務採購契約涉及契約定性之判決甚多，本人僅就台灣高等法院及其分院之判決作討論，而臺灣高等法院高雄分院未有勞務採購契約涉及契約定性之判決，是以本人僅引據臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院花蓮分院之判決，分析如下：

壹、臺灣高等法院 106 年度重上字第 142 號民事判決(108.7.30)

一、判決要旨

按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係。倘當事人所訂定之契約，其性質究係屬成文法典所預設之契約類型（民法各種之債或其他法律所規定之有名契約），或為法律所未規定之契約種類有所不明，致造成法規適用上之疑義時，法院即應為契約之定性（辨識或識別），將契約內容或待決之法律關係套入典型契約之法規範，以檢視其是否與法規範構成要件之連結對象相符，進而確定其契約之屬性，俾選擇適當之法規適用，以解決當事人間之紛爭。此項契約之定性及法規適用之選擇，乃對於契約本身之性質在法律上之評價，屬於法院之職責，與契約之解釋係就契約客體（契約內容所記載之文字或當事人口頭所使用之語言）及解釋上所參考之資料（如交易或商業習慣）之探究，以闡明契約內容之真正意涵，並不相同，自可不受當事人所陳述法律意見之拘束（最高法院 103 年度台上字第 560 號判決意旨參照）。又按委任與承攬於契約履行之過程中，皆以提供勞務給付作為手段，在性質上同屬勞務契約。然受任人提供勞務旨在本於一定之目的，為委任人處理事務，其提供勞務，應依委任人之指示，其契約之標的重在「事務之處理」；至於承攬人提供勞務乃在為定作人完成一定之工作，其服勞務具有獨立性，不受定作人之指揮監督，其契約之標的重在「一定工作之完成」。因此，民法各種之債乃將委任與承攬分別規定為兩種不同之有名契約（民法第 490 條第 1 項、第 528 條）。除各具一定分量特徵彼此不易截然分解及辨識，當事人復未就法律適用加以約定時，而應歸入非典型混合契約外，自仍應適用各該有名契約之規定，以確立當事人間之權利義務關係。查系爭契約第 2 條第 1 款標的為「違反道路交通違規案件入案作業委託服務」契約，為勞務採購契約。惟契約性質並不以形式上之名稱為斷，仍應依前揭說

明，判別其標準。上訴人依契約名稱而主張系爭契約為委任契約云云，尚難據以採憑，本院自不受拘束。

二、評析

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定。

貳、臺灣高等法院 105 年度重上字第 330 號民事判決(105.11.29)

一、判決要旨

按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部。民法第 490 條定有明文。是契約約定由承攬人供給材料之情形，如未就材料之內容及其計價之方式為具體約定，應推定該材料之價額為報酬之一部，除當事人之意思重在工作物（或材料）財產權之移轉，有買賣契約性質者外，當事人之契約仍應定性為單純承攬契約。次按所謂製造物供給契約，乃當事人之一方專以或主要以自己材料，製成物品供給他方，而由他方給付報酬之契約。此種契約之性質，究係買賣抑或承攬，仍應探求當事人之真意釋之。如當事人之意思，重在工作之完成，應定性為承攬契約；如當事人之意思，重在財產權之移轉，即應解釋為買賣契約；兩者無所偏重或輕重不分時，則為承攬與買賣之混合契約，並非凡工作物供給契約即屬承攬與買賣之混合契約（最高法院 102 年度台上字第 1468 號判決意旨參照）。

二、評析

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定。

參、臺灣高等法院 103 年度建上字第 29 號民事判決(105.4.19)

一、判決要旨

按承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之。工作係分部交付，而報酬係就各部分定之者，應於每部分交付時，給付該部分之報酬，民法第 490 條第 1 項、第 505 條分別定有明文。又民法第 490 條第 1 項規定，承攬契約之承攬人，倘未完成承攬之工作，即無報酬請求權。此與委任契約之受任人，於受委託事務處理完畢，不論有無結果，均得請求報酬之情形不同（最高法院 98 年度台上字第 504 號判決意旨參照）。查兆盈公司辯以系爭契約第 6 條第 1 項第 1 款、第 8 項第 7 款第 1 目之約定，其應指派計畫主持人負責執行，且不得轉包，屬著重事務處理過程與當事人間信賴關係之委任契約；另系爭契約第 1 條第 2 項並未約定須「完成」各項服務內始能請款，第 5 條約定依工作進度分期給付，與民法第 490 條第 1 項給付承攬報酬之規定不符，且鐵工局在原審民事準備書(三)狀與律師函皆認為委任契約云云，並提出

98年6月5日律師函為憑（見原審6卷252至253頁）。惟依系爭契約第5條付款辦法之約定，兆盈公司提出上開3項服務工作，經鐵工局核定通知後，依各服務工作進度，以固定比率分期給付服務費，與民法第505條第2項規定依工作各部分給付報酬之規定相符，顯具有完成一定工作始得支領報酬之承攬特性，與不問有無完成一定工作，只要提供勞務為事務處理，即得請領報酬之委任性質不同。再查，政府採購法第65條規定禁止轉包，避免廠商將應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行之流弊，則系爭契約第6條第8項第7款約定，兆盈公司不得轉包，但可為分包，並就分包廠商履約部分負完全責任，顯係採用政府採購法上開避免轉包弊病所為之約定，並非高度信賴專屬性之委任約款。另鐵工局原審準備(三)狀係主張兆盈公司須無可歸責之終止事由，始得請領已處理但未處理完畢工作部分報酬（見原審3卷132頁），並未主張系爭契約屬委任性質。雖鐵工局律師函論及委任條款，但關於契約之定性，即法律上如何評價契約性質，屬法律適用之範圍，法院並不受當事人主張法律見解所拘束，本院以系爭契約既重在工作之完成，應定性為承攬契約，並非委任契約。

二、評析：

此判決肯認勞務採購契約應就契約之重心所在而適用民法各種債編之規定。

肆、臺灣高等法院臺中分院 108 年度上字第 156 號民事判決(109.1.22)

一、判決要旨

一、系爭工程契約與系爭監造契約之定性：（一）關於系爭工程契約：被上訴人主張系爭工程契約係買賣契約，為潔鼎公司所否認，並抗辯稱係承攬契約云云。按系爭工程契約之性質，究係買賣，抑屬承攬？自以依當事人之意思而為解釋，以資定之。如當事人之意思，重在工作之完成（勞務之給付），適用承攬之規定；側重於財產權之移轉者，適用買賣之規定；兩者無所偏重或輕重不分時，則認為承攬與買賣之混合契約，關於工作之完成，適用承攬之規定，關於財產權之移轉，即適用買賣之規定（最高法院59年台上字第1590號、102年度台上字第1468號裁判參照）。查依系爭工程契約第1條第4項「計畫需求」之約款、工程估價單、單價分析表所示（見原審卷一第20頁背面至第21頁、37-41頁），可知得標廠商之施工內容，包括施作廠房結構、進料輸送機系統、人工分選台作業、滲出水收集系統、出水收集系統、雨水排水系統、洗車設施、水電工程系統、消防設施等完成一定工作之工程部分，及單純由得標廠商向他人購買垃圾壓縮打包機、垃圾進料鏟裝車全套及壓縮塊搬運使用之吊裝平板車等機具部分，且依工程估價單所示，可知關於應依約提供之「鏟裝車就」、「吊裝式平板車」，亦有具體約定材料內容及計價方式（見原審卷一第40頁）。而觀諸系爭工程契約之採購目的，係在苗栗縣頭份市區域性一般廢棄物處理廠內，建置垃圾壓縮打包機具設備工程，顯然亦非單獨採購上開機具而已，仍須施作其他輔助之工程設施，堪認系爭工程契約雙方就上開機具之財產權移轉及

輔助設備工程之完成，無所偏重，揆諸前揭說明，應認屬買賣及承攬之混合契約；關於系爭鏟裝車、吊裝式平板車之採購部分，係側重在財產權之移轉，應適用買賣之規定。基此，潔鼎公司抗辯稱系爭鏟裝車、吊裝式平板車應適用承攬規定云云，委不可採。（二）關於系爭監造契約：被上訴人主張系爭監造契約係委任契約，為潔鼎公司所否認，並抗辯稱係承攬契約云云。按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約，民法第490條第1項、第528條分別有明定。換言之，民法第490條第1項規定，承攬契約之承攬人，倘未完成承攬之工作，即無報酬請求權。此與委任契約之受任人，於受委託事務處理完畢，不論有無結果，均得請求報酬之情形不同（最高法院98年度台上字第504號裁判參照）。查系爭監造契約之名稱為「頭份鎮垃圾壓縮打包機具設備工程—工程專案管理（含監造）技術服務勞務採購」，契約第1條「履約標的」約定利奇公司應給付之標的及工作事項包括：協辦招標及決標、監造（其中（一）指定負責技師負責本案之監造責任，並派遣一位具備土木及相關科系之人員，於統包案施工期間留駐工地，監督、查驗統包案廠商履約…；（五）應辦理督導及查核廠商辦理材料及品質管理工作。）、其他服務，細繹其工作事項內容，乃係被上訴人針對系爭工程，委託利奇公司之招標、決標、監造及其他服務等勞務內容，協助處理，核均屬處理一定事務之性質。再參諸系爭監造契約第4條「契約價金之給付條件」第1、2款約定：「一、本契約採購案屬上級補助者，應俟上級補助款撥入本所鎮庫後，始得付款。二、工程專案管理、施工監造費，於本契約範圍全部工程完驗收合格結算後，一次付清。」，可知僅在約定付款時點，對照系爭工程契約第6條「付款辦法」係約定：「一、契約價金之給付，依甲方核定之項目內容、經乙方實際施作數量結算與設計服務費用之合計總決算數額給付…於每月為一期估驗計價撥付估驗款一次…撥付該期完成工程價值百分之九十。估驗款每期均應扣除百分之十作為保留款…」此等一般具承攬性質之報酬，係以完成之工作進度結算可請領之各期工程款，可知二者明顯不同。揆諸前揭說明，被上訴人主張系爭監造契約性質上應屬委任性質，洵屬有據，堪予採認。利奇公司以承攬契約云云置辯，即不可採。

二、評析

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定。

伍、臺灣高等法院臺中分院106年度上字第497號民事判決(107.8.22)

一、判決要旨

稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，

給付報酬之契約；約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部，民法第 490 條定有明文。準此，契約約定由承攬人供給材料之情形，如未就材料之內容及其計價之方式為具體約定，應推定該材料之價額為報酬之一部，除當事人之意思重在工作物（或材料）財產權之移轉，有買賣契約性質者外，當事人之契約仍應定性為單純承攬契約。又所謂製造物供給契約，乃當事人之一方專以或主要以自己之材料，製成物品供給他方，而由他方給付報酬之契約。此種契約之性質，究係買賣抑或承攬，仍應探求當事人之真意釋之。如當事人之意思，重在工作之完成，應定性為承攬契約；如當事人之意思，重在財產權之移轉，即應解釋為買賣契約（最高法院 59 年台上字第 1590 號判例參照）；兩者無所偏重或輕重不分時，則為承攬與買賣之混合契約，並非凡工作物供給契約即屬承攬與買賣之混合契約（最高法院 102 年度台上字第 1468 號裁判要旨參照）。

二、評析

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定。

陸、臺灣高等法院臺中分院 103 年度建上字第 7 號民事判決(104.5.12)

一、判決要旨

按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係。倘當事人所訂定之契約，其性質究係屬成文法典所預設之契約類型（民法各種之債或其他法律所規定之有名契約），或為法律所未規定之契約種類（非典型契約，包含純粹之無名契約與混合契約）有所不明，致造成法規適用上之疑義時，法院即應為契約之定性（辨識或識別），將契約內容或待決之法律關係套入典型契約之法規範，以檢視其是否與法規範構成要件之連結對象相符，進而確定其契約之屬性，俾選擇適當之法規適用，以解決當事人間之紛爭。此項契約之定性及法規適用之選擇，乃對於契約本身之性質在法律上之評價，屬於法院之職責，與契約之解釋係就契約客體（契約內容所記載之文字或當事人口頭所使用之語言）及解釋上所參考之資料（如交易或商業習慣）之探究，以闡明契約內容之真正意涵，並不相同，自可不受當事人所陳述法律意見之拘束。又委任與承攬於契約履行之過程中，皆以提供勞務給付作為手段，在性質上同屬勞務契約。然受任人提供勞務旨在本於一定之目的，為委任人處理事務，其契約之標的重在「事務之處理」；至於承攬人提供勞務乃在為定作人完成一定之工作，其契約之標的重在「一定工作之完成」。因此，民法各種之債乃將委任與承攬分別規定為兩種不同之有名契約（民法第 490 條第 1 項、第 528 條）。苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，且各具有一定之分量時，其既同時兼有

「事務處理」與「工作完成」之特質，即不能再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約（司法院院字第 2287 號解釋參照），而成為一種法律所未規定之無名勞務契約。復以委任契約為最典型及一般性之勞務契約，為便於釐定有名勞務契約以外之同質契約所應適用之規範，俾契約當事人間之權利義務關係有所依循，民法第 529 條乃規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定契約之種類者，適用關於委任之規定。」故有關由委任與承攬二種勞務契約之成分所組成之混合契約，性質上仍不失為勞務契約之一種，自應依該條之規定，適用關於委任之規定，庶符立法之旨意。

二、評析

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得適用民法委任之規定。

柒、臺灣高等法院臺南分院 103 年度重上字第 110 號民事判決(104.12.10)

一、判決要旨

按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約，民法第 490 條第 1 項、第 528 條分別定有明文。又民法第 490 條第 1 項規定，承攬契約之承攬人，倘未完成承攬之工作，即無報酬請求權。此與委任契約之受任人，於受委託事務處理完畢，不論有無結果，均得請求報酬之情形不同（最高法院 98 年度台上字第 504 號判決意旨參照）。準此，委任契約與承攬契約皆以提供勞務給付為手段，惟受任人係基於一定之目的為委任人處理事務，重視彼此之信賴關係，原則上不得使第三人代為之，亦不以有報酬之約定及有一定之結果為必要；而承攬契約則重在一定工作之完成，以獲取報酬，較不重視彼此之信賴關係，承攬人原則上得使第三人代為之，且以有一定之結果為必要。是委任契約之受任人提供勞務，為委任人處理事務，而承攬契約之承攬人亦在提供勞務，完成一定之工作，故該二契約之性質，有其相近之處，而一定工作之完成與一定事務之處理，在概念上有時難予區分，且除民法關於該二契約之強制規定外，當事人非不得以契約另為特別約定，致使當事人所為之約定，在性質上究屬承攬契約或有償委任契約更易混淆不清，此時即應探究契約當事人之真意，不能拘泥其於所用之文句，亦非得以契約某條文之約定逕為論斷。惟承攬契約與有償委任契約在性質上固有上述相近之處，然承攬人對其完成工作，應負瑕疵擔保責任（民法第 492 條），此為委任契約所無；另承攬契約之定作人得隨時終止承攬契約（民法第 511 條），而承攬人則無隨時終止契約之權，且性質上亦無終止權，僅於有解除契約之原因時，有解除權，而委任契約則當事人任何一方，得隨時終止契約（民法第 549 條第 1 項），以上承攬契約與委任契約特殊差異之處，得資為該二契約判斷之參考。查系爭契約之勞務名稱固為「台南縣環保科技學園管理/實驗廠房暨支援設施新建工

程委託專案管理（含監造）」契約，然並不能僅以「委託」二字而逕為認定系爭契約為委任契約。再由系爭契約之投標須知可知被上訴人招標本案之緣由，在於系爭工程之「規劃審查、設計審查、施工督導與履約管理、施工監造」（見原審補字卷第20頁反面），又依系爭契約第3條第3項約定上訴人之給付標的及工作事項：「1.規劃與可行性評估之諮詢及審查。2.設計之諮詢及審查。3.招標發包之諮詢及審查。4.施工督導與履約管理之諮詢及審查。5.施工監造。6.其他服務。」，並於系爭契約第4條第5項至第7項約定，上訴人應提出工作月（季）報、工作成果及工作結束後將成果交付被上訴人（見原審補字卷第10、11頁），核其內容均屬為完成一定之工作。而依兩造不爭執之事項（一）所示，系爭契約第5條約定服務費用依建造費用百分比法，服務費用如下表（一）計算。第7條（一）約定：「付款辦法1.完成第3條第3項第1款應辦之規劃事項、提出工作計畫書，並由廠商提出報告（含簡報），並經機關審查核定後，得申請機關支付契約價金總額之百分之10。2.完成第3條第3項第2款應辦之事項，由廠商提出報告（含簡報），並經機關審查核定後，得申請機關支付契約價金總額之百分之25。3.完成施工廠商甄選/簽約，得申請契約價金總額之百分之10。4.施工監造階段：廠商依工程施工進度達百分之30、60、90（以施工廠商完成施工之工程估驗金額占施工之總工程金額比率為準），得申請機關支付契約價金總額之百分之15。5.結案階段：廠商於全部各項工程完成正式驗收及完工結算及取得必要之證照，並完成接水、接電等手續及協助機關辦理設備移交清點、測試運轉及改善後，提出至請款日為止之彙整工作報表及相關文件，給付契約價金之尾款。」，由上約款可知系爭契約著重上訴人須完成一定之工作，且係採系爭工程建造費用實作數量之百分比方式結算，上訴人僅得就系爭工程實際完成之建造費用百分比之取得工作報酬，足認系爭契約之性質屬承攬契約，而非委任契約。

二、評析

此判決肯認勞務採購契約應就契約之重心所在而適用民法各種債編之規定。

捌、臺灣高等法院臺南分院97年度建上字第20號民事判決(99.9.21)

一、判決要旨：

系爭勞務採購契約應為委任與承攬之混合契約，依據民法第五百二十九條，應適用委任之相關規定：1.上訴人主張兩造間所成立勞務採購契約書，為委任契約。係以建築師法第十六條規定，並舉最高法院九十二年度台上字第一六〇三號判決認定兩造應為委任關係；復以系爭邀標書明載委託技術服務、委託服務項目及內容、上訴人委託被上訴人規劃之項目屬於建築師法第十六條得接受委託之業務、被上訴人依約應提出期初、期中、期末規劃報告，與民法第五百四十條受任人應將委任事務進行之狀況、事務之顛末向委任人報告、委任

人依民法第五百三十五條得為指示，而被上訴人得依其專業裁量而為設計監造為由。而被上訴人初則主張為具有委任、承攬之混合契約（見原審建字卷第二三頁），嗣改稱為承攬契約。係以：於系爭評選須知第三條(三)項規定招標方式為單獨承攬、第十三條第(一)項規定本案採單獨承攬、系爭勞務採購契約第三條、第二條規定被上訴人所為之規劃須交由上訴人送審，並依審查意見修正完妥至審查通過為止，被上訴人無獨立決定權、系爭契約第七條服務費之給付、第十二條第一項約定標的應符合契約約定、第十三條第六項瑕疵修補之約定，均與承攬之規定相符為由。2.按於契約自由之原則下，當事人所訂立之契約，並不以法定之有名典型契約為限，其因契約內含有多種契約之實質而構成混合契約或多種契約相互結合成為聯結契約之情形亦所多有；而混合契約係以二個以上有名契約應有之內容合併為其內容之單一契約，兩者有不可分割之關係。至於當事人間所約定之給付，是否符合法定契約類型所定之特徵，應探求當事人真意及契約目的定之；亦即，兩造間所成立者，或為委任，或為承攬，或為無名之混合契約，端視契約實際約定之內容及其屬性如何定之，不可一概而論。次按「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。」、「建築師受委託設計之圖樣、說明書及其他書件，應合於建築法及基於建築法所發布之建築技術規則、建築管理規則及其他有關法令之規定；其設計內容，應能使營造業及其他設備廠商，得以正確估價，按照施工。」、「建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守左列各款之規定：一監督營造業依照前條設計之圖說施工。二遵守建築法令所規定監造人應辦事項。三查核建築材料之規格及品質。四其他約定之監造事項。」建築師法第十六條、第十七條及第十八條分別定有明文。而實務上，就當事人委託建築師上開業務所定契約之類型，依據上開條文載明「委託」字樣，雖多認為係委任契約（最高法院九十二年度台上字第一六〇三號判決參照），然一方面建築師法就上開契約，畢竟無明文規定其所定契約之類型，另一方面，基於契約自由，仍應容許契約之當事人就其需求訂定契約類型，而非以法定有名契約為限。故而，是否符合法定契約類型（例如承攬、委任）？抑或基於實際需求，而為其它無名契約之類型，自應依探求當事人真意及契約目的定之。3.經查：依兩造所提出之上述特徵判斷，系爭契約應為勞務契約。兩造訂立系爭勞務採購契約，乃源於上訴人欲將仁愛之家老舊建築物整修，以符合公共安全及消防安全之相關法令；而系爭勞務採購契約之標的僅係：勘查地形、製作設計工程圖說、編制工程預算書、施工說明書、補充說明書（含材料及設備規範）、協助發包、供給工程圖說、工程監造、施工品質管制、規劃與可行性研究、設計、協辦招標及決標、施工監造以及其它服務（系爭採購契約第三條履約工作事項參照，見原審補字卷第九至一〇頁），而非整修仁愛之家老舊建築物之承攬契約。因系爭工程涉及建築等多項專業，故上訴人擬具系爭

邀標書，先行邀請符合政府採購法第八條之廠商參與投標，代上訴人進行專業規劃，以供承包廠商據以施工。次查，如重視設計者之資格、能力，而不論能否設計完成，均委任其處理，固可解為委任契約；然系爭契約約定俟工作完成給付報酬，亦具有承攬契約之特性。而建築師接受委託辦理建築物及其實質環境之調查等業務、規劃設計、監造等業務，建築師法訂有相關規定及限制，已如前述；而系爭契約約定履約工作事項，觀諸前揭建築師法接受委託辦理調查等業務、規劃設計、監造之規定，則應無二致。復查，民法上委任與承攬，雖均屬供給勞務契約，惟委任契約重在處理事務，委任人與受任人之間，具有信賴關係，且原則上為無償；而承攬關係，則以完成一定工作為目的，且定作人對於承攬人原則上應給付報酬。承上所述，系爭採購契約性質上並非民法上典型之承攬或委任契約，而應為「設計委託契約」。應認系爭採購契約之性質，既非委任亦非承攬，而屬於無名契約；而其性質又兼具承攬與委任之性質，故而為承攬與委任之混合契約。又稱委任者，謂當事人約定一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約，民法第五百二十八條定有明文；同法第五百二十九條並規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。」基此，各式無名契約而屬於勞務給付性質之契約，均有民法債篇有關委任規定之適用，兩造間之契約關係亦應適用委任之相關規定。

二、評析：

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得適用民法委任之規定。

玖、臺灣高等法院花蓮分院 109 年度重上字第 7 號民事判決(110/4/30)

一、判決要旨：

委任與承攬之混合契約：(1)契約之定性及法規適用之選擇：按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係。倘當事人所訂定之契約，其性質究係屬成文法典所預設之契約類型（民法各種之債或其他法律所規定之有名契約），或為法律所未規定之契約種類（非典型契約，包含純粹之無名契約與混合契約）有所不明，致造成法規適用上之疑義時，法院即應為契約之定性（辨識或識別），將契約內容或待決之法律關係套入典型契約之法規範，以檢視其是否與法規範構成要件之連結對象相符，進而確定其契約之屬性，俾選擇適當之法規適用，以解決當事人間之紛爭。此項契約之定性及法規適用之選擇，乃對於契約本身之性質在法律上之評價，屬於法院之職責，與契約之解釋係就契約客體（契約內容所記載之文字或當事人口頭所使用之語言）及解釋上所參考之資料（如交易或商業習慣）之探究，以闡明契約內容之真正意涵，並不相同，自可不受當事人所陳述法律意見之拘束（最高法院 103 年度台上字第 560 判決意旨參照）。(2)委任與承攬之混合契約二者成分特徵不易辨識情況時：苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，各具有一定之分量，且各該成

立之特徵彼此不易截然分解及辨識，當事人復未就法律之適用加以約定時，其既同時兼具「事務處理」與「工作完成」之特質，即不能再將之視為委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約，成為一種法律所未規定之無名勞務契約。復以委任契約為最典型及一般性之勞務契約，為便於釐定有名勞務契約以外之同質契約所應適用之規範，俾契約當事人間之權利義務關係有所依循，民法第 529 條乃規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。」故有關由委任與承攬二種勞務契約之成分所組成之混合契約，而彼此間之成分特徵不易截然分解及辨識時，其整體之性質既屬於勞務契約之一種，自應依該條之規定，適用關於委任之規定，庶當事人間之權利義務關係得以確立（最高法院 109 年台上字第 215 號、108 年度台上字第 2626 號、107 年度台上字第 1637 號判決意旨參照）。「本件系爭契約之名稱訂為「新竹生物醫學園區整體景觀細部設計監造委託技術服務案契約」，契約之標的包括「完成一定之工作」及「處理一定之事務」；且系爭契約之相關約定，部分帶有委任之性質，部分含有承攬之特性，為原審所認定。如果無訛，系爭契約既由委任之構成分子與承攬之構成分子混合而成，且各具有一定之分量，其性質似應認為係委任與承攬所混合而成之無名勞務契約，而非純粹典型之承攬契約。果爾，依上說明，即應適用關於委任之規定作為判斷兩造間權利義務關係之依據。」（最高法院 103 年度台上字第 560 判決意旨參照）。(3)委任與承攬之混合契約在其成分得以辨識情況時：「查本件採購契約為承攬與委任之混合契約，為原審所認定之事實。按混合契約，原則上應適用各該性質之契約，與民法第五百二十九條並規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所訂其他契約之種類者，適用關於委任之規定」之情形，未盡相同。則原審謂：各式無名契約而屬於勞務給付性質之契約，均有民法債篇有關委任規定之適用，兩造間之契約關係亦應適用委任之相關規定云云，洵有未洽。」（最高法院 100 年度台上字第 390 號判決意旨參照）。「依上訴人與羅○○簽訂委託契約中監造部分之約定，羅○○須配合上訴人之指示，且所指派現場監工人員須受上訴人及其現場監工之指示及監督，並製作工程施工監工日報表送上訴人，上訴人復得要求更換該監工人員等情，為原審確定之事實。則委託契約就此不具獨立性之提供勞務給付約定部分，似屬委任性質，與同契約設計部分之承攬性質者，自屬有異，而為非典型契約中之混合契約。依上說明，就此部分自應類推適用委任契約之規定。原審徒以羅○○及其派駐工地之監工人員應聽從上訴人之指示，另酬金之給付非依民法第五百四十五條規定預付必要之費用，即認此部分應與設計部分為相同之評價，認屬承攬性質，而非委任，難謂於法有據。」（最高法院 104 年度台上字第 1606 號判決意旨參照）。(4)前開(1)、(2)之事實並不相同，見解並無歧異：按「本件聲請人主張：兩造間之系爭委託整合契約，係兼含有委任與承攬之混合契約，究應如何適用法律？係應適用各該性質之契約，抑認為其整體之性質屬於勞務契約之一種，適用關於

委任之規定。就此爭議，最高法院 100 年度台上字第 390 號（下稱第 390 號判決）及 106 年度台上字 1166 號判決（下稱第 1166 號判決），出現歧異之見解，且屬足以影響本件裁判結果，爰聲請將此法律爭議提案予大法庭裁判等語。惟查第 390 號判決，認為委任與承攬之混合契約，爭議事項原則上應適用各該性質之契約。第 1166 號判決，認為有關由委任與承攬 2 種勞務契約成分所組成之混合契約，並各具有一定分量，然彼此間之成分特徵不易截然分解及辨識時，其整體之性質既屬於勞務契約之一種，應依民法第 529 條之規定，適用關於委任之規定。可見第 1166 號判決係在委任與承攬之混合契約二者成分特徵不易辨識情況時，始依民法第 529 條規定，適用關於委任之規定，與第 390 號判決以委任與承攬之混合契約在其成分得以辨識情況，爭議事項分別適用各該性質之規定，二者事實並不相同，核與法院組織法第 51 條之 2 歧異提案之要件不合。聲請人之聲請，不應准許。爰裁定如主文。」（最高法院 109 年度台聲字第 736 號裁定意旨參照）。

二、評析：

此判決除肯認勞務採購契約有混合契約存在之外，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定。

經由上開臺灣高等法院及其分院之判決，可得而知實務上，尤以高等法院一律肯認勞務採購契約有混合契約之存在，但在法律適用上出現有不同之見解，有認為若有區別時，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定，不易區分時，基於皆屬於勞務契約，得適用民法委任之規定，另有認為屬於混合契約時，不再予以區分，基於皆屬於勞務契約，即直接適用民法委任之規定，嗣有最高法院見解之出現，已如上述，即若有區別時，得分別視契約個別之條款內容分別適用民法各種債編之規定，不易區分時，基於皆屬於勞務契約，得適用民法委任之規定。基於我國民事訴訟在審級方面，採三級三審制為原則，通常訴訟事件，原則上由地方法院管轄第一審，高等法院或其分院管轄第二審，最高法院管轄第三審。第一審及第二審均為事實審，第三審為法律審。民事訴訟法賦與最高法院具有審查第三審上訴合法與否及是否廢棄臺灣高等法院及其分院判決之權能，臺灣高等法院及其分院就第一審判決所為事實認定及法律適用是否正當，均得加以審理及是否廢棄各地方法院判決之權能，臺灣高等法院及其分院與各地方法院理應尊重最高法院之判決，故最高法院對於勞務採購契約定性之上開法律見解似乎已成為目前之趨勢，但臺灣高等法院及其分院之見解仍殊值參考。

另有關勞務採購契約之定性也影響勞務採購契約權利義務關係發生爭議時，雙方當事人就權利之主張，當中涉及能支持一方向他方有所主張之法律規範，即所謂請求權基礎。司法實務上就對於勞務採購契約之請求權基礎之認定，涉及就勞務採購契約定性之斷定，仍以承認除有勞務採購契約本身有所約定外，絕大部分仍以民法上債務不履行之相關規定或民法上承攬契約之規定作為請求權基礎，而少部分以民法上委任契約之規定作為請求權基礎，其中以臺灣臺北地方法院 105 年度訴字第 3819 號民事判決為例，該判決除了肯認勞務採購契約有混合契約之性質存在之外，對於請求權基礎之判定，認為得視混合契約之狀況，引據民法第 529 條規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。」，適用民法上委任契約之規定作為請求權基礎，如同前述，勞務採購契約究竟應定性為何依類別之契約性質，影響當事人於訴訟上請求權之主張以及請求權時效之注意，不可不慎。有關臺灣臺北地方法院 105 年度訴字第 3819 號判決內容略要如下：

表 26 判決介紹

法院/判決字號/日期	判決要旨
臺灣臺北地方法院 105 年度訴字第 3819 號民事判決 裁判日期： 民國 106 年 07 月 26 日 裁判案由： 給付服務費等	依契約(且有肯認契約屬於混合契約，適用委任關係) 系爭契約應屬非典型契約之混合契約，應適用委任之規定：1. 按基於私法自治及契約自由原則，當事人得自行決定契約之種類及內容，以形成其所欲發生之權利義務關係。倘當事人所訂定之契約，其性質究係屬成文法典所預設之契約類型（民法各種之債或其他法律所規定之有名契約），或為法律所未規定之契約種類（非典型契約，包含純粹之無名契約與混合契約）有所不明，致造成法規適用上之疑義時，法院即應為契約之定性（辨識或識別），將契約內容或待決之法律關係套入典型契約之法規範，以檢視其是否與法規範構成要件之連結對象相符，進而確定其契約之屬性，俾選擇適當之法規適用，以解決當事人間之紛爭。此項契約之定性及法規適用之選擇，乃對於契約本身之性質在法律上之評價，屬於法院之職責，與契約之解釋係就契約客體（契約內容所記載之文字或當事人口頭所使用之語言）及解釋上所參考之資料（如交易

或商業習慣)之探究，以闡明契約內容之真正意涵，並不相同，自可不受當事人所陳述法律意見之拘束。又委任與承攬於契約履行之過程中，皆以提供勞務給付作為手段，在性質上同屬勞務契約。然受任人提供勞務旨在本於一定之目的，為委任人處理事務，其契約之標的重在「事務之處理」；至於承攬人提供勞務乃在為定作人完成一定之工作，其契約之標的重在「一定工作之完成」。因此，民法各種之債乃將委任與承攬分別規定為兩種不同之有名契約（民法第490條第1項、第528條）。苟當事人所訂立之契約，係由承攬之構成分子與委任之構成分子混合而成，且各具有一定之分量時，其既同時兼有「事務處理」與「工作完成」之特質，即不能再將之視為純粹之委任或承攬契約，而應歸入非典型契約中之混合契約（司法院院字第2287號解釋參照），而成為一種法律所未規定之無名勞務契約。復以委任契約為最典型及一般性之勞務契約，為便於釐定有名勞務契約以外之同質契約所應適用之規範，俾契約當事人間之權利義務關係有所依循，民法第529條乃規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定契約之種類者，適用關於委任之規定。」故有關由委任與承攬二種勞務契約之成分所組成之混合契約，性質上仍不失為勞務契約之一種，自應依該條之規定，適用關於委任之規定，庶符立法之旨意（最高法院103年度台上字第560號判決要旨參照）。

2. 系爭契約為勞務採購契約，為兩造所不爭（見本院卷一第60頁背面）。系爭契約第4條關於價金之給付條件，係採總包價法而依原告於簽立契約、工作進度與經費實支進度累計情形分批給付，更須於被告驗收完畢後始得請領尾款（見本院卷一第14頁背面）；復觀計畫構想書中驗收項目及標準部分（見本院卷一第185頁背面至第186頁背面），更詳列各計畫項目之驗收標準，諸如「工業區開發計畫專案分析及審查」中工業區項目10件（含）以上、環評項目58件（含）以上，「產業園區綠美化暨技術輔導」中需研擬產業園區景觀整體發展計畫1份等約定，並要求滿意之執行件數須達交辦件數80%以上始為合格等情，似可認

	為系爭契約重在一定工作之完成，而具承攬契約之性質。然細譯計畫構想書關於系爭契約之目標（見本院卷一第 122 頁至第 123 頁），之所以簽立系爭契約，乃因被告相關專業人力員額之短缺，由原告協助被告關於管理、督導工業區開發相關案件之問題剖析、方案建議，協助法令研擬修訂，或追蹤以往編定工業區之辦理現況，幫忙問題解決與提升行政效率等，可知係基於被告相關專業、人力上有所不足，而用以協助、處理被告相關事務，並說明系爭契約不具明列績效衡量指標，由原告提供關於法律專業分析及審查、發展策略及用地規劃、開發計畫專業分析及審查、工業區經營管理與執行等情，則原告履行之任務，實重在一定事務之處理。另於履約期間中，多數原告執行人員更須在被告指定之辦公室集中辦公，並有各執行人員所需學經歷之條件，在系爭契約第 12 條尚約有原告人員聘用之限制，依計畫構想書被告甚得評定原告執行人員之當否並為更換之要求（分見本院卷一第 20 頁背面、第 181 頁至第 182 頁、第 185 頁），堪認原告於履約時須受被告指示，而具委任契約之性質。系爭契約既同時兼具一定分量之承攬與委任構成份子，揆諸上開說明，應認契約性質為委任與承攬混合而成之無名勞務契約，故屬非典型契約，是應依民法第 529 條適用委任之相關規定，合先敘明。
--	---

資料來源：作者自行製表

第五章 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突

第一節 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之差異

第一項 契約訂定之法律依據不同

勞務採購契約屬於私法契約性質，已如本文前面章節所述，有關契約雙方應履行之權利義務事項，依據民法第 153 條：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」，端視契約中明訂。

依據政府採購法第 2 條規定：「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。」、政府採購法第 7 條第 3 項規定：「本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。」、政府採購法第 63 條規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任。」，基此，生物醫療廢棄物處理業者受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，基於政府採購法之規定，應先與政府機關或政府機關所屬事業簽立勞務採購契約，有關雙方間勞務採購契約之定義、定性、效力及範例已於本文前面章節內已敘及，故於本章節不再探討。

另依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 20 條規定：「清除、處理機構從事廢棄物清除、處理業務，應事先與委託人訂定契約書，並保存三年，以備主管機關查驗。但受託清除、處理因天然災害或緊急事故產生之廢棄物者，不在此限。前項契約書應附有效許可證之影本並記載下列事項：一、廢棄物之種類、代碼、性質及數量。二、清除或處理之工具、設備、方法、頻率、相關場所。三、委託期間。四、處理機構廢棄物之最終處置地點及數量。五、因故無法執行契約或其他突發事件之應變措施。六、配合委託人依本法第三十條第二項所定準則辦理相關事宜。但委託人非事業者免記載。七、其他經直轄市、縣（市）主管機關

指定者」。基此，生物醫療廢棄物處理業者受託處理生物醫療廢棄物，基於廢棄物清理法相關規定，應先與受託者簽立生物醫療廢棄物處理契約，以符合廢棄物清理法相關法令之要求，該生物醫療廢棄物處理契約內容與上開生物醫療廢棄物處理業者受託處理生物醫療廢棄物，基於政府採購法之規定，應先與政府機關或政府機關所屬事業簽立勞務採購契約之內容，誠如上述，有所不同，有關該生物醫療廢棄物處理契約內容，除應滿足符合上開公營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 20 條規定之基本規範要求外，並無再行強制要求滿足其他事項之約定，是以生物醫療廢棄物處理業者得以就其內之「處理費用」約定條款、「違約處理」約定條款或其他約定條款等事項，本於私法自治、契約自由之原則，容有契約內容決定之權利。

引此，勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之契約訂定法律依據有所不同。

第二項 契約訂定之過程不同

誠如上述，勞務採購契約之訂定過程，主要係政府機關或政府機關所屬事業辦理勞務採購標案，廠商參與投標及得標後，即與政府機關或政府機關所屬事業簽訂勞務採購契約。

另生物醫療廢棄物處理契約之訂定過程，只需在契約雙方當事人同意簽訂之下，即可簽訂契約。

因此，勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之契約訂定過程有所不同。

第三項 契約訂定之雙方當事人不同

誠如上述，勞務採購契約訂定之雙方當事人，一方為廠商，他方為政府機關或政府機關所屬事業。

另生物醫療廢棄物處理契約訂定之雙方當事人，一方為廠商，他方除得為政府機關或政府機關所屬事業外，亦得包括會產出生物醫療廢棄物之醫療院所、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠等。

基上可知，生物醫療廢棄物處理契約訂定之雙方當事人相較於勞務採購契約訂定之雙方當事人而言，簽約對象數目比較多。

第四項 契約訂定之內容不同

誠如上述，勞務採購契約之內容，主要係政府機關或政府機關所屬事業採用行政院公共工程委員會制定之勞務採購契約範本，酌加修改，所擬訂之契約內容，且契約內明文約定 1. 招標文件及其變更或補充、2. 投標文件及其變更或補充、3. 決標文件及其變更或補充、4. 契約本文、附件及其變更或補充及 5. 依契約所提出之履約文件或資料皆為契約內容之部分，契約之內容不外乎包括下列條款(具體內容得參照行政院公共工程委員會「勞務採購契約範本」)：

第 1 條契約文件及效力	第 7 條履約期限	第 13 條遲延履約
第 2 條履約標的	第 8 條履約管理	第 14 條權利及責任
第 3 條契約價金之給付	第 9 條履約標的品管	第 15 條契約變更及轉讓
第 4 條契約價金之調整	第 10 條保險	第 16 條契約終止解除及暫停執行
第 5 條契約價金之給付條件	第 11 條保證金	第 17 條爭議處理
第 6 條稅捐	第 12 條驗收	第 18 條其他

惟勞務採購契約約定之內容不無有掛一漏萬之虞，故勞務採購契約不無約定契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

另生物醫療廢棄物處理契約之內容，由契約之任一方當事人所擬訂，經他方當事人所同意簽訂，通常契約之內容不外乎包括下列條款(具體內容得參照雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司「生物醫療廢棄物委託處理契約書」¹⁶²)：

壹、基於遵守廢棄物清理法相關法令之要求，所必須擬訂之基本內容，如下：

¹⁶² 雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司「生物醫療廢棄物委託處理契約書」，網址：
<https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNzQxL3J1bGZpbGUvMTAxNzYvODQwNTI1OS84NmY3OTMyYS1jMzJiLTQ2YTUuYmE3NC0wYTJmNjkyMWYyZjQucGRm&n=MTUt55Sf54mp6Yar55mC5bui5qOE54mp5aeU6KiX6JmV55CG5aWR57SE5pu4K0evh0acrCko6Ie65YyX5biC5pS%2F5bqc55Kw5aKD5L%2Bd6K235bGA5o%2BQ5L6bKS5wZGY%3D&icon=.pdf>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。

第 1 條處理種類、性質、數量	第 5 條收集點、清運頻率、分類標準
第 2 條處理重量	第 6 條契約期限
第 3 條處理之工具、方法、設備	第 7 條於處理期間遭逢突發事件時，應立即採取以下緊急應變措施處置
第 4 條清除設備、工具、方法	

貳、由契約當事人本於私法自治、契約自由之原則所擬訂之內容如下：

第 8 條處理費用	第 10 條管轄法院
第 9 條違約處理	第 11 條契約分存

由此可見，勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之契約訂定內容，明顯有所差異。

第五項 契約訂定之爭議處理方式不同

政府機關或政府機關所屬事業與廠商就履行勞務採購契約發生爭議，應先行協調，未能達成協議，得採取下列方式處理之：

1. 依據政府採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會申請調解。
2. 經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。
3. 依據政府採購法第 102 條規定提出異議、申訴。
4. 提起民事訴訟，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。
5. 依其他法律申(聲)請調解。
6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。

另廠商與政府機關、政府機關所屬事業、醫療院所、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠等就履行生物醫療廢棄物處理契約發生爭議，應先行協商，協商不成時，通常會採取提起民事訴訟，並以雙方當事人合意之地方法院為第一審管轄法院。

是以勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之契約訂定之爭議處理方式有所不同，前者契約遇有發生履行契約爭議時，有多種選擇之救濟管道，而後者契約遇有發生履行契約爭議時，能選擇之救濟管道則比較少，通常即會採取提起民事訴訟救濟之。



第二節 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之相似性

第一項 契約訂定之目的、主體、標的、履行方式相同

勞務採購契約訂定之目的與生物醫療廢棄物處理契約訂定之目的相同，同時就同一政府機關或政府機關所屬事業就其產出之同樣生物醫療廢棄物委託同一生物醫療廢棄物處理業者採取同樣之處理設備，予以妥善、完善處理，最終由生物醫療廢棄物處理業者取得同筆處理報酬，同時分別簽訂上開二契約，此為政府機關或政府機關所屬事業就其產出之同樣生物醫療廢棄物委託生物醫療廢棄物處理業者處理之特殊性。

第二項 契約訂定之成立類似

勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約基本上皆由要約之意思表示與承諾之意思表示達成互相合意而成立，有關勞務採購契約之成立，本文已於前面章節予以介紹，勞務採購契約權利義務關係，除受契約內容之拘束外，也受政府採購法相關規範之拘束及民法之拘束，甚至涉及受到憲法、行政法之原理原則及行政院公共工程委員會函釋之拘束，業經本文於前面章節予以探討，有關生物醫療廢棄物處理契約之成立，依據民法之規定而成立，生物醫療廢棄物處理契約權利義務關係，除受契約內容之拘束外，且受民法之規定拘束，甚至受到憲法精神、解釋之拘束，自不待言，故於本文不再予以探究。

第三項 契約訂定之定性類同

有關勞務採購契約之定性，或為承攬契約、委任契約或混合契約之性質，業經本文前面章節有所探究，於本章節不再贅述，而有關生物醫療廢棄物處理契約之定性，若單純比照依據政府採購法之條文規範文義上加以解釋，似乎係屬委任契約之性質，倘比照本文前面章節就勞務採購契約之定性，予以解釋，似乎亦有承攬契約、委任契約或混合契約之性質之解釋空間，但基於下列理由，得肯認生物醫療廢棄物處理契約書之性質應屬於承攬契約。

- 一、綜觀廢棄物處理機構與事業間廢棄物處理契約書，皆肯認有使用承攬之用語，僅處理之種類有所不同，是以得佐證事業廢棄物處理契約應屬於承攬契約。

二、且依據財務部賦稅署 88 年 6 月 30 日台財稅第 881923858 號函：「主旨：關於○○縣政府與○○公司簽訂之『垃圾委託焚化處理契約』是否屬承攬契據及應如何計課印花稅乙案。說明：二、印花稅法第 5 條第 4 款規定，『承攬契據指一方為他方完成一定工作之契據。』本案依所附『垃圾委託焚化處理契約』，○○縣政府保證每年交付 372,300 公噸垃圾並按月支付服務費用，上開服務費用包括『操作維護費用』、『攤提建設費用』等，均係按每公噸之操作維護費用或攤提建設費用乘以請款月所接收之可處理廢棄物噸數計算，亦即○○縣政府支付上開費用，雖依經費來源不同，而區分不同之費用項目，惟均係依○○公司完成工作之多寡計算給付，應認屬該公司處理垃圾之報酬。故該契約核屬具有承攬契據性質，應按契約金額計課印花稅。」。此函示所指垃圾委託焚化處理契約，性質上屬於一般廢棄物處理契約，經由經濟部賦稅署認定為屬於承攬契約，而事業廢棄物處理契約與一般廢棄物處理契約僅屬於處理之廢棄物種類而有所不同，相同之地方在於一方處理廢棄物完成，另一方給付報酬，故事業廢棄物處理契約應屬於承攬契約，殊值可參。

三、況且行政院環境保護署於其醫療廢棄物宣導網—醫療機構版—問答集—委外上，有所認定事業廢棄物委託處理係屬於承攬性質：

表 27 事業廢棄物委託處理性質

委外問題	回答
醫院若以招標方式廢棄物清除處理時，僅與處理廠商簽定合約，是否違反法令呢？	1. 依據事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準(109.02.21)第43條規定，事業與受託清除及處理廢棄物者，都應簽訂書面契約，當受託清除及處理者非屬同一時，書面契約應分別簽訂；因此醫院僅與清除或處理者其中之一簽約，並不符合規定。 2. 建議醫院可以將清除、處理合併辦理招標，以免遺漏任何一方。招標時可明訂投標廠商應同時取得清除、處理許可，或由二家以上清除、處理機構合組團隊共同承攬，屬共同承攬者則應與醫院分別簽約，以符合規定。

資料來源：行政院環境保護署醫療廢棄物處理網－醫療機構

事業廢棄物管理作業參考手冊(104年版)第六章常見問答集¹⁶³

本人以為就生物醫療廢棄物處理業者受託處理事業產出之生物醫療廢棄物完成，事業給付報酬而言，應屬於承攬關係應無疑義，至於契約內仍涵蓋諸多應遵守法令之事項，若有違反，是否應做相同之解釋，是有疑義，故在契約解釋上，誠如本文就政府採購契約性質之定性所述，不無可以解釋其為混合契約之可能性。

¹⁶³ 行政院環境保護署醫療廢棄物處理網－醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(2015年版)第六章常見問答集，網址：<https://www.greenhosp.tw/Fckfile/file/環保署「醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊104年版」.pdf>(最後瀏覽日:2022年5月7日)。

第三節 勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約衝突之處理方式

勞務採購契約訂定之依據係基於政府採購法之規定要求，政府採購法經行政院公共工程委員會於1998年5月1日制定，於1998年5月27日公布，生物醫療廢棄物處理契約訂定之依據係基於公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法之規定要求，公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法經行政院環境保護署於2001年11月23日制定，最初之條文規範於其第18條規定：「清除、處理或清理機構從事廢棄物清除、處理業務，應與委託人訂定契約書，並於訂定契約書之次日起三十日內，檢具該契約書副知雙方當事人所在地之直轄市、縣(市)主管機關。變更契約書內容或終止契約時，亦同。但受託清除、處理因天然災害或緊急事故產生之廢棄物者，不在此限。前項契約書應記載下列事項：一、廢棄物之種類、性質及數量。二、清除或處理之工具、方法、設備、場所。處理或清理機構應含廢棄物中間處理及最終處置之地點及數量。三、清除或處理之最低標準(含收集頻率、收集點及分類標準)。四、許可期限。五、清除、處理或清理機構因自行停業、宣告破產或其他事由無法繼續從事清除、處理業務時，對其尚未清除、處理完竣之廢棄物處置。六、對突發事件之應變措施。七、其他經直轄市、縣(市)主管機關指定者。」，最後歷經修改條文之內容，並遞移至其第20條規定：「清除、處理機構從事廢棄物清除、處理業務，應事先與委託人訂定契約書，並保存三年，以備主管機關查驗。但受託清除、處理因天然災害或緊急事故產生之廢棄物者，不在此限。前項契約書應附有效許可證之影本並記載下列事項：一、廢棄物之種類、代碼、性質及數量。二、清除或處理之工具、設備、方法、頻率、相關場所。三、委託期間。四、處理機構廢棄物之最終處置地點及數量。五、因故無法執行契約或其他突發事件之應變措施。六、配合委託人依本法第三十條第二項所定準則辦理相關事宜。但委託人非事業者免記載。七、其他經直轄市、縣(市)主管機關指定者」，雖條文內容略有調整，但以生物醫療廢棄物處理業者而言，生物醫療廢棄物處理業者從事受託處理生物醫療廢棄物，應事先與產出生物醫療廢棄物之機構包括但不限於政府機關或政府機關所屬事業簽訂生物醫療廢棄物處理契約，是以行政院公共工程委員會制定政府採購法(1998年5月1日)早於行政院環境保護署制定公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法(2001年11月23日)，將近3

年有餘，行政院環境保護署制定公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法（2001 年 11 月 23 日）不無應發現政府採購法（1998 年 5 月 1 日）立法之情形，而衍生政府採購法要求廢棄物處理業者受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出之廢棄物，應簽訂政府採購契約之情形，致生與行政院環境保護署制定公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 18 條之規定（2001 年 11 月 23 日）之規範內容要求，有可能發生相互矛盾、衝突之地方，行政院環境保護署就公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法（2001 年 11 月 23 日）於立法時，即可避免就同一事務之法規適用上發生多頭馬車之情形，容待解決，造成法規適用上出現不圓滿之狀態，惟至 2022 年仍未見行政院環境保護署單獨出面就法規適用上發生互相矛盾、衝突之地方予以修法解決，或與行政院公共工程委員會協商、溝通，尋求達成共同修法之共識，導致勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約發生同時存在之現象，可得而知，行政院公共工程委員會或行政院環境保護署並未重視此爭議，或者有認識可能發生此爭議，但容待以統一解釋即可，甚至可能認知以目前二套法規同時併行施行，並無發生任何爭議，而未見任何提議修法之動作，本人以為此爭議之發生與解決殊值探討，勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之間，應做適度之安排，即可避免彼此衝突之發生，故有本章節內容之介紹及研究。

基於上開勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約各自簽訂之依據有所不同，前者係依據政府採購法，後者係依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法，誠如上述，那已經簽訂政府採購契約後，是否仍需依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法另行簽訂另一生物醫療廢棄物處理契約，是有疑義，尚待統一解釋。惟以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，有些政府機關或政府機關所屬事業除了簽訂勞務採購契約後，是否仍需依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法另行簽訂另一生物醫療廢棄物處理契約，諸多政府機關或政府機關所屬事業並就上開二契約書皆有簽立，但仍有些政府機關或政府機關所屬事業並未循此做法。至於上開二契約書之關係究竟為何，有所疑義，迄今於我國實務及學說仍未有任何見解予以探討，本人以為至少可以歸類成二種理論予以討論及探討：

一、獨立說

基於二契約簽訂之依據有所不同，前者係依據政府採購法，後者係依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法，內容拘束對象雖然相同，但權利義務規範內容畢竟仍有所差異，因此可以視為各自獨立及不同之契約，應分別看待。

二、補充說

基於二契約簽訂之依據有所不同，前者係依據政府採購法，後者係依據公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法，內容拘束對象相同，目的相同，縱使權利義務規範內容仍有所差異，仍然可以作為補充勞務採購契約內容不足之地方。

本人以為以採取獨立說較為可行，畢竟雖然契約雙方當事人相同，目的也是相同，但契約簽訂之過程仍有所差異，以勞務採購契約而言，雖然仍認為屬於私法上契約，但仍有政府採購法原理原則或行政法上原理原則滲透之可能性，已如上述，且勞務採購契約經簽訂後，不容任意變更內容，以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司而言，自雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司與政府機關或政府機關所屬事業簽訂勞務採購契約後，從未發生任何修改、變更勞務採購契約內容之情形，而生物醫療廢棄物處理契約係本於契約雙方當事人基於契約自由原則所簽訂，契約內容之內容仍有任意變更、修改之空間及機會，之後仍得任意由契約雙方當事人簽訂附約書或協議書，補充契約本文之不足，以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司而言，自雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司與民間之醫療院所或其他機構、單位簽訂生物醫療廢棄物處理契約後，皆有發生任何修改、變更契約內容之情形，而縱使生物醫療廢棄物處理契約之當事人一方為政府機關或政府機關所屬事業，遇有需要修改、變更契約內容之情形時，不妨得比照之，給予契約修改、變更之空間及機會才是，較為妥適。

至於勞務採購契約遇有得解除或終止之情形時，對於生物醫療廢棄物處理契約效力之影響，端視勞務採購契約經解除或終止之目的或理由，是否符合生物醫療廢棄物處理契約約定之得解除或終止之事由，若有所符合時，自得就生物醫療廢棄物處理契約進行解除或終止之動作，如未有符合時，則端視生物醫療廢棄物

處理契約係屬於符合民法債編總論之規定或民法債編各論之規定，進行解除或終止之動作。反之，生物醫療廢棄物處理契約遇有得解除或終止之情形時，對於勞務採購契約效力之影響，仍端視生物醫療廢棄物處理契約經解除或終止之目的或理由，是否符合勞務採購契約約定之得解除或終止之事由判斷之才是。

且本人以為政府採購法與公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法彼此之間並無特別法與普通法之關係，致使法律適用上產生困擾，連帶影響勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約彼此間之關係，唯一解決方式係有賴以修法方式予以解決，即或許得於廢棄物清理法相關法令內新增勞務採購契約得取代生物醫療廢棄物處理契約之文字予以解套，以杜爭議，或者得直接就公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 20 條規定予以修改為「清除、處理機構從事廢棄物清除、處理業務，應事先與委託人訂定契約書或勞務採購契約書，並保存三年，以備主管機關查驗。但受託清除、處理因天然災害或緊急事故產生之廢棄物者，不在此限。前項契約書應附有效許可證之影本並記載下列事項：一、廢棄物之種類、代碼、性質及數量。二、清除或處理之工具、設備、方法、頻率、相關場所。三、委託期間。四、處理機構廢棄物之最終處置地點及數量。五、因故無法執行契約或其他突發事件之應變措施。六、配合委託人依本法第三十條第二項所定準則辦理相關事宜。但委託人非事業者免記載。七、其他經直轄市、縣（市）主管機關指定者」，亦即經修法後，簽訂之契約類型有包括生物醫療廢棄物處理契約或勞務採購契約二種，往後生物醫療廢棄物處業者受託處理政府機關或政府機關所屬事業產出生物醫療廢棄物，經簽訂勞務採購契約後，即可不需要再行簽訂生物醫療廢棄物處理契約，並於生物醫療廢棄物處理勞務採購運作上同時將生物醫療廢棄物處理契約之內容納入勞務採購契約之中，即可完善解決勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約衝突之爭議。

第六章 結論與建議

第一節 結論

本文係本人參酌國內與本文題目相關專書、網路資料、學位論文、期刊論文及實務上見解，並加以整理與彙整而完成，經綜合本文前面各章節提出之內容，得出結論，綜觀全文內容，簡言之，就是探討目前生物醫療廢棄物處理業者所面臨之勞務採購契約法律爭議問題，論述範圍包括傳統採購行為之定性及爭議、國內外政府採購法制差異之比較、勞務採購共同投標之定性、政府採購契約之成立生效及爭議處理、勞務採購投標廠商資格要求之爭議、政府採購契約是否定性為定型化契約之爭議、採購異議制度存廢爭論不休之爭議、廢止限制公告金額以下之採購案件不得提起採購申訴之爭議勞務採購爭議處理及勞務採購契約之定性及勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突等，誠如本文前面章節所述，上開爭議容待解決，上開爭議或許已經專家學者予以探討、研究在先，而提出專業論點、建議或主張，企圖解決上開爭議之發生，有些專家學者提出解決爭議之方案殊值贊同，但仍有些許專家學者提出解決爭議之方式，縱使有所缺失，但仍具有參考之價值性，殊值可參，且現行政府採購法經過政府採購實務運作結果，仍發現有窒礙難行或有必要鬆綁或補充規定之地方，本文乃從生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約法律爭議問題之研究，並以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心予以進行探究出發，試圖集合、彙整上開專家學者就上開爭議提出之研究、建議、看法及見解進行比較與分析，旁論目前政府採購實務運作上之情形及司法實務操作上之情況，與提出本人之看法及建議，再度找出更可行，甚至更佳之爭議解決藥方，俾提供行政院公共工程委員會就現行政府採購法之實施及運作之有所困難之地方，給予修法參考使用。其未來修法內容得分為以下面向：

壹、程序正義對於政府採購行為係屬重要

政府採購行為過程中，無論政府採購行為之前階段或後階段，皆有面臨政府機關或政府機關所屬事業所採取之行政採購行為之手段或措施是否符合公平、公正、公開及合理，滿足政府採購法原理原則之要求，甚至於政府採購爭議發生時，

是否提供廠商適當之權利救濟管道，此些議題皆與政府採購行為是否賦與程序正義環環相扣，是以程序正義之保障及維持對於政府採購行為甚屬重要。

貳、統合各界提供修法建議

政府採購法之修法需求及走向，有賴各界提供修法之建議，尤以經由專家學者提出之見解，所提供之修法建議更屬具有價值性及參考性，甚為重要，並經充分蒐集、諮詢、討論，提供最佳及最適宜之政府採購法修法方向與方案，以建構更完善之政府採購採購法制。

參、合宜修法得解決政府採購爭議

有鑑於政府採購法之適當修法係政府採購法與時俱進不可或缺之要素，除了滿足程序正義之要求下，追求實體之正義於政府採購行為亦屬重要，政府採購爭議不時不斷發生，雖經學者專家理論、政府採購實務不斷堆疊提出解決方式，不失為解決政府採購爭議之方法之一，然而並不如法律以強制力為其後盾，具有拘束力，能發揮最大之功效，因此透過政府採購法之適當修法實為解決政府採購爭議之最佳重要措施，修法之評估包括政府採購協定(GPA)之變動要求、國外政府採購法制變化之參考、政府採購環境變遷、專家學者意見及政府採購法制不敷需求等，進而有待進行政府採購法之修改。

第二節 建議

在本文整個研究中發現，目前生物醫療廢棄物處理業者所面臨之勞務採購契約法律爭議問題之發生有些得透過修改政府採購法之相關規定或民法之相關規定予以解決，但仍有些爭議無法透過修改政府採購法之相關規定或民法之相關規定予以解決，只能透過專家學者之見解、觀點不斷堆疊而成為通說，予以解決，甚至為政府採購實務運作上所肯認及採用，或者之後經由司法實務運作上所認同，形成通案使用，以杜爭議不斷發生。對於有效解決上開爭議之發生，誠如本文前面章節所述，本人提出以下建議：

壹、應肯認政府採購行為過程皆有行政法原理原則及民法原理原則適用

就公法與私法於政府採購行為中是否相互影響之問題，引據知名學者蕭文生教授之見解，其認為雖然公法與私法可以區分，且於我國法秩序有其必要性，公法與私法並非相互孤立、毫無聯結或甚至相互排斥，公法與私法常會相互影響，相互牽動及關連，發生糾纏，基於公法與私法會藉用彼此之法律概念及法律解釋予以填補及補充，相互交融，其他學者稱之為公法與私法之相互滲透，誠如本文前面章節所述，本人認為公法與私法於政府採購行為中亦會相互影響，是以政府採購行為過程皆有行政法原理原則及民法原理原則適用。

貳、應肯認行政函釋之定位

就行政院公共工程委員會函釋於政府採購行為中扮演之角色而論，基於行政院公共工程委員會所作出之函釋，其重要性及影響力往往不下於受解釋之政府採購法相關規範之本身，但由於行政機關基於法定職權，就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，充實法規之內容及意涵，目前其定位只能透過行政院法務部之函釋及司法院大法官會議所作出之解釋進行摸索，找出其定位，行政院法務部之函釋及司法院大法官會議就行政解釋函之法律位階認定相當於解釋性行政規則，於效力面並有發生內部效力及間接之外部效力，誠如本文前面章節所述，本人肯認行政函釋之定位。

參、應肯定政府採購契約之成立與生效實應以雙方簽訂政府採購契約為準

就政府採購契約之成立生效之爭議而言，以招標、投標、決標之法律性質而論，招標之認定有採取要約說或要約之引誘說，並分別有學說上或實務上所肯認，基於目前通說皆認為，投標為廠商契約要約之意思表示；決標為機關契約承諾之

意思表示，機關於宣布決標時契約即已成立，也就是肯認有關招標之認定採取要約之引誘說，本人以為招標機關公布招標公告之作用本係吸引符合投標之廠商前往進行投標，滿足招標機關辦理採購標案之需求，本人建議就招標之認定應採取要約之引誘說，較為妥適。另以招標契約之法律性質而論，基於有關招標公告之法律性質，於學說上及實務上爭論不休，而有要約說、要約之引誘說之爭論，對於後續承諾時間點之認定也有所不同，進而討論若有承認招標契約之出現，有關招標契約之法律性質，又有本約說、預約說之爭論，誠如本文前面章節所述，本人以為政府採購契約係屬於機關辦理採購之重要文件之一，政府採購契約有些重要內容並未規範在投標須知文件內，得標廠商得標，僅代表得標廠商符合簽訂政府採購契約之資格，且履約過程時屬於重要之過程，故本人建議政府採購契約之成立與生效實應以雙方簽訂政府採購契約為準，較為適當。

肆、應截取德國政府採購法制之優點供我國政府採購法制參考

就國內外政府採購法制差異之比較而論，基於我國基礎法制之建構上，身受德國法制長期且深遠之影響，本人引據德國政府採購法制與我國政府採購法制來做比較，並以德國之「營業競爭限制防止法」第四章(公務發包)之第 97 條規定至第 129 條規定，與我國政府採購法之規定，試圖做比較，兩者政府採購法制有所相同及差別之地方，引據知名學者林家祺教授之見解，當中尤以德國就再審查程序一招標程序之暫停作規範(參照德國限制競爭防止法第 115 條規定)，乃基於德國於立法上採取再審查自動停止決標機制，賦與於在審查程序中無待申請，自動發生暫停採購程序之效果，為德國政府採購法制之優點。就我國而言，我國政府採購法第 82 條規定：「採購申訴審議委員會審議判斷，應以書面附事實及理由，指明招標機關原採購行為有無違反法令之處；其有違反者，並得建議招標機關處置之方式。採購申訴審議委員會於完成審議前，必要時得通知招標機關暫停採購程序。採購申訴審議委員會為第一項之建議或前項之通知時，應考量公共利益、相關廠商利益及其他有關情況。」，我國採購申訴審議委員會於完成審議前，必要時得通知招標機關暫停採購程序，惟我國實務運作上甚少動用，由於德國立法設計上較能維護廠商之權利，我國政府採購法制不妨參照德國政府採購法制之立法方式，朝向採購異議程序及採購申訴程序自動停止決標機制之修改方向去前進。

另德國就立即抗告程序之程序規定(強制律師代理及例外等)作規範(參照德國限制競爭防止法第 120 條規定),乃基於德國於立法上考量到於立即抗告程序中,所涉及之事項均為採購程序是否違反政府採購法令之專業法律爭點,非由專業律師無法勝任,因此,德國採取強制律師代理主義,必須由法院認許之律師始能代理之,但公法之法人得透過公務員或具有法官資格之雇員代理之,為例外之情形,此為德國政府採購法制之另一優點。就我國而言,我國行政訴訟法第 49 條規定:「當事人得委任代理人為訴訟行為。但每一當事人委任之訴訟代理人不得逾三人。行政訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者,亦得為訴訟代理人:一、稅務行政事件,具備會計師資格。二、專利行政事件,具備專利師資格或依法得為專利代理人。三、當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時,其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務。四、交通裁決事件,原告為自然人時,其配偶、三親等內之血親或二親等內之姻親;原告為法人或非法人團體時,其所屬人員辦理與訴訟事件相關業務。委任前項之非律師為訴訟代理人者,應得審判長許可。第二項之非律師為訴訟代理人,審判長許其為本案訴訟行為者,視為已有前項之許可。前二項之許可,審判長得隨時以裁定撤銷之,並應送達於為訴訟委任之人。訴訟代理人委任複代理人者,不得逾一人。前四項之規定,於複代理人適用之。」我國就行政訴訟程序原則上採取應以律師為訴訟代理人,但有例外情形,類同於德國之就立即抗告程序之程序規定,原則上採取應以律師為訴訟代理人,兩國就政府採購之司法救濟途徑皆採取原則上強制律師代理機制設計,並有例外採取非律師代理之情形之制度設計,兩國已有類似之司法救濟途徑制度設計。

由於德國政府採購法制就再審查程序一招標程序之暫停及立即抗告程序之程序規定(強制律師代理及例外等)不失有其優點,誠如上述,德國政府採購法制亦有其他優點,誠如本文前面章節所述,並經其他專家學者所肯認,礙於篇幅,無法一一詳述,德國政府採購法制之優點頗值我國政府採購法制未來可能修法之參考,提供未來修法之走向,本人建議我國政府採購法得就立法不足之地方予以取長截短,使我國政府採購法得更加完備。

伍、應肯認加強生物醫療廢棄物處理業者內部人員熟悉政府採購法相關法令之教育訓練

基於生物醫療廢棄物處理業者處理量能之不足，必須由其他生物醫療廢棄物處理業者緊急支援協助處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物，此情形與共同投標之情形有所不同，生物醫療廢棄物處理業者如交付全部受託處理之生物醫療廢棄物或勞務採購契約約定之主要部分予其他生物醫療廢棄物處理業者處理，此時涉及違反政府採購法第 65 條不得轉包之規定，若僅交付部分受託處理之生物醫療廢棄物予其他生物醫療廢棄物處理業者處理，且該交付之部分生物醫療廢棄物未涉及主要部分時，此時依據政府採購法第 67 條得分包之規定，係屬合法之行為，誠如本文前面章節所述，也屬於多數廠商共同履行生物醫療廢棄物清除處理勞務採購契約權利義務關係之情形。是以有關生物醫療廢棄物處理勞務採購之共同投標與生物醫療廢棄物處理勞務採購之分包雖然意義有所不同，但皆屬於多數廠商共同履行生物醫療廢棄物清除處理勞務採購契約權利義務關係之情形並無不同，基於雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司處理量能之不足，必須由其他生物醫療廢棄物處理業者緊急支援協助處理政府機關或政府機關所屬事業產出之生物醫療廢棄物之情形發生，而此情形與勞務採購契約有關得分包之約定該當。

本人建議應加強生物醫療廢棄物處理業者負責辦理參與投標政府採購標案業務之人員對於熟悉政府採購法相關法令及清楚明瞭勞務採購契約如何解釋及適用之教育訓練，使生物醫療廢棄物處理業者負責辦理參與投標政府採購標案業務之人員不至於面臨可能觸犯違反政府採購法相關法令或違反勞務採購契約之約定條款之情形發生。

陸、應肯定投標廠商資格符合公平及合理之要求

就勞務採購投標廠商資格要求之爭議而論，以政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購案件為例，有時政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理勞務採購案件時，有就投標須知內設定之投標廠商資格內容及門檻，過度嚴格或不合理及不公平，未符合實際需要，甚至有資格綁標、不當限制競爭之情形發生，或者有為特定生物醫療廢棄物處理業者量身製作，訂定過嚴過苛資格排除其他廠商參與公平競爭機會，對於有意願投標之生物醫療廢棄物處理業者而言，屬於重中之重之政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物清除、處理或清除處理採購案件發生違失，此時生物醫療廢棄物處理業者

據以提起採購異議及採購申訴，尋求權益之維護，為杜絕招標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻，以符合實際需要，避免資格綁標、不當限制競爭之情形不斷發生，雖然目前政府採購法相關法令之規定已完善，政府採購法制上已完備，已能解決投標廠商資格符合公平及合理之要求，但本人仍認為目前之政府採購法相關法令之訂定或修改仍屬不足夠，本人建議不妨透過再度修法之方式，面對解決招標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻之爭議，政府採購法第 36 條之規定得修改為「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，得就實際需要另行規定，附經公證或認證之中文譯本，並於招標文件中訂明。第一項基本資格、第二項特定資格，由主管機關定之。」及投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 2 條之規定得修改為「機關辦理採購，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項訂定投標廠商之基本資格，並載明於招標文件：一、與提供招標標的有關者。二、與履約能力有關者。本標準第 5 條規定，於政府辦理採購，準用之。」，誠如本文前面章節所述。另本人也建議對招標機關而言，採購人員所扮演之角色係屬重要，尤於招標機關在辦理政府採購案件時，其投標須知內設定投標廠商資格內容及門檻，有賴該採購人員憑採購專業予以訂定，目前行政院公共工程委員會有制定採購專業人員資格考試訓練發照及管理辦法，對採購人員進行基礎訓練、進階訓練、經考試及格，領有及格證書及管理，使採購人員更能勝任招標機關辦理政府採購案件時，符合公平、公正、公開、合理之要求，亦即除了於政府採購法之法規面落實修改，使法規設計上更為良善外，更於政府採購法之運作及操作面落實就採購人員之培訓及養成，二者缺一不可，以達招標機關辦理政府採購案件賦與之任務圓滿成功，進而基於採購人員具有專業性及熟悉政府採購法相關規定與各種民事、刑事、行政相關法規之規定，不妨參照國家考試之針對法制人員之錄取取材，設計採購人員之公務員國家考試制度，錄取符合專業需求之人才，參與承辦政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件，使杜絕政府機關或政府機關所屬事業辦理政府採購案件於投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻之現象發生之拼圖得以補齊。且於政府採購行為稽核監督面向，本人也建議

基於行政院公共工程委員會、採購稽核小組、審計機關、主管機關、主(會計)單位、政風單位等皆具有執行稽核監督之權限，基於落實採購人員勇於任事，先由政府機關或政府機關所屬事業內部自主稽核機制做起，負起事先隨時提醒採購人員辦理採購業務之盲點與採購缺失所在，適時給予招標機關輔導，並導正其不當之採購行為，比如政府採購錯誤行為之發生，包括但不限於招標機關於其投標須知內設定之過度嚴格或不合理之投標廠商資格內容及門檻，除了減少政府機關或政府機關所屬事業與廠商之間採購爭議外，更能減少政府採購人員違法脫序之採購行為，以期減少採購人員違犯未依政府採購法令規定憑辦事項之行為，並減少可能發生營私舞弊之情形。

柒、應肯認政府採購契約採取視具體狀況認定是否屬於定型化契約之看法

就政府採購契約是否定性為定型化契約之爭議，有關政府採購契約是否屬於定型化契約，存有爭議，於學說、實務各有己見，司法實務上有採取肯定說及否定說之見解，本人以為雖然就大部分之政府採購契約包括但不限於勞務採購契約而言，招標機關多係採用行政院公共工程委員會訂定之範本，作為參考，並無疑義，但基於辦理標案情形之需求不同，行政院公共工程委員會訂定之範本未能符合辦理標案之具體狀況，仍會略作調整以符合招標機關需求。且行政院公共工程委員會不是政府採購契約最後契約內容之擬訂及提供者，而係招標機關本身，亦即並非契約當事人一方，於定型化契約適用主體上，已有疑義。政府採購契約包括但不限於勞務採購契約之訂定目的在於與單一廠商簽訂，每一政府採購契約會因採購標的、採購金額之不同，而有不同之契約內容變化出現，而該內容實屬契約之重要部分，而非能一體適用，硬要將政府採購契約包括但不限於勞務採購契約定性為定型化契約，未免有所過度強求，殊值商榷。最高法院 107 年度台上字第 1653 號民事判決肯認有意投標之廠商就政府採購相關招標資料文件是有充足之時間詳細審閱，以了解得標後雙方之權利義務，倘其認契約條款對其不利，非不得提出異議或請求釋疑，亦可拒絕投標，也就是最高法院之見解有認同政府採購契約非全然屬於定型化契約。政府採購實務上為推動公共工程招標作業公開化、透明化，藉由政府採購相關案件相關招標資料文件公開閱覽，徵求廠商或民眾意見，提升公共工程規劃設計品質，以減少招標及履約爭議，此有行政院公共工程委員會公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點之相關規定可稽，且若政府採購

案件相關招標資料文件不利，政府採購法設計提出異議或請求釋疑之制度，以資救濟，倘若就如部分之見解持縱使提供政府採購案件相關招標資料文件公開閱覽，僅係使廠商有知悉內容而已，仍無事前決定該內容之機會，及雖然政府採購法設計提出異議或請求釋疑之制度，以資救濟，但經廠商提出異議或請求釋疑，期待招標機關同意修正內容，機會甚少，作為肯認政府採購契約係屬於定型化契約之理由，將使得行政院公共工程委員會公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點及政府採購法設計之提出異議、申訴或請求釋疑之制度，形同虛設。再者，揆諸民法第 245 條之 1 規定之立法理由，似乎已將附合契約之提供者限定於工商企業者，蓋政府機關係處高權之地位，未必係屬經濟上較強者，且此條文之立法係由行政院、司法院所推動，由此可推知我國對於政府採購契約包括但不限於勞務採購契約之定性並非附合契約，僅可推論出政府採購契約包括但不限於勞務採購契約類似於定型化契約，但並非就是定型化契約，因此本人建議政府採購契約不妨採取視具體狀況認定是否屬於定型化契約之看法，端視締約之目的，締約之目的在於若政府採購契約係針對不特定之多數相對人所擬訂，具有反覆使用之性質，且具有降低政府採購成本、提升政府採購效率及加速政府採購過程之功能，即應歸類於具有定型化契約之性質，若政府採購契約係不針對不特定之多數相對人所擬訂，不具有反覆使用之性質，比如偏遠地區規模較小之機關或是公立學校而言¹⁶⁴，數年之久才辦理政府採購案件一次，即不應歸類於具有定型化契約之性質。

捌、應修法防止異議制度存廢爭論不休之爭議

就採購異議制度存廢爭論不休之爭議，近年來，亦有不少專家學者主張認為有關政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序是否應朝向整合之提出，甚至認為應刪除政府採購法中就採購異議之規定，基於政府採購實務運作上對於政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序仍多泰半持肯認及支持之態度，有些學者專家仍堅持異議制度對於爭議解決顯無助益，而需思考應否存廢之論點，本人建議不妨讓政府採購法關於異議、申訴等爭議處理程序仍同時存在，而讓廠商擁有程序之處分權、程序之選擇權，得選擇提起異議後，然後再提起申訴，或者得不提起異議，直接提起申訴，皆可以行使之主張，甚至得於透過修法方式，於政府採

¹⁶⁴ 陳萬愷，同前註 139。

購法第 76 條規定(申訴之提起)增訂「廠商得不經向招標機關提出異議，直接提起申訴，並適用提起申訴之規定」之相關文字，亦即政府採購法第 76 條之規定得修改為「廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣(市)政府所設之採購申訴審議委員會申訴。地方政府未設採購申訴審議委員會者，得委請中央主管機關處理。廠商得不經向招標機關提出異議，直接提起申訴，適用第一項之規定。廠商誤向該管採購申訴審議委員會以外之機關申訴者，以該機關收受之日，視為提起申訴之日。第三項收受申訴書之機關應於收受之次日起三日內將申訴書移送於該管採購申訴審議委員會，並通知申訴廠商。爭議屬第三十一條規定不予發還或追繳押標金者，不受第一項公告金額以上之限制。」，即可。

玖、應修法保障公告金額以下之採購案件提起採購申訴之權利

就廢止限制公告金額以下之採購案件不得提起採購申訴之爭議，基於政府採購法第 76 條之規定，僅限於廠商對於公告金額以上(含)之採購案件，提起採購異議，廠商對於採購異議之處理結果不服，才可提起採購申訴，造成公告金額以下之採購案件無法尋求以採購申訴制度予以救濟，進而肇致無法尋求之後提起行政訴訟救濟之機會，容有觸及是否侵犯憲法第 16 條規定之訴訟權保障之爭議發生，甚至影響到公告金額以下之採購案件既然無法尋求以採購申訴制度予以救濟，是否得提起訴願，以資救濟，容有爭議，有認為基於憲法第 16 條規定之訴訟權保障，而建議公告金額以下之採購案件既然無法尋求以採購申訴制度予以救濟，仍得賦與直接提起訴願之救濟管道，以利廠商對於未達公告金額採購異議之處理結果不服時，有同等公平對待之救濟途徑，由於行政院公共工程委員會當初立法設計時，考量基於行政作業人力量能不足及減輕作業成本，採取限制公告金額以下之採購案件提起採購申訴，尋求救濟之機會，況且行政院公共工程委員會認為公告金額以下之採購案件，雖然不能提出申訴，但仍得循求向上級機關反映或向政府採購稽核小組提出檢舉。本人以為由於國家本係為人民而存在，政府機關係為人民服務，政府機關不能基於行政作業之便宜行事，而剝奪掉人民提起權利救濟之最基本之訴訟權保障，是以限制公告金額以下之採購案件提起採購申訴，尋求救濟之機會，形同剝奪基本訴訟權，而有違憲之疑慮，惟一解決之途徑，即透過修法之

途徑予以放寬解決。本人建議政府採購法第 76 條第 1 項之規定得修改為「廠商對於採購異議之處理結果不服，或招標機關逾前條第二項所定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，依其屬中央機關或地方機關辦理之採購，以書面分別向主管機關、直轄市或縣（市）政府所設之採購申訴審議委員會申訴。」，即可賦與公告金額以下之採購案件仍得提起採購申訴，進而提起行政訴訟之機會，避免有侵犯憲法第 16 條規定之保障人民基本訴訟權利。至於配套措施為增加採購申訴審議委員會之行政作業人力配置之需求，即可滿足達到減輕作業成本之目的，方為妥適。而不必然賦與公告金額以下之採購案件得直接提起訴願之空間，使政府採購法設計採購異議制度及採購申訴制度更形複雜化，且若給予公告金額以下之採購案件得提起訴願救濟之，等同於造成政府採購法設置採購申訴制度暨制定採購申訴之相關規定形同虛設及空洞化，可以解釋，唯一解決藥方即透過影響最小之修法方式，鬆綁公告金額以下之採購案件無法尋求以採購申訴制度予以救濟之限制，較為妥適。

拾、應肯認勞務採購之定性多樣性

目前我國關於勞務採購之型態千變萬化，具有多樣性，不適合無差別予以定性，若強加予以定性，恐怕窒礙難行，因此本人肯認應勞務採購之定性多樣性。惟就廢棄物清理之單一模式，目前我國就廢棄物清理歸類在行政院公共工程委員會所提供之「政府採購標的分類代碼表」裡之分類：勞務類—代碼：94—分類名稱(中文)：污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務內，政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理之採購案件，即定性為勞務之採購，所簽訂之政府採購契約即為勞務採購契約，並經認為屬於政府採購法第 7 條規定之屬於其他經主管機關認定之勞務，我國民法規定之勞務契約有僱傭、承攬及委任，性質上各有所差異且各有不同之條文予以規範，而就生物醫療廢棄物之委託清除、處理，所簽訂之勞務採購契約，於契約定性上應歸納為屬於勞務之委任，而屬於委任契約，或屬於清除、處理工作完成，而給付報酬之承攬，而屬於承攬契約，而有所疑義，且政府採購法第 2 條之規定並未有勞務之承攬之字樣，不無有立法之疏漏，參考在行政院就政府採購法草案中，就勞務採購部分，採取「勞務之委任或獲得」之字樣，勞務之承攬屬於勞務之獲得當中之—型態，且政府採購協定中採取服務之字樣，服務所包含之範圍較廣泛，本人建議政府採購法第 2 條之規定

得修改為「本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及服務之委任、僱傭、承攬或其他以有償契約對指定服務之採購」，較為適宜及妥當。甚有認為勞務採購契約應定性為「無名契約」，而視實際狀況適用債法各論各項契約之規定，本人以為，綜觀勞務採購契約之內容，應不僅包括一種契約法律關係，通常亦有包括數種契約法律關係在內，也就是可以稱之為混合契約，並有司法實務上之見解予以肯認，若以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，其與政府機關或政府機關所屬事業簽訂勞務採購契約後，雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司處理生物醫療廢棄物完成，而政府機關或政府機關所屬事業給付報酬，即似乎係屬於承攬契約，其他遵守法令、投保等等又似乎屬於委任契約，依據學說見解，混合契約為民法無名契約之一種。有關勞務採購契約之定性，影響所及，最主要在於報酬請求權之請求時效之問題，本人建議就廢棄物清理，基於保障廠商之權益，得於勞務採購契約內明訂報酬或其他主張之請求權時效期限，以供招標機關或廠商有所遵循。

拾壹、應修法杜絕勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突

就勞務採購契約與生物醫療廢棄物處理契約之衝突爭議，目前生物醫療廢棄物處理業者所面臨之契約法律責任，包括依據政府採購法相關規定，受託處理生物醫療廢棄物，應簽訂勞務採購契約，此是行政院公共工程委員會之採購管制要求，所衍生之契約法律責任，及依據廢棄物清理法相關規定，受託處理生物醫療廢棄物，應簽訂生物醫療廢棄物處理契約，此是行政院環境保護署之環保管制要求，所衍生之契約法律責任，以政府機關或政府機關所屬事業委託處理生物醫療廢棄物為例，此時產生一問題是當簽訂勞務採購契約後，是否仍依據廢棄物清理法相關規定，委託處理生物醫療廢棄物，應簽訂生物醫療廢棄物處理契約，亦即前者契約與後者契約同時並行存在，或者前者契約得取代後者契約，當簽訂前者契約後，即不需要簽訂後者契約，有所爭議，政府採購法與廢棄物清理法彼此之間並無特別法與普通法之關係，致使法律適用上產生困擾，本人建議唯一解決方式係有賴以修法方式予以解決，即或許得於廢棄物清理法相關法令內新增前者契約得取代後者契約之文字予以解套，以杜爭議，或者得直接就公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 20 條規定予以修改為「清除、處理機構從事廢棄物清除、處理業務，應事先與委託人訂定契約書或勞務採購契約書，並保存三年，以備主

管機關查驗。但受託清除、處理因天然災害或緊急事故產生之廢棄物者，不在此限。前項契約書應附有效許可證之影本並記載下列事項：一、廢棄物之種類、代碼、性質及數量。二、清除或處理之工具、設備、方法、頻率、相關場所。三、委託期間。四、處理機構廢棄物之最終處置地點及數量。五、因故無法執行契約或其他突發事件之應變措施。六、配合委託人依本法第三十條第二項所定準則辦理相關事宜。但委託人非事業者免記載。七、其他經直轄市、縣（市）主管機關指定者」，亦即經修法後，簽訂之契約類型有包括前者契約或後者勞契約二種，滿足簽訂前者契約後，即不需要再行簽訂後者契約，並同時將後者契約之內容納入前者契約之中，亦不失為一有效解決途徑。目前國內政府採購實務上有學校辦理學生上下學交通車租賃採購，除依據政府採購法相關規定辦理外，尚且將行政院教育部制定之「學生交通車管理辦法」納入¹⁶⁵政府採購契約條文內，殊值可參，是以本人建議國內政府採購實務上就政府機關或政府機關所屬事業辦理生物醫療廢棄物處理之政府採購案件，除依政府採購法相關規定辦理外，也可將行政院環境保護署制定之「廢棄物清理法」相關規定及包括目前生物醫療廢棄物處理業者採行之後者契約之內容，嵌入前者契約中，以資解決。

上開生物醫療廢棄物處理業者所面臨之勞務採購契約法律爭議問題，經本人先後於本文予以提出，並提供本人之淺薄之看法及建議，已如本文前面章節所述，希冀對於大家探討上開爭議議題時能有所幫助，而上揭爭議不無皆可直接透過修法予以解決，無奈目前國內尚未見任何修法之動作，希望未來能看見行政院之公共工程委員會、法務部及其他部會或立法院能提出對於上開爭議解決修法之突破。

基於政府採購法尚存有本文提出之諸多修法之問題，未來仍待促請行政院公共工程委員會邀集廠商、學者、專家召開「研修政府採購法座談會」，進行修法討論，達成修法之共識，以更能精進政府採購法更能有效符合政府採購實務上之運作，嗣後由行政院公共工程委員會擬具政府採購法修正草案，經行政院院會通過，送交立法院進行審議，經立法院三讀通過，總統公布，完成修法動作並施行。

¹⁶⁵ 彭昕晟，政府採購契約法制與實務之研究－以學校交通車採購契約之法律性質與履約爭議為核心，國立中正大學財經法律研究所碩士在職專班碩士學位論文，2015年1月14日，頁79。

生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約在我國業已行之多年，長期並未受到重視，但迄今尚未有任何學位論文或期刊論文予以探究，本文全文內並以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為例，穿針引線，貫穿本文，予以探究生物醫療廢棄物處理業者實務上實際發生之勞務採購契約法律爭議問題及提供糾紛解決之途徑，試圖建構一合理之論述，除了給予幫助明瞭生物醫療廢棄物處理業者面臨之處境及提供生物醫療廢棄物處理業者如何保障權利，值得省思。並期盼藉由本文發揮拋磚引玉之效果，引發政府機關或政府機關所屬事業之重視，作為未來政府採購法相關法令修法或實務運作上之參考。



參考文獻

一、專書(依照筆劃順序排列)

1. 王澤鑑，民法總則，頁 264—265。
2. 王澤鑑，債法原理第一冊，自刊。
3. 尹章華、邱奕澄、倪文興，政府採購法實務與運作，文笙書局股份有限公司，初版，2006 年 3 月。
4. 吳庚，行政法之理論與實用，三民出版有限公司，6 版，2015 年。
5. 林鴻銘，政府採購法之實用權益，永然文化出版，2003 年 4 月。
6. 政府採購法使用手冊(2019 年)，頁貳—12。
7. 唐國盛律師，政府採購法律應用篇，台北永然文化出版，5 版，2005 年 7 月。
8. 陳櫻琴、陳希佳、黃仲宜，工程與法律，新文京開發出版股份有限公司，2004 年 3 月。
9. 潘秀菊，政府採購法，新學林出版股份有限公司，一版一刷，2009 年 8 月。
10. 羅昌發著，政府採購法與政府採購協定論析，元照，三版，第一刷，2008 年 11 月。

二、期刊論文(依照筆劃順序排列)

1. 張祥暉，政府採購之綁標、圍標防制研究及建言，立法院院聞第 31 卷第 4 期，2003 年 4 月。
2. 黃明陽，定型化契約之簽約規制——以消費者保護法為中心，《消費者保護研究》第 20 輯。
3. 潘秀菊、張祥暉，政府採購法契約解除與終止規定之探討，法學新論，月旦法學雜誌，第 44 期，1999 年 1 月。
4. 詹森林，私法自治原則之理論與實務—臺灣法制發展之情形，國立臺灣大學法學論叢，第 22 卷第 2 期，1993 年 6 月。
5. 謝說容，淺談政府採購法第 59 條，司法周刊②，2020 年 7 月 24 日。
6. 蘇明通，政府採購之不法不當行為及其防治，律師雜誌，249 期，2000 年。

三、學位論文(依照筆劃順序排列)

1. 方星淵，政府採購法中押標金之制度與法律性質研究，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2009 年。
2. 王天健，政府採購法決標程序及相關爭議之探討及修正建議，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2004 年。
3. 李旭銘，政府採購法不良廠商爭議問題之研究，輔仁大學法律學研究所碩士論文，2004 年。
4. 李玉卿，政府採購停權制度之剖析－從預防性與裁罰性行政處分之區別出發，東吳大學法學院法律學系碩士在職專班公法組碩士論文，2020 年 8 月。
5. 李振宏，沒收與追繳押標金在政府採購行為之爭議探討，國立高雄大學法律學系研究所碩士論文，2015 年 1 月。
6. 何應朋，政府採購法爭議處理程序之研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，1999 年。
7. 呂金鑫，公共工程履約爭議處理機制之研究－以政府採購法第 85 條之 1 第 2 項為核心－，玄奘大學法律學系碩士班碩士論文，2012 年 7 月。
8. 林益年，從制度主義觀點論公共工程採購制度之困境，國立中山大學中國與亞太區域研究所博士論文，2012 年。
9. 林松金，民間參與港埠建設與政府採購法之適用研究，國立海洋大學海洋法律研究所碩士論文，2000 年。
10. 林清強，政府採購法申訴廠商償付請求權之探討－兼論其償付數額之計算基礎及舉證，東吳大學法律學系碩士在職專班法律專業組碩士論文，2011 年 8 月。
11. 林水波，政府採購撤銷決標後採購契約效力之探討，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2020 年 6 月。
12. 林宜興，我國政府採購法爭議招標爭議問題之研究－以評選程序為中心，國立中正大學法律所碩士論文，2008 年。
13. 林濬詮，政府採購貪瀆犯罪法律規範及防制作為之研究，銘傳大學法律學系碩士在職專班碩士論文，2017 年 6 月。
14. 林勇麒，從保護法益論政府採購法之刑事責任－國家法益假象下的競爭秩序守護者，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2014 年。
15. 周瑤敏，政府採購法異議及申訴制度之研究，國立政治大學法律學研究所碩士

- 論文，2004 年 1 月。
16. 吳權原，政府採購貪瀆犯罪防制之研究，逢甲大學交通工程與管理所碩士論文，2007 年。
 17. 洪宗暉，政府採購法因契約責任所導致停權處分之研究—以爭議之多重解決機制間之適用關係為中心，國防大學管理學院法律學系碩士論文，2009 年。
 18. 洪佳如，論公共工程採購契約之違約金條款，國立成功大學，法律學研究所碩士論文，1996 年。
 19. 胡宗鳴，政府採購救濟制度之比較研究—以招標爭議之救濟機制為重心，國立臺北大學法學系碩士論文，2003 年。
 20. 郎世瑀，可歸責廠商事由致解除或終止政府採購契約所生爭議問題研究，國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士學位論文，2012 年 1 月。
 21. 柯寧寧，政府採購投標廠商資格設定之研究，國立中央大學營建管理研究所碩士論文，2006 年 7 月。
 22. 施欣妤，政府採購選商決定之司法審查—以採購標的規格與廠商資格之審查為中心，國立臺北大學法律學系碩士論文，2019 年 8 月。
 23. 唐迪俊，政府採購爭議處理之法律經濟分析，玄奘大學法律學系碩士在職專班碩士論文，2011 年。
 24. 許耀昇，政府採購法對科技專案影響評估之研究，國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士論文，1999 年。
 25. 陳萬愷，政府採購契約之司法管制—以定型化契約管制為中心，國防大學法律學系碩士論文，2019 年。
 26. 陳思宏，雙階關係中前階行為效力對後階行為之影響—以政府採購為中心，東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2011 年。
 27. 陳漢瑩，政府採購法爭議處理機制之研究—以教學醫院為例，銘傳大學公共事務學系碩士在職專班碩士論文，2005 年。
 28. 陳冠樺，政府採購決標制度之研究—以審標時機關採用次低標之裁量空間為探討中心，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2013 年 1 月。
 29. 陳膺，聯合採購發包機制之風險管控成效—以臺北市公立學校工程採購為例，國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士論文，2021 年 2 月。

30. 陳瑞柱，我國政府採購契約法律適用之研究－以綠化工程契約為核心，亞洲大學財經法律學系碩士論文，2021年7月。
31. 陳柏涵，政府採購法圍標罪之研究－以實務判決為中心，國立中正大學法律學系碩士論文，2020年7月。
32. 張永富，政府採購招標審標決標之研究－以標價偏低顯不合理之處置為中心，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2011年1月。
33. 莊賀元，政府採購法先調後仲機制之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，2009年6月。
34. 梁錦文，公共工程採購代辦法律關係之探討－以法律行為主體之認定及其權利（義務）為中心，國立高雄大學法律學系研究所碩士論文，2013年1月。
35. 梁靜媛，政府採購稽核制度之研究，國立交通大學管理學院（管理科學學程）碩士班碩士論文，2004年1月。
36. 郭希得，公立學校勞務採購契約之研究～以校外教學旅遊服務為例，國立成功大學科技法律研究所碩士論文，2008年。
37. 傅家瑋，政府採購招標決標與爭議處理之研究－以台南科學工業園區減振工法規劃技術服務採購案為核心，中國文化大學法律學院法律學研究所碩士論文，2010年6月。
38. 黃培誠，工程採購契約遲延問題之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2011年7月。
39. 黃榆楹，競爭法與政府採購法對於圍標、綁標行為規範之比較研究，國立臺北大學法學系碩士論文，2003年。
40. 黃俊通，政府採購法下工程統包之研究，國防管理學院法律研究所碩士論文，2001年。
41. 彭楚榮，政府採購弊案之探討，國立雲林科技大學會計系碩士論文，2015年6月。
42. 彭昕晟，政府採購契約法制與實務之研究－以學校交通車採購契約之法律性質與履約爭議為核心，國立中正大學財經法律研究所碩士在職專班碩士學位論文，2015年1月14日。
43. 嵇珮晶，政府採購爭議之處理制度－兼論仲裁制度適用於公共工程爭議及改進

之道，國立臺北大學法學系碩士論文，2003 年。

44. 趙修華，人力派遣採購最有利標評選項目與權重之研究，佛光大學公共事務學系碩士在職專班碩士論文，2012 年 6 月。
45. 蔡秋聰，政府採購法救濟制度之分析，國立高雄大學法律學系碩士班碩士論文，2007 年。
46. 鄭敏伶，健全政府採購作業—以個案機關為例，東吳大學會計學系碩士在職專班碩士論文，102 年 8 月。
47. 廖傳賀，圍標犯罪之研究—以政府採購法第八十七條規定為中心，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2011 年。
48. 廖宗聖，WTO 架構下政府採購協定適用範圍之研究——兼論我國政府採購法相關規定，世新大學法律學系碩士論文，2001 年。
49. 蕭念祖，政府採購法實務——以基隆港務局為例，國立海洋大學航運管理學系碩士論文，2000 年。
50. 蕭仁瑚，我國政府採購法異議申訴制度之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，2006 年。

四、研究計畫

1. 計畫主持人陳建文助理教授、協同主持人劉素吟律師，行政院法規委員會委託研究計畫，私法關係行政規制之法制體例研究 公寓大廈管理條例、消費者保護法與勞動契約法制發展經驗之觀察比較，2009 年 11 月。

五、網路資料(依照筆劃順序排列)

1. 王梅玲，比較研究 Comparative research，2012 年 10 月圖書館學與資訊科學大辭典，國家教育研究院雙語語詞、學術名稱暨辭書資訊網，網址：<https://terms.naer.edu.tw/detail/1679273/>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
2. 王耀誠、顏志昇，試析我國政府採購法規與新版政府採購協定之合致性，經貿法訊第 156 期(2014 年 1 月 10 日)，網址：<http://www.trade.law.nccu.edu.tw/epaper/no156/2.pdf>(最後瀏覽日 2022 年 4 月 6 日)。
3. 中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網—申訴調解之書類表格與流程—異議申訴流程圖，網址：<https://ws.pcc.gov.tw/001/upload/old/oldupload/upload/article/0e47bf54a6e921d50d1fe9473ff0e3c.pdf> (最後瀏覽日：2022 年

6 月 13 日)。

4. 公共工程委員會網頁，網址：<https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzQyL3JlbGZpbGUvMzY5Njc0ODEMTI4NC83NWEyMWJlNy1hZjh1LTQ0ZGMtOTgwOC1kYTMwMThlY2NhMDEucGRm&n=My7luLinlkjkuYvmipXmqJnlu6D1lYbln7rmnKzos4fmoLxbMV0ucGRm&icon=..pdf>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。
5. 公共工程委員會網頁，網址：<https://esvc.fnp.gov.tw/download/4d46cda90fac449d879c6aea73c355e4>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。
6. 台灣採購公報網決標公司資料庫，網址：https://www.taiwanbuying.com.tw/QueryCloseCase_Terminate.ASP(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。
7. 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，認識醫療廢棄物，網址：<https://medwast.wae.epa.gov.tw/index3.html> (最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
8. 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，醫療廢棄物的種類，首頁>管理現況>何謂醫療廢棄物>醫療廢棄物的種類，網址：<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J02.html>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
9. 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，醫療廢棄物定義，首頁>管理現況>何謂醫療廢棄物>醫療廢棄物定義，網址：<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J01.html>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
10. 行政院環境保護署醫療廢棄物資訊網，生物醫療廢棄物的物種，首頁>管理現況>何謂醫療廢棄物>生物醫療廢棄物的物種，網址：<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J03.html>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
11. 行政院環境保護署醫療廢棄物處理網－醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(2015 年版)第六章常見問答集，網址：<https://www.greenhosp.tw/Fckfile/file/環保署「醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊 104 年版」.pdf>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。
12. 全國法規資料庫，網址：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcpde=A0030096>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。
13. 全國法規資料庫，網址：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030057> (最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。
14. 投標須知及招標文件製作(報告人：行政院公共工程委員會劉彩霞)ppt，網址

: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vhSLuAYT&id=AF58FB029DC31ACDB167D6DE1E0B2BC735399BB3&thid=0IP.vhSLuAYTSXJWZDHkAtYoIwHaFP&mediaurl=https%3a%2f%2fimage.slidesharecdn.com%2fpur001213973996747759-8%2f95%2fpur001-11-728.jpg%3fcb%3d1213950848&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.bel48bb806134972566431e402d62823%3frik%3ds5s5NccrCx7elg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=728&expw=1030&q=採購流程圖&simid=608022105096528738&FORM=IRPRST&ck=2c0E46FCE5FFF4905DF9B23A86_35A61E&selectedIndex=99&ajaxhist=0&ajaxserp=0(最後瀏覽日：2022 年 5 月 6 日)。

15. 林淑女整理，189. 文獻分析法 (Document Analysis)，社團法人中華民國晴天社會福利協會，網址：<https://www.sunnyswa.org.tw/12345/189-%e6%96%8d%bb%e5%88%86%e6%9e%90%e6%b3%95%ef%bc%88document-analysis%ef%bc%89>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
16. 林易典副教授，德國限制競爭防止法 2015 年最新翻譯，德國限制競爭防止法，網址：<https://www.ftc.gov.tw/upload/6488ee19-7b9a-4caf-b78a-f41ed39Da5af5>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。
17. 政府資料平臺網頁－資料集 / 重點事業廢棄物－生物醫療廢棄物之處理方式，網址：<https://data.gov.tw/dataset/47255>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
18. 「政府採購法第 59 條第 2 項之性質」鑑定意見書，網址：<https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzc1L3JlbGZpbGUvMTkwMjEvODYyOTA1Ny91MzIyNmI4YS0yMGU3LTRkZGItd0ExMi05ZDQyOTU4M2EwZGUucGRm&n=6Zmz6Yym6IqzLeOAjOaUv%2BW6n0a0oeizv0azleesrDU55qKd56ysMumgheS5i%2BaAp%2BizquOAjSms5XlvovpkZHlrpmhI%2Fopovmm7gucGRm&icon=.pdf>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 6 日)。
19. 政府採購法主(會)計人員應行注意事項(報告人：洪澤仁，104 年 10 月 29 日)ppt，網址：<https://slidesplayer.com/slide/11409417/>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 6 日)。
20. 能基實業有限公司網頁－旋窯／旋轉乾燥爐－旋轉窯焚化爐架構圖，網址：<en>

ergYTEK.tw/tw/a14.html(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。

21. 財團法人中技社，政府採購法修訂與落實之研討，專題報告，2020-5，網址：
<https://www.ctci.org.tw/media/8711/2020-05-政府採購法修訂與落實之研討.pdf>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。
22. 雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司「生物醫療廢棄物委託處理契約書」，網址：
<https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNzQxL3JlbGZpbGUvMTAxNzMvODQwNTI1OS84NmY3OTMyYS1jMzJiLTQ2YTUtYmE3NC0wYTJmNjkyMWYyZjQucGRm&n=MTUt55Sf54mp6Yar55mC5bui5q0E54mp5aeU6KiX6JmV55CG5aWR57SE5pu4K0evh0acrCko6Ie65YyX5biC5pS%2F5bqc55Kw5aKD5L%2Bd6K235bGA5o%2BQ5L6bKS5wZGY%3D&icon=..pdf>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 7 日)。
23. 新北市政府法制局網頁－採購申訴調解－爭議處理程序－申訴案件流程，網址：
<https://www.law.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=2838c99ae3b46b5f>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。
24. 劉尚志、林三元、宋皇志，走出繼受、邁向立論：法學實證研究之發展，專題：法實證研究，科技法學評論，3 卷，頁 1(2006 年)，網址：
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/107690/1/3_2_1.pdf(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
25. 碩豐法律事務所，民法詞彙－契約神聖/契約嚴守，法律辭典，網址：
https://shuofeng.com.tw/newsdetail_3_143.html(最後瀏覽日：2022 年 5 月 3 日)。
26. 衛生福利部疾病管制局，疾病介紹，首頁，傳染病與防疫專題，傳染病介紹，第五類法定傳染病，嚴重特殊傳染性肺炎，網址：
<https://www./Category/Page/vle0MKqwuEbIMgqaTeXG8A>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
27. 醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊(2008 年版)，網址：
http://www.greehosp.tw/Fckfile/file/醫療機構事業廢棄物管理作業參考手冊_97 年版_99/更新.pdf
<https://medwaste.epa.gov.tw/Contents/J01.html>(最後瀏覽日：2022 年 4 月 6 日)。
28. 聯晟法網，契約自由原則，網址：
<https://www.rclaw.com.tw/post-274-8180>(最後瀏覽日：2022 年 5 月 6 日)。
29. 璞實法律事務所網頁，政府採購法上的綁標概念，傅建中結構技師，法務室，

中興工程顧問股份有限公司，2016 年 1 月 12 日，網址：<https://www.cawlawfirm.com/cawlawfirm/2016/01/12/>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。

30. 競爭法與能源法，德國營業競爭限制防止法－第六次修正，網址：<https://www.angle.com.tw/File/Try/5D172RA-3.pdf>(最後瀏覽日：2022 年 6 月 13 日)。

